

1889), se ejercen por la posesión (art. 1891), y pueden recaer sobre cosas registrables (art. 1890).

Se dice que el dominio está desmembrado, ya que el dueño se desprende de algunas de sus facultades (v. gr.: uso y goce) en favor de otro.

Se dice, especialmente en el caso del usufructo, que este último tiene el "dominio útil", mientras que el dueño conserva la "nuda propiedad" o propiedad desnuda. Claro que los otros derechos reales de disfrute también conceden a su titular alguna utilidad.

El dominio acepta la concurrencia de varios derechos reales limitados de disfrute. Así, por ejemplo, una cosa gravada con usufructo también puede estar soportando una servidumbre, y también más de una (v. gr.: de paso y de acueducto). Pueden coexistir derechos de diversa naturaleza. Cuando se presenta alguna incompatibilidad, entran a jugar los principios de prioridad y preferencia.

II. Concepto de usufructo

Tiene un ámbito de aplicación importante, aunque en la práctica se observa que muchas veces es utilizado en casos de donación del dominio, con reserva del usufructo. En ocasiones se trata de padres que se aseguran su permanencia en el inmueble mientras vivan. El Código define al usufructo de la siguiente forma: "Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia" (art. 2129).

Se desprende claramente de la definición que el dueño de una cosa (excepcionalmente un bien) confiere al usufructuario las facultades de usar y gozar (*ius utendi* y *ius fruendi*). Asimismo, este último puede disponer de su derecho, mientras que el dueño también conserva su poder de disposición.

Dado que el dueño conserva su facultad de disponer (*ius abutendi*), puede gravar la cosa con otros derechos reales, los que deberán respetar al usufructuario si fue constituido con anterioridad. Así, por ejemplo, si luego de constituido el usufructo sobre un inmueble, éste es hipotecado, en el supuesto de ejecutarse el inmueble deberá el adquirente respetar el derecho del usufructuario (*prior in tempore potior in jure*).

a) *Es un derecho real*

Además de mencionarlo la definición del artículo 2129, el usufructo está enumerado entre los derechos reales en el artículo 1887, inciso h.

Lo importante es que goza de los atributos típicos de los derechos reales y, en lo que aquí interesa, la relación directa e inmediata con el objeto. El usufructuario obtiene provecho de la cosa sin necesidad del nudo propietario, no hay intermediario. Esto es lo que distingue a este derecho real de los derechos personales, especialmente de la locación.

b) *Sobre cosa ajena*

El objeto del usufructo siempre es un bien ajeno, no puede recaer sobre uno propio.

No obstante, en ciertos casos la cosa puede ser parcialmente propia. Así ocurre cuando el usufructo se constituye por todos los condóminos en favor de uno solo de ellos.

c) *Facultad de usar, gozar y disponer*

Este uso y goce no es similar al del dueño, tiene limitaciones. La facultad de disponer no se refiere al dominio, obviamente, sino al propio derecho de usufructo.

Cabe advertir que el dueño le cede al usufructuario las facultades de uso y goce. Pero en verdad no son iguales, ya que el usufructuario en algún momento debe restituir el objeto, por lo que ese uso y goce no puede alterar la sustancia de la cosa.

El Código prevé que el usufructuario puede transmitir su derecho (art. 2142). También puede constituir derechos reales de uso, habitación y servidumbre (art. 2142).

d) *No alterar la sustancia*

Dice el artículo 2129 que el usufructuario no puede alterar la sustancia del objeto.

En el segundo párrafo aclara que "Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba". El artículo 2145

también se refiere a esta obligación, haciendo hincapié en que debe preservarse el destino.

Las *Institutas* de Justiniano decían: *salva rerum substantia*.

Por ende, en lo que respecta a la cosa, el usufructuario no debe: 1) alterarla o transformarla en sus características esenciales, esto es, aquellas que la hacen ser lo que es y no otra cosa diferente, tiene que ver con su materia y forma; 2) alterar el destino que le hubiese impuesto el dueño.

El Código agrega que si se trata de un derecho, no debe ser menoscabado. Así, por ejemplo, si da un crédito en usufructo, el usufructuario no puede hacer nada que atente contra la integridad de dicho crédito.

e) *Es un derecho temporario*

El usufructo no puede ser constituido de manera perpetua, sino por un tiempo. Cualquiera sea el plazo convenido, no puede ir más allá de la vida del usufructuario, se extingue cuando venza el plazo o condición pactados, o bien por la muerte del usufructuario, lo que ocurra primero. En el caso de las personas jurídicas, el máximo autorizado es de cincuenta años, si no se previó uno menor.

Además, el usufructo no se transmite por causa de muerte a los herederos (art. 2140).

f) *Divisible*

El usufructo, a diferencia del derecho real de servidumbre, es un derecho esencialmente divisible, porque la cosa fructuaria que es su objeto es susceptible de división.

III. Objeto

Se puede constituir usufructo sobre cosas ciertas y determinadas, sobre derechos cuando la ley lo autoriza, sobre cosas fungibles en un supuesto excepcional, y sobre universalidades cuando es de origen testamentario. Dice el artículo 2130 que "El usufructo puede ejercerse sobre la totalidad, sobre una parte material o por una parte indivisa de los siguientes objetos:

"a) una cosa no fungible;

"b) un derecho, sólo en los casos en que la ley lo prevé;

"c) una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales;

"d) el todo o una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen testamentario".

Como surge del principio del artículo, en armonía con lo previsto en el artículo 1883, el usufructo puede abarcar todo el objeto o una parte material de él. Así, por ejemplo, el usufructo puede gravar todo un campo, o sólo a una fracción de dicho inmueble. Desde otro ángulo, cuando son varios los usufructuarios, se genera entre ellos un usufructo (art. 2132), y lo ejercerán por una parte indivisa. Además, el artículo 1989 le permite a un condómino gravar su parte indivisa, lo que implica que podría constituir usufructo por su parte ideal.

a) *Cosa mueble o inmueble*

El primer inciso hace referencia a que el usufructo puede recaer sobre una cosa mueble o inmueble ajena, actual, no fungible ni consumible, razón por la cual el usufructuario tiene la obligación de devolver la misma cosa al extinguirse el usufructo.

b) *Derecho*

Una novedad es que, excepcionalmente, el usufructo puede recaer sobre un derecho. El inciso b, aclara que ello se permite "sólo en los casos en que la ley lo prevé".

Un caso de usufructo que recae sobre un derecho podría ser el supuesto en que se lo constituya sobre un *crédito instrumentado*. Al usufructuario le corresponderán los intereses devengados durante la vigencia del usufructo. Una vez cobrado el crédito, el usufructo se extingue al desaparecer su objeto. Otro caso lo constituye la anticresis del usufructo (art. 2213).

También fuera del Código se ha legislado sobre el usufructo de bienes que no son cosas; así, el usufructo de acciones de las sociedades anónimas (art. 218, ley 19.550) y el usufructo de cuotas de las sociedades de responsabilidad limitada (art. 156, ley 19.550).

Los derechos intelectuales podrían ser su objeto si la ley lo permite (art. 2130, inc. b).

c) *Cosa fungible. Cuasiusufructo*

El denominado cuasiusufructo surgió en el Derecho Romano en forma tardía, al extenderse el objeto a las cosas fungibles. En el usufructo común, el dueño conserva la propiedad de la cosa, que debe ser restituida por el usufructuario al extinguirse su derecho. En cambio, en el cuasiusufructo, el usufructuario adquiere la propiedad de las cosas entregadas, ya que al concluir su derecho debe restituir otras de la misma especie y calidad (v. gr.: cien bolsas de trigo), o su valor. Aquí no rige el *salva rerum substantia*; incluso, el cuasiusufructuario puede disponer de la propiedad en favor de otro.

En cuanto al cuasiusufructo, sólo se lo permite sobre un conjunto de animales. El inciso c, del artículo 2130 dice "fungible". El Código sólo admite el cuasiusufructo de un conjunto de animales, no de otras cosas fungibles, y menos aún consumibles. El usufructuario debe devolver lo que recibió, y si faltan animales, cosas de la misma especie y calidad (art. 2141, inc. a).

d) *Usufructo universal*

El inciso d, habla del usufructo universal. Se refiere a las "universalidades de derecho", toda vez que en relación con las universalidades de hecho el usufructo es siempre a título singular.

En este caso el testador hace un legado a favor de una persona determinada a la cual le otorga el uso y goce de una parte de su patrimonio.

Cuando el usufructo es testamentario, el inventario y estado deben hacerse por escritura pública (art. 2137).

Se puede interpretar que, en caso de haber deudas, las que gravan a los frutos sean soportadas por el usufructuario, mientras que las que gravan el capital sean a cargo del propietario (arg. arts. 2317/2320). Si el usufructo recae sobre una parte alcuotas, en esa proporción deberá responder el usufructuario por aquellas obligaciones que gravan los frutos.

Debe respetarse la legítima (art. 2460).

IV. Legitimados para constituir usufructo

Dispone el artículo 2131 lo siguiente: "Sólo están legitimados para constituir usufructo el dueño, el titular de un derecho de propiedad horizontal, el superficiario y los comuneros del objeto sobre el que puede recaer".

En lo que hace a la superficie, hay una contradicción. Según el artículo 2120 el superficiario sólo puede constituir derechos reales de garantía, mientras que el dueño no puede turbar al superficiario (art. 2121). Entonces, el dueño puede si no turba, pero el superficiario no puede, ya que esta norma sólo admite derechos de garantía. Pero el artículo 2131 menciona al "superficiario", en franca contradicción. Se puede interpretar que prevalece el artículo 2131 por tratarse de una norma especial sobre quiénes pueden constituir usufructo.

Con respecto al condómino y la parte indivisa —tampoco mencionado claramente por el artículo 2131— resulta aplicable el artículo 1989. Este último dice que "Cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos".

Nada se dice de los "conjuntos inmobiliarios", del "tiempo compartido" y del "cementerio privado". Lo cierto es que el usufructo, aunque con dificultades mayores o menores, no es incompatible con ninguno de ellos.

V. Usufructo a favor de varias personas

a) *Cousufructo. Derecho de acrecer*

Dispone el Código en el artículo 2132: "El usufructo puede establecerse conjunta y simultáneamente a favor de varias personas. Si se extingue para una subsiste para las restantes, pero sin derecho de acrecer, excepto si en el acto constitutivo se prevé lo contrario".

Se trata del cousufructo. Cuando el usufructo se constituye a favor de varias personas, se da una comunidad del derecho real, que debe regirse por las normas del condominio en tanto sean compatibles (art. 1984).

Pueden ser dos o más los cusufructuarios. No es necesario que sus cuotas sean iguales, ello dependerá de lo previsto en el acto constitutivo. Si se guardó silencio, se presume que lo son (art. 1983).

En el supuesto de que sean varios los usufructuarios, y se extinga para uno de ellos, los restantes continúan ejerciendo el derecho conferido. Se extingue el usufructo cuando se extinga para el último de ellos, o bien venza el plazo previsto. No hay derecho de acrecer entre ellos, a menos que se haya previsto lo contrario en el acto constitutivo.

Si así se hubiera establecido, por ejemplo, en caso de fallecimiento de uno de los usufructuarios el goce que éste tenía sobre la cosa fructuaria no se reúne con la nuda propiedad, sino que se suma al derecho de goce del otro u otros usufructuarios, incrementando o acreciendo su usufructo, y en consecuencia demorando o prolongando la separación de la propiedad de la del usufructo.

b) *Prohibición de usufructos sucesivos*

Dice la última parte del artículo 2132 que "No puede establecerse usufructo a favor de varias personas que se suceden entre sí, a menos que el indicado en un orden precedente no quiera o no pueda aceptar el usufructo".

El Código no permite que se establezcan usufructos sucesivos sino simultáneos a favor de diferentes personas. El motivo es que se trata de un derecho temporario y vitalicio, y de admitirse esa modalidad su duración podría ser muy extensa.

Hay una excepción a la prohibición de usufructos sucesivos, si el primero no quiere o no puede aceptar el usufructo. Así, por ejemplo, José en su testamento le deja el usufructo de una casa a Juan, y a la muerte de Juan, a Pedro. No es válido el constituido en favor de Pedro, a menos que Juan no acepte el establecido a su favor en primer término. Podría suceder también que Juan no pueda aceptar si, por ejemplo, fallece antes que el testador.

VI. Modos de constitución

El usufructo puede ser adquirido por contrato (oneroso o gratuito),

por testamento, y por prescripción. El Código establece en el artículo 2134 que "El usufructo puede constituirse:

- "a) por la transmisión del uso y goce con reserva de la nuda propiedad;
- "b) por la transmisión de la nuda propiedad con reserva del uso y goce;
- "c) por transmisión de la nuda propiedad a una persona y el uso y goce a otra".

Otras normas del Código armonizan con lo aquí previsto. Así el artículo 1551, al contemplar el objeto de la donación. Por su parte, prevé el artículo 2416 que "El donante puede transmitir la plena propiedad de los bienes donados, o bien únicamente la nuda propiedad, reservándose el usufructo".

a) *Usucapión*

Cabe advertir que además del contrato y el testamento, el usufructo también puede constituirse por *usucapión* (art. 2565). No hay casos de usufructo legal, es decir que surjan por voluntad de la ley, como sí ocurría en el Código de Vélez (usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos menores).

b) *Prohibición de constitución judicial*

Establece el artículo 2133 que "En ningún caso el juez puede constituir un usufructo o imponer su constitución". El artículo 1896, en las disposiciones generales comunes a todos los derechos reales, había sentado que "el juez no puede constituir un derecho real o imponer su constitución, excepto disposición legal en contrario".

VII. Presunción de onerosidad

El usufructo puede constituirse por un acto oneroso o gratuito. En el primer caso, cuando el usufructuario se obliga a pagar un precio en dinero, en la medida en que sean compatibles, se aplican las reglas previstas para la compraventa (art. 1124, inc. a). En el segundo supuesto, si la transmisión o constitución es gratuita, se aplican las normas sobre donación (art. 1543).

Establece el artículo 2135 del Código que "En caso de duda, la constitución del usufructo se presume onerosa".

Cabe entender que la presunción es iuris tantum. No obstante, el Código dice en el artículo 2461, sobre la transmisión de bienes a legitimarios, que "Si por acto entre vivos a título oneroso el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario".

VIII. Duración

El usufructo es un derecho temporario, está limitado en el tiempo, no es perpetuo. La razón de esta característica es evitar que el dominio permanezca desmembrado por un período extenso.

El usufructo dura de acuerdo al plazo o condición establecido en el acto constitutivo. Si las partes no lo han fijado, el Código lo fija supletoriamente, ya que no puede extenderse más allá de la vida del usufructuario. Además, la muerte es una causal de extinción del usufructo, en el supuesto de que el plazo previsto fuese mayor (art. 2152, inc. a). Es un derecho real vitalicio que, por ende, no se transmite a los herederos (art. 2140).

Teniendo en cuenta que puede ser usufructuaria una persona jurídica, su extinción también marca el fin del usufructo. Si esto no ocurre, durará tanto como se haya previsto, con el límite de cincuenta años contados desde la constitución de dicho derecho real (art. 2152, inc. b).

Si hay varios usufructuarios que ejercen el derecho en forma conjunta y simultánea, el usufructo puede durar tanto como se haya previsto, o hasta que muera el último de los usufructuarios.

Estas disposiciones son de orden público, no pueden ser dejadas de lado por la convención o el testamento.

IX. Modalidades

Según el artículo 2136: "El usufructo puede ser establecido pura y simplemente, sujeto a condición o plazo resolutorios, o con cargo. No

MNR

puede sujetarse a condición o plazo suspensivos y si así se constituye, el usufructo mismo se tiene por no establecido. Cuando el testamento subordina el usufructo a una condición o a plazo suspensivos, la constitución sólo es válida si se cumplen antes del fallecimiento del testador".

Si se permitiera la constitución del usufructo bajo condición o plazo suspensivo el propietario no cuidaría ni mejoraría la cosa puesto que cumplido el plazo o la condición otra persona recibiría la cosa para usufructuarla.

X. Derechos del usufructuario

En primer lugar, el usufructuario tiene derecho al uso y goce del objeto sobre el que recae su derecho. Puede usarla y gozarla como lo haría el dueño, pero con la limitación de no alterar la sustancia. No puede alterar el destino aunque es relevante lo que se haya previsto en el título constitutivo.

El uso y goce puede ser directo o indirecto, ya que el Código autoriza al usufructuario a transmitir su derecho, o a constituir derechos reales (v. gr.: anticresis) o personales (v. gr.: locación) de uso y goce (art. 2142).

a) *Frutos. Productos. Acrecentamientos naturales*

a.1) *Frutos percibidos*

El usufructuario tiene derecho a percibir frutos, a quedarse con los percibidos y a exigir los pendientes al tiempo de constituirse el usufructo. En cambio, le corresponden al dueño los pendientes al momento de extinguirse el derecho de disfrute (art. 2141, incs. a, y b).

a.2) *Conjunto de animales*

Si los animales que conforman el conjunto perecen en parte (parcialmente) sin culpa del usufructuario (art. 2153), éste tiene la opción de continuar en el usufructo reemplazando a su costa los animales que faltan, o bien culminar el usufructo entregando los que no hubieren perecido (art. 2141, inc. a). Con mayor razón deberá reemplazarlos si hubo culpa de su parte.

Ahora, "Si el usufructo es de un conjunto de animales que perece

en su totalidad sin culpa del usufructuario, éste cumple con entregar al nudo propietario los despojos subsistentes" (art. 2153). Así, por ejemplo, si con motivo de una inundación murieran todos los animales, el usufructuario ya no está obligado a reemplazarlos: el usufructo se extingue y sólo deben entregar al dueño los despojos.

a.3) *Productos*

El inciso c, del artículo 2141 dice que pertenecen al usufructuario "los productos de una explotación ya iniciada al tiempo de constituirse el usufructo". Se alude a una explotación cualquiera. No obstante, si se trata de minas, se aplica el artículo 365 del Código de Minería, que establece otra solución.

Lo que se extrae de una explotación ya iniciada (v. gr.: una cantera) no son frutos sino que ingresan dentro de la noción jurídica de productos, los que al no resultar renovables implican la alteración de la sustancia y por ende de la cosa fructuaria.

a.4) *Acrecentamientos*

El último párrafo del artículo 2141 dice que "El uso y goce del usufructuario se extiende a los acrecentamientos originados por hechos de la naturaleza, sin contraprestación alguna".

Se refiere a la accesión y al aluvión, entre otros.

a.5) *Tesoros*

Nada dice el artículo 2141 sobre los tesoros. El usufructuario, según el Código, tiene derecho a buscar tesoros (art. 1952), de modo que si encuentra alguno le pertenece la mitad (art. 1953). Si el descubridor es un tercero, deberá repartirlo con el dueño, y nada le corresponderá al usufructuario.

b) *Mejoras facultativas*

Dispone el artículo 2143 que "El usufructuario puede efectuar otras mejoras, además de las que está obligado a hacer, si no alteran la sustancia de la cosa. No tiene derecho a reclamar su pago, pero puede retirarlas si la separación no ocasiona daño a los bienes".

El usufructuario debe realizar a su costa las mejoras de mero mantenimiento y las necesarias para la conservación de la cosa, cuya causa sea posterior al inicio del usufructo, y las demás que se originen por su culpa (arts. 2146/2147). Fuera de las que está obligado, puede realizar otras, si no alteran la sustancia de la cosa. Así, por ejemplo, si lo desca, puede realizar mejoras útiles o suntuarias.

Aun cuando dichas mejoras aumenten el valor de la cosa, el usufructuario, al extinguirse su derecho, no puede reclamar su pago, "pero puede retirarlas si la separación no ocasiona daño a los bienes".

c) *Derechos reales y personales*

Establece el artículo 2142 que "El usufructuario puede transmitir su derecho, pero es su propia vida y no la del adquirente la que determina el límite máximo de duración del usufructo. Con carácter previo a la transmisión, el adquirente debe dar al nudo propietario garantía suficiente de la conservación y restitución del bien.

"El usufructuario puede constituir los derechos reales de servidumbre y anticresis, uso y habitación y derechos personales de uso o goce. En ninguno de estos casos el usufructuario se exime de sus responsabilidades frente al nudo propietario".

c.1) *Transmisión del usufructo*

El primer párrafo del artículo 2142 armoniza con el artículo 2140, que dice que es intransmisible por causa de muerte. Sí se lo puede transmitir por actos entre vivos y el límite "máximo" es la vida del transmitente. Esto es así, claro está, si no se fijó otro plazo menor (art. 2152, inc. a), como bien dice el artículo 2153. No exige el Código la conformidad del nudo propietario.

Así, por ejemplo, si Juan transmite su usufructo a Pedro, y un día Juan muere, en ese momento acaba el usufructo. Si no muere, el plazo máximo será el que beneficiaba al primero (Juan), cualquiera sea el que haya pactado con su sucesor. De no ser así, se prolongaría de manera extensa el dominio desmembrado, la separación entre la nuda propiedad y el dominio útil podría ser indefinida de verificarse sucesivas cesiones.

Se dice en el segundo párrafo del artículo 2142 que si el usufructuario constituye derechos reales o personales, no "se exime de sus responsabilidades frente al nudo propietario". Si no se libera por constituir un derecho de uso o una locación, se puede inferir que tampoco lo hará por transmitir el derecho de usufructo. Al final, el artículo dice: "En ninguno de estos casos el usufructuario se exime de sus responsabilidades frente al nudo propietario".

El Código exige que el adquirente dé una garantía. La garantía, que es por regla optativa (art. 2139), en este supuesto es obligatoria, ya que la norma dice "el adquirente debe".

Otro problema a resolver es qué pasa si muere el cesionario del usufructo: 1) ¿Revierte al usufructuario original?; 2) ¿lo continúan sus herederos hasta que venza el plazo primitivo?; 3) ¿el nudo propietario recupera la cosa? Si bien con dudas, parece que no puede revertir al usufructuario original, ya que dicho usufructuario transmitió su derecho en forma definitiva. La segunda posibilidad tampoco es aceptable, pues se permitiría un usufructo transmisible por herencia, lo que el Código prohíbe expresamente (art. 2140). Cabe inclinarse por la extinción del usufructo y la consolidación de todas las facultades en el dueño pleno.

c.2) Constitución de otros derechos

El segundo párrafo del artículo 2142 acepta que pueda constituir uso y habitación, a pesar de que alguna doctrina minoritaria cuestionaba esto. Debería decirse en este párrafo que también el límite es la duración del usufructo, aunque sí lo dice el artículo 2153.

En cuanto a la anticresis, armoniza con el artículo 2213, que legitima al usufructuario en una suerte de cesión del usufructo en garantía.

Como el usufructuario es titular de un derecho real que se ejerce por la posesión y goza del derecho de disponer (*ius abutendi*), puede gravar con uso, habitación, servidumbres o anticresis, el fundo sujeto al usufructo pero ellos no pueden durar más allá de acabado su derecho, porque ello importaría vulnerar el principio del *salva rerum substantia*, ya que si quedaran subsistentes la cosa volvería disminuida al nudo propietario. Sí, por el contrario, podrían durar menos que su derecho.

También puede el usufructuario ceder el uso y goce mediante derechos personales como, por ejemplo, la locación. Podría suceder la situación inversa, esto es que el usufructuario entre en posesión de un inmueble ya alquilado. En tal caso, deberá respetar el contrato (art. 1189, inc. b).

Además del usufructuario originario, también sus sucesores particulares pueden constituir los mencionados derechos reales o personales (art. 2153).

Queda claro que en estos casos de derechos reales o personales, el usufructuario no se desliga de sus obligaciones frente al nudo propietario.

No autoriza el Código la constitución de hipoteca sobre el usufructo, como sí admite la legislación española en el artículo 107, inciso 1º, de la ley hipotecaria. Cabe preguntarse el motivo, teniendo en cuenta que ahora el Código admite la ejecución del usufructo por parte de acreedores (art. 2144).

d) Ejecución por acreedores

El Código consagra aquí una novedad importante. Dice el artículo 2144: "Si el acreedor del usufructuario ejecuta el derecho de usufructo, el adquirente del usufructo debe dar garantía suficiente al nudo propietario de la conservación y restitución de los bienes".

Así como el usufructuario puede transmitir su derecho, también puede ser embargado y ejecutado por sus acreedores. El adquirente debe dar garantía, la que en este caso es obligatoria (también en el supuesto de transmisión voluntaria —art. 2142—), dejando de lado la regla de ser facultativa (art. 2139). Sea la transmisión voluntaria o forzosa el adquirente debe dar una garantía obligatoriamente (arts. 2142 y 2144).

En el caso de adquisición del derecho de usufructo por vía de la subasta judicial, el límite del usufructo queda sujeto al término pactado en el contrato constitutivo de usufructo o bien a la vida del usufructuario que figura en el título que dio origen al usufructo. El hecho de que la adquisición del derecho real de usufructo se haga por vía de subasta judicial no puede empeorar la situación del nudo propietario.

e) *Prescripción adquisitiva en favor de un tercero*

Otra situación que puede darse es que su derecho de usufructo sea adquirido por un tercero por usucapión. En tal caso, es posible interpretar que ello no puede empeorar la situación del nudo propietario, y que no puede durar más que el plazo original.

No obstante, surgen dudas, si se tiene presente que la prescripción adquisitiva es un modo originario de adquirir y que no hay vínculo alguno entre el usufructuario original y aquel que adquiere por usucapión. Siguiendo este razonamiento, en el caso de un inmueble, puede interpretarse que el usufructo original se extinguió por el no uso, y que el usucapiente ha adquirido un derecho de disfrute distinto, autónomo, cuyo plazo máximo será su propia vida.

En tal caso, el usufructuario original será responsable ante el nudo propietario por los perjuicios que la situación le cause (art. 2149).

Es difícil que se presente un caso semejante, pues el tercero que poseyó durante veinte años podría alegar que adquirió el dominio en lugar del usufructo.

f) *Acciones*

El usufructuario está legitimado para promover acciones posesorias o reales en defensa de su poder de hecho y de su derecho real.

Si se trata del usufructo de un crédito, podría ejercer las acciones necesarias para su cobro.

g) *Derecho de retención*

Podría ocurrir que al momento de extinguirse el usufructo, el nudo propietario adeudara alguna obligación al usufructuario. Así, por ejemplo, no haberle entregado los frutos pendientes al momento de la constitución (art. 2141, inc. b), o que el segundo hubiese hecho mejoras que debían ser solventadas por el nudo propietario (art. 2147).

Prevé el Código que el acreedor puede retener la cosa que debe restituir, hasta el pago de lo que se le adeude en razón de la cosa (art. 2587)

h) *Inventario y estado*

El inventario se refiere a las cosas dadas en usufructo y consiste en efectuar un detalle descriptivo de cada cosa que lo compone y del estado en que se encuentran. Se suele usar el inventario para las cosas muebles, especialmente cuando son varias, y el estado para los inmuebles. Igualmente, es importante que se fije el valor de los bienes a entregar. El usufructuario deberá, al momento de su culminación, entregar la misma cosa con los deterioros o desgaste normal por el uso y el paso del tiempo, de allí la importancia de determinar claramente las cosas que son su objeto, su valor, y el estado en el que se encuentran al momento de su constitución.

Establece el artículo 2137 que "Cualquiera de las partes contratantes tiene derecho a inventariar y determinar el estado del objeto del usufructo, antes de entrar en su uso y goce. Cuando las partes son mayores de edad y capaces, el inventario y determinación del estado del objeto del usufructo son facultativos y pueden hacerse por instrumento privado. En caso contrario, son obligatorios y deben ser hechos por escritura pública.

"Si el usufructo se constituye por testamento, quien ha sido designado usufructuario está obligado a inventariar y determinar el estado del objeto, en escritura pública. Esta obligación tampoco es dispensable.

"La parte interesada puede reclamar en cualquier momento el cumplimiento de la ejecución no efectivizada".

Como surge de la norma, la realización del inventario y del estado es facultativa, cuando los contratantes son capaces. Se torna obligatoria cuando hay incapaces, y cuando es constituido por testamento.

Si se hubiese pactado la necesidad de hacer inventario o estado, o éstos son obligatorios por haber un incapaz o haber sido constituido por testamento, la falta de inventario no importa la extinción del usufructo, ya que el Código establece que "La parte interesada puede reclamar en cualquier momento el cumplimiento de la ejecución no efectivizada" (art. 2137, último párrafo).

Pero ello puede traer otras consecuencias, ya que el usufructuario que se niega a recibir los bienes por su negativa a inventariarlos o a

determinar su estado debe pagar las mejoras hechas por el nudo propietario luego del acto constitutivo (art. 2147, segundo párrafo). Esto no se aplicará si los bienes se entregaron, pero se llegará a la misma solución, ya que a partir de que recibió los bienes el usufructuario está obligado a realizar las mejoras necesarias.

Si no se pacta lo contrario, todo indica que el usufructuario es quien debe soportar los gastos de inventario o estado, especialmente en los casos en los que está obligado a hacerlo. Es dicho sujeto quien se beneficiará con la explotación de los bienes.

Agrega el artículo 2138 que "La falta de inventario y de determinación del estado de los bienes hace presumir que se corresponden con la cantidad indicada en el título y que se encuentran en buen estado de conservación, excepto que se haya previsto lo contrario".

XI. Obligaciones del usufructuario

a) *No alterar la sustancia. Destino*

El usufructuario, al extinguirse su derecho, como no le pertenece, debe restituir el objeto al nudo propietario. Por tal razón, el Código le impone el clásico deber de conservar la cosa y, especialmente, de *no alterar su sustancia*. El Código explica que "Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba" (art. 2129, segundo párrafo). Más que de una obligación, en verdad se trata de un límite que establece el Código a las facultades del usufructuario.

Agrega el artículo 2145, en el capítulo dedicado a las obligaciones del usufructuario, que "El uso y goce por el usufructuario debe ajustarse al destino de los bienes del usufructo, el que se determina por la convención, por la naturaleza de la cosa o por el uso al cual estaba afectada de hecho".

Es obvio que el usufructuario no puede destruir la cosa, lo que provocaría la extinción del derecho real (art. 1907). El Código va más lejos, todo esto significa que el usufructuario no puede alterar o transformar la cosa en sus características esenciales, esto es, aquellas que la hacen ser lo que es y no otra cosa diferente. Debe usarla y gozarla en forma razonable, sin ningún abuso.

Además, debe ajustarse al destino económico impuesto por el propietario. Por un lado, están en juego la materia y forma; por otro, el destino.

El destino no es inflexible, pues si bien debe ser el correspondiente a la naturaleza de la cosa o al cual estaba afectada de hecho, puede determinarse "por la convención" (art. 2145), lo que significa que el propietario y el usufructuario pueden convenir un destino diferente al que la cosa estaba afectada.

Agrega el Código que si el objeto del usufructo es un derecho, se altera la sustancia si se "lo menoscaba" (art. 2129). Podría ocurrir que se grave con usufructo un crédito instrumentado, y que el instrumento se pierda o destruya.

El uso abusivo, o la alteración de la sustancia, son causas de extinción del usufructo (art. 2152, inc. d). No es imputable al usufructuario la alteración debida a vetustez o caso fortuito (arg. art. 2146).

b) *Mejoras*

El artículo 2146 del Código se refiere a las mejoras obligatorias (v. gr.: las necesarias para mantener la cosa en buen estado), mientras que el artículo 2143 prevé las facultativas: "El usufructuario puede efectuar otras mejoras, además de las que está obligado a hacer, si no alteran la sustancia de la cosa. No tiene derecho a reclamar su pago, pero puede retirarlas si la separación no ocasiona daño a los bienes".

Esta necesidad de hacer mejoras necesarias para mantener la cosa en buen estado, así como la de reparar los deterioros originados por su culpa, se vincula con la obligación examinada anteriormente de no alterar la sustancia.

Debe realizar las mejoras originadas en deterioros posteriores al acto constitutivo (ver art. 2147): a) las de mero mantenimiento; b) las necesarias; c) las causadas por su culpa.

Además, es responsable de los deterioros que puedan causar terceros contratantes, a quienes les haya transmitido el derecho, o cedido el uso y goce a través de derechos reales o personales (art. 2142).

En cuanto a las mejoras por causa anterior a la constitución del

usufructo, dice el artículo 2147: "El usufructuario no está obligado a hacer ninguna mejora por causas originadas antes del acto de constitución de su derecho.

"Sin embargo, el usufructuario que no recibe los bienes por su negativa a inventariarlos o a determinar su estado, debe pagar esas mejoras realizadas por el nudo propietario".

c) *Impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes*

Dice el artículo 2148 que "El usufructuario debe pagar los impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes que afectan directamente a los bienes objeto del usufructo". Esta norma, además, armoniza con el texto del artículo 2050.

El usufructuario debe pagar los impuestos que afecten "directamente a los bienes". El Código entiende que si el usufructuario goza de los bienes, deben estar a su cargo los impuestos. Esto es, sin perjuicio de lo que puedan disponer otras leyes impositivas.

¿Qué pasa si no paga? Es una posibilidad que se pida la resolución del contrato. La otra alternativa es que el acreedor puede ejecutar el derecho de usufructo, extremo permitido (art. 2144), con lo cual el acreedor podrá cobrar su crédito y el usufructuario dejará de serlo.

d) *Comunicación al nudo propietario*

Se dispone en el artículo 2149 que "El usufructuario debe comunicar al nudo propietario las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razón de la cosa. Si no lo hace, responde de todos los daños sufridos por el nudo propietario".

Dado que el usufructuario debe conservar las cosas objeto del usufructo tal cual las recibió, para restituirlas indemnes al propietario al momento de culminar el usufructo, si un tercero perturbara los derechos del propietario, el usufructuario está obligado a ponerlo en su conocimiento y, si no lo hiciera así, responde de todos los daños que al propietario le resulten como si hubiesen sido ocasionados por su culpa.

Por ejemplo, el usufructuario es responsable si por negligencia dejare que un tercero adquiriera el inmueble por usucapión.

La perturbación puede ser de derecho, como sucedería si, por ejem-

MNR

plo, alguien demandara por reivindicación y el usufructuario omitiera avisarle al nudo propietario. A su vez, tiene que informarle al reivindicante quién es el dueño de la cosa (arg. art. 2255).

e) *Restitución*

Dice el artículo 2150: "El usufructuario debe entregar los bienes objeto del usufructo a quien tenga derecho a la restitución al extinguirse el usufructo, en la cantidad y estado a que se refieren los artículos 2137 y 2138".

En el caso del conjunto de animales, deberá reemplazar aquellos que hubieren perecido (arts. 2141, inc. a, 2153), si no opta por su extinción. La reposición podría ser efectuada con las crías de tales animales. Es otra manera de no alterar la sustancia, en este caso de una universalidad de hecho. No obstante, si el perecimiento es total, se extingue el usufructo (art. 2153).

f) *Inventario*

Como se expuso anteriormente, al tratar los derechos del usufructuario, el inventario y estado son esencialmente facultativos, pero hay supuestos en los que son obligatorios para el usufructuario.

Establece el Código en el artículo 2137 que "Cualquiera de las partes contratantes tiene derecho a inventariar y determinar el estado del objeto del usufructo, antes de entrar en su uso y goce. Cuando las partes son mayores de edad y capaces, el inventario y determinación del estado del objeto del usufructo son facultativos y pueden hacerse por instrumento privado. En caso contrario, son obligatorios y deben ser hechos por escritura pública.

"Si el usufructo se constituye por testamento, quien ha sido designado usufructuario está obligado a inventariar y determinar el estado del objeto, en escritura pública. Esta obligación tampoco es dispensable.

"La parte interesada puede reclamar en cualquier momento el cumplimiento de la ejecución no efectivizada".

g) *Garantía*

El artículo 2139 expresa que "En el acto de constitución puede

establecerse la obligación previa al ingreso en el uso y goce, de otorgar garantía suficiente, por la conservación y restitución de los bienes, una vez extinguido el usufructo".

La garantía es optativa.

La garantía puede ser personal (v. gr.: fianza, fideicomiso, seguro, etc.) o real (hipoteca, prenda, anticresis). Lo que importa es que sea "suficiente" en orden a la conservación y restitución de los bienes. Puede ser dada por el usufructuario o por un tercero.

En el caso de que el usufructuario transmita su derecho a un tercero, la garantía es obligatoria. La debe dar el adquirente.

XII. Derechos del nudo propietario

a) Actos de disposición

El nudo propietario mantiene en su poder el *ius abutendi*, es decir el derecho a disponer de la cosa, pues si bien el dominio se encuentra desmembrado, lo cierto es que sigue siendo el titular del derecho real de dominio, aunque imperfecto.

Dice el artículo 2151 que "El nudo propietario conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho, pero no debe turbar el uso y goce del usufructuario. Si lo hace, el usufructuario puede exigir el cese de la turbación; y, si el usufructo es oneroso, puede optar por una disminución del precio proporcional a la gravedad de la turbación".

En cambio, si adquiriera una servidumbre en favor del fundo, ello beneficiaría al usufructuario, quien no tendría motivos para oponerse. El usufructuario tiene derecho a que la cosa objeto de su derecho se mantenga como era al tiempo de constituirse, lo que no se afecta si la situación es mejorada. Por el contrario, no podría el dueño renunciar a una servidumbre activa que fuera de utilidad para el usufructuario (v. gr.: de acueducto), pues ello turbaría su uso y goce.

El segundo párrafo del artículo 2151 es novedoso. Parece una suerte de *actio quanti minoris*.

b) Otros derechos

El artículo 2151, examinado en el punto anterior, se refiere al plano del derecho real. El nudo propietario puede tener otros derechos en su relación con el usufructuario, emergentes del vínculo obligacional que también los une.

Así, por ejemplo, es posible que se pacte la obligación de hacer inventario y estado en los supuestos en los que no es obligatorio, o el otorgamiento de una garantía (arts. 2137 y 2139).

Tiene derecho a realizar aquellas mejoras que no están a cargo del usufructuario, como si, por ejemplo, la cosa fuera destruida por caso fortuito, o estuviera deteriorada por vetustez (art. 2146). Asimismo, puede reclamar las realizadas por la demora del usufructuario en recibir los bienes (art. 2147, segundo párrafo).

Tiene también derecho a exigirle al usufructuario que cumpla con sus obligaciones, ya sean las asumidas, o las que se imponen en el Código. Así, por ejemplo, que se haga cargo de las mejoras necesarias para la conservación de la cosa (art. 2146), que se haga cargo de impuestos o expensas (art. 2148), de pedirle la entrega de los frutos pendientes al momento de la extinción del usufructo (art. 2141, inc. b), etcétera. Esto incluye también el derecho de realizar visitas periódicas al inmueble, o pedir la exhibición si se trata de una cosa mueble.

En el caso de que la cosa dada en usufructo sea despojada, o sufra turbaciones, el propietario cuenta con las acciones posesorias y reales pertinentes. Asimismo, si se dan las condiciones, puede ejercer la acción de deslinde, en cuyo caso deberá citar al usufructuario (art. 2267).

En lo que hace a su derecho real, puede exigir que cese un uso y goce que afecte la sustancia de la cosa, o que sea abusivo y, en su caso, demandar la extinción del usufructo (art. 2152, inc. d).

XIII. Deberes del nudo propietario

a) Entregar el objeto

Una vez celebrado el contrato, el dueño tiene la obligación de entregarle el objeto al usufructuario para que pueda gozar de él. Con

la tradición nacerá el derecho real. Si no lo hace, el usufructuario puede demandarlo para que cumpla con tal obligación.

Si no se establece lo contrario, cabe inferir que la cosa debe entregarse con todos sus accesorios.

b) *Mejoras*

El nudo propietario tiene el deber de realizar aquellas mejoras que no están a cargo del usufructuario, o de pagar su valor.

c) *Obligación de saneamiento*

Cuando el usufructo es constituido por título oneroso, el nudo propietario debe garantizar al usufructuario el goce pacífico de su derecho. Esta garantía es de la misma clase que la que debe el vendedor al comprador. La obligación de garantía no deriva aquí de las relaciones jurídicas existentes entre el nudo propietario y el usufructuario en su carácter de tales, sino del contrato que ha dado nacimiento al usufructo.

En el caso del usufructo constituido a título gratuito, se aplican supletoriamente las reglas sobre donación (art. 1543). Las garantías de evicción y por vicios ocultos no se deben, en principio, porque el legislador ha considerado que al realizar un acto de esta clase, el donante o el testador han querido transmitir la cosa o el derecho de uso y goce de ella tal cual lo tenían, con todos los vicios o defectos que pudieran afectar su propio derecho. Ver artículos 1556/8.

XIV. Extinción del usufructo

a) *Modos generales de extinción*

El usufructo puede extinguirse por alguno de los modos previstos para la extinción de los derechos reales.

Dice el artículo 1907 que "Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena".

En el caso del usufructo, el "abandono" sería la renuncia del usufructuario, para diferenciarlo del no uso, que es otra causa de extinción. Si el usufructuario constituyó derechos reales o personales en favor de terceros, su renuncia no debe perjudicarlos.

En cuanto a la "destrucción total de la cosa", cabe advertir que no se extingue el usufructo cuando se trata de cosas fungibles, que es el caso del conjunto de animales, ya que pueden ser reemplazados los que hayan muerto por otros de igual especie y cantidad (arts. 2141, inc. a, y 2153). Tampoco se extingue si la destrucción es parcial, continúa sobre lo que reste. Así, por ejemplo, en el incendio parcial de un edificio, el usufructo continuará sobre la parte no afectada. Esto es así tanto en el caso de haber sucedido este hecho por caso fortuito como en el de haber ocurrido por culpa del usufructuario. Claro que en esta última hipótesis, el usufructuario deberá hacerse cargo de las reparaciones necesarias (art. 2146).

La "consolidación" se da cuando se reúnen ambas calidades en la misma persona. Así, por ejemplo, si el usufructuario compra o hereda la propiedad de la cosa que disfruta.

Si el usufructuario constituyó derechos reales o personales en favor de terceros, la consolidación no debe perjudicarlos.

No se produce la consolidación si el usufructuario adquiere el condominio de la cosa que disfruta (arg. arts. 1989 y 2131).

b) *Medios especiales de extinción*

Además de los modos generales de extinción, aplicables a todos los derechos reales, el Código prevé algunos que son especiales, propios del usufructo (art. 2152).

b.1) *Vencimiento del plazo. Cumplimiento de la condición*

Este caso no está mencionado en el artículo 2152, pero surge del resto del articulado, ya que el usufructo es por esencia un derecho temporario, nunca puede ser perpetuo. El plazo de duración es un plazo máximo, pero que puede no ser agotado si llegan a producirse otras causas legales de extinción del usufructo, como la muerte si es una persona humana, o la extinción de la persona jurídica, el no uso o el uso abusivo.

Nada impide que la duración del usufructo, en lugar de un plazo, esté subordinada al cumplimiento de una condición resolutoria. El usufructo durará hasta que se cumpla tal condición, o hasta que muera el usufructuario, lo que ocurra primero.

Dentro de esta causal se puede incluir a la resolución por incumplimiento.

b.2) Muerte

El usufructo debe durar hasta que se cumpla el plazo o la condición pactados. Ahora, si antes de ese momento, ocurre la muerte del usufructuario, se extingue en ese instante por ser un derecho *vitalicio, intransmisible por vía hereditaria* (art. 2140).

Lo mismo sucede si no se pactó ningún plazo o condición. Acaecida la muerte se extingue el derecho. De modo que la muerte extingue el usufructo, haya o no plazo previsto. Es un tope insuperable.

El único supuesto en el que puede subsistir a la muerte es en el caso de que sean varios los usufructuarios de manera conjunta, en cuyo caso la muerte de uno no lo extingue, sino la muerte de todos, si aún no se cumplió el plazo o la condición previstos.

b.3) Extinción de la persona jurídica

El inciso b, del artículo 2152 extiende el plazo a 50 años. Ocurre que las personas jurídicas no mueren como las personas humanas, por lo que se prevé el supuesto de su extinción como tales. La cesación de la existencia de la persona jurídica equivale a la muerte de las personas humanas.

Si se pactó un plazo o condición, habrá que atenerse a esas modalidades, pero hay un límite de 50 años.

Cuando se trata de una persona humana, no hay un plazo máximo de este tipo. Así, por ejemplo, si la persona vive 80 años más luego de la constitución, y no se previó un plazo menor, eso durará el usufructo.

Las personas jurídicas se extinguen por su disolución y liquidación. Las causales están enumeradas en el artículo 163.

b.4) No uso

El derecho de dominio es perpetuo y, por ende, no se extingue por el no uso. En cambio, el usufructo, como otros derechos limitados, es temporario y susceptible de extinguirse por dicho motivo. La inercia del usufructuario reviste singular importancia, con prescindencia de la posesión, o no, por parte de un tercero o del nudo propietario. Es suficiente con la inactividad del usufructuario.

El inciso c, del artículo 2152 establece como causal de extinción el no uso durante diez años. Esto es así, cualquiera sea el motivo. Si hay cusufructuarios, bastaría con el uso de uno para mantener el derecho de ambos. El Código exige "el no uso por persona alguna", de manera que si alguna persona usa el derecho no se extingue.

b.5) Uso abusivo. Alteración de la sustancia

El artículo 2152, inciso d, faculta al propietario a reclamar la extinción del usufructo en el supuesto de demostrar el uso abusivo y la alteración de la sustancia. Se entiende que la situación debe ser "grave". El reclamo deberá ser formulado ante un juez, ya que dice dicha norma que la causal debe ser "comprobada judicialmente".

b.6) Resolución de los derechos del constituyente

Esta causal no está mencionada por el artículo 2152 ya que surge de los principios generales. No es propia del usufructo sino común a otros derechos reales. Así, si el dueño revocable grava un inmueble con usufructo, y su derecho se resuelve, se extingue también el usufructo al operar la resolución con efecto retroactivo (arts. 1966, 1967, 1969). No es así cuando se trata de cosas muebles y el usufructuario es de buena fe y a título oneroso (arts. cit.).

b.7) Resolución y revocación

Por aplicación de los principios generales se puede resolver el contrato por incumplimiento o revocarlo por las causas previstas para las donaciones, si fue constituido a título gratuito.

b.8) *Legado*

El artículo 2460 autoriza a los legitimarios a extinguir el usufructo constituido por el testador, entregando la porción disponible.

c) *Efectos de la extinción*

Cuando cesa el usufructo, el nudo propietario recupera el objeto, ya que el usufructuario debe restituir los bienes a quien tenga derecho en la cantidad y estado a que se refieren los artículos 2137 y 2138 (art. 2150). El usufructuario queda convertido en tenedor a nombre del nudo propietario hasta que la entrega se concrete.

Si se niega a restituir, o intervierte el título, el propietario deberá iniciar acciones para recuperar el objeto. Serán aplicables las normas previstas para el poseedor de mala fe (arts. 1935/1936). Diferente será la situación si tiene derecho a ejercer el derecho de retención en función de gastos hechos en la cosa que no estaban a su cargo.

Agrega el artículo 2153: "Extinguido el usufructo originario se extinguen todos los derechos constituidos por el usufructuario y sus sucesores particulares.

"El usufructo cedido por el usufructuario, no puede durar más allá de la oportunidad prevista para la extinción del usufructo originario.

"Si el usufructo es de un conjunto de animales que perece en su totalidad sin culpa del usufructuario, éste cumple con entregar al nudo propietario los despojos subsistentes. Si el conjunto de animales perece en parte sin culpa del usufructuario, éste tiene opción de continuar en el usufructo, reemplazando los animales que faltan, o de cesar en él, entregando los que no hayan perecido".

B) USO

I. Concepto

El uso es el derecho real sobre cosa ajena que confiere a su titular la facultad de usar y gozar, con límites establecidos en el título constitutivo. Generalmente (no imperativamente), este uso y goce se limita a las necesidades del usuario y de su familia, lo que lo diferencia del usufructo.

Este uso y goce es más limitado, pues se tiene muy en cuenta la persona del usuario y de su familia. Este factor hace que el derecho de uso no pueda ser constituido en favor de una persona jurídica.

Dice el Código que "El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce se entiende que se constituye un usufructo.

"El derecho real de uso sólo puede constituirse a favor de persona humana" (art. 2154).

Como el usufructo, es un derecho temporario y vitalicio. También hay que respetar la sustancia del objeto.

En definitiva, el uso es un usufructo reducido, limitado.

II. Objeto

Puede ser establecido sobre toda especie de cosas muebles o inmuebles, cuyo goce pueda ser de alguna utilidad para el usuario. Puede comprender los frutos de un fundo ajeno. En este último caso, generalmente el uso queda limitado a las necesidades del usuario y su familia.

Pero según el Código no es fundamental que el derecho de uso se limite a las necesidades del usuario y de su familia, ya que de la lectura del artículo 2157 surge: "...cuando el uso de éstos se limita a las necesidades del usuario y su familia". Quiere decir que puede haber casos en los que no se limite de esta forma.

III. Régimen legal. Normas supletorias

"Se aplican al uso las normas del Título VIII de este Libro, a excepción de las disposiciones particulares establecidas en el presente" (art. 2155). Por ende, se aplican las reglas previstas para el usufructo, con las pocas excepciones previstas en el Título IX (v. gr.: no puede constituirse en favor de una persona jurídica, no se pueden constituir derechos reales en favor de terceros, el objeto es una cosa, el embargo tiene límites).

Por otro lado, en caso de duda, cabe interpretar que se está en presencia de un usufructo en lugar de un derecho de uso. Debe estar limitado el uso y goce en el título, pues de no ser así se trata de usufructo (art. 2154).

IV. Facultades del usuario

a) Limitaciones al uso y goce

El usuario tiene el uso y goce de la cosa, pero con límites, pues de no haberlos no habría uso sino usufructo (art. 2154).

La extensión y los límites en el derecho real de uso regulado en el Código actual no están dados primordialmente por las necesidades del usuario y de su grupo familiar, dado que la limitación del uso y goce surge del título constitutivo.

Así por ejemplo si un campo forestado sobre el cual se constituyó un derecho real de uso tiene capacidad para generar 100.000 toneladas de leña en un año, pero en el contrato constitutivo se estableció que el usuario sólo podía gozar de 5.000 toneladas anuales, dicha cantidad será el límite del uso y goce.

b) Limitaciones a la facultad de disponer

Dice el artículo 2156, bajo el título *Limitaciones*, que "El usuario no puede constituir derechos reales sobre la cosa".

Cabe interpretar que puede transmitir su derecho, en las mismas condiciones previstas para el usufructo, ya que el Código sólo le impide constituir derechos reales sobre la cosa (v. gr.: servidumbre). Obsérvese que al tratar el derecho de habitación, dice expresamente que la habitación no es transmisible por actos entre vivos, y que el habitador no puede constituir derechos reales (art. 2160), mientras que al regular el derecho de uso sólo señala lo segundo.

No obstante, pueden surgir dudas si se repara en la definición que hace el Código del derecho de uso, ya que menciona a las facultades de usar y gozar de una cosa ajena (art. 2154), sin aludir a la facultad de disponer jurídicamente, lo que sí hace el artículo 2129 al definir al usufructo.

Hubiera sido preferible mayor claridad en las definiciones del Código, y en lo que hace a la tipicidad de los derechos reales.

c) Derechos personales

El Código le prohíbe al usuario constituir derechos reales. Nada dice sobre los derechos personales, por lo que se puede inferir que lo que no está prohibido está permitido. Se extinguen al acabar el uso.

V. Ejecución por acreedores

Dispone el Código que "Los frutos no pueden ser embargados por los acreedores cuando el uso de éstos se limita a las necesidades del usuario y su familia" (art. 2157).

Por ende, los acreedores del usuario, en principio, pueden embargar los frutos, no el derecho de uso. Así como los frutos pueden ser cedidos o arrendados, pueden ser embargados. Por excepción, tales frutos serán inembargables cuando el uso se limita a las necesidades del usuario y de su familia. La razón es su carácter alimentario.

En cuanto al concepto de familia, puede seguirse como pauta lo previsto en el artículo 246 al proteger la vivienda.

C) HABITACIÓN

I. Concepto

Dice el artículo 2158 que "La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia.

"El derecho real de habitación sólo puede constituirse a favor de persona humana".

II. Caracteres

a) *Temporario*: el derecho de habitación es limitado en el tiempo, en lo cual sigue la naturaleza del usufructo, pudiendo extenderse como máximo a la vida del beneficiario.

b) *Inherente a la persona*: el derecho de habitación es constituido en consideración esencial a la persona del beneficiario.

c) *Intransmisibile*: el artículo 2160 del Código establece que el derecho real de habitación no es transmisible por actos entre vivos ni por causa de muerte. El habitador no puede constituir derechos reales o personales sobre la cosa.

d) *Inembargable*: por sus características, se encuentra fuera del comercio, y por esa razón no puede ser atacado por los acreedores del habitador.

e) *El objeto es un inmueble*: debe ser un inmueble apto para vivienda. Puede ejercerse sobre todo el inmueble o sobre una parte material.

f) *No se puede alterar la sustancia*.

g) *Puede surgir de la ley*: el derecho de habitación puede surgir por voluntad del legislador, como ocurre en los casos del cónyuge o conviviente supérstite (arts. 527 y 2383).

III. Régimen legal

Dice el artículo 2159 que "Se aplican a la habitación las normas del Título IX de este Libro, a excepción de las disposiciones particulares establecidas en el presente". Se trata de las normas previstas para el uso (al que se le aplican las del usufructo con salvedades), pero con las excepciones previstas en este Título X.

Así, por ejemplo, el habitador no tiene derecho a percibir frutos, su derecho es absolutamente intransmisibile e inembargable, el objeto es un inmueble habitable.

IV. Objeto

Dice el Código, al definir la habitación, que este derecho real consiste en "morar en un inmueble". "Morar" significa habitar o residir habitualmente en un lugar. Debe tratarse de uno apto para vivienda.

Confirma la idea el artículo 2161, que alude a "una parte de la casa que se le señala para vivienda". Aquí aparecen los vocablos "casa" y "vivienda", que dan mayor precisión al contorno de este derecho real.

V. Impuestos, contribuciones y reparaciones

Dice el Código que "Cuando el habitador reside sólo en una parte de la casa que se le señala para vivienda, debe contribuir al pago de las cargas, contribuciones y reparaciones a prorrata de la parte de la casa que ocupa" (art. 2161).

Se trata de una solución equitativa, pues si se aprovecha sólo una parte del inmueble, no parece justo que se pague por todos los gastos que devenga esa cosa, sino en parte proporcional.

VI. Derecho real de habitación del cónyuge o conviviente supérstite

La protección del derecho a la vivienda, en general, y de la vivienda familiar, en particular, tiene jerarquía constitucional. Así, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la protección integral de la familia y el acceso a una vivienda digna. A su vez, los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, Const. Nac.) consagran, en varias oportunidades, el derecho humano a la vivienda.

a) *Cónyuge supérstite*

Dice el artículo 2383 que "El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante".

Este derecho real nace por voluntad de la ley, y no es necesario requerirlo, ya que surge de pleno derecho. Con la apertura de la sucesión nace el derecho de habitación sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar conyugal.

b) *Requisitos*b.1) *Inmueble de propiedad del causante*

Tiene que tratarse de un inmueble de propiedad del causante, sin importar que sea propio o ganancial, y que a la apertura de la sucesión no se encuentre en condominio con otras personas.

b.2) *No tener atribución preferencial*

En la hipótesis de ser posible la atribución preferencial de la propiedad del inmueble al cónyuge superviviente en los términos del artículo 2381, inciso a, no tendría sentido el derecho real de habitación.

b.3) *Último hogar conyugal*

La norma exige que el inmueble en cuestión haya sido el último hogar conyugal. Si los cónyuges se mudaron a otro, no se podría hacer valer este derecho. Es "el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges" (art. 2621).

c) *Caracteres*c.1) *Vitalicio y gratuito*

El cónyuge superviviente tiene el derecho de por vida, sin que se extinga por contraer un nuevo matrimonio o vivir en unión convivencial. En efecto, el habitador podrá vivir solo o junto con su familia, y el hecho de que sea gratuito implica que los restantes coherederos no pueden reclamarle el pago de un canon por el uso, como así tampoco a quienes lo ocupen junto con el cónyuge.

c.2) *Oponibilidad*

El nacimiento de este derecho se producirá con la muerte del causante, y por tratarse de un derecho real sobre un inmueble deberá ser inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble. El derecho real de habitación es oponible *erga omnes*, incluso a los acreedores de los herederos; mas no así a los acreedores del causante, quienes entonces podrán llevar adelante la ejecución.

d) *Extinción*

El derecho real de habitación del cónyuge superviviente se extingue por las causales previstas para la extinción del usufructo, en tanto sean compatibles (arg. arts. 2155 y 2159).

e) *Situación del conviviente superviviente*

Dispone el artículo 527 que "El conviviente superviviente que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.

"Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.

"Se extingue si el conviviente superviviente constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta".

Como se puede apreciar, el derecho del conviviente es más acotado. La principal diferencia entre ambos supuestos es que a través del derecho real de habitación se garantiza al cónyuge a mantenerse en el inmueble, sin perjuicio de la existencia de otros inmuebles o de la capacidad económica que pudiere tener para adquirir una vivienda. En cambio, el conviviente debe carecer de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que le permitan el acceso. Asimismo, en el caso del conviviente: no opera de pleno derecho sino que debe solicitarlo; no es vitalicio sino que tiene un plazo máximo de dos años; hay previstas causales de extinción (cuando el conviviente superviviente constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, o adquiere vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ella).

El derecho real de habitación del conviviente superviviente contemplado no alcanza a las uniones de parejas cuando uno o ambos de sus integrantes tengan impedimento de ligamen.

CAPÍTULO XVIII

SERVIDUMBRE

MNR

SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto y caracteres. III. Objeto. IV. Clasificación. V. Legitimación. VI. Modalidades. VII. Transmisibilidad. VIII. Derechos y obligaciones del titular dominante. IX. Derechos del titular sirviente. X. Extinción.

I. Introducción

El término "servidumbre" ostenta diferentes acepciones en el lenguaje corriente, pero en el léxico jurídico, en su forma más restrictiva, la servidumbre implica un gravamen sobre un fundo en beneficio de otro fundo, vale decir que significa establecer una utilidad o ventaja en interés del fundo dominante, que deberá respetar el propietario del sirviente.

El fundo dominante se beneficia con alguna utilidad, una ventaja, mientras que el sirviente sufre una restricción que debe soportar. El titular del fundo sirviente debe dejar hacer, o no hacer, pero en ningún caso la servidumbre implica un "hacer". La servidumbre es un beneficio para un inmueble, y una carga para otro.

La servidumbre tiene su razón de ser en procurar una racional y más eficiente explotación y utilización de los predios. Esto se aprecia claramente, por ejemplo, en la servidumbre de tránsito que le permite al titular del inmueble dominante poder atravesar otros predios para llegar o salir del suyo. O bien si carece de agua y necesita transportarla desde otro inmueble vecino. Dichos inmuebles, de no existir una servidumbre, carecerían de valor. Aquí se aprecia también la función social de la propiedad.

II. Concepto y caracteres

Establece el artículo 2162 que "La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo".

Al aludir a dos inmuebles queda claro que no son servidumbres el usufructo, el uso ni la habitación. Se establece que consiste en otorgar alguna utilidad.

a) *Derecho real*

En primer lugar, se trata de un "derecho real" porque: 1) la mutación de los propietarios no trae cambio alguno en las relaciones recíprocas de las heredades; 2) quien por un título cualquiera adquiere un fundo, al cual es debida una servidumbre, puede usar de ella, aunque no fuese indicada en el contrato de venta; 3) el nuevo propietario de una heredad gravada con una servidumbre debe sufrirla aun cuando hubiese adquirido la heredad sin cargas (ver art. 2172); 4) la muerte de quien ha constituido una servidumbre no la extingue; 5) si el dueño del predio sirviente se niega a sufrir la servidumbre, el derecho del dueño del predio dominante no se resuelve en obtener los daños y perjuicios sino que puede exigir que los tribunales le hagan dar el goce efectivo de la servidumbre; 6) se hallan presentes caracteres notorios de los derechos reales como la inmediatez, la adherencia y lo absoluto.

b) *Duración*

La servidumbre puede ser "perpetua o temporaria". Sólo las servidumbres reales pueden ser perpetuas, a no ser que la convención de las partes las limite en el tiempo (art. 2165), mientras que las personales, en cambio, duran como máximo la vida del titular (art. 2165), o 50 años cuando se trata de una persona jurídica (art. 2182, inc. c).

c) *Se requieren dos inmuebles*

Como surge de la propia definición del artículo 2162, este derecho

real se establece entre dos inmuebles, pertenecientes a personas distintas, al menos parcialmente, ya que un inmueble podría pertenecer a una persona que fuera condómino del otro.

De allí que se concluye que el artículo consagra la máxima romana *nemine res sua servit* que se traduce en que nadie puede tener una servidumbre sobre la cosa propia.

El inmueble en cuyo beneficio se establece la servidumbre se llama heredad, fundo o predio dominante, claro está, siempre hablando de una servidumbre real, pues si bien por definición una servidumbre personal también requiere dos inmuebles para su constitución, el beneficio recae sobre la persona de su titular, al que algunos autores, siguiendo al *Esbozo* de Freitas, llaman titular dominante. Que la servidumbre requiere siempre de un fundo dominante es ratificado por el artículo 2172, en el que afirma que "Ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante..."

Una servidumbre no puede ser vendida por separado, ni en un remate (ver art. 2178), porque la servidumbre no se debe sino a ese fundo; es inherente, se trata de una carga real (art. 1888).

El predio dominante es aquel que recibe el beneficio, la utilidad, la ventaja, de la constitución de servidumbres reales o personales, aunque en estas últimas la ventaja está ligada a una o más personas determinadas (arts. 2165 y 2167).

Ya sea la servidumbre real o personal, el inmueble que soporta la carga siempre se denomina sirviente.

d) *Ubicación de los inmuebles*

Resulta del artículo 2165 que la ubicación de los fundos en una servidumbre puede no ser de contigüidad ("sin ser indispensable que se toquen"), mientras que se asegure una ventaja real a la heredad dominante. Surge el interrogante sobre si deben necesariamente estar ubicados cerca uno del otro o si puede existir una servidumbre a favor de un inmueble situado a gran distancia. A pesar de que en la práctica resultaría difícil que existan dos personas interesadas en dar a luz un derecho con tales características, la doctrina ha brindado ejemplos en los que bien puede pensarse en la constitución de una servidumbre

cuyo beneficio es aprovechado por el titular de un fundo alejado del dominante, como el clásico de la posibilidad de sacar agua de un inmueble lejano, si es el único pozo en los alrededores.

e) *Otros caracteres*

La servidumbre es un derecho real "principal" (art. 1889), recae sobre cosa registrable (art. 1890), y no se ejerce por la posesión, pero cuando es positiva se ejerce por actos posesorios concretos y determinados (art. 1891). Para ser oponible a terceros interesados de buena fe precisa de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble (art. 1893).

f) *Contenido*

En cuanto al contenido, el artículo 2162 dice que el titular puede obtener del fundo dominante alguna "utilidad". Se trata de obtener alguna ventaja, que puede consistir en facultar al titular de la servidumbre a usar del inmueble ajeno, o impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos. No puede haber servidumbre sin alguna utilidad o ventaja. Tampoco puede absorber toda la utilidad susceptible de brindar el inmueble afectado, porque entonces se trataría de un usufructo.

No es fácil establecer el contenido exacto del derecho de servidumbre, dada la amplitud con la que está concebido el concepto. Generalmente, la desmembración de la propiedad que éste implica puede consistir en no tener el derecho de hacer todo lo que se podría hacer, si no existiese ese derecho (no hacer o *non faciendo*), o bien, tener que sufrir que otra persona haga alguna cosa que habría derecho de impedirle hacer, si no estuviera constituida la servidumbre (sufrir alguna cosa o *in patiendo*). En este sentido, el artículo 2164 se refiere a "soportar" o a una "abstención".

De lo expuesto se puede inferir que nunca la servidumbre puede importar un hacer, por cuanto el hacer es típico y exclusivo de los derechos personales. Rige un principio que viene del Derecho Romano: *servitus in faciendo consistere nequit*.

Si se establece una obligación de hacer al constituir la servidumbre,

como obligación accesoria (v. gr.: limpiar el camino), sólo tendrá alcance personal. El Código regula los "derechos del titular sirviente", no sus "obligaciones".

Aquí no hay sujeto activo y sujeto pasivo. Se trata de un beneficio para un predio y de un gravamen para otro. Claro que hay un titular de la servidumbre, que es la persona titular del inmueble dominante.

De lo contrario, habría que admitir la existencia de derechos reales *in faciendo*, pero ello desnaturalizaría el sistema del Código.

g) *Principio de la "atipicidad" de las servidumbres*

Según el artículo 1884, la estructura de los derechos reales surge de la ley, y sería nula la configuración de un derecho real de manera distinta.

Sin embargo, en materia de servidumbres el Código ha permitido a los particulares cierta libertad en lo que hace a su constitución y a las estipulaciones en los títulos que sirvan de fuente a este derecho real, y que tradicionalmente los autores han llamado "principio de atipicidad". Eso sí, esta libertad encuentra su límite en el respeto al esquema impuesto por los caracteres necesarios que no pueden ser alterados sin violar el orden público, principio rector en la regulación de los derechos reales. En primer lugar, el contenido de la servidumbre no puede consistir en un hacer (art. 2164) y debe procurar una utilidad aunque sea "de mero recreo".

El concepto de "mero recreo" no es tan amplio como parece, ya que surge del artículo 2165 que la servidumbre debe asegurar "una ventaja real" al inmueble dominante. No puede ser una ventaja imaginaria o hipotética, sino verdadera. Tal ventaja significa, vista desde el otro lado, un "menoscabo" para el sirviente; debe ser el menor menoscabo posible (art. 2181).

Aunque no dice que si no hay ninguna ventaja no hay servidumbre, puede arribarse a similar conclusión (ver art. 2165). Hay que tener presente que si desaparece "toda utilidad", la servidumbre se extingue (art. 2182, inc. a).

h) *Inseparabilidad. Inherencia de la servidumbre al fundo dominante y al fundo sirviente*

Las servidumbres son inseparables del inmueble al que activa o pasivamente pertenecen. Al ser así, tienen carácter accesorio, pues no subsisten por sí solas, requieren de los dos inmuebles. Así resulta que no se puede enajenar la servidumbre si no se enajena también el inmueble, ni viceversa. Tampoco una servidumbre podría ser hipotecada o embargada si no lo es el inmueble al que accede. No podría un extraño adquirir la servidumbre en una subasta.

Prevé el artículo 2172 que "Ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante..." Explica este artículo que la servidumbre, como carga real que es, no puede separarse del inmueble.

La regla es la transmisibilidad de los derechos reales (art. 1906); la servidumbre lo es, pero en tanto acompañe al inmueble que es transmitido.

La inherencia es una de las características necesarias de la servidumbre como de todo derecho real, con la diferencia, en relación a los restantes, de que la inherencia en la servidumbre comprende tanto al derecho del titular del fundo dominante como a la carga del titular del fundo sirviente, aunque el artículo 2172 sólo se refiera al dominante.

El artículo 2172 que aquí se analiza, combinado con el artículo 2165, es claro en que sólo se aplica la regla de la inherencia tratándose de servidumbres reales (no personales), las que, consideradas activa y pasivamente, son inherentes al fundo dominante y al fundo sirviente y siguen con ellos a cualquier poder que pasen, lo que no sucede con las personales (art. 2165). En las reales, se transmite la servidumbre a los sucesores porque el objeto de ésta es el inmueble, mientras que en las personales su finalidad no es beneficiar al inmueble dominante sino al titular de este último, no obstante que también se ejercen sobre un inmueble.

i) *Indivisibilidad*

El Código de Vélez establecía que la servidumbre es indivisible

como carga y como derecho. El Código actual nada dice sobre el punto, pero se puede llegar a la misma conclusión. Cabe advertir que el artículo 2163 dice que la servidumbre puede recaer sobre todo o una parte del inmueble, pero no dice que se pueda ejercer por una parte alcuota, como sí lo prevé para los derechos reales en general y para el usufructo (arts. 1883 y 2130). Las servidumbres no pueden adquirirse o perderse por partes alcuotas ideales, y los propietarios de las diferentes partes pueden ejercerlas, pero sin agravar la condición de la heredad sirviente.

Sin perjuicio de lo expuesto, el ejercicio de la servidumbre es divisible. Así, por ejemplo, si una persona tiene derecho a pasar por el inmueble vecino de mañana, de tarde y de noche, puede hacerlo sólo de mañana.

j) *Servidumbre administrativa*

Por servidumbre administrativa debe entenderse, siguiendo a Marienhoff, a aquel "...derecho real administrativo constituido por el Estado (*lato sensu*), sobre un bien del dominio privado o dominio público, con el objeto de que tal bien sea usado por el público en la forma que resulte del acto o hecho constitutivo del gravamen".

Se constituyen siempre a favor del Estado nacional o de empresas concesionarias del servicio eléctrico de jurisdicción nacional, y con el objeto de servir a un fin público. Se conciben como un poder jurídico sobre la cosa, poder que es esencialmente un derecho real. De allí la necesidad de señalar una diferencia entre estas servidumbres y las limitaciones al dominio impuestas por razones de interés público. Estas últimas se fundan en la aplicación del poder de policía y se traducen en restricciones y no en una desmembración del derecho de propiedad, justificándose en la solidaridad de intereses y en el concepto social de la propiedad privada.

Característica de esta servidumbre administrativa es la inexistencia de fundo dominante reemplazado por la colectividad en la figura del Estado u otra entidad de Derecho Público, que es uno de los sujetos de la relación jurídica, esto es, aquel a quien se atribuye el derecho de servidumbre.

III. Objeto

Se refiere el artículo 2163 al objeto de este derecho real: "La servidumbre puede tener por objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno".

Las servidumbres en la práctica pueden tener una variedad infinita. A veces afectan sólo una parte material del inmueble, como ocurre con la servidumbre de paso o la de acueducto; o la altura del edificio, como la servidumbre de vista. O bien, la servidumbre de vista ofrece una ventaja a la parte del edificio que la enfrenta.

Pero si bien la redacción del artículo no deja lugar a dudas al permitir solamente establecer una servidumbre sobre una "parte material" del inmueble, no está de más reiterar que tampoco puede establecerse una servidumbre por uno de los copropietarios sobre su parte indivisa (ver arts. 1989/1990, 2168), pues se violaría el principio de indivisibilidad de las servidumbres, no mencionado por el Código, pero que implica que no se la puede adquirir de esa forma. Como derecho es indivisible, aunque sea posible dividir su ejercicio (v. gr.: pasar por un determinado lugar, o sólo de mañana, etc.).

Podría haber servidumbres recíprocas entres dos inmuebles, de manera que ambos serían dominante y sirviente a la vez.

Dice el artículo 2165, respecto de los dos inmuebles, que no es "indispensable que se toquen". Generalmente ambos inmuebles son contiguos, vecinos, pero no es un requisito indispensable. Incluso, puede haber un fundo intermedio entre ambos. La cuestión es si uno le procura al otro una ventaja, una utilidad.

IV. Clasificación

a) Positiva y negativa

Dispone el artículo 2164: "La servidumbre es positiva si la carga real consiste en soportar su ejercicio; es negativa si la carga real se limita a la abstención determinada impuesta en el título".

La servidumbre positiva le permite al titular del fundo dominante realizar alguna actividad (v. gr.: sacar agua), y el titular del fundo sirviente debe soportar (dejar hacer, *in patiendo*). La negativa le permite

exigir al titular del fundo sirviente una abstención (v. gr.: no construir más allá de cierta altura, no edificar). Es negativa la que prohíbe hacer algo que le sería lícito hacer al dueño si no existiera la servidumbre (*non faciendo*).

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los derechos reales se ejercen por la posesión, con excepción de las servidumbres negativas y la hipoteca. Las positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados (art. 1891) y se adquieren —entre otros modos— por la tradición, que se refleja en el "primer uso" (art. 1892).

Dado que el Código dispone que los derechos reales "principales" se pueden adquirir por prescripción (art. 2565), y que para ello la posesión debe ser "ostensible y continua", se puede concluir que las servidumbres positivas se pueden adquirir por usucapión.

b) Real y personal

b.1) Servidumbre real

De la sola lectura del artículo 2165 se desprende que la servidumbre real, o predial como también se la denomina, requiere necesariamente para su existencia de dos inmuebles, mientras que la utilidad que brinda el fundo sirviente debe recaer en beneficio del fundo dominante y no de su titular, por lo que en nada incide el cambio en la persona de este último.

Dice esta norma que la ventaja real le debe corresponder a la heredad dominante, esto es, sin importar quién sea su titular. La servidumbre real, mirada desde uno u otro inmueble, "es inherente" a ellos. Esto significa que transmitido uno, o los dos, la servidumbre —como derecho y como carga real— continúa gravándolos, no se extingue. En cambio, la personal se extingue —si no se pactó un plazo menor— con la persona titular del inmueble dominante, o con su enajenación.

b.2) Servidumbre personal

La categoría de la servidumbre personal es la que más dificultades de interpretación ha presentado en relación a su contenido. Dice el artículo 2165 que "...La servidumbre real considerada activa y pasivamente es inherente al fundo dominante y al fundo sirviente..." La expresión "es

inherente", reservada para las servidumbres reales, no puede servir de argumento de quienes sostienen que el usufructo, el uso y la habitación constituyen servidumbres personales. Ya se dijo anteriormente que todas las servidumbres necesitan de dos inmuebles para existir.

No hay inherencia al fundo dominante en las servidumbres personales, las que, si bien no pueden ser separadas del fundo ni formar el objeto de una convención, ni ser sometidas a gravamen alguno (tal como ocurre con las servidumbres reales -arts. 2165, 2172-), no se transmiten a los sucesores porque acaban con la muerte del titular o a los 50 años si fueran a favor de personas jurídicas, no admitiéndose pactos en contrario (art. 2152, inc. c).

Al igual que las servidumbres reales, las personales también requieren para su constitución de la existencia de dos inmuebles, pero la utilidad del fundo sirviente recae ya no directamente sobre el fundo dominante sino sobre la persona de su titular.

En suma, la servidumbre personal procura una utilidad a una persona determinada, más que al inmueble. Así, por ejemplo, el titular de un inmueble tiene especial interés en entrar al inmueble vecino para recoger flores, por su actividad personal. El día que el inmueble sea transmitido a otra persona, para ésta carecería de toda utilidad.

b.3) Presunciones

La servidumbre real se presume perpetua y la personal vitalicia. En ambos casos, se puede pactar un plazo menor.

Además, en caso de duda, la servidumbre se presume personal.

b.4) Servidumbre personal a favor de varios titulares

Dice el Código que "La servidumbre personal puede establecerse a favor de varias personas. Si se extingue para una subsiste para las restantes, pero sin derecho de acrecer, excepto que el título prevea lo contrario.

"No puede establecerse la servidumbre personal a favor de varias personas que se suceden entre sí, a menos que el indicado en un orden precedente no quiera o no pueda aceptar la servidumbre" (art. 2167).

Este artículo impide el derecho de acrecer (excepto pacto en con-

SERVIDUMBRE
MNR

trario), así como la sucesión, en las servidumbres personales. Es una regulación similar a la prevista para el usufructo y el derecho de acrecer (art. 2132). Se trata de una solución prevista para el usufructo y para la institución de herederos (está vedada la sustitución fideicomisaria), que el Código traslada a las servidumbres.

Puede establecerse la servidumbre personal a favor de varias personas para que la ejerzan al mismo tiempo, pero no para que una suceda a la otra. La razón es evitar que se perpetúe una servidumbre que por ser personal está destinada a concluir con la vida del titular, si no se pactó un plazo menor.

Se aclara que la única posibilidad de admitir la sucesión se daría si el indicado en primer lugar no quiere o no puede aceptar la servidumbre. No sería, en rigor, una verdadera sucesión, sino que uno entra en lugar de otro que nunca adquirió la servidumbre.

c) Voluntaria o forzosa

Por regla, la servidumbre resulta de un acuerdo entre el titular del fundo dominante y el del fundo sirviente. No obstante, el Código prevé que puede haber derechos reales impuestos por la ley (art. 1894), y en lo que aquí interesa, aclara que hay servidumbres impuestas por la ley y cuáles son. En efecto, dice el artículo 2166 que "Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa.

"Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante, o para la población, y la de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías.

"Si el titular del fundo sirviente no conviene la indemnización con el del fundo dominante, o con la autoridad local si está involucrada la población, se la debe fijar judicialmente.

"La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible".

c.1) *Servidumbres forzosas*

Se llaman de esta forma aquellas servidumbres que la ley autoriza e impone, con prescindencia de la voluntad u oposición del titular del fundo sirviente. Si se dan determinadas circunstancias, un titular de un derecho real sobre un inmueble puede obligar a su vecino a soportar una servidumbre, aunque no quiera. La ley lo impone.

Ello no implica que el titular del fundo sirviente no pueda convenir con —por ejemplo— el del predio dominante y se constituya la servidumbre de paso a favor de este último, pues nada impide que el derecho real sea fruto de un convenio entre vecinos (servidumbre “convencional”).

Son excepcionales pues el dominio se presume libre de cargas, de ahí que la regla es que nadie puede imponer una servidumbre; debe haber una necesidad especial. Además, los casos tienen que surgir en forma expresa de la ley; la enumeración es taxativa. Se presume la libertad de los inmuebles.

Si el dueño del fundo sirviente no colabora o no acepta la servidumbre, el interesado puede demandarlo judicialmente para imponerla. La acción, dice la norma, “es imprescriptible”. Cabe entender que se trata de una acción real, más precisamente, la confesoria.

La servidumbre forzosa es irrenunciable (art. 12), resguarda el interés público al tener en miras fundamentalmente razones económicas de bien común.

Obviamente, el titular del fundo sirviente tiene derecho a una indemnización. Si no hay acuerdo con el titular del fundo dominante, “o con la autoridad local si está involucrada la población, se la debe fijar judicialmente”. Es interesante que en aquellos casos en los que la población de un lugar esté interesada en ejercer alguna servidumbre forzosa (v. gr.: acueducto), sea la autoridad local quien cargue con la indemnización. En rigor, al no visualizarse claramente la existencia de un fundo dominante, parece esta figura estar más cerca de una servidumbre administrativa.

c.2) *Servidumbre de tránsito*

Los titulares de inmuebles, si lo desean, pueden gravarlos con ser-

vidumbres de paso a favor de sus vecinos. Aquí rige la autonomía de la voluntad y el principio de atipicidad de las servidumbres. No obstante, si se dan ciertas condiciones, el tránsito por el inmueble de otro se puede imponer, aun contra su voluntad.

La servidumbre de tránsito, también llamada “de paso”, es una de las más antiguas modalidades de este gravamen; se trata de una servidumbre coactiva (no voluntaria), que se caracteriza por su inderogable necesidad y estrecha dependencia de los presupuestos legales, fundándose en el interés de los particulares o en la utilidad pública. Esta servidumbre coactiva es siempre típica o nominada y tiene por única fuente a la ley.

Es menester que se trate de un inmueble “sin comunicación suficiente con la vía pública”. Por ende, no es necesario que no tenga comunicación alguna, sino que no sea suficiente. Se daría este último supuesto cuando el camino fuera tan estrecho que sólo permitiera el paso de las personas, o bien el paso de personas y animales de ganado mayor o menor, pero no el de vehículos de tracción a sangre o mecánica, necesarios para una adecuada y racional explotación agrícola, ganadera o industrial del fundo.

Los fundos obligados al paso podrán ser linderos o no. Bastará que se interpongan en el trayecto consiguiente al acceso para que puedan resultar directamente afectados, y sobre todo aquellos que se encuentren en la línea recta más corta a la vía pública, medida desde el predio encerrado.

Nada impide que la servidumbre se constituya mediante paso subterráneo o a través de un puente, si las circunstancias técnico-legales lo tornaran imprescindible.

Esta servidumbre, teniendo en cuenta que deriva del interés público y no de una persona en particular, es real.

Para calcular la indemnización son pautas importantes el valor del terreno ocupado y el perjuicio que sufre el inmueble sirviente.

c.3) *Servidumbre de acueducto*

En un breve concepto de la presente servidumbre cabe remitirse a la idea del paso de agua (*acqua*) por predios ajenos mediante una

canalización (*ductos*), sea ésta cubierta o no. La servidumbre de acueducto es para transportar agua, no para tomarla. El titular de un inmueble que necesita del agua para su explotación económica puede hacerla pasar por otro u otros predios, con el deber de indemnizar.

Dice el artículo 2166 que la servidumbre es viable "cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante, o para la población". Cuando es necesaria para la población, el interés público es evidente, aunque como se dijo anteriormente, aquí la servidumbre parece tener naturaleza administrativa.

c.4) *Servidumbre de recibir agua*

La servidumbre típica de recibir aguas de predios ajenos (*desagüe*) consiste en obligarse al sirviente a tolerar el ingreso de las aguas que provengan de otras heredades; a diferencia de la tratada anteriormente, en el presente supuesto el destino final de las aguas no es el dominante, sino el sirviente.

Esta clase de servidumbre importa que el sirviente reciba las aguas artificiales originadas en un predio superior a partir de algún artefacto o maquinaria (bomba de extracción, molino, etc.). El artículo 2166 pone un límite a la imposición de la servidumbre, cual es que no resulte "perjuicio grave para el fundo sirviente". De ser así, será necesaria la canalización subterránea o en cañerías.

El artículo 2166 aclara que estas servidumbres forzosas son reales.

d) *Activa y pasiva*

La servidumbre se llama activa enfocada desde el fundo dominante, y pasiva respecto del fundo sirviente. Esto se relaciona con el predio que se beneficia o con el que se grava.

Esta clasificación no es adoptada por el Código.

e) *Continua y discontinua*

La servidumbre es continua cuando se ejerce sin necesidad de un hecho actual del hombre, como ocurre con la de acueducto. La discontinua es la que su ejercicio requiere un hecho del hombre y

se da un intervalo de tiempo. Así, por ejemplo, la de tránsito, que requiere que el hombre pase.

Esta clasificación estaba en el Código de Vélez, pero no ha sido adoptada por el Código actual.

f) *Aparente y no aparente*

La servidumbre aparente es la que se manifiesta, se aprecia, por signos, está a la vista. Así ocurre, por ejemplo, con la de acueducto, si los canales están visibles, o la de paso, si hay sendas o piedras que indican el camino. Es no aparente si no se aprecia por una señal exterior (v. gr.: el acueducto es subterráneo).

El Código actual no ha recogido estas dos últimas clasificaciones.

g) *Perpetua o temporaria*

Esta clasificación surge en forma tácita del artículo 2165, que presume la perpetuidad de las servidumbres reales. Lo cierto es que las reales pueden ser perpetuas o temporarias, mientras que las personales siempre son temporarias.

V. Legitimación

a) *Legitimados para constituir una servidumbre*

Indica el artículo 2168 que "Están legitimados para constituir una servidumbre los titulares de derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión. Si existe comunidad debe ser constituida por el conjunto de los titulares".

El artículo 2168 legitima para constituir una servidumbre a los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, lo que comprende tanto a los titulares de derechos sobre cosa propia, como a los titulares de derechos reales sobre cosa ajena, como sucede con el usufructuario.

El usufructuario puede establecer una servidumbre sobre la cosa dada en usufructo, pero sólo por el tiempo que dure el usufructo y sin perjuicio de los derechos del nudo propietario, salvo que el usu-

fructuario constituyente de la servidumbre haya convenido un plazo menor de duración con el titular de la servidumbre del fundo dominante.

Similar apreciación puede formularse respecto del acreedor anticresista, aunque el Código no mencione entre sus facultades al tratar este derecho real.

En el caso de los conjuntos inmobiliarios, el artículo 2084 prevé que, mientras haya mayoría, puede haber servidumbres entre distintos conjuntos entre sí, o con terceros.

Cabe advertir que no todos los titulares de derechos reales poseedores pueden constituir una servidumbre: a) el usuario y el habitador no pueden (arts. 2156, 2160); b) para el usuario de tiempo compartido no parece viable esta facultad (ver art. 2095); c) tampoco para el titular del derecho de sepultura (ver art. 2107); d) en el derecho de superficie, el propietario podría en la medida que no turbe al superficiario (art. 2121).

Si se trata de condóminos, será necesaria la conformidad de todos.

b) *Modos de constitución*

Aunque no se los menciona expresamente, son el contrato, en cuyo caso el primer uso equivale a la tradición si la servidumbre es positiva (art. 1892), y un acto de última voluntad. Se podría mencionar a la ley cuando la servidumbre es forzosa (art. 2166), pero en verdad lo que hace la ley es otorgar un derecho al titular del derecho real para reclamar la imposición de la servidumbre.

b.1) *Prescripción*

Se presentan dudas con la *prescripción larga*, ya que el Código actual suprimió la clasificación de servidumbres continuas y aparentes. No obstante, teniendo en cuenta que la servidumbre es un derecho real principal (art. 1889), y que por regla los derechos reales principales son susceptibles de ser adquiridos de esta forma (art. 2565), cabe interpretar que es posible, pero sólo para las servidumbres positivas, en las que el primer uso es modo suficiente (art. 1892). El interesado deberá probar que ejerció una servidumbre positiva en forma continua

durante el plazo legal. El artículo 1891 prevé que este tipo de servidumbre se ejerce "por actos posesorios concretos y determinados".

La *prescripción breve* podría ser útil para sanear los defectos del título otorgado por quien no estuviese legitimado (arg. art. 2119).

b.2) *Testamento*

Las hipótesis más comunes de constitución de una servidumbre por testamento se dan en los casos en que el testador, propietario de dos inmuebles, dispone legar cada uno de ellos a dos personas distintas disponiendo que uno de los predios quedará gravado por una servidumbre a favor del otro o a favor de la persona del beneficiario, o bien cuando el testador dueño de un solo inmueble dispone que al momento de su muerte, su predio quedará gravado por una servidumbre a favor de otro predio vecino, cuyo titular será el legatario beneficiario. Esta disposición deberá ser respetada por sus herederos, siempre y cuando no afecte su legítima, tratándose de herederos forzosos.

c) *Prohibición de servidumbre judicial*

Dispone el artículo 2169 que "En ningún caso el juez puede constituir una servidumbre o imponer su constitución". Es consecuencia de la regla general del artículo 1896, que impide al juez imponer o constituir derechos reales. Por ende, no está permitido que el juez imponga una servidumbre. Aquí la norma es categórica ya que dice "en ningún caso".

d) *Presunción de onerosidad*

Según el artículo 2170, "En caso de duda, la constitución de la servidumbre se presume onerosa". La servidumbre puede, o no, ser onerosa, pero esto último se presume. Se establece una presunción que puede evitar conflictos entre los interesados.

Cabe inferir que la presunción es *iuris tantum*, y que pesará sobre el titular del fundo dominante la prueba de lo contrario.

VI. Modalidades

La servidumbre, como suele ocurrir con muchos derechos y actos jurídicos, puede ser sometida a modalidades. Lo confirma el artículo 2171, al establecer que "La servidumbre puede sujetarse a cualquier modalidad". Las modalidades de los actos jurídicos están reguladas por los artículos 343/357.

Las servidumbres pueden someterse a un plazo o condición que limiten su duración. Sin embargo, tratándose de servidumbres reales, si no se ha convenido un límite temporal, ellas son consideradas perpetuas (art. 2165), mientras que si fueran servidumbres personales, y tampoco existiere un pacto acerca de la duración del gravamen, se extienden hasta la muerte del beneficiario, y no más allá de 50 años si el titular fuere una persona jurídica, estando prohibida toda estipulación en contrario.

VII. Transmisibilidad

Como ya se señaló, la servidumbre real no puede ser transmitida a un tercero con independencia del inmueble dominante o del sirviente; es inherente a éstos (art. 2165). La servidumbre personal, si es transmitido el fundo dominante, se extingue, ya que no es inherente al inmueble dominante (art. 2165).

Prevé el artículo 2172, en su segundo párrafo, que "La servidumbre personal es intransmisibile por causa de muerte, sin perjuicio de lo dispuesto para la servidumbre a favor de varias personas con derecho de acrecer".

VIII. Derechos y obligaciones del titular dominante

a) Constitución de derechos personales

El titular de una servidumbre activa, esto es, enfocada desde el fundo dominante, sólo está habilitado para constituir derechos personales respecto de la utilidad que le brinda la servidumbre. Establece el artículo 2173 que "El titular de una servidumbre puede constituir sobre ella derechos personales con relación a la utilidad que le es

conferida, sin eximirse de su responsabilidad frente al propietario. No puede constituir derechos reales".

Cabe recordar que el titular puede ser el dueño u otro, como el usufructuario.

El Código sólo permite la constitución de derechos personales con relación a la utilidad obtenida. Así, por ejemplo, el usufructuario titular de una servidumbre que obtiene agua o flores del inmueble vecino, luego podría celebrar contratos sobre ese beneficio. Incluso, por ejemplo, una servidumbre de vista podría ser explotada comercialmente.

Si el que celebra derechos personales sobre la utilidad fuera, por ejemplo, el usufructuario, aclara la norma que es "sin eximirse de su responsabilidad frente al propietario", lo cual es obvio ya que los derechos personales son relativos (art. 1021).

Hay que tener en cuenta que la constitución de derechos personales es válida en la medida en que no se agrave la situación del fundo sirviente (arts. 2175 y 2181). Estos derechos se extinguen cuando finalice la servidumbre (art. 2183).

b) Extensión de la servidumbre

El alcance de la servidumbre se rige, como principio, por los términos del título constitutivo de origen. Sin perjuicio de ello, aclara el artículo 2174 que "La servidumbre comprende la facultad de ejercer todas las servidumbres accesorias indispensables para el ejercicio de la principal, pero no aquellas que sólo hacen más cómodo su ejercicio".

Este artículo 2174 se refiere a la ampliación de los derechos del titular del fundo dominante a las servidumbres accesorias. Así, por ejemplo, en una servidumbre de sacar agua es necesario el paso para poder llegar al lugar en el que se encuentra el agua.

El artículo sólo concede al propietario del fundo dominante la facultad de ejercer las servidumbres accesorias que revistan el carácter de "indispensables" para el uso de la servidumbre principal, y le niega el ejercicio de aquellas servidumbres no indispensables cuyo contenido sólo lo tomarían más cómodo.

Estas servidumbres accesorias no fueron objeto de algún contrato, ya que las impone la ley, si se extingue la servidumbre principal desaparecen las accesorias. Siguen su suerte.

c) *Ejercicio de la servidumbre*

El ejercicio de la servidumbre implica obtener alguna utilidad o ventaja del fundo sirviente.

El Código aplica una regla antigua, que viene del Derecho Romano, en el sentido de que no debe agravarse la situación del fundo sirviente. Dice el artículo 2175 que "El ejercicio de la servidumbre no puede agravarse si aumentan las necesidades del inmueble dominante, excepto que se trate de una servidumbre forzosa".

Existe una regla de que el ejercicio de la servidumbre debe causar el menor agravio posible al fundo sirviente.

La norma dispone que de no haberse pactado otra cosa en el título, el límite del ejercicio de una servidumbre es el de las necesidades del predio dominante en la extensión que tenía cuando fue constituida, es decir, no pueden tomarse en consideración las nuevas necesidades del predio que surjan con posterioridad.

En cuanto a la excepción, si la servidumbre es forzosa, ocurre que al no haber título ni posibilidad de negociar, la ley deba imponer este criterio. Así, por ejemplo, si hay necesidad de pasar más veces que antes, o si aumenta la explotación y se necesita sacar más agua a través de la servidumbre de acueducto. De no ser así, la servidumbre se vería desnaturalizada. Cabe entender que este aumento de las necesidades también debe ser indemnizado y que, a falta de acuerdo, el resarcimiento será fijado por el juez.

d) *Mejoras necesarias*

El Código faculta al titular dominante a realizar mejoras necesarias en el inmueble sirviente. Dispone el artículo 2176 que "El titular dominante puede realizar en el inmueble sirviente las mejoras necesarias para el ejercicio y conservación de la servidumbre. Están a su cargo, a menos que el gasto se origine en hechos por los cuales debe responder el titular del inmueble sirviente o un tercero".

Debe tratarse de mejoras necesarias, esto es, indispensables para el mantenimiento y conservación de la servidumbre. En cambio, el titular dominante no puede realizar obras que agraven la situación del fundo sirviente, ni siquiera si aumentan las necesidades del dominante (art. 2175).

Se trata de un derecho del dominante, no de una obligación que pueda exigir el sirviente, ya que las mejoras lo benefician a aquél. Además, el artículo 2176 dice que el titular dominante "puede", no que debe.

No obstante lo previsto en el artículo que consagra el principio general y no estando interesado el orden público, aunque nada dice la norma, se puede entender que está permitido que se pacte en contrario y, en consecuencia, que se imponga al dueño de la heredad sirviente la obligación accesoria de hacerse cargo de las obras necesarias para el ejercicio y conservación de la servidumbre. Tales convenios importarán derechos personales, no inherentes a la servidumbre. Lo que no se podría es pactar que los actos que constituyan el objeto principal de la servidumbre (por ejemplo, llevar el agua a una heredad dominante) deban ser cumplidos por el titular del fundo sirviente, pues se estaría en presencia de un derecho real *in faciendo*.

e) *Trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbre*

El titular del fundo sirviente y los terceros deben abstenerse de realizar trabajos que impidan el ejercicio de la servidumbre. Si lo hacen, deberán hacerse cargo de volver las cosas a su anterior estado. Prevé el artículo 2177 que "El titular dominante puede obligar a quien hizo en el inmueble sirviente trabajos que menoscaban el ejercicio de la servidumbre a restablecer la cosa a su estado anterior, a su costa. Si el inmueble sirviente pasa a poder de otro, éste sólo debe tolerar la realización de las tareas, sin poder reclamar contraprestación alguna".

e.1) *Obligación de no menoscabar la servidumbre*

Así como es principio en las servidumbres que el propietario del fundo dominante no puede de ninguna manera agravar la situación del fundo sirviente, tampoco el propietario de la heredad sirviente

puede hacer nada que disminuya o menoscabe en modo alguno el uso de la servidumbre constituida.

Sin embargo, si del uso de la servidumbre le resultare un perjuicio que pudiese evitarse, sin privar al poseedor del fundo dominante de las ventajas de que gozare, el titular sirviente "puede exigir que la constitución y el ejercicio de la servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmueble gravado" (art. 2181). Por ejemplo, si el lugar asignado primitivamente por el dueño de la heredad sirviente para el ejercicio de la servidumbre llegase a serle muy incómodo, o le privase de hacer en él reparaciones importantes, podrá ofrecer como asiento de la servidumbre otro lugar cómodo al dueño o poseedor del predio dominante, y éste no podrá rehusarlo. Se trata de una derivación de la regla que impone el ejercicio de la servidumbre del modo menos perjudicial para quien la debe soportar.

e.2) Sanción en caso de incumplimiento

Ahora bien, si el titular sirviente no puede hacer nada que disminuya o menoscabe en modo alguno el uso de la servidumbre, mucho menos podrá ejecutar trabajos contrarios a su ejercicio. No obstante, si los hace está obligado a restablecer a su costa las cosas a su antiguo estado (v. gr., a través de una acción confesoria), y puede ser condenado en su caso a pagar los daños y perjuicios.

f) Ejecución por acreedores

Como ya se explicó anteriormente, la servidumbre es una carga real inherente al inmueble, no puede ser separada ni ser objeto de acto jurídico alguno, ni de ejecución, con independencia del inmueble al que accede. Por tal motivo, dispone el artículo 2178 que "En ningún caso la transmisión o la ejecución de la servidumbre pueden hacerse con independencia del inmueble dominante".

g) Comunicación al sirviente

El titular dominante debe informar al titular sirviente de las pretensiones de terceros. Si no lo hace, es responsable. Prevé el artículo 2179 que "El titular dominante debe comunicar al titular sirviente

las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razón del ejercicio de la servidumbre. Si no lo hace, responde de todos los daños sufridos por el titular sirviente".

Así, por ejemplo, debe denunciar las usurpaciones al propietario del fundo sirviente para que éste pueda obrar contra los usurpadores, ello sin perjuicio de que el titular dominante se encuentra legitimado activamente para iniciar por derecho propio las reales a fin de mantener o restablecer su derecho, lo que sin duda aprovecha al propietario (arts. 2238 y 2264, especialmente).

IX. Derechos del titular sirviente

a) Disposición jurídica y material

Dispone el artículo 2180, primera parte, que "El titular sirviente conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho. No pierde el derecho de hacer servir el predio a los mismos usos que forman el objeto de la servidumbre. Así, aquel cuyo fundo está gravado con una servidumbre de paso conserva la facultad de pasar él mismo por el lugar".

El artículo 2180 establece que, cumplidas las obligaciones de tolerar o abstenerse, "el titular sirviente conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho". Es decir que, fuera de la restricción a su derecho, el titular no deja de ser dueño (o titular de otro derecho real) del inmueble y puede realizar todo aquello que puede efectuar un dueño o titular del derecho real correspondiente.

Por lo tanto, puede realizar actos de disposición jurídica (v. gr.: venta, permuta, donación, constituir otros derechos reales, etc.) y actos de administración (v. gr.: locación). Estos actos no deben interferir en la servidumbre ya existente; así, por ejemplo, si grava el inmueble con una nueva servidumbre, la segunda no debe perjudicar a la primera (art. 2180, segundo párrafo). También puede disponer materialmente del inmueble, en la medida en que no perjudique a la servidumbre.

b) Defensas que puede oponer el titular dominante

Dice el artículo 2180, en su segunda parte, que el titular sirvien-

te "No debe turbar el ejercicio de la servidumbre, ni siquiera por la constitución de otra. Si lo hace, el titular dominante puede exigir el cese de la turbación; si la servidumbre es onerosa puede optar por una disminución del precio proporcional a la gravedad de la turbación".

c) *Suerte de los derechos reales constituidos*

En algún caso o situación, puede suceder que los derechos reales posteriores puedan perjudicar a los ya constituidos con anterioridad. Lo cierto es que el perjuicio no será tal, ya que entrará a jugar el derecho de preferencia (*ius preferendi*), característico de los derechos reales (ver art. 1886). Así, por ejemplo, si el inmueble está hipotecado, el titular del fundo sirviente puede gravarlo con una servidumbre, pero si el inmueble debe ser ejecutado lo será libre de la servidumbre, por ser la hipoteca de fecha anterior y oponible *erga omnes*. Si la servidumbre se constituyó primero, la solución será la contraria.

d) *Alcances de la constitución y del ejercicio*

Según el artículo 2181: "El titular sirviente puede exigir que la constitución y el ejercicio de la servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmueble gravado, pero no puede privar al dominante de la utilidad a la que tiene derecho.

"Si en el título de la servidumbre no están previstas las circunstancias de lugar y tiempo de ejercicio, las debe determinar el titular sirviente". Se trata de otra aplicación de la regla de que la servidumbre debe causar el menor agravio posible al fundo sirviente.

d.1) *El ejercicio de la servidumbre debe efectuarse del modo menos perjudicial para quien la debe soportar*

Esta regla fue señalada anteriormente, pues también se desprende de los artículos 2174 y 2175 y es reiterada en el artículo 2181. A su vez, el artículo 1941 dispone que en caso de duda sobre la existencia de un gravamen, debe interpretarse que el dominio es perfecto, esto es, a favor de la libertad del inmueble, lo que de alguna manera repercute en el artículo que aquí se comenta. La servidumbre existe, esto no está en discusión, pero hay que interpretarla de la manera menos gravosa.

El artículo 2181 —aunque no lo diga expresamente— permite requerir la modificación incluso de lo convenido, cuando se advierta que existe una forma de ejercer la servidumbre de manera menos perjudicial. Así, por ejemplo, el titular sirviente le requiere al dominante cambiar la franja por la que se ejerce el paso, ya que la parte del inmueble que soporta la servidumbre será destinada a un jardín de infantes, o a la construcción de un edificio, o a ser vendida, y el precio que se obtenga será más alto si el inmueble está libre de servidumbres. Sería una actitud abusiva por parte del titular del fundo dominante oponerse a este cambio, que satisface intereses relevantes del dueño del fundo sirviente sin significar para él un sacrificio importante.

d.2) *Facultad del titular sirviente*

La servidumbre debe ejercerse, en primer lugar, de acuerdo a lo que diga el título de su constitución. Si las circunstancias de lugar y tiempo no han sido previstas (v. gr.: horario para el paso), las determina el titular sirviente. Esto es así para que busque la manera de que la servidumbre le cause el menor agravio posible.

El titular sirviente no debe ejercer esta facultad de modo arbitrario o abusivo.

X. Extinción

a) *Medios generales*

En primer lugar, la servidumbre se puede extinguir por alguno de los medios generales previstos para la extinción de todos los derechos reales.

a.1) *Renuncia o abandono*

El artículo 1907 menciona como causa de extinción de los derechos reales al "abandono". Se trata de la renuncia de la persona que se encuentra favorecida por la servidumbre. Pueden renunciar el propietario del fundo dominante, los condóminos (todos), o bien otros titulares de derechos reales legitimados para adquirir servidumbres cuando ellos

fueron los constituyentes (ver art. 2168). En el caso de estar el fundo gravado con usufructo, la renuncia hecha por el dueño debe producir efectos después de la extinción del usufructo, ya que no puede perjudicar al usufructuario (ver art. 2151). Si la servidumbre se puede extinguir por renuncia, con mayor razón puede acabar por convenio de los interesados.

La renuncia no sería posible, sin embargo, en las servidumbres forzosas, ya que está en juego el orden público.

a.2) Destrucción de la cosa

Ésta es otra causal mencionada por el artículo 1907, salvo que la ley autorice su reconstrucción.

Si bien es difícil trasladarla a la servidumbre, podría darse el caso de que su ejercicio llegase a ser absolutamente imposible por razón de ruina de alguno de los predios, o por un cambio sobreviniente a la heredad dominante, o a la heredad sirviente, ya provengan de la naturaleza o de un hecho lícito de un tercero.

Sin perjuicio de lo que se dijo, no se extinguiría la servidumbre cuando las cosas cambiadas son restablecidas, o lo destruido es reparado (pudiendo volver a ser ejercida la servidumbre), si ello es posible, siempre que se hubiere hecho antes de los 10 años fijados por el artículo 2182, inciso b.

a.3) Consolidación

Las servidumbres se extinguen, asimismo, por la reunión en la misma persona de la propiedad del predio dominante y del predio sirviente, cualquiera que haya sido la causa que la haya motivado, o del predio dominante y la parte del fundo sirviente sobre la cual recaigan. La confusión puede darse en cabeza de uno de los dos titulares o de un tercero que adquiera la propiedad de ambos. La extinción de la servidumbre por confusión es una consecuencia de ser un derecho real sobre cosa ajena, de modo que nadie puede tener una servidumbre sobre su propio inmueble (*nemini res sua servit*).

b) Medios especiales de extinción

b.1) Extinción por falta de utilidad

Dispone el artículo 2162 que la servidumbre concede al titular del inmueble dominante "determinada utilidad sobre el inmueble sirviente", la que puede ser incluso de "mero recreo". El artículo 2165 dice que la carga de la servidumbre real debe "asegurar una ventaja real a la heredad dominante", ya que no se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad que no reporten ventaja para nadie. Si después de constituida, la utilidad desaparece, la servidumbre se extingue (art. 2182, inc. a).

b.2) Extinción por el no uso

Concluye también la servidumbre por su no uso durante 10 años. Dice el inciso b, del artículo 2182 "por cualquier razón", de modo que es así aunque haya sido causado por caso fortuito o fuerza mayor. Ésta es una causal de extinción común a los derechos reales de disfrute. No aclara el Código cuándo el tiempo empieza a correr, pero puede inferirse que se cuenta el plazo desde el día en que se haya dejado de usar, o desde el día en que se ha hecho un acto contrario a su ejercicio (v. gr.: desde que se dañaron las cañerías en la servidumbre de acueducto).

También señala la norma que se produce la extinción por el no uso "por persona alguna". Por ende, si alguna persona ejerce la servidumbre, aun cuando no sea el titular del derecho real, no hay extinción.

Se han citado ejemplos clásicos, como si se ha secado una fuente en la que se había constituido el derecho de sacar agua, la servidumbre se extingue y no revive porque el agua vuelva a brotar después de 10 años. Lo mismo sucedería en la *servitus altius non tollendi*, con precisa determinación del límite de la altura, si el propietario del fundo sirviente edifica a mayor altura que la que le estaba permitida por la servidumbre, y el propietario del predio dominante deja pasar los 10 años sin hacer valer su derecho, sin ejercer el *ius prohibendi*.

b.3) *Vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición*

Las servidumbres se pueden someter a un plazo o condición que limiten su duración (art. 2171). Sin embargo, tratándose de servidumbres reales, si no se ha convenido un límite temporal, ellas son consideradas perpetuas (art. 2165), mientras que si fueran servidumbres personales, y tampoco existiere un pacto acerca de la duración del gravamen, ellas duran hasta la muerte del beneficiario, y no más allá de 50 años si el titular fuere una persona jurídica, estando prohibida toda estipulación en contrario. Además, aun cuando se hubiere pactado un plazo de duración, no pueden extenderse más allá de la muerte.

c) *Efectos de la extinción*

Dice el artículo 2183: "Extinguida la servidumbre, se extinguen todos los derechos constituidos por el titular dominante". Los derechos constituidos por el titular dominante no pueden sobrevivir a la extinción de la servidumbre; siguen su suerte.

El titular dominante sólo puede constituir derechos personales respecto de la utilidad que le concede la servidumbre.

Es obvio que, extinguida la servidumbre, y al no seguir gozando de la utilidad que ésta le suministraba, los derechos de explotación sobre tal utilidad no pueden continuar; carecerían de objeto.

CAPÍTULO XIX
DERECHOS REALES DE GARANTÍA
(primera parte)
MNR

SUMARIO: I. Introducción. II. Convencionalidad. III. Accesoriedad. IV. Créditos garantizables. V. Especialidad. VI. Indivisibilidad. VII. Extensión en cuanto al objeto. VIII. Extensión en cuanto al crédito. IX. Subrogación real. X. Facultades del constituyente. XI. Cláusula nula. XII. Responsabilidad del propietario no deudor. XIII. Rango de los derechos reales de garantía. XIV. Extinción. Subasta. XV. Cancelación.

I. Introducción

Una gran novedad que trae el nuevo Código Civil y Comercial es un capítulo con "disposiciones comunes" a todos los derechos reales de garantía previstos en el Título XII del Libro Cuarto. En efecto, en el Capítulo 1 se establecen disposiciones comunes a la hipoteca, la anticresis y la prenda, sin perjuicio de las normas especiales que regulen a cada uno de ellos. Estas reglas generales "comunes" han permitido que el tratamiento de cada derecho real de garantía sea más reducido.

a) *Garantías*

Se entiende por garantía, en sentido amplio, toda medida de refuerzo que se añade a un derecho de crédito para asegurar su satisfacción, atribuyendo al acreedor un nuevo derecho subjetivo o nuevas facultades.

Si se deslinda la responsabilidad patrimonial común a todos los deudores, la garantía, en sentido estricto o específico, viene entonces a añadir al crédito algo de lo que de por sí carece, de manera tal que dicha adición refuerza al acreedor su expectativa de que el crédito será satisfecho.

No hay que confundir responsabilidad con garantía. La primera es inherente al propio crédito, y se vincula con la posibilidad que tiene el acreedor de agredir el patrimonio del deudor en caso de incumplimiento, en tanto los bienes permanezcan en dicho patrimonio. Ahora, no todos los créditos cuentan con garantía, ya que ésta consiste en fortalecer la situación jurídica del acreedor a través de la creación de nuevos poderes o derechos (personales o reales).

Hay distintas clases de garantías. En ocasiones, la simple retención de la cosa funciona como tal. Una muy difundida es la fianza, donde una persona garantiza con su patrimonio el posible incumplimiento del deudor. Otra de las tantas previstas por el Código es la cesión de derechos en garantía (art. 1615), o el fideicomiso con fines de garantía.

La fianza antes mencionada, como otras, es una garantía de índole personal, ya que si el deudor no cumple, otra persona puede sufrir el reclamo del acreedor. Esta persona responde con su patrimonio.

En cambio, los derechos reales de garantía recaen sobre bienes determinados y tienen varios efectos, entre ellos la oponibilidad *erga omnes*, los derechos de preferencia y de persecución y, especialmente, la potestad conferida al acreedor de dirigirse contra el objeto gravado a fin de realizar su valor y de esa forma cobrar su crédito.

Tradicionalmente se distingue, dentro del conjunto de las garantías, a las garantías reales de las garantías personales. Las primeras consisten en la afectación preferencial de bienes de propiedad del deudor o de un tercero a la satisfacción de la obligación en cuya garantía se gravan. Las segundas, en cambio, importan la asunción de otra obligación, con un deudor distinto del deudor principal, cuyo propósito es satisfacer subsidiariamente la obligación principal (es decir, para el caso en el que ésta no hubiera sido cumplida por el deudor) por vía de ampliar el poder de agresión del acreedor.

b) Finalidad de las garantías

Las garantías apuntan principalmente a la tutela del crédito, a dar mayor seguridad. Se trata de una especie dentro del género "tutela del derecho". El tema también se vincula con el desarrollo económico

y el impulso de la economía. Cuanto mayor sea la seguridad, y menor el riesgo, en una economía "normal", hay más probabilidades de que las personas tengan acceso al crédito a menor tasa de interés, y así disfrutar de un mayor bienestar. Cuando el riesgo es mayor, el crédito suele escasear y ser más caro. De ahí la importancia de contar con garantías efectivas y expeditivas.

Mientras el deudor esté en condiciones de hacer frente a sus obligaciones, el acreedor no corre mayores riesgos. No obstante, el peligro puede aumentar en proporción directa al mayor plazo que haya otorgado para efectuar el pago, ya que la solvencia del deudor al tiempo de contraer la obligación puede decaer posteriormente, sea como consecuencia de aumentar sensiblemente su pasivo o por actos de enajenación de sus bienes que provoque una disminución patrimonial.

El mayor endeudamiento puede traer aparejada la concurrencia de una pluralidad de acreedores, quienes, por aplicación del principio aludido y de la igualdad que establecen los artículos 743 y 2581, cobrarán sus respectivos créditos a prorrata, pudiendo sufrir en la misma proporción una reducción en el monto de lo que tienen derecho a percibir.

A fin de evitar esta situación de incertidumbre y ponerse a cubierto de eventuales oscilaciones en el patrimonio del deudor, los acreedores condicionan el otorgamiento de crédito a la constitución de garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que asuma el deudor. Esto tiene a su vez un efecto secundario, beneficioso para el deudor, ya que podrá encontrar mejores condiciones para obtener crédito en la medida en que le asegura al acreedor mayores posibilidades de cobrar íntegramente lo que le pertenece.

c) Derechos reales de garantía

Como se adelantó, el Código trata en una parte general disposiciones comunes a los derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, anticresis. Por ende, se examinarán a continuación estas disposiciones correspondientes a tales derechos reales. Luego, se examinarán por separado cada uno de ellos, de acuerdo al orden propuesto por el Código.

En este campo, en buena medida, rige el orden público, de modo que los derechos reales de garantía deben reunir ciertos requisitos que hacen a su validez.

d) *Derechos reales de garantía legislados fuera del Código Civil y Comercial*

1) La ley 20.094, respecto de los buques, contempla la hipoteca y la prenda navales.

2) El Código Aeronáutico (ley 17.825), por su parte, solamente contempla al derecho real de hipoteca.

3) El decreto-ley 6582/58, a su vez, contempla como derecho real de garantía, en materia de automotores, a la prenda con registro (conf. inc. a, del art. 19 del decreto citado).

4) El decreto 15.348/46 ratificado por la ley 12.962 trata la prenda con registro en sus dos variantes (prenda fija y flotante).

5) Los warrants —que confieren al acreedor una garantía real sobre los efectos depositados— están regulados por la ley 9643, incorporada al Código de Comercio (según su art. 33) —de modo que conserva su vigencia (art. 5º, ley 26.994)—.

6) Los debentures se rigen por los artículos 326, 327 y 331 a 333 de la ley 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales), que la nueva normativa denomina “Ley de Sociedades”.

II. Conventionalidad

Establece el artículo 2185 que “Los derechos reales de garantía sólo pueden ser constituidos por contrato”. No es posible constituirlos por testamento, ni por imposición judicial o legal.

La convención requiere la voluntad de las dos partes (art. 957), que son: el constituyente, que puede ser deudor o no, y el acreedor.

Agrega el artículo 2185 que el contrato debe ser “celebrado por los legitimados y con las formas que la ley indica para cada tipo”. El contrato puede ser hecho en instrumento público o privado, excepto cuando se grave una cosa inmueble, en cuyo caso será exigible la escritura pública (art. 1017, inc. a).

En cuanto a los legitimados, ello depende del derecho real de que se trate y de cuál sea su objeto. Así, por ejemplo, los titulares del derecho real de propiedad horizontal pueden gravar con hipoteca o con anticresis, pero no con prenda, que recae sobre cosas muebles.

La hipoteca no se ejerce por la posesión. Se constituye, entonces, con el otorgamiento del título en la forma requerida por la ley, y se la inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble para que sea oponible.

Si el acreedor no comparece al acto, puede aceptarlo después, antes de la inscripción (art. 2208). La aceptación posterior también debe ser formalizada en una escritura pública, si se trata de inmuebles.

a) *Diferencias entre causa fuente y convención*

Cabe la distinción, por un lado, de la causa fuente, de las obligaciones puras y simples, o modales, es decir, sujetas a plazo, condición o cargo y que pueden consistir en un hecho positivo (dar o hacer) o negativo (no hacer) generadores de la garantía real, y por el otro, del convenio que tiene por única finalidad constituir e instrumentar el derecho real de garantía.

b) *Derechos reales de garantía tácitos o legales*

A diferencia de los convencionales, que se constituyen por la voluntad de las partes, los legales son de existencia forzosa, porque la ley obliga a constituirlos cuando concurren los supuestos que ella determina.

El Código los excluyó pues tenían el grave problema de la generalidad del gravamen al afectar todos los bienes presentes y futuros de un deudor, su indeterminación en cuanto al monto, y su clandestinidad al permanecer oculto para los terceros, ya que, al no estar sujetas a la formalidad de la inscripción registral, no eran conocidas, y además, eran tácitas, es decir, no provenían de una expresa convención constitutiva.

La Ley Hipotecaria española enumera las siguientes: en favor de las mujeres casadas sobre los bienes de sus maridos; por las dotes; en favor de los hijos o parientes reservatorios; hijos bajo patria potestad

sobre los bienes de los padres, siempre que el padre o la madre hubieren contraído nuevo matrimonio; en favor de los menores o incapaces sujetos a tutela; en favor del Estado sobre los bienes de quienes contratan con dicho ente; en favor de los aseguradores sobre bienes de los asegurados por razón del premio o dividendo del seguro (art. 168).

Este tipo de hipotecas, en rigor, deben ser llamadas "tácitas", en tanto que, a diferencia de las legales, no exigen para su validez y eficacia ni la constitución por contrato, ni mandato judicial, ni la publicidad registral. Son fuertemente criticadas, ya que constituyen los mayores enemigos de un sistema de publicidad del estado jurídico de los inmuebles.

En cambio, las hipotecas legales, según el artículo 158 de la Ley Hipotecaria española, son las que se pueden imponer forzosamente. Esto significa que la hipoteca legal no es creada por la ley automáticamente —como sucede en las tácitas—, sino que la ley concede el derecho a exigir a una de las partes su constitución y a reclamar judicialmente la imposición si la otra se resiste. La hipoteca legal recae sobre bienes determinados, no sobre todo el patrimonio del deudor.

El hecho de que la ley, en algún caso, exija la constitución de una garantía real, no significa que éstas puedan ser impuestas judicialmente. Así, por ejemplo, para que el juez autorice al tutor a prestar dinero de su tutelado, deberá haber alguna garantía real (art. 121, inc. b), pero eso no faculta al juez a imponerla. Lo mismo puede decirse del caso previsto en el artículo 440.

c) *La hipoteca unilateral en la Ley de Obligaciones Negociables*

La ley 23.576 del año 1989 (con las modificaciones de la ley 23.962) configura una excepción al carácter convencional de la hipoteca, pues no hace falta la presencia de un representante de los futuros titulares de los títulos para constituir (o cancelar) el gravamen real sin necesidad de la aceptación por los acreedores, al disponer que "Las sociedades por acciones, las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas en el país, y las sucursales de las sociedades por acciones constituidas en el extranjero [...] pueden contraer empréstitos mediante la emisión de obligaciones negociables" (art. 1º) y que "La hipoteca se constituirá [...] por declaración unilateral de la emisora cuando no concu-

rra un fiduciario [...] y no requiere la aceptación por los acreedores" (art. 3º), surtiendo efectos "contra la emisora y los terceros desde su inscripción" (art. 32).

d) *No son susceptibles de prescripción adquisitiva*

Según el artículo 2565 sólo los derechos reales principales se pueden adquirir por la prescripción: los derechos reales de garantía son accesorios, de modo que no pueden ser adquiridos por usucapión. Ocurre que para su existencia dependen de un crédito, y éste no surge del paso del tiempo. Además, la hipoteca suma otra razón, ya que no se ejerce por la posesión.

III. Accesoriedad

Establece el artículo 1889 que "Los derechos reales son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda". Agrega el artículo 2186 que "Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran, son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal, excepto en los supuestos legalmente previstos.

"La extinción de la garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito".

La accesoriedad de los derechos reales de garantía juega con relación a un vínculo jurídico (un contrato) que es fuente generadora de obligaciones, y no respecto de éstas, cuyo cumplimiento es el que verdadera y efectivamente su deudor asegura con el derecho real.

Dice el artículo 2186 que "Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran". Se refiere al "crédito" en singular, ya que la idea tradicional es que a una obligación corresponde una garantía (v. gr.: hipoteca). No obstante, cabe advertir que el derecho real de garantía puede tener por objeto asegurar más de un crédito.

Es fuerte la conexión entre el crédito y el derecho real que lo garantiza. Es así que no puede desligarse del crédito para cuya seguridad nació y pasar, por ejemplo, a garantizar otro distinto. Tampoco puede ser cedido con independencia de la obligación garantizada. No puede haber derecho real de garantía sin crédito al que acceda.

Como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si se extingue el crédito se extingue el derecho real que lo garantiza (conf. art. 857). En cambio, puede extinguirse el derecho real sin que se extinga el crédito. Como ocurre, por ejemplo, si el acreedor renuncia a la garantía, o el objeto garantizado se destruye, o se revoca el dominio del constituyente con efecto retroactivo.

La regla de que la extinción del crédito principal determina la extinción del derecho real de garantía encuentra excepciones.

- 1) Un caso es el de la extinción de la obligación por *novación*. Dice el artículo 940 que "La novación extingue la obligación originaria con sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva; en tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación sólo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio".
- 2) Tampoco se extingue la garantía si el pago lo realiza un tercero no deudor, que se subroga en los derechos del acreedor. En efecto, establece el artículo 918 que "El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor, y los accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores, y garantes personales y reales, y los privilegios y el derecho de retención si lo hay".

Así, por ejemplo: Juan es acreedor de Pedro y este último hipoteca su casa en garantía. Ignacio le paga a Juan y lo desinteresa. No obstante, la hipoteca no se extingue ya que Ignacio, al subrogarse en los derechos del acreedor al que le pagó, puede ahora ejecutar el inmueble ocupando el lugar que tenía dicho acreedor.

Para satisfacer el principio de accesoriedad es menester individualizar con la mayor cantidad de datos posibles a la obligación que se garantiza, en especial: a) acreedor y deudor; b) si la prestación consiste en dar, hacer o no hacer; c) la causa que les dio origen (acto jurídico, hecho antijurídico o disposición legal).

No obstante, como se verá más adelante, también es posible garantizar con derechos reales créditos cuyos elementos no estén individualizados desde el origen (art. 2189).

IV. Créditos garantizables

La regla es que cualquier crédito puede ser asegurado con un derecho real de garantía y, como se dijo, pueden ser más de uno los garantizados por un derecho real, aunque el Código se refiera al "crédito" en singular. El artículo 2187 dispone lo siguiente: "Se puede garantizar cualquier crédito, puro y simple, a plazo, condicional o eventual, de dar, hacer o no hacer. Al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y su causa, con las excepciones admitidas por la ley".

La obligación puede constar en el mismo acto constitutivo del derecho real de garantía o puede estar en un documento separado.

a) Crédito sujeto a condición suspensiva

Cuando un crédito está sujeto a condición suspensiva, no es exigible hasta que se verifique el hecho sujeto a condición (v. gr.: te pagaré \$ 1.000 si el barco llega de Asia). Esta obligación puede ser garantizada con un derecho real, como se desprende del artículo 2187. No obstante, cabe preguntarse qué ocurre si antes de cumplirse la condición, otros acreedores pretenden subastar el objeto que sirve de garantía. Si el objeto se remata y se llevan el dinero, si la condición se cumple el acreedor no podría hacer valer su garantía ni su privilegio.

Para evitar esta solución poco valiosa, dispone el artículo 2197 que el acreedor puede cobrar, y agrega en la segunda parte que "Si el crédito está sujeto a condición suspensiva, puede requerirse que ofrezca garantía suficiente de la restitución de lo percibido en la extinción del artículo 349 para el caso de frustración de la condición".

b) Crédito sujeto a condición resolutoria

Aquí la situación es la contraria a la señalada en el punto anterior. El crédito es absolutamente exigible, pero podría dejar de serlo si la condición se cumple. Así, por ejemplo, Juan le debe a Pedro \$ 1.000, pero si su sobrino se recibe de abogado se extingue la deuda. Si esta obligación se garantiza con un derecho real, el acreedor está facultado para hacer rematar el objeto y cobrarse su crédito, pero podría resultar perjudicial para otros acreedores, si luego la condición se cumple.

Como se desprende del artículo 347, tales acreedores podrían requerir "medidas conservatorias". Podrían, entonces, solicitar un embargo sobre el dinero que retire el acreedor privilegiado, o solicitarle alguna garantía para el caso de que la condición se cumpla.

c) *Plazo suspensivo*

A diferencia de la condición, el plazo siempre se verifica, no es un hecho incierto. Si el crédito está sujeto a un plazo suspensivo, llegado el día será exigible. Si antes de cumplido el término, otros acreedores pretendieran ejecutar el objeto de la garantía, aquí con más razón todavía el acreedor de dicha obligación tiene derecho a que se asegure su derecho para cuando sea exigible.

La solución más lógica es interpretar que el plazo caducó.

d) *Plazo resolutorio*

Si el crédito está sujeto a un plazo resolutorio, es actualmente exigible. Claro que si el acreedor percibe el dinero, el día que el término se cumpla deberá restituirlo. Para que no se perjudiquen otros acreedores, cabe proponer la misma solución que para el supuesto del crédito sujeto a condición resolutoria.

e) *Crédito eventual*

El artículo 2187 menciona que también puede ser garantizado con un derecho real un crédito eventual. Es eventual aquel crédito que actualmente no tiene existencia real, ni siquiera como condicional, pero está en proceso de gestación, y por ende, puede llegar a tenerla, como en el caso de una constitución de hipoteca sobre el saldo deudor de una cuenta corriente mercantil o bancaria.

El derecho real que ampara un crédito eventual tiene validez actual y conforma un derecho real exigible, y por tanto, el acreedor podría solicitar judicialmente que se decreten medidas conservatorias que impidan la disminución del valor del objeto asiento de la garantía.

En el caso de los créditos eventuales, no es posible describir en el contrato la obligación, con la exactitud que exige el artículo 2187, ya que en ese momento la obligación puede no existir. Habrá que

MNR

mentar el contrato o causa fuente de la cual pueden derivarse tales créditos en el futuro, y las operaciones así aseguradas. Es importante, como se verá más adelante, la expresión del monto máximo del gravamen (art. 2189).

Ejemplo de esta situación es el conocido caso de constitución de una hipoteca por los diversos saldos deudores que pueda arrojar una cuenta corriente bancaria (cuenta en rojo, en descubierto).

V. Especialidad

Entre otros caracteres esenciales de los derechos reales de garantía se encuentra la especialidad. La especialidad tiene que ver con dos aspectos, el objetivo, relacionado con el objeto asiento del gravamen, y el crediticio que tiene que ver con la obligación garantizada y el monto del gravamen.

a) *En cuanto al objeto*

Para que concuerde con el principio de la especialidad en cuanto al objeto, las cosas o derechos sobre los que recae el derecho real de garantía deben estar especificados en su acto constitutivo con absoluta precisión, pues, no puede constituirse esta garantía real sino sobre un objeto que "debe ser actual, y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo" (art. 2188).

Es inadmisibles una mención genérica de los mismos, como ocurría con las hipotecas legales y generales del Derecho patrio no aceptadas por el Código, en protección del acreedor y del interés general. En el Derecho Romano las hipotecas podían recaer sobre la totalidad de los bienes de una persona, presentes y futuros.

En lo que respecta a los inmuebles, con el catastro y dentro de la técnica del folio real implantado por la Ley Nacional Registral 17.801, resulta imposible en la práctica que haya una imprecisión del inmueble gravado con hipoteca o anticresis, pues se halla perfectamente descripto en la matrícula del Registro de la Propiedad.

El Código, además, regula el objeto de la hipoteca en una norma separada. Dice el artículo 2209 que "El inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas perimetra-

les, superficie, colindancias, datos de registraci3n, nomenclatura catastral, y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualizaci3n". Esta exigencia es aplicable tambi3n a la anticresis cuando el objeto sea un inmueble.

Respecto de automotor hay que identificar su marca, modelo, tipo, n3mero de dominio, marca y n3mero de motor y chasis y uso o destino.

Por 3ltimo, surge del art3culo 2188 que el objeto del derecho real de garant3a debe ser "actual", esto es, no pueden gravarse bienes futuros, que a3n no existan.

b) *En cuanto al cr3dito*

La especialidad respecto del cr3dito est3 ligada a la responsabilidad respecto a la cuant3a; es decir, a una cantidad de dinero determinada, o en su caso, el consiguiente valor estimativo.

El C3digo se limita a exigir que se establezca solamente el monto a que se extiende la garant3a real, y que determina el l3mite de la responsabilidad.

Establece el art3culo 2189 que "El monto de la garant3a o gravamen debe estimarse en dinero. La especialidad queda cumplida con la expresi3n del monto m3ximo del gravamen".

Los derechos reales de garant3a pueden constituirse en seguridad de cualquier tipo de obligaci3n, como se vio anteriormente. Ya se trate de una de dar sumas de dinero, o de otra especie, habr3 que consignar en el acto constitutivo un "monto", una cantidad de dinero, que obrar3 como m3ximo de la garant3a real.

As3, por ejemplo, si se asegura una obligaci3n de hacer (v. gr.: dar un concierto) y se pacta una hipoteca para garantizar los posibles perjuicios que resultar3an del incumplimiento de la obligaci3n, ese monto m3ximo operar3a como tope de la responsabilidad del derecho real. As3, si el deudor no cumple y causa un da3o por \$ 1.000.000, 3sa es la suma que deber3 en concepto de indemnizaci3n. Si dicha obligaci3n se garantiz3 con hipoteca, y se estim3 el monto en \$ 800.000, el deudor debe \$ 1.000.000, y el acreedor hasta la suma de \$ 800.000; tendr3 el privilegio que le otorga la garant3a real, y por encima de esa cantidad ser3 acreedor, pero quirografario. As3 funciona el tope m3ximo.

La especialidad no tiene nada que ver con el aspecto crediticio, sino con la responsabilidad o l3mite del gravamen, esto es, la indicaci3n del monto m3ximo. Es decir, no tiene relaci3n alguna con la individualizaci3n del cr3dito en el acto de origen, eso ser3 —en todo caso— un tema propio del principio de la accesoriedad.

La especialidad est3 dada no s3lo en protecci3n del constituyente, sino tambi3n en protecci3n de terceros, que tendr3n seguramente inter3s en conocer el pasivo de sus deudores, con los consiguientes privilegios, y poder analizar as3 las capacidades de pago consecuentes, y la certeza del cr3dito debe surgir de la pertinente publicidad posesoria o registral; vale decir que la garant3a no se extienda m3s all3 del monto establecido.

Asimismo, es un dato sumamente importante para quien desee adquirir la cosa gravada. As3, por ejemplo, un inmueble hipotecado se puede vender y quien lo compre soportar3 la carga real, pero la responsabilidad se limita al monto expresado en el acto constitutivo.

b.1) *Tope m3ximo*

Aclara el art3culo 2189, en su segundo p3rrafo, que "...el gravamen constituye el m3ximo de la garant3a real por todo concepto, de modo que cualquier suma excedente es quirografaria, sea por capital, intereses, costas, multas, u otros conceptos". Esta norma consagra para todos los derechos reales de garant3a la fijaci3n del monto como "tope m3ximo", sin distinguir los cr3ditos determinados de los cr3ditos indeterminados en su causa-fuente, ni tampoco establece diferencia alguna con relaci3n al objeto de la obligaci3n, sea de una suma de dinero o cualquier otra prestaci3n.

No hay que confundir el monto del cr3dito con el monto del gravamen. El primero responde a la suma efectivamente adeudada, cuya determinaci3n no puede ocurrir a la fecha de constituci3n del derecho real. El segundo responde a esa cantidad "tope o m3xima" hasta la cual responde el derecho real, que le confiere al acreedor las facultades reipersecutorias y de privilegio que distinguen a los derechos reales de garant3a.

Sin embargo, tambi3n se puede interpretar que este tope m3ximo opera s3lo si se trata de cr3ditos indeterminados.

Otra consecuencia es que el propietario no deudor se libera abonando ese monto (art. 2199).

El artículo 2193 dispone que "La garantía cubre el capital adeudado y los intereses posteriores a su constitución, como así también los daños y costas posteriores que provoca el incumplimiento. Los intereses, daños y costas anteriores a la constitución de la garantía quedan comprendidos en su cobertura sólo en caso de haberse previsto y determinado expresamente en la convención". Armonizado este artículo con el artículo 2189, cabe llegar a la conclusión de que la garantía cubre los rubros mencionados, pero hasta el monto máximo del gravamen. Si hay un excedente, no estará cubierto por la garantía real, cuando se trata de créditos indeterminados (ver también arts. 2582, inc. e, y 2583).

La primera interpretación puede traer algunos problemas. En el caso de una obligación de dar una suma de dinero, no se puede ignorar la situación inflacionaria que soporta, lamentablemente, nuestro país. Por ende, atarse a un monto fijo puede ser riesgoso para las partes, ya que deben cubrirse del flagelo inflacionario, especialmente el acreedor. Esto puede inducir a que "infle" el monto máximo para cubrir la desvalorización monetaria, y las altas tasas de interés.

A la vez, esta solución genera una desigualdad injusta y arbitraria, porque protege más al deudor incumplidor que al cumplidor.

La segunda posición, que limita la aplicación del artículo 2189 a los créditos indeterminados, mientras que para los determinados remite al artículo 2193 (como era en el Código derogado), es más razonable, práctica y realista. El privilegio lo fija el artículo 2583.

b.2) Créditos indeterminados

El crédito puede estar individualizado en todos los elementos desde el origen o puede nacer posteriormente. Este último es el caso de la llamada "hipoteca abierta". Además, como se dijo, pueden ser más de uno los créditos garantizados.

La expresión *hipoteca abierta* se utiliza a menudo y ha sido ganada por la costumbre en la práctica notarial y financiera, pero su denomi-

nación y funcionamiento no fueron acogidos favorablemente por la doctrina en general, y su concepto no es unívoco.

En lo que aquí interesa, se refiere a todos los créditos indeterminados que ingresen en la garantía real beneficiándose con las operaciones que la integran tanto el acreedor como el deudor.

También apodada hipoteca global, flotante, paraguas o con indeterminación sustantiva o de causa. Es la hipoteca que asegura una masa de créditos indeterminados en su causa-fuente, sean presentes y/o futuros, a favor de un acreedor determinado, por un monto máximo y durante un plazo cierto. La garantía puede asegurar obligaciones variadísimas y determinadas sólo en líneas generales.

Este sistema tiene la ventaja de simplificar las tramitaciones tendientes a obtener créditos, abaratar sus costos, y ahorrar la constitución sucesiva de nuevos gravámenes reales, o tener que efectuar ampliaciones del primigenio acto escriturario, evitando de igual modo la afectación de los restantes bienes inmuebles pertenecientes al deudor, que los podrá ofrecer -incidentalmente- en garantía de distintas operaciones con otros acreedores. Favorecen condiciones que permiten a un deudor obtener crédito, a un costo menor y de una forma más rápida y ágil. Si cada vez que se pretenda garantizar una obligación hubiera que constituir un derecho real de garantía accesorio, el costo sería mucho mayor, mientras que de esta forma los gastos operan en la primera oportunidad, ya que esa garantía va amparando en su seno obligaciones diversas que van con el tiempo determinándose.

El Código, en los artículos 2187 y 2189, admite expresamente esta posibilidad, no sólo para la hipoteca, sino para todos los derechos reales de garantía (prenda y anticresis). El derecho real será válido y oponible *erga omnes*, en la medida que se vislumbre la razón de ser de la causa fuente generadora de las obligaciones que serán objeto de la garantía real, y siempre que se consigne la cantidad cierta de dinero, plazos acordados, y el tipo de interés pactado si se tratare de una obligación dineraria, declarándose para las restantes obligaciones no dinerarias, el valor estimativo de la deuda; todo ello, a fin de que quede explícitamente fijado el límite de responsabilidad del asiento del derecho real de garantía.

En concreto, las obligaciones garantizadas pueden ser eventuales

o futuras, es decir, no haber nacido aún. Lo que debe inexorablemente existir al tiempo de la constitución es el contrato u otra causa fuente de las obligaciones del cual aquéllas puedan nacer. Esa causa fuente debe estar descripta en el acto constitutivo; si no es así, no habrá ninguna seguridad. Es necesario que haya algunos parámetros que estén claramente establecidos desde el principio, y que haya ciertos límites, para que no se desnaturalice el principio de especialidad.

No obstante, esta conclusión no es irrefutable, ya que también se afirma que el Código permite las garantías abiertas aun cuando no se indique siquiera la causa fuente de los créditos futuros o indeterminados. Se dice que se instauró un sistema "muy abierto y flexible", con apoyo en el artículo 2186 que permite excepciones al principio de accesoriedad, en la última parte del artículo 2187 que permite excepciones a la necesidad de individualizar el crédito al constituirse la garantía, y en el texto del artículo 2189 que admite que el crédito pueda nacer posteriormente.

Como se señaló anteriormente, para satisfacer el principio de especialidad, debe indicarse en el acto constitutivo la suma de dinero que operará como tope máximo (art. 2189).

b.3) Límite en el tiempo

Concluye el artículo 2189, último párrafo, que "El acto constitutivo debe prever el plazo al que la garantía se sujeta, que no puede exceder de diez años, contados desde ese acto. Vencido el plazo, la garantía subsiste en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia".

Esto no significa que los derechos reales de garantía no pueden durar más de diez años. No es así, salvo que el derecho de anticresis no puede extenderse más de diez años si se trata de inmuebles, y de cinco si se trata de cosas muebles (art. 2214). En ocasiones, la duración del derecho real de garantía dependerá de la duración del derecho del constituyente (v. gr.: un superficiario constituye una hipoteca -art. 2120-, o un usufructuario grava la cosa con anticresis -art. 2142-).

Lo que quiere expresar el artículo 2189 es que cuando se constituye un derecho real de garantía sobre créditos indeterminados, la garantía asegura a los créditos nacidos dentro de ese plazo máximo de diez años

(puede ser menor). Esto es, si nacen nuevos créditos entonces indeterminados luego de transcurrido el plazo máximo, no estarán cubiertos por la garantía, la que "subsiste" por los "créditos nacidos" durante ese tiempo.

b.4) Título ejecutivo

Un tema espinoso de las hipotecas abiertas se suscita respecto de la habilidad ejecutiva de los títulos extrahipotecarios que acompaña el ejecutante para acreditar y liquidar el crédito indeterminado en el título de la garantía. Estos documentos complementarios de la escritura de hipoteca en la mayoría de los casos son creados unilateralmente por el acreedor con posterioridad al otorgamiento de la escritura (certificados de saldos deudores emitidos por contadores, escribanos, etc.) y este proceder puede afectar el derecho de defensa del deudor, en una ejecución que tiene limitadas defensas.

El Código contempla para los créditos eventuales que se originan en la cuenta corriente (arts. 1438 y 1440) y la cuenta corriente bancaria (arts. 1403 a 1407) un procedimiento de conformación de saldo que permite expedir el título ejecutivo del crédito. Este recaudo también se deberá exigir análogamente para otro tipo de contratos semejantes con prestaciones periódicas, como el de suministro (v. gr.: art. 1186), que la mayoría de las veces se configura como una garantía abierta.

c) Cláusulas de ajuste

La ley 23.928 (convertibilidad) prohibió la indexación a partir del 1º de abril de 1991.

Esta ley continúa vigente, lo que ha hecho caer en desuso a la ley 21.309. Además, el artículo 2189 exige que se establezca un monto máximo para fijar la responsabilidad de la garantía real, lo que impide la aplicación de índices que eleven dicha cantidad. No obstante, de continuar el proceso inflacionario actual, se presentarán nuevos problemas, o bien los contratantes pondrán un monto máximo más alto para cubrirse del flagelo inflacionario.

d) *Contratos en moneda extranjera*

El artículo 765 establece lo siguiente: "La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal".

Ahora, la obligación de dar moneda extranjera es reputada de "dar cantidades de cosas" y, como consecuencia de ello, se dispone que "el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal".

En lo que interesa al principio de especialidad, cabe recordar que el artículo 2189 exige que "El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero". En función de lo dispuesto por el artículo 765, si se fija un monto en moneda extranjera ello no sería "dinero", y no estaría satisfecho el recaudo de especialidad. Incluso, pueden presentarse problemas en el Registro de la Propiedad Inmueble, si se pretende inscribir un derecho real de garantía cuyo monto está expresado en moneda extranjera, como ocurrió en otra época.

Puede alegarse en contra de esta interpretación que el artículo 2189 se contenta con la expresión de una "cantidad", de un "monto", cualquiera sea la moneda que se utilice, pues de lo que se trata es de saber con precisión hasta dónde alcanza la responsabilidad del gravamen. No obstante, lo cierto es que esta modificación nos retrotrae a problemas que estaban superados.

Además, bien puede interpretarse que el artículo 765 no es de orden público. La redacción del artículo 962 del Código establece que "Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible". Las normas supletorias, usuales en materia contractual, son aplicables cuando las partes no hayan establecido ninguna previsión sobre el particular y siempre las partes de común acuerdo podrían dejarlas sin efecto.

También puede interpretarse la norma en forma literal. En efecto,

el hecho de que el artículo 765 diga "puede", y no "debe", puede ser considerado como un argumento que refuerza su carácter supletorio. Adicionalmente, una interpretación armónica con el artículo 766 (que establece que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, es decir, la que se obligó) intensifica la idea de que aquella norma no es imperativa.

e) *Defectos en la especialidad*

Establece el artículo 2190 que "La constitución de la garantía es válida aunque falte alguna de las especificaciones del objeto o del crédito, siempre que se la pueda integrar de acuerdo al conjunto de las enunciaciones del acto constitutivo".

El incumplimiento del principio de especialidad puede provocar la nulidad de la garantía. Sin embargo, se brinda la oportunidad de suplir las omisiones incurridas en las especificaciones de que da cuenta el artículo 2190, y son los tribunales que entiendan en el juicio los que tienen las más amplias facultades de apreciación según el conjunto de las enunciaciones y las pruebas aportadas para precisar lo faltante y decidir si la garantía cuestionada satisface el principio de la especialidad.

VI. *Indivisibilidad*

Entre los caracteres está la indivisibilidad, que el artículo 2191 establece en los siguientes términos: "Los derechos reales de garantía son indivisibles. La indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos, están afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes". A diferencia de la accesoriedad, de la convencionalidad y de la especialidad, la indivisibilidad es un carácter natural, no imperativo, ya que las partes o el juez pueden dejarlo de lado.

Al ser así, mientras haya un saldo impago la garantía subsiste íntegra sobre la totalidad del objeto *tota in totum et qualibet parte*. La indivisibilidad tiene lugar activamente, esto es, desde el punto de vista de los sujetos de la garantía, acreedores y sus herederos, como pasi-

vamente, mirado desde el deudor y sus herederos, y se extiende tanto al crédito como al objeto de la garantía.

Así, por ejemplo, si el deudor debe \$ 100.000 y abonó \$ 90.000, por los \$ 10.000 restantes el acreedor puede ejecutar todos y cada uno de los bienes afectados a la garantía. No hay división.

a) *La indivisibilidad es un carácter natural*

La indivisibilidad es un atributo natural, las partes pueden pactar lo contrario, haciendo renunciaciones o modificaciones, inclusive el tribunal así también puede disponerlo (art. 2191).

b) *Consecuencias en cuanto al crédito*

b.1) *Lado activo*

Desde el punto de vista del acreedor —si hubiere varios—, cuando el deudor simplemente mancomunado paga solamente a uno de ellos la cuota parte de su crédito, no se extingue parcialmente el derecho real de garantía, pudiendo cualquiera de los restantes coacreedores que no han cobrado, promover o continuar el juicio sobre la totalidad del o de los bienes en la medida de su interés en el crédito.

b.2) *Lado pasivo*

Tiene lugar cuando el deudor fallece y en su lugar quedan herederos que soportarán la deuda de acuerdo con el porcentual que concurren a la herencia, y si uno de ellos se libera abonando su parte proporcional, igualmente la garantía continuará gravitando sobre el todo del objeto, en cuyo caso el acreedor podrá ejecutarlo para cobrarse compulsivamente lo adeudado por los restantes coherederos con la venta del mismo.

c) *Consecuencias en cuanto al objeto*

c.1) *Lado activo*

Si no es cumplida la obligación principal, la ejecución judicial se dirige contra la garantía, es decir, el objeto gravado, y como la indi-

MNR

visibilidad radica en que cada parte del bien garantiza el total del crédito, si se subdividiera la cosa cada parte de ésta responderá por el total de la deuda.

El principio de indivisibilidad se aplica aun al caso en que la garantía comprenda varias cosas, teniendo entonces el acreedor la facultad de dirigirse contra cualquiera de ellas, aunque ulteriormente se hubiesen constituido otros derechos reales de garantía, y de realizar simultáneamente el conjunto de todos los bienes y cada una de sus partes o hacer ejecutar uno solo, aun en el caso de que algunos se encuentren actualmente en el dominio de terceros no deudores. Ello no obstante, el juez podrá por causa fundada fijar un orden para la venta de los bienes afectados (art. 2191, último párrafo).

Los jueces pueden, independientemente de la voluntad del acreedor, disponer el remate progresivo de los bienes en diferentes fechas, de modo que se cause el menor perjuicio posible, siempre y cuando exista causa fundada, como sería el caso de que el acreedor en primer grado quiera ejecutar entre varios inmuebles hipotecados por una misma deuda aquel que está gravado con una hipoteca de segundo o tercer grado con lo cual una vez realizado el bien este otro acreedor se queda sin garantía, o que elija entre distintos inmuebles el que constituye el hogar del deudor cuando puede realizar sin dificultad los otros, inclusive, porque están desocupados, o que el acreedor decida ejecutar un inmueble que se halla en poder de un tercero en lugar de aquel que integra el patrimonio del deudor. De lo contrario se consagraría un abuso del derecho por parte del acreedor (art. 10).

Si el precio obtenido no alcanzare a cubrir el crédito, se continuará con el remate del resto de los bienes afectados a la garantía.

c.2) *Lado pasivo*

Si la cosa se hubiese subdividido entre varios condóminos o enajenado una fracción del mismo o pasado a coherederos, cada una de las partes o fracciones transmitidas entre vivos o *mortis causa* queda afectada a la garantía real y puede ser ejecutada por el acreedor para cobrarse el total de la deuda con su producido. Los nuevos condóminos no podrán pretender la división del privilegio que continúa pesando sobre la totalidad de la cosa.

d) *Excepciones a la indivisibilidad de la hipoteca*d.1) *Acuerdo de partes*

Dice el párrafo tercero del artículo 2191 que "Puede convenirse la divisibilidad de la garantía respecto del crédito y de los bienes afectados..." Si hay convención entre los involucrados, no hay inconveniente. Así, por ejemplo, podrían acordar que una casa hipotecada se divida en distintas unidades funcionales afectadas al régimen de propiedad horizontal, y que se ejecute una de ellas. Si no alcanza para satisfacer el crédito, se sigue con las restantes.

d.2) *Decisión judicial*

En caso de ejecución de varios bienes al mismo tiempo el juez se encuentra facultado para fijar un orden y que la subasta sea progresiva.

Otra alternativa es que el propietario de la cosa pida su división. Así, por ejemplo, que pida la división en lotes o el fraccionamiento. Esta posibilidad debe ser analizada desde el punto de vista material, jurídico y económico, para que de ello no se "occasione perjuicio al acreedor", lo que conduce a una situación de hecho que deberá ser valorada por el tribunal, como sería la disminución del valor de los predios, o que la división implica la realización de trámites y adecuaciones que insumirán mucho tiempo.

Así, los jueces pueden ordenar la subasta por separado de cada lote o inmueble, aun cuando en la escritura de hipoteca se hubiere estipulado que la venta deberá hacerse en bloque —y asimismo la cancelación parcial de la hipoteca—, si fuere más beneficioso para todos, facilitando la venta, obteniéndose mejor precio, y quizá cubriendo con una parte de los lotes el importe del crédito, con la posibilidad de que quede —inclusive— un remanente para el deudor propietario o que el saldo de la deuda resulte menor.

No está legitimado solamente el propietario del bien para peticionar tal división, sino también el propio acreedor, "si hace a su propio interés".

Aunque la deuda comprenda bienes que sean susceptibles de ser fraccionados no podrán dividirse cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento (art. 228, segundo párrafo).

VII. *Extensión en cuanto al objeto*

El artículo 2192 constituye una norma de orden público por cuanto versa sobre el objeto mismo del derecho real. No pueden los particulares modificarla (arg. art. 1884).

Los derechos reales tienen por objeto cosas y, excepcionalmente, derechos (art. 1883). En el caso de la hipoteca, el objeto es un inmueble y, en ocasiones, un bien (v. gr.: derecho de construir, plantar o forestar —art. 2120—). La anticresis recae sobre inmuebles o cosas muebles registrables (art. 2212). La prenda, sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados (art. 2219).

a) *Extensión de la garantía*

Dice el artículo 2192 que "En la garantía quedan comprendidos todos los accesorios físicamente unidos a la cosa, las mejoras y las rentas debidas..."

a.1) *Accesorios físicamente unidos*

El principio general es que los accesorios del bien gravado están afectados a la garantía mientras estén unidos al principal, *accessorium sequitur principale*.

Hay que recordar que las cosas muebles pueden convertirse en inmuebles por accesión física como resultado de un acto voluntario de una persona cuando están adheridas materialmente al suelo con el carácter de perdurables (art. 226), como, por ejemplo, instalaciones sanitarias de un baño, artefactos de cocina, o cañerías en general, agua, electricidad, gas, etcétera, que no pueden retirarse sin deteriorar o afectar la estructura del inmueble. Ello es así, en tanto no estén ya gravados con prenda o sean propiedad de terceros (art. 2192, incs. a, y b).

También puede suceder la unión de dos cosas muebles. Cuando la cosa mueble principal está gravada, lo estará también aquella accesoria que esté físicamente adherida (ver art. 230), en tanto no esté ya gravada con prenda o sea propiedad de un tercero (art. 2192, incs. a, y b).

El Código exige que los accesorios estén unidos físicamente a la cosa, de modo que si son separados, dejan de estar comprendidos en la garantía.

En tal caso, el acreedor podrá ejercer las alternativas que le ofrece el artículo 2195 cuando el propietario disminuye el valor de la garantía. Además, si se trata de cosas muebles que han pasado a terceros de buena fe y a título oneroso, no pueden ser perseguidas (art. 1895).

a.2) *Mejoras sobrevinientes*

Las mejoras son las que acceden a la cosa por la incorporación de diferentes elementos materiales luego de constituido el gravamen, con el consiguiente incremento del valor intrínseco de la cosa. Quedan incluidas en la garantía.

Estas mejoras pueden ser naturales (producidas por la naturaleza -v. gr.: acrecentamiento del terreno por aluvión-) o artificiales (producidas por el hecho del hombre). Ejemplo clásico de esto último es la construcción sobre un terreno baldío, que también quedará comprendida en la garantía. Esto es así aun cuando tales mejoras sean hechas por un tercero.

En el caso inverso, dice la segunda parte del artículo 2194 que "En caso de extinción parcial del objeto, la garantía subsiste, además, sobre la parte material restante". Si es reconstruido, la garantía se extenderá nuevamente a tales mejoras.

En caso de ser hechas por un tercero, en algún caso la garantía no las alcanzará, si es que el tercero puede retirarlas sin detrimento de la cosa.

En el caso de que la garantía recaiga sobre el *derecho de superficie*, ya sea el derecho a construir, plantar o forestar, o sobre lo construido, plantado o forestado (art. 2120), la garantía se irá extendiendo a medida que el objeto crezca en función de la actividad del superficiario. Obviamente, si la garantía fue constituida por el propietario del terreno, no se extenderá a tales mejoras o acrecentamientos.

a.3) *Rentas debidas*

Debe tratarse de rentas "debidas", es decir, aún no percibidas por el constituyente del gravamen. Así, por ejemplo, si un inmueble está hipotecado, y su dueño lo alquila, los arriendos aún no percibidos podrían ser embargados por el acreedor hipotecario para hacer valer su privilegio.

Le asiste al acreedor el derecho a cobrar los arriendos vencidos y no percibidos por el deudor, siempre y cuando éste se encuentre en mora. Para ello es necesario obtener una medida judicial (por ej.: embargo con orden de que se depositen judicialmente o la designación de un interventor en la misma ejecución o por otra vía procesal), sin que haya que demostrar que el inmueble no cubre el crédito reclamado, en razón de que el dispositivo legal no lo exige y tales rentas o alquileres forman parte de la garantía como accesorios del inmueble, gozando el acreedor del consiguiente privilegio, desplazando inclusive a cualquier otro acreedor embargante aun de fecha anterior.

a.4) *Extinción de cargas*

Así, por ejemplo, si un inmueble soporta una servidumbre, o un usufructo, y luego es hipotecado, en caso de ejecución el adquirente deberá respetar dichos gravámenes por ser anteriores a la constitución de la hipoteca. Pero si por algún motivo dichos derechos de disfrute se extinguieran, ello beneficiaría al acreedor hipotecario, cuya garantía ahora es más amplia que en su origen. Si remata el inmueble, ya no hay derechos ajenos que respetar.

a.5) *Frutos*

Los frutos no son accesorios al inmueble, sino que, pendientes, forman parte de éste.

Por lo tanto, mientras no sean separados forman parte de la garantía, al ser integrantes del inmueble.

b) *Casos en los que no se extiende la garantía*

b.1) *Accesión moral*

El artículo 2192 establece que la garantía se extiende a "todos los accesorios físicamente unidos a la cosa". Por ende, en aquellos supuestos en que los accesorios carezcan de una unión física, material, y estén vinculados con la cosa por la profesión del propietario o la explotación del inmueble (accesión moral), no están incluidos. Así, por ejemplo, están

comprendidos los artefactos del baño adheridos al suelo, pero no lo están los escritorios de un estudio jurídico, o el torno que utiliza un dentista.

La última parte del artículo 226 en forma categórica confirma lo expuesto.

b.2) *Bienes gravados con prenda o que pertenezcan a terceros*

Dice la segunda parte del artículo 2192 que "Sin embargo, no están comprendidos en la garantía:

- "a) los bienes físicamente unidos a la cosa que están gravados con prenda constituida antes que la hipoteca o son de propiedad de terceros, aunque su utilización por el deudor esté autorizada por un vínculo contractual;
- "b) los bienes que posteriormente se unen físicamente a la cosa, si al tiempo de esa unión están gravados con prenda o son de propiedad de terceros, aun en las condiciones antes indicadas".

Por lo tanto, si a un inmueble que está hipotecado se le adhiere físicamente una cosa mueble que ya estaba gravada con prenda antes de constituirse la hipoteca, o estaba gravada con prenda al tiempo de esa unión, no estará comprendida en la hipoteca. Pareciera que los dos incisos podrían haberse refundido en uno solo, ya que lo que interesa es que la cosa mueble estaba prendada al tiempo de la unión, sea la prenda anterior o posterior a la hipoteca.

El otro supuesto es que la cosa mueble que se une físicamente a un inmueble hipotecado haya pertenecido a un tercero antes de constituirse la hipoteca, o al momento de la unión.

Teniendo en cuenta que el artículo 1895 adjudica la propiedad de una cosa mueble no hurtada ni perdida al subadquirente de buena fe y a título oneroso, cabe interpretar que cuando el Código se refiere a la propiedad de un tercero, se trata de casos en los que dicha norma no se aplica, ya sea por ser una cosa hurtada o perdida, por haber sido adquirida a título gratuito, o bien por faltar la buena fe.

b.3) *Minas o yacimientos*

Tampoco se extiende la garantía a las minas o yacimientos que se hallen en el inmueble gravado, porque según la ley de hidrocarburos

es una propiedad distinta de la del suelo, que pertenece al dominio público del Estado nacional (ley 17.319).

VIII. Extensión en cuanto al crédito

Por regla, "El privilegio no se extiende a los intereses, ni a las costas, ni a otros accesorios del crédito, excepto disposición legal expresa en contrario" (art. 2577). Sin embargo, como se verá, hay disposiciones especiales para los derechos reales de garantía que se apartan de dicho principio.

Este tema está contemplado en el artículo 2193: "La garantía cubre el capital adeudado y los intereses posteriores a su constitución, como así también los daños y costas posteriores que provoca el incumplimiento. Los intereses, daños y costas anteriores a la constitución de la garantía quedan comprendidos en su cobertura sólo en caso de haberse previsto y determinado expresamente en la convención".

El crédito del acreedor garantizado con un derecho real goza de privilegio especial (art. 2582, inc. e), esto es que puede cobrar con preferencia a otros acreedores, quirografarios o con privilegio inferior. El artículo 2583 explica el alcance de dicho privilegio, que no se limita al capital adeudado.

En efecto, además del capital, comprende *intereses, daños y costas*. La obligación puede llevar *intereses* compensatorios si son convenidos entre el acreedor y el deudor y que en caso de no acordarlos, ni imponer determinada especie las leyes o los usos, el juez puede fijarlos (art. 767). A su vez, a partir de la mora el deudor debe los intereses moratorios (art. 768).

Puede haber capitalización de intereses, lo que se denomina *anatocismo*. Los intereses devengados, o anteriores como los menciona el artículo 2193, pueden ser incorporados al capital si así resulta del propio acto constitutivo, en cuyo caso dejarán de ser intereses y se convertirán en "principal", pudiendo generar nuevos intereses (art. 770, inc. a). También si la obligación es demandada judicialmente (art. 770, inc. b).

Lo dispuesto sobre intereses posteriores a la constitución de la garantía debe ser armonizado con lo previsto en el artículo 2583, inciso b, que extiende el privilegio de los derechos reales de garantía a

“los intereses correspondientes a los dos años anteriores a la ejecución y los que corran durante el juicio, correspondientes a los créditos mencionados en el inciso e) del artículo 2582”.

Debe considerarse incluida dentro de la garantía la *cláusula penal* (art. 790).

Por último, están incluidas las *costas*, esto es, los gastos producidos para hacer efectiva la garantía real mediante la ejecución judicial (o extrajudicial de la ley 24.441) desembolsados por el ejecutante, como ser, los gastos de justicia, anotación de embargo, etcétera.

Ahora bien, hay que tener presente que si bien los referidos intereses, daños y costas gozan de privilegio junto al capital, todo esto tiene un límite que es el monto máximo del gravamen establecido en el acto constitutivo (art. 2189) cuando se trata de créditos indeterminados. El excedente del tope o monto máximo reviste el carácter de crédito quirografario.

IX. Subrogación real

Se suele denominar subrogación real a la sustitución jurídica de un bien por otro en el patrimonio de una misma persona, de tal modo que el bien nuevo, ya sea una cosa mueble o inmueble, un crédito o una indemnización, ocupe el lugar del bien antiguo para ser sometido a su mismo régimen.

Dos normas se ocupan del tema. El artículo 2194 dice que “La garantía se traslada de pleno derecho sobre los bienes que sustituyen a los gravados, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la subrogación real”. En idéntico sentido, el artículo 2584 establece que “El privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyen los bienes sobre los que recae, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la subrogación real”.

Si la cosa gravada es enajenada, en principio, la garantía no se traslada al precio, ya que el acreedor tiene el derecho de persecución, y el adquirente recibe la cosa con la carga real que debe soportar. Cabe dejar a salvo el caso especial de venta de la cosa dada en prenda previsto en el artículo 2228. Tampoco si el propietario grava con ser-

vidumbre el inmueble y cobra un precio por ello, ya que tal servidumbre será inoponible al acreedor (art. 2196).

De tal forma, lo previsto en el artículo 2194 tiene aplicación cuando la garantía se extingue totalmente (v. gr.: subasta), o el objeto es reemplazado por otro, total o parcialmente, ya sea por acuerdo de partes o por disposición legal. Los casos más claros son la indemnización por siniestro o por expropiación.

La subrogación se produce de pleno derecho, esto es, sin necesidad de petición especial o de decisión judicial.

a) Seguro por siniestro

Cuando el objeto gravado estuviere asegurado y se produjese un siniestro que lo destruyere total o parcialmente con motivo de un incendio, explosión, derrumbe por fallas del suelo, tornado, meteoro o cualquier otro acontecimiento, la garantía se extiende a la indemnización debida por la aseguradora.

El artículo 84, ley 17.418, supliendo un vacío legislativo —como lo destaca su Exposición de Motivos en el N° XXV— reglamenta el ejercicio del derecho de los acreedores hipotecarios y prendarios para reclamar de la aseguradora la indemnización dineraria.

b) Seguro de vida

Tratándose de un crédito hipotecario para vivienda, es usual que se contrate un seguro de vida e incapacidad a cargo del deudor por el monto de la deuda, y así, si se produce su fallecimiento o incapacidad, la deuda quedará cancelada con el importe de la indemnización proveniente del seguro contratado a tales fines.

c) Expropiación

Cuando el objeto de la garantía es expropiado la indemnización debida por el sujeto expropiante no se incorpora al patrimonio del constituyente del derecho real de garantía, sino que es percibida por el acreedor como otro caso de subrogación real, porque “Los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización quedando aquélla libre de todo gravamen”, como dice la

última parte del artículo 28 de la Ley Nacional de Expropiaciones 21.499, o, en su caso, según lo que disponga la respectiva legislación local.

X. Facultades del constituyente

Hay que tener en cuenta que los derechos reales de garantía pueden ser constituidos por el dueño, los condóminos, el titular del derecho de propiedad horizontal, de un conjunto inmobiliario, el superficiario o el usufructuario (arts. 2120, 2142, 2206, 2213).

El constituyente (deudor o tercero), respetando el derecho de garantía que constituyó, conserva sus facultades inherentes al derecho real del que es titular. Dice el artículo 2195 que "El constituyente de la garantía conserva todas las facultades inherentes a su derecho, pero no puede realizar ningún acto que disminuya el valor de la garantía. Si esto ocurre, el acreedor puede requerir la privación del plazo de la obligación, o bien puede estimar el valor de la disminución y exigir su depósito o que se otorgue otra garantía suficiente".

a) *Actos que puede realizar*

El constituyente conserva la facultad de realizar los actos inherentes a su derecho.

Así, por ejemplo, si se trata de un dueño que gravó la cosa inmueble o mueble registrable con algún derecho de garantía, sus facultades son amplias. Puede realizar actos de disposición (vender, donar, abandonar, gravar con otros derechos reales) y actos de administración (v. gr.: alquilar, si ello no está prohibido en el acto constitutivo). También puede disponer materialmente, si no entregó la posesión.

Además, no hay que olvidar que si se prohibiera enajenar en el acto constitutivo, tal cláusula sería inválida, salvo que se refiera a persona determinada (art. 1972).

b) *Límite*

En todos los casos hay un límite: "no puede realizar ningún acto que disminuya el valor de la garantía" (art. 2195).

Así, por ejemplo, el dueño de un edificio hipotecado no debe des-

MNR

truirlo, ni talar los árboles de un bosque, etcétera. Generalmente se trata de actos materiales, ya que los actos jurídicos no deberían producir el efecto de disminuir la garantía, en tanto serían inoponibles al acreedor (art. 2196).

No obstante, los actos jurídicos podrían perjudicar al acreedor cuando tuvieran el efecto de hacer más difícil la ejecución de la garantía, como si enajena una parte o todo el inmueble a personas diferentes, obligando al acreedor a perseguir en forma separada a varios adquirentes.

c) *Caso del arrendamiento*

La locación o arrendamiento constituye un acto de administración de la cosa. Si bien con ese contrato queda reducida la disponibilidad material de ella, al punto de influir negativamente en su realización pues la subasta no la hace cesar, cierto es que no existe norma que prohíba la constitución de la locación sobre la cosa gravada.

Lo expuesto, en rigor, encuentra en la práctica que cuando se conviene la constitución de un derecho real de garantía como por ejemplo el de hipoteca, las partes pacten la prohibición de dar el bien en arriendo. La legalidad del pacto ha sido reconocida por nuestros tribunales de manera uniforme, por lo que habrá de prevalecer la prohibición por sobre la continuidad de la locación, si esta última fuere posterior. Se considera en estos casos que inscripto el contrato hipotecario, el eventual locatario no podría desconocer la restricción convencional pactada. Distinta sería la solución si el arrendamiento tuviere fecha cierta anterior a la del gravamen.

Otras situaciones que podrían perjudicar al acreedor se darían si el plazo de la locación fuese excesivamente prolongado, o el alquiler irrisorio, o se hubiera percibido anticipadamente.

Si la cosa es subastada, estará legitimado activamente también el adquirente para promover el respectivo incidente de desocupación en el mismo juicio, excepto que haya ocurrido previamente el lanzamiento (art. 598, CPCCN).

d) *Medidas en caso de alteración de la garantía*

La segunda parte del artículo 2195 autoriza para el caso de la

alteración del valor de la cosa distintas medidas, a saber: a) privación del plazo de la obligación: en este supuesto, como se explicó, verificada la disminución de la garantía el acreedor puede optar por exigir la deuda como de plazo vencido; b) exigir el depósito —en garantía y a título conservatorio— de un valor estimado al de la disminución; c) exigir otra garantía, real o personal. Aunque la norma no lo dice, es claro que si los actos que disminuyen el valor de la garantía aún no se consumaron, el acreedor podría intentar medidas cautelares para evitarlos, en forma preventiva (art. 1711).

e) *Inoponibilidad*

Confirmando lo expuesto anteriormente, dispone el artículo 2196 que "En caso de ejecución, son inoponibles al acreedor los actos jurídicos celebrados en perjuicio de la garantía".

De tal forma, si, por ejemplo, sobre el inmueble gravado se constituye una servidumbre, si bien ello le quita valor, en definitiva el acreedor no se verá perjudicado porque al ser tal gravamen inoponible, puede ejecutarlo como si la servidumbre no existiera. Ello es así, por ser la garantía anterior a la servidumbre; si fuera al revés sería otra la solución. Rige la regla primero en el tiempo, primero en el derecho.

Lo mismo se puede decir para el caso de la locación celebrada a pesar de estar prohibida en el acto constitutivo o en condiciones perjudiciales para el acreedor.

El artículo 2196 dice que son inoponibles "los actos jurídicos celebrados en perjuicio de la garantía". Por ende, aquellos actos que no la perjudiquen son oponibles al acreedor. Así, por ejemplo, si el constituyente de una hipoteca vende el inmueble hipotecado, ello no le causa perjuicio al acreedor ya que puede perseguirlo en manos de quien se encuentre si es que debe ser ejecutado.

f) *Realización por un tercero*

Hay otro supuesto en el que el acreedor puede privar al deudor del plazo, y es cuando el objeto es realizado por un tercero. En efecto, dice el artículo 2197 que "Si el bien gravado es subastado por un

tercero antes del cumplimiento del plazo, el titular de la garantía tiene derecho a dar por caduco el plazo, y a cobrar con la preferencia correspondiente".

Si se trata de un acreedor en primer grado, cuyo crédito vence más adelante, y el bien es subastado por un tercero, dicho acreedor podrá cobrar de acuerdo a su "preferencia", esto es, antes que el ejecutante. Si es al revés, cobrará primero el ejecutante. Si hay varios acreedores, también su suerte dependerá de su preferencia. La prioridad entre los derechos reales se establece de acuerdo a la fecha de su constitución, siempre que hayan sido publicitados debidamente (v. gr.: inscripción registral, tradición).

XI. *Cláusula nula*

Si el deudor de la prestación no cumple, el acreedor debe ejecutar el bien objeto de la garantía de acuerdo a las condiciones de ejecución previstas para cada derecho real de garantía en particular, y de conformidad con lo previsto por las leyes especiales (v. gr.: ley 24.441) y el Código Procesal local.

Al ser así, dispone el artículo 2198 que "Es nula toda cláusula que permite al titular de un derecho real de garantía adquirir o disponer del bien gravado fuera de las modalidades y condiciones de ejecución previstas por la ley para cada derecho real de garantía". La norma impide: 1) adquirir; 2) disponer, fuera de los modos legalmente autorizados. Se trata de evitar la usura.

Así, por ejemplo, si se pactara en el acto constitutivo que si el deudor no cumple el acreedor se quedará con el objeto gravado, semejante cláusula no tendría validez. Esta posibilidad se conoce como "pacto comisorio", también suele estar condenada por legislaciones extranjeras. Por regla, debe hacerse una subasta.

La segunda prohibición destinada a la protección de los intereses del deudor está referida a los modos de ejecución de la garantía, los que no pueden diferir de los específicamente reglados en el Código y en otras leyes.

El artículo 2211 permite convenciones sobre la ejecución, en la medida que la ley las autorice.

El Código, aunque con ciertos límites, es más flexible en materia de prenda (art. 2229).

XII. Responsabilidad del propietario no deudor

Generalmente es el deudor quien garantiza el cumplimiento de su obligación con un derecho real (hipoteca, prenda o anticresis). Pero también puede ser una persona diferente quien lo haga, sin revestir la calidad de deudor. Así, por ejemplo, Juan es deudor de Pedro, pero como Juan no tiene algún bien que sirva de objeto a la garantía, o los que tiene no son interesantes, Alberto constituye un derecho real en garantía de la obligación de Juan, sin ser deudor. En este caso, una persona es el deudor, y otra distinta es el constituyente de la garantía.

También puede suceder que el deudor sea el constituyente, pero que luego enajene a un tercero el bien objeto del derecho real de garantía. Ya se ha visto que el propietario conserva sus facultades, entre ellas la de enajenar (art. 2195). El adquirente, si no asume la deuda, será propietario del bien gravado pero no deudor. En este caso, así como en el anterior, la responsabilidad de quien es propietario sin ser deudor está limitada.

Dice el artículo 2199 que "El propietario no deudor, sea un tercero que constituye la garantía o quien adquiere el bien gravado, sin obligarse en forma expresa al pago del crédito asegurado, responde únicamente con el bien objeto del gravamen y hasta el máximo del gravamen".

Por ende, responde: 1) sólo con el bien gravado; no con todo su patrimonio; 2) hasta el máximo del gravamen, en la hipótesis de que el monto de la deuda sea superior.

Es muy probable que un tercero que decida adquirir una cosa ya gravada con un derecho real de garantía no pague todo su precio, sino que tenga en cuenta el monto del gravamen y lo descuenta. En ocasiones, sucede que dicho tercero se compromete a pagar el crédito del deudor, pero todos estos convenios son inoponibles al acreedor, salvo que los acepte expresamente.

Si el tercero se obligara "en forma expresa al pago del crédito

asegurado", y el acreedor lo aceptara como deudor, respondería con todo su patrimonio. El acreedor debe aceptar, pues no se le puede imponer un deudor si no quiere. En tal caso, si acepta, el acreedor tendría dos deudores, ya que para considerar liberado al primero hará falta una declaración expresa en ese sentido (arts. 936 y 944). Si lo hace, habrá un nuevo y único deudor.

En suma, cuando el propietario de la cosa gravada también es deudor, responde con todo su patrimonio; cuando no es deudor, responde sólo con la cosa y hasta el máximo del gravamen fijado para cumplir con el principio de especialidad (ver art. 2189).

a) *Diferencias entre constituyente no deudor y tercero adquirente*

Cuando el gravamen es constituido por otra persona que no sea el deudor, el constituyente no es tercero sino parte, desde que principia la relación con el acreedor a partir del mismo acto constitutivo, habiendo tenido, inclusive, oportunidad de discutir y negociar las cláusulas de la escritura de hipoteca, y eso no podía ocurrir con el posterior adquirente.

Otra diferencia puede verse en la *cesión del crédito*. Si se cediera el crédito, resulta aplicable el artículo 1640: "Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquéllas".

b) *Cosa no registrable prendada*

Cuando se constituye en garantía de una obligación una prenda, el constituyente debe entregarle la posesión al acreedor o a un tercero (art. 2221). Por ende, no podría el propietario enajenar dicha cosa mueble a otra persona diferente, ya que no podría hacerle tradición, necesaria para que adquiriera el dominio.

c) *Ejecución contra el propietario no deudor*

Si el deudor no cumple con la prestación a su cargo, el acreedor puede demandarlo. En el supuesto de que el bien gravado se encuentre

en poder de un propietario no deudor, el acreedor también puede demandar al segundo, cumpliendo con algunos requisitos:

c.1) *Previo reclamo al deudor*

Dice el artículo 2200 que "En caso de ejecución de la garantía, sólo después de reclamado el pago al obligado, el acreedor puede, en la oportunidad y plazos que disponen las leyes procesales locales, hacer intimar al propietario no deudor para que pague la deuda hasta el límite del gravamen, o para que oponga excepciones".

El deudor moroso siempre tiene que ser previamente intimado de pago, ya sea que él haya sido el constituyente de la garantía como en el caso de que su deuda esté garantizada por otra persona (propietario no deudor). Ello porque la acción tiene carácter mixto, personal contra el deudor obligado al cumplimiento de la deuda, y real dirigida a la cosa o bien propiedad del tercero no deudor, y tramita en un solo y mismo juicio.

El Código no fija el plazo de la intimación, sino que lo deja librado a lo que dispongan las leyes procesales locales.

c.2) *Defensas*

Continúa el artículo 2200 estableciendo que "El propietario no deudor puede hacer valer las defensas personales del deudor sólo si se dan los requisitos de la acción subrogatoria.

"Las defensas inadmisibles en el trámite fijado para la ejecución pueden ser alegadas por el propietario no deudor en juicio de conocimiento".

Dice que puede hacer valer las "defensas personales del deudor" sólo si se puede subrogar. Esto es algo confuso, ya que hay ciertas defensas que son comunes al deudor y al propietario no deudor, al margen de la subrogación (v. gr.: incompetencia, falta de personería). Lo que no podría son las que la norma llama "personales", esto es, propias del deudor (v. gr.: compensación), salvo que pueda subrogarse.

Además de las "defensas personales del deudor", el propietario no deudor podrá hacer valer las defensas que le sean propias, si son per-

tinentes. Así, por ejemplo, la nulidad de la garantía por no estar cumplidos los requisitos esenciales para su validez, o que el crédito ya fue cancelado, o que todavía no es exigible, que la garantía le era inoponible, etcétera. Esto dependerá también de lo que dispongan las leyes procesales.

c.3) *Pago*

La otra opción que tiene el propietario no deudor, si no tiene defensas que oponer, o si las opuso y fueron rechazadas, es pagar para evitar la ejecución (art. 2202). De no ser así, el bien gravado será ejecutado y finalmente subastado. El pago le permite subrogarse en los derechos del acreedor, si esto le resulta útil como, por ejemplo, para agredir otros bienes afectados a la misma deuda (art. 2202, inc. c).

El pago no siempre resulta extintivo de la obligación *erga omnes*; puesto que no es necesariamente liberatorio para el deudor. Si el pago emana de la persona que debe soportar definitivamente la carga integral de la deuda, es extintivo bajo todos sus aspectos; pero no lo es, por el contrario, cuando el cumplimiento no emana del deudor sino de una persona distinta, o cuando se lo hace con dinero proporcionado al obligado por un tercero, que además no tiene la intención de hacerle a aquél una liberalidad.

c.4) *Pedir que se cite a otros propietarios*

Prevé el artículo 2202, inciso c, que el propietario no deudor tiene derecho a: "en caso de existir otros bienes afectados a derechos reales de garantía en beneficio de la misma deuda, hacer citar a sus titulares al proceso de ejecución, o promover uno distinto, a fin de obtener contra ellos la condenación por la proporción que les corresponde soportar según lo que se haya acordado o, subsidiariamente, por la que resulta del valor de cada uno de los bienes gravados".

Supóngase lo siguiente: Juan es deudor de Pedro, y ofrece en garantía tres inmuebles diferentes, que serán hipotecados en garantía de dicho crédito. Luego los inmuebles son enajenados a diferentes personas, que son entonces propietarios no deudores. Como Juan no cum-

ple, luego de ser intimado, Pedro inicia la ejecución contra uno solo de los inmuebles, ya que tiene esa opción.

Alberto, propietario no deudor del inmueble que se pretende ejecutar, solicita entonces que se cite al juicio a los titulares de los otros inmuebles para que contribuyan con él a pagarle al acreedor (Pedro), "por la proporción que les corresponde soportar". ¿Cómo se determina esta proporción? En primer lugar, habrá que ver si los interesados han acordado algo. Si nada pactaron, en función del valor de cada inmueble. Así, si el inmueble de Alberto vale \$ 100.000, y el de los otros titulares \$ 50.000 cada uno, Alberto deberá pagar el doble que los otros dos.

En subsidio, se podrá acudir a lo previsto en el artículo 841.

Si no los cita al juicio, puede más adelante promover un proceso distinto para recuperar parte de lo que pagó (art. 820), en la proporción indicada. Dado que se subrogará en los derechos del acreedor, podrá repetir agrediendo los bienes afectados a la misma deuda con el mismo privilegio que tenía el acreedor desinteresado.

c.5) Subrogación

Si el propietario no deudor pagó la deuda garantizada para evitar la ejecución, tiene derecho, entre otros, a "subrogarse, en la medida en que procede, en los derechos del acreedor" (art. 2202, inc. b).

Si paga la deuda se subroga automáticamente en los derechos del acreedor interesado, ocupará su lugar, en lo que respecta a rango y privilegio, respecto al objeto liberado y a otros bienes siempre que estén afectados al mismo crédito. No necesita que el acreedor le ceda sus derechos y acciones. Por ende, promoverá un proceso contra los otros titulares de bienes afectados al mismo crédito para que se los condene a restituir parte de lo que pagó en la proporción que corresponda (pactada o en función del valor de los bienes). Si dichos bienes son ejecutados por otros acreedores, el propietario no deudor que pagó podrá hacer valer su privilegio.

c.6) Indemnización

Haya o no otros bienes afectados al mismo crédito que le permitan al que pagó recuperar parte de lo que invirtió, en todos los casos dicho

propietario no deudor que sufrió la ejecución puede reclamar del deudor principal el reintegro de lo que pagó, o la indemnización que corresponda por haber sido subastada la cosa objeto de la garantía (art. 2202, inc. a).

Claro que contra el deudor tendrá un crédito quirografario si no existen otros bienes afectados con un derecho real de garantía al mismo crédito.

No siempre tendrá derecho a repetir contra el deudor principal, pues ello dependerá de lo que hayan pactado en el contrato de transmisión. Así, por ejemplo, Juan es dueño de un inmueble que vale \$ 400.000 y que está hipotecado por \$ 200.000. Pedro se lo compra, y en lugar de pagarle \$ 400.000, le abona \$ 200.000 y estipulan que se hará cargo de la hipoteca. Si bien dicho pacto es inoponible al acreedor, en el caso de ejecución, si Pedro le abona al acreedor \$ 200.000 para evitar la subasta, o no le paga nada y el inmueble es subastado, no tendrá luego derecho a reclamarle a Juan una indemnización, pues entre ellos rige lo acordado.

c.7) Derecho al remanente

Puede suceder que el propietario no deudor no tenga defensas que oponer, o las que opuso fueron rechazadas, no pague, y decida soportar la ejecución, lo que implica que el bien gravado sea rematado. En tal caso, dispone el artículo 2201 que "Una vez realizado el bien afectado por la garantía, el propietario no deudor tiene derecho al remanente que excede el monto del gravamen, con exclusión del precedente propietario y de los acreedores quirografarios".

Si hubiera un excedente, esto es que la cosa fue subastada por un monto mayor al que le correspondía al acreedor, ese remanente le corresponde al propietario no deudor.

c.8) Prorratio de saldos en caso de haber otros acreedores

Este problema puede presentarse cuando se gravaron con derechos reales de garantía varias cosas en favor del acreedor que está en primer grado, pero cada una de esas cosas registra, por ejemplo, otros derechos reales de garantía en segundo y tercer grado en beneficio de acreedo-

MNR

res distintos. Como se vio anteriormente, puede perseguirse a uno de los objetos o a todos simultáneamente, con prescindencia de a quién pertenezca o de la existencia de otras garantías (art. 2191, segundo párrafo).

En la hipótesis de que dicho acreedor persiga a todos conjuntamente, se realice la subasta, y perciba su crédito, es importante saber cómo contribuye cada bien al pago de la deuda para determinar cómo se distribuye el saldo (si lo hay) y cómo seguirán cobrando los otros acreedores. Según el artículo 2202, inciso c, la proporción es la que se haya acordado (supuesto que difícilmente se presente), o de acuerdo a "la que resulta del valor de cada uno de los bienes gravados".

Mariani de Vidal ofrece el siguiente ejemplo, muy didáctico: "Hay dos lotes -A y B- gravados ambos con una hipoteca en primer grado por la suma de \$ 300. Por su parte, el fundo A reconoce una hipoteca en segundo grado por \$ 60 y una en tercer grado por \$ 40. A su vez, el inmueble B tiene una hipoteca en segundo grado por \$ 30. El acreedor en primer grado ejecuta ambos inmuebles y se obtienen en la subasta \$ 200 por el lote A y \$ 400 por el lote B: en total \$ 600. A ese total obtenido ha contribuido el lote A con un tercio y el lote B con dos tercios. Pagado aquel crédito -\$ 300- sobran \$ 300. En virtud de la doctrina arriba citada, de estos \$ 300 corresponderán \$ 100 al lote A y \$ 200 al lote B -dos tercios-, para distribuirse entre los acreedores hipotecarios de grado ulterior. En cambio, si se hiciera incidir por partes iguales la hipoteca sobre ambos inmuebles, cada uno debería aportar \$ 150 de la hipoteca general, y entonces no podrán cobrar íntegramente los acreedores en segundo y tercer grado del lote A".

c.9) *Requerir garantías*

El propietario no deudor tiene derecho a requerir que se ofrezca garantía suficiente de la restitución de lo percibido, si se trata de un crédito sujeto a una condición que luego puede frustrarse (art. 2197).

XIII. Rango de los derechos reales de garantía

El constituyente puede gravar la cosa con más de un derecho real de garantía, idéntico o diferente. Así, por ejemplo, se puede consti-

tuir sobre el objeto más de una hipoteca, o bien hipoteca primero y anticresis después. En el caso de que concurren diversos derechos reales cuyos acreedores pretendieran hacer valer su preferencia, la solución es asignarle prioridad al primero en el tiempo, y así sucesivamente.

Se trata de acreedores privilegiados, esto es que pueden cobrar antes que los quirografarios, pero cuando concurren entre ellos, la preferencia la tiene el más antiguo, y así sucesivamente. Esta ubicación que tiene cada acreedor se denomina "rango", que indica la posición que tiene cada uno respecto de los otros.

Así, por ejemplo, si se constituye una primera hipoteca, tres meses después una segunda, y seis meses después una tercera, el primero estará en primer grado, el segundo en segundo grado, y el tercero en tercer grado. Si se ejecuta el inmueble, ése será el orden en el que percibirán sus créditos. Si se extinguiera la primera hipoteca, el acreedor que está en segundo lugar avanzaría al primero, y así sucesivamente, ya que en el sistema argentino el rango es de avance, no es fijo como en el Derecho alemán.

Dicho orden, como se dijo, depende de la prioridad temporal, de su antigüedad (*prior in tempore, potior in jure*), lo que es común no sólo a los derechos de garantía sino a todos los derechos reales.

El rango, si hay convenios al respecto, se puede compartir, postergar, permutar o reservar (arts. 2223 y 19, ley 17.801).

XIV. Extinción. Subasta

a) *Extinción de los derechos reales de garantía*

Los derechos reales de garantía se extinguen, en primer lugar, por las causas generales de extinción de todos los derechos reales, en la medida en que les sean aplicables. Así, por ejemplo, la destrucción total de la cosa (art. 1907). En segundo lugar, pueden extinguirse por la extinción del crédito al que acceden, por vía de consecuencia (art. 2186). En tercer lugar, pueden presentarse otras causas específicas, que extingan la garantía sin extinguir la obligación principal, como podría ser la renuncia del acreedor (art. 2186).

b) *Efectos de la subasta*

Dice el artículo 2203 que "Los derechos reales de garantía se extinguen por efecto de la subasta pública del bien gravado, si sus titulares fueron debidamente citados a la ejecución, sin perjuicio del derecho y preferencias que les correspondan sobre el producido para la satisfacción de sus créditos".

El juicio ejecutivo puede ser promovido por el acreedor cuyo crédito se encuentra garantizado por un derecho real, o por un acreedor quirografario. Si la ejecución es intentada por un acreedor común, deben ser citados los titulares de derechos reales de garantía. En el caso de inmuebles o de cosas muebles registrables, surgirá su existencia del informe del Registro correspondiente.

Se realiza la subasta, y todos los derechos se extinguen, ya que las garantías se trasladan sobre el precio obtenido en el remate. Los acreedores, debidamente citados, ejercerán su privilegio, y si hay remanente cobrarán su crédito los acreedores quirografarios a prorrata.

Para que se produzca la extinción de dichos derechos reales es necesario, como prevé la norma, que hayan sido debidamente citados los titulares, para que puedan hacer valer sus derechos e ir contra el precio obtenido en el remate. Si no fue así, la subasta les resultará inoponible, lo que significa que el adquirente deberá cargar con los derechos reales de garantía que cuenten con la debida publicidad. De ocurrir esto, su situación será equivalente a la de un propietario no deudor. También deben ser citados embargantes; la omisión genera consecuencias similares.

XV. Cancelación

Cuando las garantías tienen por objeto cosas registrables, se inscriben en el Registro respectivo. Una vez extinguido el derecho real, corresponde dejar sin efecto esa inscripción. Es lo que se llama "cancelación".

La cancelación es el acto jurídico unilateral por el cual se solicita —presentando el documento respectivo— al Registro que se deje sin efecto ni valor jurídico la inscripción del derecho real de garantía.

El acto de la cancelación de ordinario será la consecuencia de la extinción de la obligación principal, aunque esta última puede haber quedado sin efecto (v. gr.: por pago) sin que se haya efectuado la cancelación del gravamen ni su consiguiente inscripción registral.

Además de voluntaria o judicial, la cancelación puede ser total o parcial.

Diffícilmente sea el acreedor el que inicie *motu proprio* el trámite de cancelación en el Registro al carecer de motivación propia para hacerlo, y menos aún si tiene en cuenta el consiguiente costo que hay que abonar. El principal interesado en obtenerla e inscribirla en el Registro será siempre el constituyente de la garantía real o el tercer adquirente, o llegado el caso un acreedor de grado ulterior con su garantía inscrita que quiere avanzar para ocupar el lugar que deja el gravamen cancelado, quedando los costos usualmente a cargo del deudor como suele estipularse en el respectivo acto constitutivo, que tendrá que abonarlos previamente cuando requiera la cancelación.

La cancelación puede ser voluntaria o judicial.

Como establece el último párrafo del artículo 2204, "En todos los casos puede requerirse que la cancelación se asiente por nota marginal en el ejemplar del título constitutivo de la garantía".

a) *Cancelación voluntaria*

Establece el artículo 2204 que "Las garantías inscritas en los registros respectivos se cancelan: a) por su titular, mediante el otorgamiento de un instrumento de igual naturaleza que el exigido para su constitución, con el que el interesado puede instar la cancelación de las respectivas constancias registrales..."

Es fundamental la intervención del "titular" de la garantía (o de sus herederos). El trámite puede ser realizado por otra persona, generalmente el deudor o el propietario de la cosa, pero el documento debe emanar del titular de la garantía. Esto es lógico, ya que si no fuera así el propietario de la cosa gravada se presentaría unilateralmente en el Registro y pediría la cancelación, lo cual podría dejar al acreedor sin su preferencia, sin publicidad, y luego enajenar la cosa como si

estuviera libre de gravámenes. El acto es unilateral, aunque pueden intervenir ambos, acreedor y propietario de la cosa gravada.

Debe tratarse de un "instrumento de igual naturaleza que el exigido para su constitución".

Por hipótesis, el acreedor declara voluntariamente que quiere cancelar el gravamen por encontrarse enteramente satisfecha la obligación garantizada, procediéndose luego -sin su intervención- al consiguiente trámite en el registro en donde se hará la anotación. El trámite, como dice el artículo 2204, lo hará el "interesado", generalmente el deudor o el propietario de la cosa gravada.

b) *Cancelación judicial*

Puede ocurrir que el acreedor no pueda, no colabore o directamente no expida voluntariamente el documento necesario para obtener la cancelación. En tal caso, agrega el artículo 2204 que puede ser ordenada "por el juez, ante el incumplimiento del acreedor, sea o no imputable; la resolución respectiva se inscribe en el registro, a sus efectos" (inc. b).

El proceso será contencioso, dirigido contra el acreedor o sus herederos, o quien lo represente si está ausente o es incapaz, o quien sea cesionario de su crédito. Una vez que la sentencia esté firme, se librarán los oficios y testimonios pertinentes para ser presentados en el Registro.

c) *Cancelación automática*

Se llama así a la que se produce por el mero transcurso del tiempo, computado desde la toma de razón, si antes no se solicita la renovación, ya que el Código fija plazos de caducidad de la inscripción (no del derecho real). Puede ocurrir que transcurra el plazo pero que la garantía se encuentre vigente, por lo que si no se renueva la inscripción antes de vencido el plazo legal se pierde la prioridad por falta de publicidad y oponibilidad. Así, si alguien de buena fe adquiere un inmueble sin que se haya informado la garantía, para él será inoponible.

Esto no afecta a las partes, sus herederos, ni a otros interesados

si son de mala fe, esto es que sabían o debían saber, actuando con diligencia, de la existencia del gravamen.

El Código fija plazos de caducidad de la inscripción. Si se trata de una hipoteca, los efectos de la inscripción duran veinte años (art. 2210). Si se trata de la anticresis, el término es de veinte años para inmuebles, y de diez años para muebles registrables (art. 2218).

En el caso de la prenda con registro, prevé el artículo 23 del decreto-ley 15.348/46 el plazo de cinco años.

CAPÍTULO XX
DERECHOS REALES DE GARANTÍA
(segunda parte)

MNR

SUMARIO: A) Hipoteca. I. La hipoteca en el Derecho Romano. II. Concepto. III. Caracteres. IV. Legitimación. V. Hipoteca de parte indivisa. VI. Forma del contrato constitutivo. VII. Determinación del objeto. VIII. La denominada hipoteca revertida. IX. Duración de la inscripción. X. Extinción de la hipoteca. XI. Ejecución. Convenciones. XII. Letras hipotecarias. B) Anticresis. I. Concepto. Definición legal. II. Legitimación. III. Plazo máximo. IV. Derechos del acreedor. V. Deberes del acreedor. VI. Gastos. VII. Duración de la inscripción.

A) HIPOTECA

I. La hipoteca en el Derecho Romano

En Roma se conocían cuatro contratos reales: el *mutuum* o préstamo de consumo, el *commodatum* o préstamo de uso, el *depositum* y el *pignus* o contrato de prenda. En la antigua Roma había dos formas principales de garantizar una deuda, con eficacia real: 1) la fiducia consistía en que el deudor trasladaba *cum creditore* la propiedad de un bien al acreedor para garantizar la deuda; 2) la prenda o *pignus*, con una regulación muy parecida a la actual.

El *pignus* consistía en la entrega de una cosa al acreedor para seguridad de su crédito, con cargo para este acreedor de restituirla después de haber obtenido la debida satisfacción. El *pignus* adolecía de un grave inconveniente, y era que si bien es cierto que el acreedor no podía beneficiarse con los frutos de la cosa, privaba al deudor de la posesión y uso de la misma. De ahí surgió la necesidad de buscar

un procedimiento más completo, mediante el cual se protegiese al acreedor con una garantía igual, pero que dejase la posibilidad al deudor, al menos hasta el vencimiento de la obligación, de poder usar y gozar de la cosa, y es así como se llega a la creación de la hipoteca.

II. Concepto

La hipoteca, junto a la anticresis y la prenda, es uno de los derechos reales de garantía incluidos en el libro dedicado a los derechos reales. El Código expresa el concepto de hipoteca en el artículo 2205: "La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado".

La definición es, en esencia, correcta, pero cabe una observación. Dice que recae "sobre uno o más inmuebles", pero lo cierto es que los derechos reales de garantía también pueden tener por objeto bienes que no sean cosas (art. 2188), y el Código, al regular el derecho de superficie, prevé que puede ser objeto de una hipoteca "el derecho de construir, plantar o forestar" (art. 2120, primer párrafo), derecho que no es exactamente una cosa inmueble.

Tampoco es exacto que el o los inmuebles "continúan en poder del constituyente", ya que el propietario puede enajenarlos a terceros. Lo que ha querido expresar el artículo 2205 es que el derecho real de hipoteca se constituye sin necesidad de tradición (conf. arts. 1891/1892).

Fuera de ello, como surge de la definición, el o los inmuebles afectados son del constituyente, que puede ser deudor, o no.

Como ocurre con los derechos reales, también la hipoteca otorga facultades a su titular. Aquí no se trata del uso, goce o disposición, sino de facultades diferentes, consistentes en perseguir el objeto y percibir el crédito con la preferencia que corresponda, en el supuesto de que el deudor no cumpla con su obligación. El *ius persequendi* y el *ius preferendi* son condiciones típicas de todos los derechos reales.

Se ha visto al examinar el principio de la especialidad en cuanto

al crédito (art. 2189) que dicho privilegio se extiende hasta el monto máximo fijado en el acto constitutivo. Si el crédito del acreedor supera dicho monto, el excedente lo podrá percibir pero sin privilegio.

Al acreedor hipotecario le asisten contra su deudor dos acciones diferentes: una, la acción personal, que nace del vínculo jurídico que da lugar al otorgamiento de la garantía hipotecaria; otra, la acción real, nacida de la hipoteca misma. Ordinariamente estas dos acciones se ejercen conjuntamente: si el deudor no paga, el acreedor reclama el pago de su crédito (acción personal) y procede a la ejecución y venta del bien para cobrarse con su precio (acción real).

a) *Naturaleza jurídica de la hipoteca: Derecho real*

El nuevo Código ha ratificado el carácter real del derecho de hipoteca. Lo enumera en el artículo 1887, inciso 1, y el artículo 2205 destaca en la definición que se trata de un derecho real de garantía, legislado justamente en el Título XII, dedicado a tales derechos.

b) *Se constituye por contrato*

La celebración del contrato, bajo la forma que el Código exige (escritura pública), da nacimiento a este derecho real, ya que no es necesaria la tradición: no se ejerce por la posesión.

La inscripción registral es declarativa, al solo efecto de hacer oponible el derecho a terceros interesados de buena fe.

III. Caracteres

1º) Es un derecho real accesorio, ya que supone la existencia de un crédito (o más de uno), cuyo pago asegura.

2º) Se trata de un derecho indivisible, que se funda en la voluntad presunta de las partes, y significa que la hipoteca subsiste toda entera sobre el bien gravado (o los bienes gravados), aun cuando una parte de la deuda haya sido pagada, mientras se siga debiendo algo al acreedor.

3º) Salvo supuestos de excepción, su objeto es un inmueble.

4º) Sólo puede ser convencional. El Código desecha la vía judicial, la testamentaria y la tácita o legal.

5º) Es menester satisfacer el principio de especialidad, tanto sobre el objeto como respecto del crédito.

6º) Al acreedor se le da la acción hipotecaria, o sea el derecho a perseguir la cosa, aun cuando se hubiera transferido a un tercero, venderla y cobrarse de su precio.

7º) Hay derecho de preferencia, vale decir que, después de la venta, el acreedor hipotecario tiene derecho a cobrarse de su producido con prelación a los demás acreedores quirografarios (privilegio) y de prevalecer sobre los titulares de derechos reales constituidos con posterioridad (derecho de preferencia).

IV. Legitimación

El Código indica, en el artículo 2206, quiénes se encuentran legitimados para constituir el derecho real de hipoteca. Dice que "Pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie".

a) Dueño

Esto no ofrece ninguna dificultad. La persona humana o jurídica que es dueña de un inmueble, aun cuando esté gravado con otros derechos reales, puede constituir una hipoteca. Si el dueño es casado, requerirá el consentimiento de su cónyuge (art. 470, inc. a). Si se trata de una unión convivencial registrada se aplica esta solución cuando se pretenda hipotecar la "vivienda familiar" (art. 522).

b) Condominio

La hipoteca debe ser constituida por todos los condóminos en forma conjunta (art. 1990). Cada uno de ellos, individualmente, sólo puede afectar su parte indivisa (art. 1989).

c) Propiedad horizontal

El titular de una unidad funcional sujeta al régimen de propiedad

horizontal, sin duda, puede gravarla con una hipoteca. El gravamen comprende la proporción de las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, si la hay (arts. 2039, 2045).

d) Conjuntos inmobiliarios

Aquí se aplican las normas previstas para el derecho de propiedad horizontal (art. 2075), por lo que se reitera lo expuesto.

e) Superficie

Dice el artículo 2120 que "El titular del derecho de superficie está facultado para constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de construir, plantar o forestar o sobre la propiedad superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de duración del derecho de superficie..." También el propietario del suelo conserva la facultad de hipotecar (art. 2121).

f) Tiempo compartido y cementerios

Aclarado lo anterior, de la lista de derechos reales sobre cosa propia, el artículo 2206 excluye al tiempo compartido y al cementerio privado; al menos, no los menciona. Por ende, a pesar de que el artículo 2101 diga que al adquirente del tiempo compartido se le aplican las normas sobre derechos reales, y que el artículo 2112 diga lo mismo para el derecho de sepultura, estos dos últimos no se encuentran legitimados para gravar con hipoteca. Tampoco puede hacerlo el titular del dominio del cementerio (art. 2104). En cambio, el propietario del inmueble afectado a tiempo compartido puede constituir hipoteca luego de la afectación, con el alcance previsto en el artículo 2093 (art. 2091, segundo párrafo).

g) Usufructuario

Si bien el usufructo es un derecho real transmisible y ejecutable por los acreedores (art. 2144), el usufructuario no se encontraría legitimado por el artículo 2206 para constituir hipoteca sobre su derecho (conf. art. 2142).

La particularidad es que sí se encuentra legitimado el usufructuario para constituir anticresis (arts. 2142 y 2213). La justificación del distinto tratamiento podría ser que el usufructuario cuenta con la posesión de la cosa, y se la puede entonces entregar al anticresista, máxime recordando que ambos derechos reales tienen por objeto el aprovechamiento de los frutos.

No obstante, el asunto es opinable, ya que si cualquier acreedor del usufructuario puede ejecutar su derecho, no se advierten motivos para que no pueda hacerlo un acreedor con derecho de preferencia y de persecución, como lo es el acreedor hipotecario.

V. Hipoteca de parte indivisa

El condómino tiene amplias facultades con relación a la parte indivisa. Prevé el artículo 1989 que "Cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible..."

Agrega el artículo 2207 que "Un condómino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. Mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no presta consentimiento expreso".

Queda claro entonces que el acreedor hipotecario, si el deudor no cumple, puede ejecutar la cosa por la parte indivisa antes de que se haga la partición. Si la partición se hizo, también puede hacerlo a pesar del efecto declarativo que le asiste a dicho acto (arts. 1996 y 2403), ya que le es inoponible.

De tal forma, sólo se vería impedido de ejecutar la parte indivisa el acreedor hipotecario si, realizada la partición, el inmueble le toca en lote a otro condómino y él presta su consentimiento expreso, o la partición se hizo judicialmente.

El Código no exige la notificación al acreedor, pero se puede deducir esta obligación tácita de hacerlo, pues de lo contrario será inoponible lo que se decida sin darle al acreedor la oportunidad de hacer valer sus derechos.

VI. Forma del contrato constitutivo

Ya se dijo que los derechos reales de garantía sólo pueden constituirse por contrato. Al tratarse de un derecho real que recaerá sobre un inmueble, la forma exigida es la escritura pública (art. 1017, inc. a). El Código, en forma un tanto innecesaria, reitera esta exigencia en el artículo 2208: "La hipoteca se constituye por escritura pública excepto expresa disposición legal en contrario..."

a) Promesa de hipoteca

Si el contrato se hubiese otorgado en instrumento privado, es válido e implica una "promesa de hipoteca" que debe ser cumplida. Resulta aplicable el artículo 1018. También esta solución se desprende del artículo 969.

Así, por ejemplo, Juan recibe un dinero en préstamo y se compromete en un instrumento privado a constituir una hipoteca en garantía de ese crédito. Si no lo hace, el acreedor puede demandarlo judicialmente para que cumpla y, de ser necesario, el juez puede hacerlo en su nombre.

La situación puede darse cuando se celebra un boleto de compraventa de un inmueble y se conviene en que el precio será pagado a plazos, y en garantía del pago el deudor (comprador) se obliga a constituir una hipoteca sobre dicho inmueble.

Igualmente sucede en el otorgamiento de créditos, donde es habitual que el deudor se obligue a constituir una hipoteca cuando la deuda alcance una suma determinada.

b) Excepciones

Sin perjuicio de lo expuesto, pueden encontrarse asimismo supuestos en los que no sea necesaria la escritura pública para constituir el derecho real de hipoteca, de ahí que el artículo 2208 exija dicho instrumento, "excepto expresa disposición legal en contrario". Así sucede con el artículo 3° de la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables.

También se resolvió que la constitución de hipoteca por el saldo de precio de un inmueble adquirido en subasta pública encuadra en la excepción a la regla de la escritura pública consagrada en el Código.

Asimismo, la hipoteca naval y la hipoteca aeronáutica en ciertos casos pueden ser realizadas por escritura pública o por instrumento privado autenticado (art. 501, ley 20.094; art. 53, Código Aeronáutico, respectivamente).

c) *Aceptación del acreedor*

No es necesario que los contratantes expresen su voluntad en el mismo instante, ya que dispone el artículo 2208 que "...La aceptación del acreedor puede ser ulterior, siempre que se otorgue con la misma formalidad y previamente a la registración".

El Código fija dos condiciones: 1) la aceptación también debe ser formalizada en escritura pública; 2) debe ser previa a la registración.

VII. Determinación del objeto

Uno de los requisitos de orden público en materia de derechos reales de garantía es la especialidad en cuanto al objeto. El objeto debe ser actual y estar individualizado adecuadamente en el acto constitutivo (art. 2188). Agrega el artículo 2209 que "El inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral, y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización".

Pero estas enunciaciones o pautas tienen que ser interpretadas con cierta laxitud, por eso es que la hipoteca no se anulará por falta de algunas de las designaciones prevenidas siempre que se pueda venir en conocimiento positivo de la designación que falte, correspondiendo a los tribunales decidir el caso por la apreciación del conjunto de las enunciaciones del acto constitutivo, como lo resuelve el artículo 2190.

No siempre el objeto será un inmueble. La hipoteca naval tiene por objeto a todo buque que tenga un tonelaje de arqueo total no menor a diez toneladas aun en construcción, también sobre el artefacto naval habilitado o en construcción (arts. 499 y ss., ley 20.094). La hipoteca del Código Aeronáutico tiene por objeto aeronaves inscriptas y matriculadas, o bien en construcción, y también los motores inscriptos en el Registro Nacional de Aeronaves (arts. 52 y ss., ley 17.285).

VIII. La denominada hipoteca revertida

Se suele denominar hipoteca inversa, revertida, o exigible *post mortem*, a la que se constituye en garantía de un préstamo otorgado a una persona que ha superado determinada edad o grado de discapacidad, propietaria de un inmueble libre de cargas, por un determinado plazo, que se concreta en entregas periódicas, garantizando el mismo con una hipoteca sobre la propiedad, con la particularidad de que será exigible al fallecer el propietario.

La denominación de hipoteca inversa proviene de la traducción de *reverse mortgage*. Es amplia su difusión en el Derecho Comparado.

Algunos autores prefieren la denominación de "mutuo hipotecario exigible *post mortem*".

A favor de su utilización se argumenta la posibilidad de obtener recursos económicos genuinos por parte de personas de edad mayor, sin necesidad de tener que desprenderse de la propiedad que habían adquirido a través de muchos años de esfuerzo y de trabajo. Se afirma que la necesidad de procurarse dinero por parte de personas de edad avanzada, que quizás deben vivir hoy día de sus magras jubilaciones y pensiones, admite en la institución de la hipoteca revertida un canal a través del cual pueden en forma digna y sin los trastornos que importa el desplazamiento del hábitat en donde han desarrollado sus vidas, coadyuvar a mejorar su calidad de vida en su última etapa.

IX. Duración de la inscripción

Cualquiera sea el plazo de duración de la hipoteca, lo cual dependerá del crédito que garantiza, el Código establece un plazo de caducidad de la inscripción registral, si antes no fue cancelada por el interesado o por un juez. En efecto, dispone el artículo 2210 que "Los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término de veinte años, si antes no se renueva". Los efectos de la caducidad son automáticos, a diferencia de la cancelación, que requiere la actividad del interesado y la presentación de un documento ante el Registro.

No es un plazo de prescripción sino de caducidad, lo que significa que no se suspende ni se interrumpe (art. 2567). No se extingue el

derecho real, sino la inscripción. Si transcurre el plazo sin que antes se renueve la inscripción, se pierden "los efectos del registro de la hipoteca", esto es, la oponibilidad y, consecuentemente, la preferencia. La hipoteca sigue existiendo, pero como si no estuviera inscrita. Si se reinscribe luego de vencido el término de caducidad, se habrá perdido la prioridad y será oponible a terceros desde ese momento. Por ende, si en el tiempo intermedio se hubiera adquirido un derecho distinto (v. gr.: otra hipoteca), el acreedor hipotecario se verá postergado. Seguirá siendo acreedor, pero habrá perdido las ventajas que tenía.

X. Extinción de la hipoteca

a) *Por vía de consecuencia*

Como es sabido, como ocurre con los derechos reales de garantía, la hipoteca es accesoria de uno o más créditos. Por ende, la extinción total de la obligación garantizada (v. gr.: por pago) determina el fin del derecho real accesorio (art. 2186). Ésta es la regla que puede sufrir alguna excepción, como en el caso de la novación, o del pago hecho por un tercero.

La extinción del crédito debe ser total, pues su cancelación parcial hace que subsista la hipoteca, por ser indivisible.

b) *Por vía principal*

Pueden darse situaciones en que, sin que se extinga el crédito garantizado, la hipoteca se extinga.

Cabe mencionar a la renuncia formalizada en escritura pública, esto es, al abandono del derecho real, y a la consolidación, que se presentaría si confluyen la propiedad de la cosa y el derecho de hipoteca en la misma persona (v. gr.: acreedor hipotecario que hereda el inmueble hipotecado). El artículo 1907 menciona también a la destrucción de la cosa, pero aquí cabe hacer la salvedad de que la hipoteca subsistirá sobre el suelo, y que se extenderá a la indemnización, si es que se obtiene alguna (art. 2194).

También se extinguirá la hipoteca si se resuelve con efecto retroactivo el derecho del constituyente, como sucede en los casos de

dominio revocable. Otro supuesto sería el vencimiento del plazo, cuando quien la constituyó tenía un derecho sujeto a término, como sucede con el superficiario.

Finalmente, el modo especial de extinción del derecho real es la subasta, en cuyo caso los derechos de todos los acreedores —si fueron debidamente citados— se trasladan al precio obtenido (art. 2203).

XI. Ejecución. Convenciones

Si el deudor no cumple, el acreedor hipotecario puede entonces ejecutar la hipoteca, ya sea contra dicho deudor y, de existir, contra el propietario del inmueble que no sea obligado, o que sea codeudor. En cada provincia y en la Capital Federal, los respectivos códigos procesales regulan el procedimiento de esta ejecución especial.

Sin perjuicio de ello, pueden existir leyes especiales que regulen un procedimiento diferente al estrictamente judicial (v. gr.: ley 24.441). Los contratantes pueden someterse libremente a esos sistemas alternativos. Dispone el artículo 2211 que "Lo previsto en este Capítulo no obsta a la validez de las convenciones sobre ejecución de la hipoteca, reconocidas por leyes especiales".

Las partes pueden pactar un procedimiento de ejecución, distinto al regulado en el Código Procesal, siempre y cuando esté reconocido por "leyes especiales". No pueden idear cualquier sistema, sino someterse a alguno que esté aprobado por las leyes vigentes.

El artículo 52 de la ley 24.441 permite la ejecución de la hipoteca de manera extrajudicial. Ello tiene lugar en las hipotecas en las cuales se hayan emitido letras hipotecarias con la constancia prevista en el artículo 45, y todas aquellas en que se hubiere convenido expresamente someterse a las disposiciones de ese régimen.

En la misma línea se enrola el artículo 45 de la ley 24.441, que establece que el portador de la letra hipotecaria o de alguno de los cupones "puede" ejecutar el título por el procedimiento de ejecución especial previsto en el Título IV (*De los créditos hipotecarios para la vivienda*).

En caso de no pactar un procedimiento especial y dejar librada la eventual ejecución a lo dispuesto por el Código Procesal, fuera de

algunas normas de orden público irrenunciables (v. gr.: intimación de pago, oponer excepciones), también otros aspectos pueden ser pactados por las partes válidamente. Así, se han admitido convenios vinculados a la desocupación, la base del remate, conservar el acreedor el título de propiedad, entre otros, por lo que se entiende que si las partes guardan silencio sobre el particular habrá de interpretarse que adscriben al régimen procesal pertinente.

XII. Letras hipotecarias

La ley 24.441 regula en el Título III a las letras hipotecarias, cuyo antecedente es el pagaré hipotecario previsto por el artículo 3202 del Código Civil derogado.

Se trata de un título de crédito, es decir, un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en él, según la siempre vigente definición de Vivante. Literal porque la naturaleza, calidad y contenido del derecho se regula por lo que se expresa en el documento. La autonomía importa la existencia de un derecho originario para los terceros que hayan adquirido el título de buena fe, con independencia de los anteriores poseedores. Por fin, son necesarios, porque la posesión del documento es condición para el ejercicio, transmisión y extinción del derecho incorporado.

Dice el artículo 36 que la emisión de letras hipotecarias sólo puede corresponder a hipotecas de primer grado y estar consentida expresamente en el acto de la constitución de la hipoteca, y el 37 cierra definitivamente toda controversia sobre la verdadera naturaleza jurídica de la "letra hipotecaria", al expresar: "la emisión de letras hipotecarias extingue por novación la obligación que era garantizada por la hipoteca".

En cuanto a los plazos, debe entenderse que estas letras hipotecarias sólo son factibles con fecha fija de vencimiento o a determinado tiempo de la fecha y que no lo son las pagables a la vista o a determinado tiempo vista (ver art. 85 del decreto-ley 5965/63).

La letra hipotecaria de la ley 24.441, no obstante su denominación, no tiene la estructura trilateral de la letra de cambio, sino la bilateral del pagaré: en esta "letra" sólo aparecen las personas del librador y

del beneficiario y no existe un girado o sujeto indicado por el librador para cumplimentar a la orden de pago. Característica propia de este título, diversa de la generalidad de ellos, es que su emisión extingue por novación —que así tiene fuente legal— la obligación que era garantizada por la hipoteca (art. 37). Las letras hipotecarias son emitidas por el deudor e intervenidas por el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda a la jurisdicción donde se encuentre el inmueble hipotecado, en papel que asegure su inalterabilidad, bajo la firma del deudor, el escribano y un funcionario autorizado del Registro, dejándose constancia de su emisión en el mismo asiento de la hipoteca. Se trata de títulos cambiarios de carácter formal, por lo cual las letras deberán contener enunciaciones específicamente determinadas en cuanto a nombres de las personas del deudor y del acreedor, monto de la obligación, tipo de moneda en que se emite, plazos y estipulaciones respecto del pago, lugar de pago, tasas de interés, datos y ubicación del inmueble hipotecado, etcétera (art. 39). La cancelación de la inscripción se podrá hacer a pedido del deudor mediante la presentación de las letras y cupones, con la constancia de haberse efectuado todos los pagos. El certificado extendido por el juez tiene el mismo valor que los documentos a estos fines (art. 48).

La hipoteca de máximo no admite letras hipotecarias. Se entiende que las letras no pueden existir en las hipotecas de máximo porque el monto de la obligación deber ser cierto y determinado al momento de la constitución y, además, no puede estar sujeto a elementos ajenos a la letra, ya que esto la privaría de uno de sus caracteres, la completitud.

A diferencia de lo previsto por el artículo 2187 del Código Civil y Comercial, se afirma que estas letras sólo pueden garantizar obligaciones de dar sumas de dinero, encontrándose especialmente excluida la posibilidad de garantizar obligaciones condicionales o eventuales.

La letra hipotecaria coloca a la hipoteca un par de "alitas" que permitirán que junto a los pagos mensuales de los deudores hipotecarios proliferen innumerables créditos y desenvolvimiento de fondos —extrahipotecarios— que tengan como raíz y salvaguarda el crédito hipotecario. ¿Cómo es ello posible? Mediante la letra hipotecaria, que sin afectar ni interferir para nada con las obligaciones propias del acreedor

hipotecario, que construye para vender, y del deudor hipotecario, que paga para tener su techo —en la forma, tiempo y condiciones acordados entre las partes—, permite que ese sólido vínculo crediticio pueda ser utilizado, “titulizado” o “securitizado” —en lenguaje actual—, de modo tal que el dinero en curso, en lugar de cumplir simplemente su ciclo, cumpla en ese mismo tiempo varios ciclos más, en lugar de la inmovilización a que estamos habituados. Ahorro y movilización de la riqueza es el objetivo perseguido.

La ley 24.441, además de las letras hipotecarias de naturaleza cartular, admite también las escriturales.

La cancelación de la inscripción de la hipoteca se puede realizar con la presentación de las letras pagas o de sus cupones que acrediten los respectivos pagos de capital e intereses de cada letra (art. 48). Así lo establece el artículo 48 de la ley, agregando que el certificado extendido por el juez tendrá el mismo valor que las letras o cupones a los efectos de su presentación para la cancelación de la hipoteca. No obstante, aunque no lo dice el texto legal, la cancelación de la hipoteca podrá solicitarse únicamente si se acredita la cancelación de todas las letras hipotecarias emitidas y de sus respectivos servicios. Las cancelaciones parciales de hipoteca tan sólo podrán exigirse por el deudor siempre que así se hubiera pactado en la convención hipotecaria.

Las letras hipotecarias constituyen un único instrumento continente tanto de la deuda como de la garantía real. Por eso, para su ejecución le basta al acreedor su sola presentación con la demanda y, en caso de haberse emitido, los cupones que se encuentren en su poder.

El título hábil para iniciar esta ejecución especial de hipotecas (extrajudicial) en la ley 24.441 estará constituido por el título-valor entendido como el documento necesario, para ejercer el derecho autónomo y literal, expresado en el mismo con sus consiguientes atributos derivados de los papeles de comercio como de formalidad (art. 39) que aquí se acentúa, ya que, la ausencia de algún requisito formal del título trae aparejada su nulidad (art. 2º, decreto-ley 5965/63, según reenvío del art. 46, ley 24.441), completividad, en razón de que se basta a sí mismo sin necesitar de ningún elemento extracartular para exigir su cumplimiento, y abstracción, puesto que la relación jurídica que deviene del título se abstrae del negocio causal que le ha dado

origen, independizándose el título valor (art. 35) a punto tal que el derecho real hipotecario se ha incorporado al mismo (art. 44, primera parte).

Será suficiente su sola presentación, para que se dé curso a la ejecución, dado que el derecho real hipotecario se encuentra incorporado al título, rigiéndose además por las disposiciones del Código en materia de hipoteca (art. 44).

B) ANTICRESIS

I. Concepto. Definición legal

a) *Antecedentes históricos*

La anticresis existía en el Derecho Romano, que parece haberla tomado del Derecho griego: consistía en una estipulación en virtud de la cual, en el contrato de *pignus*, las partes podían convenir que el acreedor, en cambio del uso de su capital, es decir, como compensación de los intereses, tenía el derecho de percibir los frutos de la cosa empeñada; pero la anticresis podía ser también celebrada sin que existiese contrato de *pignus*. Etimológicamente, la palabra “anticresis” deriva del griego *antichresis*, de *anti*, contra, y *chresis*, uso; significaría, pues, contra uso, lo cual está perfectamente de acuerdo con la idea esencial de este derecho, pues el deudor usa del capital y el acreedor usa de los frutos de la cosa dada en anticresis.

Durante la Edad Media y Moderna, la prohibición del préstamo a interés llevaba como consecuencia la de la anticresis, pero este contrato se realizaba bajo la forma de venta con pacto de retroventa: el precio de venta correspondía al importe del préstamo; los alquileres que se estipulaban eran el valor del interés. Pero una vez que la prohibición de estipular un interés por el préstamo de dinero desapareció, la anticresis fue aceptada como un contrato perfectamente legítimo en la generalidad de las legislaciones antiguas y modernas.

b) *Definición legal*

Establece el artículo 2212 que “La anticresis es el derecho real

de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda”.

Desde hace tiempo se observa que la anticresis es un contrato raramente celebrado, porque la desposesión del deudor, y, por consiguiente, el crédito de éste queda agotado con la primera operación de garantía que realiza a base del inmueble dado en anticresis: las ventajas de la hipoteca son infinitamente superiores y de ahí que a medida que la legislación hipotecaria se perfecciona, la anticresis va paulatinamente desapareciendo de la vida práctica del Derecho. Siempre se la ha mirado con desconfianza: en un tiempo por usuraria, en otro por perjudicar innecesariamente al deudor, y luego por anacrónica.

El nuevo Código Civil y Comercial contiene una primera novedad en cuanto a su objeto, pues el derecho no sólo se constituye sobre inmuebles, sino también sobre cosas muebles registrables, lo que revela la preocupación del codificador por dar a esta garantía real una mayor amplitud para extender su aplicación a otros objetos que sean fructíferos. Se apuesta a una revitalización de esa garantía, de muy limitada difusión en la actualidad, acaso por el anquilosado y contradictorio régimen del Código derogado.

Podría confundirse esta extensión del objeto de la anticresis a las cosas muebles registrables con la prenda anticrética (art. 2225), pero hay diferencias ya que la prenda sólo puede recaer sobre cosas muebles no registrables y créditos instrumentados (art. 2219).

Comparando la anticresis con la hipoteca y la prenda, se pueden señalar las siguientes diferencias:

- 1) En cuanto al objeto: la anticresis recae sobre cosas inmuebles y muebles registrables. La hipoteca, sobre cosas inmuebles. La prenda, sobre cosas muebles no registrables y créditos instrumentados.
- 2) En cuanto a la posesión de la cosa: en la anticresis, como en la prenda, ella pasa al acreedor o a un tercero. En la hipoteca, queda en poder del constituyente.

- 3) En cuanto a los frutos: la percepción de ellos por el acreedor es de la esencia del derecho, en tanto que en la hipoteca no existe tal cosa, y en la prenda es la excepción.
- 4) La anticresis tiene un plazo máximo de duración y también es menor el plazo de caducidad de la inscripción que el de la hipoteca, cuando se trata de cosas muebles. En la prenda no hay registro.
- 5) El usufructuario puede constituir anticresis, pero no hipoteca ni prenda. Esta última sólo por el dueño o los condóminos.
- 6) En caso de ejecución, el acreedor prendario, bajo ciertas condiciones, puede adjudicarse la cosa prendada (art. 2229).
- 7) Las facultades de uso y goce son regla en la anticresis y excepción en la prenda.
- 8) El acreedor anticresista puede dar la cosa en arrendamiento; en la prenda tal facultad debe ser consentida por el constituyente. No existe en la hipoteca para el acreedor.
- 9) Aunque por aplicación del artículo 2189 del Código, pueda entenderse aplicable a este caso el nacimiento posterior del crédito, parece necesario que el crédito esté individualizado *ab initio*, so pena de impedir que se concrete la imputación de los frutos que se perciben.

Dejando de lado las diferencias, cabe remarcar similitudes, ya que los tres son derechos reales de garantía, y deben cumplir los recaudos previstos por el Código para tales derechos (v. gr.: especialidad, indivisibilidad, accesoriedad, subrogación, etc.).

Se diferencia del usufructo en el hecho de que, mientras este último concede a su titular el disfrute de la cosa sin alterar la sustancia, la anticresis impone un deber concreto de servirse de los frutos para imputarlos al pago de una deuda. El usufructuario tiene el uso y el goce de la cosa, mientras que el acreedor anticresista tiene el deber de hacer redituable a la cosa objeto del derecho real de garantía.

c) Objeto

Pueden ser objeto de este derecho “cosas registrables individuali-

zadas". Quedan descartadas las cosas muebles no registrables y aquellas que no estén individualizadas (v. gr.: cosas inciertas, fungibles).

d) *Posesión*

Es un derecho real que se ejerce por la posesión. Por ende, el constituyente de la garantía deberá hacer tradición para que el acreedor adquiera el derecho real. Claro que si la inscripción registral es constitutiva, el derecho real nacerá cuando se concrete, pero ello no releva de la entrega de la posesión.

Es de la esencia de este derecho real la entrega de la posesión a fin de que el acreedor pueda ejercer sus facultades, especialmente la de percibir los frutos. También es factible que la cosa sea entregada a un tercero designado por las partes.

II. Legitimación

Dispone el artículo 2213 que "Pueden constituir anticresis los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, superficie y usufructo".

A diferencia del derecho de hipoteca, se excluye al titular de un conjunto inmobiliario, y se incluye al usufructuario.

La inclusión del usufructuario es lógica, ya que él tiene derecho a los frutos. La anticresis sólo puede existir en tal caso mientras dure el usufructo, si este derecho se extingue, el derecho de anticresis queda también extinguido, aun antes del vencimiento del plazo por el cual fue constituido (arg. art. 2153, primer párrafo), o del plazo máximo fijado por el artículo 2214.

Lo mismo sucede si la anticresis es constituida por el superficiario (arts. 2120, 2125).

III. Plazo máximo

Según el artículo 2214: "El tiempo de la anticresis no puede exceder de diez años para cosas inmuebles y de cinco años para cosas muebles registrables. Si el constituyente es el titular de un derecho real de duración menor, la anticresis, se acaba con su titularidad".

Cumplido el plazo máximo, en caso de que la deuda subsista, el acreedor puede ejecutar el bien y percibir su crédito con privilegio.

El plazo fijado por el artículo 2214 es el tope máximo. Puede establecerse uno menor, y también puede durar menos si dura menos el derecho del constituyente. Así, por ejemplo, si es constituido por un usufructuario, y éste muere, se extingue el usufructo y, por ende, la anticresis otorgada, aun cuando no hubiera transcurrido el término pactado ni el máximo fijado por la ley.

IV. Derechos del acreedor

a) *Uso y goce*

El derecho más importante que asiste al titular de la anticresis es el que explica el artículo 2215: "El acreedor adquiere el derecho de usar la cosa dada en anticresis y percibir sus frutos, los cuales se imputan primero a gastos e intereses y luego al capital, de lo que se debe dar cuenta al deudor".

El acreedor tiene el derecho de percibir los frutos, pero con cargo, es decir, con la obligación de imputarlos a lo que le es debido, es decir, a los gastos e intereses primero, y luego al capital, en la forma que la ley determina.

Los gastos no son las mejoras útiles que están a cargo del acreedor (art. 2217), ni los que deban realizarse por su culpa.

Fenecido el plazo de anticresis, si los frutos no hubieren alcanzado para extinguir la obligación, el acreedor puede ejecutar el inmueble o cualquier otro bien del deudor, debiendo siempre rendir cuentas.

b) *Derecho a arrendar la cosa*

Dispone el artículo 2216 que "El acreedor anticresista debe conservar la cosa. Puede percibir los frutos y explotarla él mismo, o darla en arrendamiento; puede habitar el inmueble o utilizar la cosa mueble imputando como fruto el alquiler que otro pagaría..."

c) *Derecho a ejecutar*

Si la cosa no fue fructífera, o los frutos no fueron suficientes para cu-

brir gastos, intereses y capital, una vez vencido el plazo el acreedor puede ejecutarla para percibir su crédito (art. 2203).

El Código no prevé la posibilidad de acudir a formas de ejecución distintas a la prevista por el Código Procesal, como lo hace cuando trata la hipoteca (art. 2211), y la prenda (art. 2229).

Tampoco autoriza al acreedor a quedarse con la cosa en pago, como sí prevé, bajo ciertas condiciones, en el derecho de prenda (art. 2229). El pacto comisorio está absolutamente vedado (conf. art. 2198).

d) *Privilegio*

El artículo 2582 determina en seis incisos cuáles créditos gozarán de privilegio especial, en una enumeración que armoniza con la Ley de Concursos (art. 241).

El inciso e, de dicho artículo, por su parte, enumera entre los privilegios especiales a "los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrants y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante", es decir, a los créditos con garantías reales. Y regula estos créditos en lo relativo a su extensión (art. 2583, incs. b, y c) y rango (art. 2586, primer párrafo y especialmente incs. c, e, y f).

Este privilegio sólo le asistirá en supuestos de ejecuciones individuales, porque la Ley de Concursos 24.522 no lo entroniza como tal, de modo que el anticresista no contará con privilegio alguno en los concursos (art. 239, ley 24.522).

V. Deberes del acreedor

a) *Conservar la cosa*

Éste es el primer deber que le impone el artículo 2216. Es lógico que si el deudor entregó una cosa en garantía, cuando el crédito sea satisfecho la debe recibir en buen estado, en lo posible en una situación similar a como la entregó. Si el acreedor no la conserva en buen estado, será responsable.

b) *No alterar el destino*

Dice el artículo 2216, segundo párrafo, que "Excepto pacto en contrario, no puede modificar el destino ni realizar ningún cambio del que resulta que el deudor, después de pagada la deuda, no puede explotar la cosa de la manera que antes lo hacía".

Por ejemplo, el anticresista no podría dedicar a la ganadería un campo que estaba destinado a la agricultura, ni dedicar a otra clase de agricultura un campo que estaba plantado con viñas.

c) *Rendir cuentas al deudor*

Esta obligación está prevista en el artículo 2215, que se titula *Derechos del acreedor*. La mención al deber de "dar cuenta al deudor" debió ser expresada en el artículo que sigue, dedicado a sus "deberes".

El artículo 2215 no explica la manera en que ello debe ser cumplido, aunque el artículo que sigue, en el tercer párrafo, remite a las reglas del mandato. Por tal motivo, serán aplicables los artículos 858, 859, 860, entre otros.

d) *Responsabilidad*

También dispone el artículo 2216 que "...El acreedor debe administrar conforme a lo previsto por las reglas del mandato y responde de los daños que ocasiona al deudor.

"El incumplimiento de estos deberes extingue la garantía y obliga al acreedor a restituir la cosa al titular actual legitimado".

e) *Pago de contribuciones y cargas*

Establece el artículo 2217 que "el acreedor está obligado a pagar las contribuciones y las cargas del inmueble".

Entran en la categoría de contribuciones y cargas todos los impuestos que gravan la propiedad, como la contribución territorial, impuestos municipales, agua, etcétera. Se trata de una consecuencia de su carácter de poseedor (ver art. 1939). Frente a los titulares de

dichos créditos, el propietario no deja de ser un legitimado pasivo en caso de ser reclamadas.

La misma solución hay que aplicar respecto de impuestos y contribuciones que graven cosas muebles objeto de la anticresis (v. gr.: impuesto a la patente de un automóvil).

f) *Restituir la cosa*

Una vez que se extinga el crédito garantizado, o en su caso el derecho real de garantía, la cosa debe ser restituida a su titular.

VI. Gastos

a) *Mejoras necesarias*

Dice el artículo 2217 que "El titular del objeto gravado debe al acreedor los gastos necesarios para la conservación del objeto, aunque éste no subsista..." Esto se explica porque el acreedor posee una cosa ajena para percibir su crédito, de modo que los gastos de conservación, esto es, aquellos necesarios para que la cosa se mantenga en buen estado, le corresponden a su dueño.

Esto es así aunque el objeto gravado "no subsista". Cabe entender que, a pesar de los esfuerzos del acreedor por conservarlo, el objeto no pudo subsistir.

Si el acreedor afronta tales gastos, podrán ser imputados a los frutos percibidos. Si esto fuera insuficiente, dicha suma deberá ser reintegrada por el deudor.

b) *Mejoras útiles*

En cambio, "El acreedor no puede reclamar los gastos útiles sino hasta la concurrencia del mayor valor del objeto" (art. 2217). Estas mejoras, que no son indispensables para mantener la cosa en buen estado, si el acreedor las realiza son a su cargo, ya que las hizo en su propio provecho. No obstante, si de ellas resultara un mayor valor para la cosa, ese *plus* sí podría reclamarlo (conf. art. 1938). Se trata de evitar un enriquecimiento sin causa.

VII. Duración de la inscripción

Como se explicó respecto de la hipoteca, no hay que confundir la extinción del derecho real con la caducidad de la inscripción en el Registro. Son independientes. Puede subsistir el derecho real pero perderse la oponibilidad derivada de la inscripción, si no se renueva previamente. Dispone el artículo 2218 que "Los efectos del registro de la anticresis se conservan por el término de veinte años para inmuebles y de diez años para muebles registrables, si antes no se renueva".

Teniendo en cuenta el plazo máximo de duración de este derecho real (art. 2214), es difícil que se presente esta situación. Podría darse si vencido el plazo máximo de duración, el deudor no cumpliera con su obligación, en cuyo caso el acreedor tendría interés en mantener la inscripción, en tanto el crédito no prescriba.

CAPÍTULO XXI
DERECHOS REALES DE GARANTÍA
(tercera parte) **MNR**

SUMARIO: C) Prenda. I. Disposiciones generales. II. Prenda con registro. III. Prenda de cosas. IV. Prenda de créditos.

C) PRENDA

I. Disposiciones generales

El nuevo Código, si bien mantiene los caracteres propios del instituto, consolida la distinción entre prenda común o con desplazamiento y prenda con registro o sin desplazamiento, regulando solamente el primer supuesto, toda vez que remite a las leyes especiales para el tratamiento de la segunda. A su vez, la prenda legislada en el Código puede recaer sobre: 1) cosas muebles no registrables; 2) créditos instrumentados.

a) *Concepto*

En líneas generales, el derecho real de prenda es aquel que recae sobre bienes muebles cuya posesión se transmite en garantía del cumplimiento de una obligación contraída por el transmitente o un tercero. Como lo que se transmite sólo es la posesión, el acreedor que recibe la cosa no puede disponer de ella (salvo un supuesto excepcional) y, en caso de incumplimiento, deberá instar la realización de su valor, o, al menos, que se estime justamente para poder adjudicársela.

El desplazamiento posesorio reviste singular importancia. Es lo

que hace que el constituyente no pueda disponer de la cosa o del crédito, ni destruirla o deteriorarla, etcétera.

Este derecho real se caracteriza por ser: 1) sobre cosa ajena; 2) de garantía; 3) accesorio; 4) indivisible; 5) se ejerce por la posesión; 6) convencional; 7) debe satisfacer el principio de especialidad, en cuanto al objeto y en cuanto al crédito.

b) *Legitimación*

Establece el Código que "...Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios..." (art. 2219). Al tener por objeto cosas muebles no registrables, se reduce el ámbito de los legitimados, a diferencia de la anticresis, que abarca más situaciones.

En el caso de que la cosa se encuentre en condominio, todos ellos deberán prestar su conformidad para gravarla con prenda (conf. art. 1990). En teoría, un condómino podría gravar su parte indivisa (art. 1989). El problema es que hay que entregarle la posesión al acreedor o a un tercero, y si los restantes condóminos no lo permiten, no podrá nacer el derecho real. Si lo aceptan, el acreedor o el tercero serían una suerte de depositario respecto de los condóminos que no son deudores ni constituyentes del derecho real, sino que sólo entregan la posesión.

c) *Objeto*

"La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados..." (art. 2219). La prenda de cosas muebles registrables se rige por la legislación especial.

c.1) *Cosas muebles*

El concepto de cosas surge del artículo 16, y el de cosas muebles del artículo 227. Cabe descartar a las cosas futuras ya que, como ocurre con los derechos reales, la necesidad de hacer la tradición lo impide. No obstante, las cosas futuras podrían ser objeto de una promesa de prenda.

También la prenda puede recaer "en títulos u otros bienes negociables en bolsas o mercados públicos" (conf. art. 1859).

En cuanto a los documentos con derecho incorporados, dispone el

Código que "La prenda de títulos valores se rige, en lo pertinente, por las reglas de la prenda de cosas" (art. 2231).

c.2) *Casos controvertidos*

La doctrina se ha planteado algunas cuestiones.

Sostuvo hace tiempo Salvat que el *dinero* puede también ser dado en prenda. La operación presenta en tal caso un carácter particular, porque el acreedor pignoraticio se convierte en propietario de los billetes o monedas entregadas en garantía, obligándose, en caso de pago, a la restitución de una suma igual: se ha propuesto por esto designar esta operación con el nombre de "prenda irregular", por analogía con el depósito irregular. En contra de esta postura se sostiene que se trata de cosas fungibles, y que el derecho de prenda debe satisfacer el principio de especialidad. Además, al convertirse el acreedor en propietario, se desnaturaliza la prenda, derecho real sobre cosa ajena. Se suma a esto la prohibición del pacto comisorio. Si se tratara de dinero fajado sin posibilidad de ser abierto, la solución es más sencilla.

Hay quienes sostienen que las *cuotas sociales de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL)* son cosas muebles que pueden cederse, embargarse y ejecutarse, y por ese motivo la prenda sobre ellas es válida.

c.3) *Créditos*

También pueden ser su objeto los créditos instrumentados.

d) *Constitución. Requisitos*

Establece el Código que se constituye la prenda "...por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes..." (art. 2219).

El contrato puede ser hecho por "instrumento público o privado", de fecha cierta. Es lógico, ya que la escritura pública se exige obligatoriamente para los inmuebles (art. 1017, inc. a). A ello se suma la entrega de la cosa o del título de crédito, que puede ser recibida por el acreedor prendario, o por un tercero que las partes designen.

e) *Contenido del contrato*

"...El instrumento debe mencionar el importe del crédito y contener la designación detallada de los objetos empeñados, su calidad; peso, medida, descripción de los documentos y títulos, y demás datos que sirven para individualizarlos" (art. 2222).

Se trata de cumplir con el *principio de la especialidad*. Por un lado, debe indicarse en el contrato "el importe del crédito" garantizado. Ése será el monto del gravamen, salvo que las partes pacten uno diferente. Fijará el límite el privilegio del acreedor por todo concepto (art. 2189).

En cuanto al objeto, el artículo 2188 exige que el objeto esté individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo, lo que reitera el artículo 2222 al requerir "la designación detallada de los objetos empeñados".

f) *Oponibilidad*

Agrega el artículo 2222 que "La prenda no es oponible a terceros si no consta por instrumento público o privado de fecha cierta, cualquiera sea la cuantía del crédito".

La oponibilidad de la prenda a los terceros interesados de buena fe no se logra por el solo desplazamiento de la cosa sino que se requiere además el cumplimiento del requisito de la fecha cierta de su acto constitutivo. El cumplimiento de uno solo de esos requisitos es insuficiente para la oponibilidad de la prenda, la que puede oponerse recién desde el momento en que se cumplan ambos recaudos.

g) *Importancia de la posesión*

Dice el artículo 2221 que "Los derechos provenientes de la prenda sólo subsisten mientras el bien afectado se encuentra en poder del acreedor o del tercero designado..."

El artículo 2221 se refiere a supuestos en los que la posesión se pierde de manera definitiva, ya sea en forma voluntaria o por desapoderamiento, pero no sucede así mientras el acreedor, acciones mediante, pueda recuperar la cosa.

g.1) *Posesión de un tercero*

Como se dijo anteriormente, la posesión la puede ejercer un tercero elegido por las partes, distinto del acreedor. Esta posibilidad de posesión en un tercero faculta al deudor a constituir varias prendas sobre la misma cosa a la vez, lo que exime al acreedor de las responsabilidades propias de la guarda y conservación de la cosa.

g.2) *Pérdida, sustracción o entrega de la cosa*

Pueden presentarse situaciones en las que el acreedor o el tercero pierdan la posesión real o la tenencia de la cosa, pero que de todos modos no pierdan los derechos que confiere el derecho real de prenda. El Código establece que "...Se reputa que el acreedor o el tercero continúan en posesión de la prenda cuando media pérdida o sustracción de ella o hubiera sido entregada a otro con obligación de devolverla. Si el acreedor pierde la posesión de la cosa, puede recuperarla de quien la tiene en su poder, sin exceptuar al propio constituyente de la prenda" (art. 2221).

Por ende, si al acreedor o al tercero lo desapoderan de la cosa, si bien dejan de ser poseedores, el Código reputa que continúan siéndolo; se trata de una ficción que tiende a evitar la injusta situación de que el acreedor, despojado, pierda también su derecho prendario. Además, esto también beneficia al deudor, quien sigue siendo tal pero así conserva la garantía. De no ser así, acreedor y deudor continuarían su vínculo personal, pero habrán perdido el gravamen, lo cual perjudica a ambos.

El Código aplica la misma solución en el supuesto de que la cosa "hubiera sido entregada a otro con obligación de devolverla". Esto es lógico ya que aquí no se perdió la posesión si fue transmitida a otro que la tiene que devolver por alguna causa (v. gr.: contrato de depósito, o se entregó para que se realice alguna reparación, etc.). Esto es así aun cuando el acreedor se la hubiera entregado al propio deudor, si lo hizo con la referida finalidad. Así, por ejemplo, si se la devolvió momentáneamente para que efectúe unas reparaciones.

g.3) *Restitución voluntaria de la cosa*

En el caso visto en el punto anterior el acreedor o el tercero eran

desapoderados por un tercero, contra su voluntad. El Código reputa que la prenda continúa. Distinta es la solución si el acreedor restituyera voluntariamente la cosa a su deudor. Dice el artículo 954 que "La restitución al deudor de la cosa dada en prenda causa sólo la remisión de la prenda, pero no la remisión de la deuda". En tal caso, lo que se extingue es la prenda, no el crédito garantizado.

g.4) Interrupción de la prescripción

El acreedor prendario mantiene sus derechos mientras la cosa se encuentre en su poder, o en el de un tercero. Por lo tanto, no puede correr la prescripción de la obligación principal, ya que el deudor que entregó la posesión está reconociendo el derecho del acreedor (art. 2545). Se puede citar en apoyo de esta interpretación lo previsto por el Código para quien ejerce el derecho de retención, ya que dice que "interrumpe el curso de la prescripción extintiva del crédito al que accede" (art. 2592, inc. e).

h) Prendas sucesivas

Dice el Código que "Puede constituirse una nueva prenda sobre el bien empeñado, a favor de otro acreedor, si el acreedor en cuyo poder se encuentra consiente en poseerlo para ambos o si es entregada en custodia a un tercero en interés común..." (art. 2223).

Para que sea posible la segunda prenda, el acreedor que ya adquirió el derecho real de garantía debe prestar su conformidad, ya sea para "poseer para ambos", esto es, continuar poseyendo pero ahora en la calidad de poseedor a nombre propio y en nombre de otro, o bien acepta desprenderse de la cosa y que se entregue a un tercero, quien la cuidará en interés común, es decir, de los dos acreedores.

Si bien el Código no lo dice, podría el segundo acreedor ser quien posea la cosa en nombre suyo y del primer acreedor. Claro que es difícil imaginar que el primero acepte esta situación, por los riesgos que implica.

Si la cosa ya estaba en poder de un tercero, el constituyente puede gravarla nuevamente, ya que eso no perjudica al primer acreedor, quien tiene prioridad, por haber nacido su derecho con antelación (arg. art. 2195). Lo que no puede el constituyente es disminuir el valor de la garantía.

i) Rango de los acreedores

En el caso de prendas sucesivas (pueden ser varias), los acreedores tienen un rango, un lugar, de acuerdo a la fecha de su constitución. Dice el Código que "...La prioridad entre los acreedores queda establecida por la fecha de su constitución..." (art. 2223).

La prioridad está ligada a "la fecha de su constitución". Cabe entender por tal, no la fecha del instrumento público o privado, sino la de la adquisición del derecho real cuando se reúnen título y modo. Así, por ejemplo, si el deudor constituye una prenda en favor de un acreedor el 1° de noviembre, pero no hace tradición, y el 20 de noviembre grava la misma cosa con otra prenda a favor de otro acreedor, y al segundo le entrega la posesión, este último habrá sido el primero en adquirir el derecho real y, por lo tanto, debe prevalecer (conf. art. 757, inc. b).

Si ninguno adquirió aún el derecho real por no haberse cumplido el modo, entonces sí la prioridad debe establecerse atendiendo a la fecha cierta del título constitutivo.

La regla, pues, es que el primero en adquirir el derecho real es quien tiene prioridad en caso de prendas sucesivas. "...No obstante, las partes pueden, mediante declaración de su voluntad formulada con precisión y claridad, sustraerse a los efectos de esta regla y establecer otro orden de prelación para sus derechos, a fin de compartir la prioridad o autorizar que ésta sea compartida" (art. 2223).

El Código autoriza a los interesados a modificar la regla, en tanto manifiesten en forma clara y contundente su voluntad de apartarse de dicho principio. En especial es fundamental la conformidad del acreedor que está ubicado en el primer lugar.

El Código dice que pueden "compartir la prioridad o autorizar que ésta sea compartida". En el primer caso, el primer acreedor conviene con el segundo en compartir ambos el primer lugar. La segunda hipótesis consiste en que el único acreedor prendario, por el momento, acepta compartir su lugar en el futuro, en la hipótesis de que se constituya una segunda prenda. En tal caso, deberá indicarse el monto que la segunda podrá alcanzar.

El Código se refiere a "compartir" la prioridad. Pero también el

que está en primer lugar podría aceptar ser pospuesto a un segundo lugar (reserva de rango), o bien permutar su posición con otro acreedor. La permuta entre uno que está primero y otro que está tercero requerirá, obviamente, la conformidad del ubicado en segundo término.

j) *Derechos y deberes del acreedor*

El acreedor puede:

- 1) Poseer la cosa, o depositarla en poder de un tercero, hasta tanto el deudor satisfaga su obligación. Si el acreedor realiza gastos de conservación, se los puede reclamar al deudor (art. 2227) y, si la cosa produce frutos, puede percibirlos e imputarlos a dicha deuda, si no se pactó lo contrario (art. 2225).
Esta posesión no le da derecho a usar de la cosa sin autorización del deudor y, aun autorizado o siendo ello necesario, en ningún caso puede abusar de esta facultad (art. 2226).
- 2) Ejercer las acciones correspondientes para reclamar o defender la cosa, incluso contra el deudor o contra el constituyente.
- 3) Realizar el valor de la cosa si el deudor no satisface la obligación a su cargo. En el caso de subasta o venta, el acreedor tiene derecho a cobrar su crédito del precio obtenido, ejerciendo su privilegio si concurren otros acreedores. Si se trata de créditos dados en prenda, puede percibirlos incluso judicialmente si es menester (art. 2234). Luego tendrá que rendir cuentas (art. 2230).
- 4) En determinadas condiciones, adjudicarse directamente la cosa (art. 2229).

k) *Extinción del derecho real de prenda*

k.1) *Por vía indirecta*

Como es sabido, como ocurre con los derechos reales de garantía, la prenda es accesoria de uno o más créditos. Por ende, la extinción total de la obligación garantizada (v. gr.: por pago) determina el fin del derecho real accesorio (art. 2186). Ésta es la regla que puede sufrir alguna excepción, como en el caso de la novación, o del pago hecho por un tercero.

La extinción del crédito debe ser total, pues su cancelación parcial hace que subsista la prenda, por ser indivisible.

k.2) *Por vía directa*

Pueden darse situaciones en que, sin que se extinga el crédito garantizado, la prenda se extinga.

Cabe mencionar a la renuncia, esto es, al abandono del derecho real, y a la consolidación, que se presentaría si confluyen la propiedad de la cosa y el derecho de prenda en la misma persona (v. gr.: acreedor prendario que hereda el objeto prendado). El artículo 1907 menciona también a la destrucción de la cosa, pero aquí cabe hacer la salvedad de que se extenderá a la indemnización, si es que se obtiene alguna (art. 2194).

Un caso particular es el de la pérdida de la posesión, en la hipótesis de que el acreedor prendario restituyera la cosa o el título del crédito recibido (art. 2225). Dice el artículo 954 que "La restitución al deudor de la cosa dada en prenda causa sólo la remisión de la prenda, pero no la remisión de la deuda".

Finalmente, el modo especial de extinción del derecho real es la subasta, o la venta privada, en cuyo caso los derechos de todos los acreedores —si fueron debidamente citados— se trasladan al precio obtenido (art. 2203).

k.3) *Efectos de la extinción*

Extinguida la prenda, el acreedor o el tercero deben restituir la cosa o el instrumento probatorio del crédito prendado. Cabe aclarar que esto es así en tanto el deudor haya cumplido su obligación, o el crédito garantizado aún no sea exigible. Ello porque hay supuestos en los que, si bien el derecho real se extinguió, no es posible la restitución del objeto como, por ejemplo, si fue subastado o se destruyó.

II. *Prenda con registro*

La ley 9644 de 1914 introdujo la prenda sin desplazamiento, limitada al aspecto agrario, luego perfeccionada por la ley 12.962.

Como se dijo, el Código se ocupa de la prenda con desplazamiento, cuyo objeto son cosas muebles no registrables o títulos de crédito. Ciertas cosas muebles registrables también pueden ser objeto del derecho de prenda, pero se trata de la prenda con registro, legislada fuera de este Código, que se caracteriza por la falta de desplazamiento.

Esto lo aclara el artículo 2220: "Asimismo, puede constituirse prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las que los contratantes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero, sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena. Esta prenda se rige por la legislación especial".

El Código pide que se le atribuya "un valor consistente en una suma de dinero" para que se cumpla con el principio de especialidad. Lo demás queda librado a la legislación especial, en tanto no colisione con el Código.

Mientras que la prenda con registro se hace cognoscible a los terceros básicamente a través de las constancias del Registro público respectivo (por ej. de automotores y créditos prendarios, de buques, etc.), la prenda con desplazamiento carece de publicidad registral y se vale para su oponibilidad a terceros interesados de buena fe de la publicidad posesoria y de la fecha cierta del instrumento portante de su contrato constitutivo.

Esta "legislación especial" es hoy el decreto-ley 15.348/46 (ratificado por ley 12.962, t. o. por decreto 897/95), que mantiene su vigencia (art. 5°, ley 26.994).

Esta legislación especial limita sus beneficios a ciertos acreedores (art. 5°), con el objeto —no siempre logrado— de combatir la usura. Regula distintos tipos de prenda: fija, flotante (art. 14) o sobre fondos de comercio (art. 11, inc. d).

También hay que tener en cuenta a la ley 9644 que regula la "prenda agraria", que recae sobre "Las máquinas en general, aperos e instrumentos de labranza; los animales de cualquier especie y sus productos, como las cosas muebles afectadas a la explotación rural; y los frutos de cualquier naturaleza correspondientes al año agrícola en que el

MNR

contrato se realice, sean pendientes, sean en pie o después de separados de la planta, así como las maderas, los productos de la minería y los de la industria nacional" (art. 2°).

Si bien dichas cosas no son registrables, sí debe inscribirse el contrato en el Registro público, que funcionará en las oficinas nacionales o provinciales que determine el Poder Ejecutivo (art. 7°). Por el artículo 49 del decreto-ley 15.348/46 se dispone que los contratos celebrados según la ley 9644 se regirán por sus disposiciones, salvo que los contratantes convengan en que queden sujetos al régimen legal de la prenda con registro regulada por dicha norma.

III. Prenda de cosas

Luego de establecer las disposiciones generales aplicables tanto a la prenda de cosas como a la prenda de créditos, el Código contiene normas específicas dedicadas a la prenda de cosas que, en aquello que no tenga modificaciones especiales, se aplicarán también subsidiariamente a la prenda de créditos (art. 2232).

a) *Prenda de cosa ajena*

En el contrato de prenda de cosa ajena el constituyente se obliga, expresa o tácitamente, a adquirir la propiedad antes de entregarla al acreedor; si la entrega antes de haberla adquirido, el contrato es nulo, por falta de legitimación; si la adquiere luego, la prenda queda convalidada (ver art. 1885).

Es posible que el acreedor reciba en garantía una cosa que no pertenezca al constituyente, de buena fe, esto es, creyendo que sí le pertenecía. Una vez enterado, si no hubo convalidación, se comporta como un hombre honesto y se le entrega al verdadero dueño que se la reclama. La situación está contemplada en el artículo 2224: "Si el acreedor que recibe en prenda una cosa ajena que cree del constituyente la restituye al dueño que la reclama, puede exigir al deudor la entrega en prenda de otra de igual valor. Si el deudor no lo hace, el acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación principal aunque tenga plazo pendiente; si el crédito está sujeto a condición se aplica el artículo 2197". Se trata de un supuesto de evicción (ver arts. 1039 y concs.).

Si las partes no se ponen de acuerdo sobre el valor de la cosa a entregar, la cuestión deberá ser decidida judicialmente.

b) *Frutos. Prenda anticrética*

Existe la posibilidad de que la cosa entregada en prenda sea fructífera, que genere frutos naturales o civiles (crías de animales, objeto que es alquilado temporariamente, etc.). Si no se pacta lo contrario, serán imputados al pago de la deuda. Cabe recordar que, según lo previsto en el artículo 2192, en la prenda quedan comprendidos todos los accesorios físicamente unidos a la cosa, las mejoras y las rentas debidas. En cuanto a frutos artificiales, en principio el acreedor no tiene derecho a usar de la cosa (art. 2226), por lo que ello dependerá de lo que las partes hayan convenido, ya que no rige aquí el orden público.

Dice el artículo 2225 que "Si el bien prendado genera frutos o intereses el acreedor debe percibirlos e imputarlos al pago de la deuda, primero a gastos e intereses y luego al capital. Es válido el pacto en contrario".

Se ha caracterizado esta figura como "prenda anticrética" en tanto entremezcla ambas figuras, permitiendo entonces aplicar los frutos de una cosa —aquí a su vez objeto de prenda— al pago de una deuda principal. Es una suerte de anticresis sobre cosa mueble no registrable, semejante a la existente en el Derecho Romano. Se comprenden tanto los frutos naturales como los civiles.

Debe aplicarse por analogía al acreedor prendario el deber impuesto al anticresista de dar cuenta al deudor de la imputación de los frutos a la cancelación de la deuda (art. 2215).

c) *Uso y abuso*

La regla es que el acreedor no puede usar de la cosa dada en prenda, a menos que se pacte algo diferente. En caso de estar autorizado, dicho uso no puede ser abusivo, no puede dañar la cosa. Dice el artículo 2226, primer párrafo, que "El acreedor no puede usar la cosa prendada sin consentimiento del deudor, a menos que el uso de la cosa sea necesario para su conservación; en ningún caso puede abusar en la utilización de la cosa ni perjudicarla de otro modo".

Al ser el acreedor pignoraticio, un poseedor de la cosa recibida en garantía del cobro de un crédito, resulta consecuencia lógica que no posea —*per se*— la facultad de servirse de la cosa. Para ello requiere del consentimiento del deudor, el que puede darse en cualquier momento. Si la cosa prendada fuera propiedad de un tercero no deudor, debiera ser éste quien autorice al acreedor a servirse de aquélla.

Por excepción, podrá usar de la cosa sin consentimiento del deudor, si ello es "necesario para su conservación". Sea o no necesario, en ningún caso está permitido el abuso, ni ninguna actividad que perjudique a la cosa. El uso debe ajustarse al destino de la cosa prendada, el que se determina por la convención, por la naturaleza de la cosa o por el uso al cual estaba afectada de hecho (aplicación analógica del art. 2145).

Continúa diciendo el artículo 2226 que "El incumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, da derecho al deudor a: a) dar por extinguida la garantía y que la cosa le sea restituida; b) pedir que la cosa se ponga en depósito a costa del acreedor; c) reclamar daños y perjuicios".

d) *Gastos*

En forma similar a la prevista para la anticresis (art. 2217), dispone el artículo 2227 que "El deudor debe al acreedor los gastos originados por la conservación de la cosa prendada, aunque ésta no subsista. El acreedor no puede reclamar los gastos útiles sino hasta la concurrencia del mayor valor de la cosa". Esto se explica porque el acreedor posee una cosa ajena para percibir su crédito, de modo que los gastos de conservación, esto es, aquellos necesarios para que la cosa se mantenga en buen estado, le corresponden a su dueño.

Si no se trata de gastos indispensables, el acreedor deberá contar con la aprobación del deudor si pretende —luego de efectuados— reclamarlos. Ello reconoce una excepción en el propio texto normativo, y es que si realizadas aquellas mejoras y comprobado que fuere que han dado un "mayor valor a la cosa", el acreedor tiene derecho a su reclamo (conf. art. 1938). Se trata de evitar un enriquecimiento sin causa.

e) *Venta del bien empeñado*

Como se ha visto, el acreedor debe conservar la cosa para ser restituida al constituyente si su crédito es satisfecho, o bien para ejecutarla en caso contrario. No puede, por ende, vender la cosa mientras ejerce su derecho, salvo que se presente la situación excepcional prevista en el artículo 2228: "Si hay motivo para temer la destrucción de la prenda o una notable pérdida de su valor, tanto el acreedor como el constituyente pueden pedir la venta del bien [...] La cosa empeñada puede también venderse a petición de otros acreedores. En tal caso, como en los anteriores, el privilegio del acreedor prendario se ejerce sobre el precio obtenido". La venta produce la desafectación de la cosa a la prenda; el privilegio del acreedor se traslada por subrogación real al precio obtenido, como imponen los artículos 2194 y 2197, sin importar quién pidió la venta de la cosa.

e.1) *Venta pedida por otro acreedor*

Cualquier acreedor, no sólo el prendario, puede pedir la venta de la cosa. Aun cuando sea quirografario y se advierta que si la cosa se vende, y cobran antes otros acreedores, no podrá percibir su crédito, de todos modos puede ejercer el derecho de pedir la enajenación, si se dan las condiciones previstas.

Ante una orden judicial de secuestro de la cosa prendada el acreedor prendario tendrá que entregarla y luego presentarse en el respectivo juicio para hacer valer su privilegio sobre el producido de la subasta, por la vía incidental o por medio de una tercería de mejor derecho.

e.2) *Restitución de la cosa*

Se dijo anteriormente que si existe peligro de que la cosa se destruya o desvalore notablemente, se la puede vender, en cuyo caso el derecho real se ejerce sobre el precio obtenido. La otra alternativa es que se sustituya a dicha cosa por otra. En efecto, dice la segunda parte del primer párrafo del artículo 2228: "Asimismo, el constituyente puede recabar la devolución de la prenda sustituyéndola por otra garantía real equivalente y, si se presenta ocasión favorable para su venta, requerir la autorización judicial para proceder, previa audiencia del acreedor".

El constituyente reemplaza el objeto dado en prenda por otro, o bien constituye "otra garantía real equivalente", teniendo en cuenta que la restitución de la cosa implica la extinción de la prenda. Podría ser una hipoteca o una anticresis en lugar de la garantía extinguida.

f) *Ejecución*

Si el deudor no cumple con la prestación a su cargo, el acreedor entonces puede llevar adelante la ejecución de la cosa, para así cobrar su crédito con el privilegio correspondiente.

En cuanto a la forma de realizar la venta, el Código ofrece distintas alternativas por las que puede optar, en tanto en el contrato constitutivo no se haya pactado algo diferente. Las posibilidades son tres: 1) venta pública; 2) venta privada; 3) adjudicación.

f.1) *Ejecución judicial*

Una alternativa con la que cuenta el acreedor prendario, bien tradicional, es acudir al juicio de ejecución prendaria organizado por los códigos procesales de cada jurisdicción. El artículo 2229 dispone que "El acreedor puede vender la cosa prendada en subasta pública, debidamente anunciada con diez días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponde al lugar en que, según el contrato, la cosa deba encontrarse..."

El deudor y el constituyente deben ser citados y oídos en el juicio.

Será juez competente el del lugar en el que se encuentre la cosa.

f.2) *Venta de títulos*

Agrega el artículo 2229 que "Si la prenda consiste en títulos u otros bienes negociables en bolsas o mercados públicos, la venta puede hacerse en la forma habitual en tales mercados, al precio de cotización".

Por ende, si por ejemplo se hubiesen dado en prenda acciones o títulos públicos que cotizan en bolsa, la venta puede hacerse en tales mercados, a su valor real, sin necesidad de acudir a una subasta pública, en la que es sabido que el precio que se paga es inferior al de plaza.

f.3) *Otras opciones*

Continúa diciendo el artículo 2229 que "Las partes pueden convenir simultáneamente con la constitución que [...] b) la venta se puede realizar por un procedimiento especial que ellas determinan, el que puede consistir en la designación de una persona para efectuarla o la venta por el acreedor o por un tercero a precios que surgen de un determinado ámbito de negociación o según informes de los valores corrientes de mercados al tiempo de la enajenación que indican una o más cámaras empresariales especializadas o publicaciones designadas en el contrato".

Surge de la norma que las partes pueden convenir en el acto constitutivo acudir a un procedimiento especial, diferente al organizado por el Código Procesal. Les da mucha libertad ya que indica que es el procedimiento "que ellas determinan", y luego da un ejemplo: "el que puede consistir en la designación de una persona para efectuarla o la venta por el acreedor o por un tercero". Cabe inferir que este procedimiento especial que pueden pactar las partes no es el único, pues dice "el que puede consistir en", dando cabida a otras formas que las partes imaginen en ejercicio de su libertad contractual.

Al ser así, reviste fundamental importancia lo que se prevea en el acto constitutivo.

Aquí se aprecia que el carácter autoliquidable de la prenda es uno de los rasgos más sobresalientes del Código en la materia.

Quien haga la venta deberá recabar información sobre el precio de plaza del producto que se trate.

Así, por ejemplo, si se trata de un antiguo reloj de marca, se podrá consultar a quienes se dedican a la venta de antigüedades, publicaciones sobre el tema, etcétera.

f.4) *Adjudicación al acreedor*

El artículo 2198 establece como principio general que "Es nula toda cláusula que permite al titular de un derecho real de garantía adquirir o disponer del bien gravado fuera de las modalidades y condiciones de ejecución previstas por la ley para cada derecho real de garantía". Se trata de la prohibición del pacto comisorio, para evitar

que el acreedor se abuse de la situación y se quede con un objeto cuyo valor supere al monto del crédito que el deudor no pudo satisfacer. Esto se considera usurario. No hay que olvidar que el acreedor, que tiene la cosa en su poder, tiene una situación de superioridad respecto del deudor.

No obstante, en el ámbito de la prenda, el Código es un tanto más flexible. También prevé el citado artículo 2229 que "...a) el acreedor se puede adjudicar la cosa por la estimación del valor que de ella se haga al tiempo del vencimiento de la deuda, según lo establezca el experto que las partes designen o bien por el que resulte del procedimiento de elección establecido; en su defecto, el experto debe ser designado por el juez a simple petición del acreedor..." Esto debe convenirse en el acto constitutivo o en acto separado pero "simultáneamente" (art. 2229, tercer párrafo).

Lo que no puede el acreedor es apropiarse de la cosa directamente, ni por el precio estipulado en el contrato de prenda. Ocurre que con el transcurso del tiempo el precio de la cosa puede variar, y es posible que al momento del incumplimiento, su valor sea superior al asignado originariamente. Si el acreedor se quedara con una cosa cuyo valor es más alto que el previsto al formalizar el contrato, estaría obteniendo un beneficio indebido.

Para evitar esta situación, el Código permite al acreedor hacerse dueño de la cosa, pero "por la estimación del valor que de ella se haga al tiempo del vencimiento de la deuda".

f.5) *Carácter optativo de las alternativas*

En el cuarto párrafo, establece el artículo 2229 que "A falta de estipulación en contrario, estas alternativas son optativas para el acreedor, junto con las indicadas en los párrafos primero y segundo de este artículo, según el caso".

Las alternativas son tres según se ha visto: 1) subasta pública; 2) venta privada; 3) adjudicación al acreedor. Se suma a este panorama el caso especial de la venta de acciones o títulos en los mercados específicos.

Pues bien, si no se pacta lo contrario, "estas alternativas son op-

tativas para el acreedor", de modo que si el deudor no cumple con sus obligaciones el acreedor decidirá (optará) por uno de los caminos descriptos.

f.6) *Adquisición del acreedor*

El último párrafo del artículo 2229 prescribe que "El acreedor puede adquirir la cosa por la compra que haga en la subasta o en la venta privada o por su adjudicación". Una posibilidad es que el acreedor opte por adjudicarse la cosa directamente, siempre que se estime el valor al tiempo del vencimiento de la deuda. Otra posibilidad que tiene el acreedor de hacerse dueño de la cosa pasa por adquirirla en la subasta o venta privada, según el procedimiento que él mismo haya elegido.

Si adquiere en la subasta o venta privada, lo que hará el acreedor es compensar su crédito y, en su caso, pagar la diferencia.

f.7) *Rendición de cuentas*

Dispone el artículo 2230 que "Efectuada la venta, el acreedor debe rendir cuentas..." Esta rendición de cuentas, lógica para quien administra una cosa ajena y luego promueve su ejecución o adjudicación, será el resultado de la imputación efectuada por el acreedor.

Prevé el artículo 2230 sobre dichas cuentas "que pueden ser impugnadas judicialmente, pero ello no afecta la validez de la enajenación".

g) *Documentos con derecho incorporado. Títulos valores*

Una evolución del derecho de los títulos valores es la aplicación del régimen de las cosas muebles a los créditos, a los títulos de crédito. El derecho contenido en el título se constituye con el mismo, nace con él y viene dentro de él; se produce un vínculo indisoluble entre derecho (contenido) y documento (continente). Esta característica es la que brinda un régimen especial, pues la garantía prendaria (esto es, la cosa objeto de la garantía real) recae tanto en el documento (cosa) como en el derecho en él incorporado (crédito); recae sobre el resultado de esa combinación y los límites del objeto prendado derivan de un

especial esquema normativo: el régimen cambiario. Se produce una suerte de cosificación del derecho.

El Código, y también el ordenamiento cambiario, con una clara intención de facilitar la circulación de los derechos cartulares (así sea al menos como garantía), prevé expresamente la prenda de títulos valores en garantía de una relación anterior entre las partes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

No podrá el acreedor prendario, so pretexto de ejercer las facultades legalmente conferidas, modificar los aspectos substanciales del crédito prendado o menoscabar el derecho gravado.

La cosificación del crédito prendado, como asiento idóneo del gravamen, no impide el ejercicio por el dueño del mismo de todas las facultades inherentes a la propiedad del crédito cedido en garantía.

Dice el artículo 2231 que "La prenda de títulos valores se rige, en lo pertinente, por las reglas de la prenda de cosas". Esta remisión es, como dice el artículo, "en lo pertinente".

Se puede constituir el derecho real de prenda por instrumento separado, o es suficiente con un simple endoso del portador legitimado, con la cláusula "en prenda" u otra expresión equivalente a favor del endosatario (acreedor de la deuda garantizada), quien queda legitimado para cobrar el título a su vencimiento y, con ese importe, cancelar el crédito de la operación garantizada, descontando los gastos en los que incurrió y reintegrando el remanente —si lo hubiere— al endosante.

El acreedor prendario (endosatario en prenda) está en posesión de los títulos y de esa posesión deriva la posibilidad de ejecutarlo y de asumir frente a terceros una aparente propiedad de dichos títulos. El propietario del título, al carecer de la posesión del documento, no puede hacer valer por sí mismo el derecho incorporado en el título y pretender legítimamente que el deudor se abstenga de cumplir la obligación al acreedor prendario; pero, en cambio, puede mediante una acción personal reclamar daños y perjuicios al acreedor prendario que se haya extralimitado en el ejercicio de sus derechos y obtenido una utilidad que excede la determinada por el contrato.

IV. Prenda de créditos

Los créditos no son cosas ni son objeto de posesión, de ahí que el Código los trate por separado. No obstante, se permite la prenda de estos bienes si se reúnen ciertas condiciones, en especial que el crédito se encuentre instrumentado, su entrega al acreedor o a un tercero, y la notificación al deudor del crédito prendado. El desplazamiento hace que el deudor prendario no pueda disponer de dicho crédito, y le transmite al acreedor la legitimación para exigirlo del deudor, si el obligado no cumple.

a) *Créditos instrumentados*

Dice el artículo 2232 que "La prenda de créditos es la que se constituye sobre cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido".

La posibilidad de preñar créditos, siempre que estén instrumentados, está admitida por el Código. Se trata de instrumentos públicos o privados en los que se estatuye, a favor del futuro deudor prendario, un crédito pasible de ser reclamado a un tercero.

Se exige que el crédito conste por escrito, en un instrumento, ya que debe serle entregado al acreedor o a un tercero, lo que no sería posible con un crédito que no reúna tal condición. El desplazamiento es relevante para el derecho real de prenda. Al ser así, algunos autores no admiten la constitución de esta prenda sobre derechos intelectuales, marcas de fábrica y patentes de invención, mientras que otros se pronuncian por la afirmativa alegando que el título a ser entregado al acreedor es el certificado de inscripción en el Registro respectivo.

El Código parece dar la razón a los segundos, ya que dispone el artículo 2232, en su segundo párrafo, que "La prenda se constituye aunque el derecho no se encuentre incorporado a dicho instrumento y aunque éste no sea necesario para el ejercicio de los derechos vinculados con el crédito prendado". Además, también prevé que los derechos puedan ser objeto de los derechos reales, lo que muestra un espíritu muy amplio.

La doctrina admite la posibilidad de que se constituya prenda sobre una factura, certificados de obra pública, alquileres, entre otros.

Lo cierto es que el criterio es amplio, si se tiene en cuenta que

MNR

según el artículo 2232 la prenda puede tener como objeto "cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido", esto es, cualquiera sea su causa fuente: una compraventa, un mutuo, una locación, etcétera. A su vez, el artículo 1615, respecto de la cesión en garantía de derechos, dice que "...las normas de la prenda de créditos se aplican a las relaciones entre cedente y cesionario", y agrega el artículo 1616: "Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina, o de la naturaleza del derecho".

Si el acreedor percibe el crédito —judicial o extrajudicialmente— en fecha anticipada a la de vencimiento de la obligación garantizada con prenda, su derecho se traslada a la suma de dinero obtenida, operando una subrogación real.

a.1) *Concurso del deudor*

Si el acreedor ha recibido títulos de crédito, en concepto de garantía o prenda, carece de derecho, frente a la presentación concursal del deudor, para compensar su crédito con los fondos percibidos de los deudores de los títulos entregados en garantía, y ello aun cuando tal facultad esté prevista en el contrato de mutuo celebrado entre el deudor y el acreedor, pues cláusulas semejantes caen fulminadas por la nulidad prevista por el artículo 2198 del Código Civil y Comercial.

El acreedor debe verificar su crédito al igual que todos los acreedores, como requisito previo a la ejecución especial (art. 33, ley 19.551).

a.2) *Aplicación supletoria*

El último párrafo del artículo 2232 dispone que "Se aplican supletoriamente las reglas sobre prenda de cosas".

b) *Constitución*

La prenda de créditos se constituye en concreto cuando se notifica la existencia del contrato al deudor del crédito prendado (art. 2233). Esto es, se debe notificar la cesión en garantía al deudor del crédito cedido para que dicha cesión en garantía quede formalmente constituida y resulte oponible al deudor y frente a terceros.

En suma, para que nazca el derecho real de prenda sobre el crédito pignorado es necesario que concurren los siguientes requisitos:

- a) Que las partes otorguen el contrato de prenda por instrumento público o privado, el que para ser oponible a terceros debe tener fecha cierta;
- b) que el crédito pignorado esté instrumentado, en el sentido que pueda probarse por medio de un documento, y que el constituyente lo entregue al acreedor prendario o al tercero designado por las partes, y
- c) que se notifique la existencia del contrato de prenda al deudor del crédito pignorado (arg. art. 1620).

b.1) *Notificación*

En cuanto a la forma de la notificación, el artículo 1620 dispone que debe ser realizada por instrumento público o privado con fecha cierta.

b.2) *Sujetos*

La notificación puede ser realizada por cualquiera de las partes, constituyente o acreedor, aunque es este último quien posee un especial interés en efectuarla a fin de consolidar la transmisión operada en su favor, sustrayendo el negocio del ataque de los acreedores del primero (embargos, ejercicio de acciones subrogatorias, etc.).

b.3) *Lugar de la notificación*

El Código impone la notificación en forma escrita, por medio de instrumento público o privado con fecha cierta. Parece conveniente que se realice en el domicilio real del deudor. No se considera válida la notificación al domicilio constituido en el contrato, porque éste tiene sólo efectos entre partes.

c) *Conservación y cobranza*

Artículo 2234: "El acreedor prendario debe conservar y cobrar, incluso judicialmente, el crédito prendado. Se aplican las reglas del mandato".

El acreedor no es titular del crédito que recibió en garantía. Si lo fuera, se trataría de una transmisión fiduciaria y no de una prenda. Por ende, no puede celebrar sobre los créditos gravados transacción o contratos que impliquen su negociación. Solamente el artículo 2234 le reconoce al acreedor prendario la facultad de cobrar.

El acreedor prendario tiene la posesión del crédito con la finalidad de restituirlo al deudor si éste cumple con su obligación. Puede ocurrir que antes del vencimiento de la obligación garantizada con prenda, el crédito cedido en garantía venza, en cuyo caso tiene que cobrarlo, incluso judicialmente si es necesario.

El artículo 2234 establece que deben aplicarse las reglas del mandato. El titular del crédito es el mandante, y es mandatario el acreedor prendario, quien en interés común y por imperativo legal debe conservar y cobrar el crédito pignorado.

c.1) *Prestación dineraria*

Dice el segundo párrafo del artículo 2234 que "Si la prestación percibida por el acreedor prendario consiste en dinero, debe aplicar lo recibido hasta cubrir íntegramente su derecho contra el deudor y en los límites de la prenda".

Si el crédito del acreedor prendario aún no es exigible, deberá conservar el dinero y la prenda subsistirá sobre el dinero (prenda irregular) hasta tanto el acreedor tenga derecho a cobrar su propio crédito.

c.2) *Prestación no dineraria*

Culmina el artículo 2234 aclarando el camino a seguir si el crédito dado en prenda contenía una prestación no dineraria. Dice que "Si la prestación percibida no es dineraria el acreedor debe proceder a la venta de la cosa, aplicándose el artículo 2229".

Así, por ejemplo, si el deudor le hubiera dado en prenda al acreedor un contrato de compraventa que le da derecho a recibir una determinada cosa mueble, el acreedor no puede apropiarse de esta cosa. Lo que debe hacer es venderla para, con el dinero obtenido, cobrar así su propio crédito.

c.3) *Opción o declaración de las partes*

Se expuso anteriormente que el crédito dado en prenda puede ser exigible antes o después que el crédito del acreedor prendario. Puede suceder que la exigibilidad de la obligación dada en garantía dependa de una opción o declaración del constituyente, como puede suceder en las obligaciones de género (art. 762), alternativas (art. 779), facultativas (art. 786) o disyuntivas (art. 853), en un contrato de opción (art. 996), etcétera. En tal caso, "...el acreedor prendario puede hacer la respectiva manifestación, por su sola cuenta si su propio crédito es exigible, y de común acuerdo con aquél en caso contrario" (art. 2235).

Si aún no es exigible, puede hacer la declaración pero de común acuerdo con su deudor (acreedor del crédito dado en prenda).

"Si la opción o la declaración corresponden al deudor del crédito dado en garantía, sólo producen efecto si se comunican al propio acreedor y al prendario" (art. 2235, segundo párrafo).

Lo previsto en el artículo 2235 es supletorio de la voluntad de las partes, pues dicha norma establece, en su último párrafo, que "Son válidos los pactos en contrario que celebran el acreedor prendario y el constituyente de la prenda".

d) *Participación en contrato con prestaciones recíprocas*

Dispone el artículo 2236 que "Si el crédito prendado se origina en un contrato con prestaciones recíprocas, en caso de incumplimiento del obligado prendario el acreedor puede enajenar forzosamente la participación de aquél en dicho contrato, sujeto a las limitaciones contractuales aplicables.

"Si la cesión de la participación del constituyente está sujeta al asentimiento de la otra parte de tal contrato, y éste es negado injustificadamente, debe ser suplido por el juez.

"Por participación se entiende el conjunto de derechos y obligaciones derivados del contrato".

e) *Extinción de la prenda pero no del crédito*

Este caso está previsto por el artículo 2237: "Extinguida la prenda

por cualquier causa sin haberse extinguido el crédito dado en prenda, el acreedor debe restituir el instrumento probatorio del crédito prendado y notificar la extinción de la prenda al deudor del crédito prendado".

No importa la causa por la cual se extinga el derecho real de prenda. Cualquiera sea ella, el acreedor carecerá de derecho para conservar en su poder el crédito instrumentado que le fue entregado en garantía, por lo que debe restituirlo al constituyente y, además, notificar al deudor de dicho crédito. Esta notificación es de suma importancia, ya que de no hacerse el deudor no estaría enterado de la extinción de la prenda, y se corre el riesgo de que pague al acreedor indebidamente. En caso de duda, le convendrá consignar judicialmente.

CAPÍTULO XXII
DEFENSAS DE LA POSESIÓN Y DE LA
TENENCIA. ACCIONES POSESORIAS

MNR

SUMARIO: I. La protección posesoria en general. II. Defensas en el Derecho positivo. III. Las vías legales para adquirir la posesión. IV. Naturaleza jurídica de las acciones posesorias. V. Defensa extrajudicial. VI. Acción de despojo. VII. Acción posesoria de mantener. VIII. Procedimiento judicial. IX. Daño temido.

I. La protección posesoria en general

El Código trata en el Título XIII del Libro Cuarto las acciones posesorias y las acciones reales. En el Capítulo 1 se ocupa de las defensas de la posesión y de la tenencia, esto es, de las llamadas acciones posesorias.

La persona que ejerce un señorío sobre una cosa, aun cuando no tenga un derecho sobre ella, tiene el de ser amparado frente a cualquier perturbación o desapoderamiento que provenga de un tercero, sin necesidad de alegar ni de probar que tiene un derecho sobre dicha cosa; es suficiente acreditar la relación de poder que existía sobre ella para lograr el amparo, incluso si dicho tercero es el dueño o tiene algún derecho sobre el objeto.

La protección de la posesión, a primera vista, tiene rasgos extraños y contradictorios, ya que puede ocurrir que el ordenamiento jurídico tutele a quien ha violado sus preceptos (v. gr.: el que se apodera ilícitamente de una cosa) y, en cambio, coloque en una situación de inferioridad a quien no hace más que ejercer su derecho (v. gr.: el propietario que reacciona frente a quien obtuvo una cosa

que le pertenece por la fuerza). Sin embargo, aquí radica el secreto del fenómeno posesorio, cual es proteger situaciones de hecho, con prescindencia del derecho que puedan tener las partes, para favorecer la armonía social, la convivencia, el orden, y evitar la justicia por mano propia.

Se trata de juicios destinados a restaurar la situación posesoria antecedente una vez comprobados tal situación y el desapoderamiento, o a prevenir este último. El litigio versa exclusivamente sobre el hecho posesorio, o en su caso la tenencia.

Se encuentran en este Capítulo 1 dos acciones: hay una acción específica de acuerdo a la lesión sufrida (turbación o desapoderamiento), de modo que hay dos acciones, la de despojo y la de mantener. El poseedor o el tenedor pueden sufrir dos tipos de ataque: desapoderamiento o turbación, y para cada uno de ellos se regulan acciones específicas, cuyo objeto es mantener o recuperar la cosa.

También el Código admite, si se dan ciertas circunstancias, una defensa extrajudicial, que es una excepción a la regla que impide hacer justicia por mano propia.

a) Antecedentes históricos

En el Derecho Romano clásico fue determinante la presencia del pretor, quien hizo utilización de los llamados "interdictos" que se resumían en una orden basada en un acto de *imperium*, destinados a tutelar relaciones no contempladas por el *ius civile*. Si la orden no era acatada, la cuestión se ventilaba ante el juez, quien debía hacer mérito de si existieron las modalidades o circunstancias que tuvo en cuenta el pretor para dictarla.

Al tiempo de la compilación de Justiniano, los interdictos perdieron sus características originales, aunque no la denominación, porque superado el procedimiento formulario, se transformaron en verdaderas acciones posesorias en las cuales era de rigor la aplicación del Derecho vigente.

Hubo dos clases de interdictos posesorios: los organizados para mantener la posesión (*retinendæ possessionis*) y para recuperarla (*recuperandæ possessionis*). Una tercera clase, los destinados a adquirir

la posesión (*adipiscendæ possessionis*), no participa de las características de los anteriores, que presuponen una posesión amenazada o perdida, sino una posesión nunca tenida y que se pretende adquirir. En esta clase se ubicaba, entre otros, el interdicto *quorum bonorum*, cuya finalidad era permitir a los herederos entrar en posesión de la herencia. El interdicto de adquirir se examinará más adelante.

Los interdictos para mantener la posesión, destinados a proteger al poseedor de molestias o turbaciones, también llamados, por dicha razón, conservatorios, eran dos: el *uti possidetis* y el *utrubi*; el primero para las cosas inmuebles y el segundo para los muebles, diferencia que desapareció en el Derecho justinianeo.

Los interdictos para recuperar la posesión también fueron dos: el *unde vi* y el *unde vi armata*. Ambos eran otorgados en el caso de desposesiones violentas, sin o con armas, respectivamente, y sólo para inmuebles, ya que para los muebles el *utrubi* también tenía efectos restitutorios. Ambos se unificaron en el *Corpus Iuris*. Los interdictos tutelaban al poseedor que no hubiese obtenido la posesión por medio de la violencia o clandestinamente (*vi aut clam*). Al demandado se le permitía valerse de la excepción de posesión viciosa.

En la Edad Media surgieron nuevos remedios posesorios: la *exceptio spoli*, la *actio spoli* y el *possessorium summarissimum*.

El *possessorium summarissimum* (siglo XIII) defiende la posesión y la tenencia y tiene efecto conservatorio y restitutorio a la vez. Debía ser resuelto rápidamente, las más de las veces con base en el mero *corpus*.

Del Derecho consuetudinario francés se extrae, a partir del siglo XIV, a la *complainte de saisine et de nouvelleté*, sancionada por la ordenanza de Carlos VII de 1667, tanto para conservar como para obtener la restitución de la posesión anual y no viciosa sobre inmuebles, y la *réintégrande*, de naturaleza policial, remedio restitutorio que se confería a poseedores y tenedores de inmuebles, y se controvierte si también protegía a los poseedores de cosas muebles.

El *Code Civil* no reguló la materia de las acciones posesorias, las que fueron previstas por el Código de Procedimientos sin especificaciones ulteriores. No obstante, la práctica judicial distinguió a las re-

feridas acciones, reconociendo a la *réintégrande* una esfera más amplia de legitimación, al admitir su uso por parte de poseedores no anuales y de tenedores. Esta amplitud fue, finalmente, objeto de reconocimiento legislativo, cuando una ley dictada en 1975 le agregó al Código los artículos 2282 y 2283.

b) *Fundamentos*

El fundamento de la protección posesoria es uno de los temas más discutidos por la doctrina. La doctrina se interroga por qué se protege al poseedor sin pedirle la acreditación de un derecho y aun en contra de quien tenga título. Cabe también preguntarse por qué se protege al despojante cuando es atacado por aquel a quien despojó.

Así, se ha sostenido, en coincidencia con Savigny, que afectar la posesión es comprometer la esfera personal del poseedor (teoría relativa), constituyendo un ataque a la persona. De tal forma, la protección posesoria es una consecuencia de la prohibición de la violencia: la reparación de los daños causados por la violencia exige el mantenimiento o el restablecimiento, según los casos, del estado de hecho alterado.

Por el lado de Ihering, se ha considerado que la defensa de la posesión es un bastión avanzado de la defensa de la propiedad (teoría también relativa). Al ser la posesión la exteriorización de la propiedad, su protección es un complemento necesario de la protección de la propiedad, una facilitación de la prueba en beneficio del propietario, al que le bastará para vencer en el juicio probar el hecho de la posesión.

Por otro lado están las teorías absolutas, que consideran que la posesión es un bien en sí mismo, y que por lo tanto requiere una protección autónoma.

En verdad, las teorías de Savigny y de Ihering no son incompatibles, sino que se complementan: la posesión se protege porque la paz y el orden social exigen que los estados de hecho no sean alterados por propia autoridad de los particulares. Pero al mismo tiempo, en muchos casos, la protección de la posesión se traduce en la protección del derecho; protección que ofrece la ventaja de realizarse a través de un procedimiento sencillo, en el que no es necesario probar el derecho, sino solamente la relación posesoria y la lesión de que ha sido objeto,

Se reitera, entonces, que no cabe fundamentar la defensa de la posesión en alguna de las teorías que se han elaborado, con exclusión y olvido de las demás. Todas ellas concurren, en mayor o en menor grado, a formar un fundamento complejo y plural.

c) *Concepto y finalidad*

Las acciones posesorias son acciones judiciales que procuran, en forma más expeditiva que la de un juicio normal, que quien ostenta una relación de poder pueda poner fin a una turbación, o recuperar el objeto si es despojado. Como se trata de cuestiones de hecho, la prueba no debe versar sobre el derecho de poseer, y la sentencia no hace cosa juzgada de manera definitiva. Se tutela la relación de poder con independencia de la existencia, o no, de un derecho que la sustente.

Las acciones posesorias sirven para lesiones sufridas tanto en cosas inmuebles como muebles. El artículo 2238 se refiere a "el objeto", expresión que abarca ambas clases y que comprende, además, a las universalidades de hecho (arts. 2241/2242).

Puede tener aquí cabida una modalidad especial de las acciones posesorias, que es la obra nueva prevista en el artículo 2241.

d) *Concepto de turbación*

En términos generales, puede decirse que la turbación consiste en la actividad que obstaculiza o torna más gravosa a la posesión, o a la tenencia. A diferencia del despojo, la molestia no priva al poseedor del goce de la cosa, pero turba su ejercicio. Se trata de actos que implican una molestia y que provocan un cambio en la situación de hecho, que hacen que la posesión, o la tenencia, no puedan ser ejercidas en el modo en el que se lo venía haciendo.

Dice el artículo 2238 que las acciones posesorias "...Se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor. Hay turbación cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor".

d.1) *"Actos materiales"*

Los actos a los que se refiere el artículo 2238 son los actos posesorios, esto es, actos materiales (ver art. 1928). No revisten este carácter las palabras, ni los actos jurídicos (v. gr.: iniciación de una demanda); debe tratarse del ejercicio de vías de hecho.

Los ejemplos que suele ofrecer la doctrina de este tipo de actos son: labranza del campo, corte de frutos, abatimiento de un árbol, remoción de un seto, apertura o cierre de un foso, apertura de zanjas para levantar una cerca o valla que habría de incluir en su perímetro la parcela del afectado, el paso con carro repetidas veces, la colocación de un candado en el camino de paso aunque sea fácil su apertura.

Siguiendo esta línea de ideas, por ejemplo, si el oficial de Justicia pretende llevar adelante el lanzamiento de un inmueble ordenado por un juez, si bien realiza actos materiales contra la voluntad del poseedor, no hay turbación —y tampoco despojo— por no tratarse de una actuación de hecho sino de derecho (ejercicio de una función legítima).

d.2) *"Producidos o de inminente producción"*

El Código protege la relación de poder no sólo cuando los actos materiales indebidos se realizaron, sino también cuando es inminente su producción. Se trata de prevenir, y no sólo de otorgar un remedio ante hechos consumados.

d.3) *"Ejecutados con intención de tomar la posesión"*

No basta para que se configure la turbación con que el acto se realice contrariando la voluntad del poseedor; es necesario, además, que el autor tenga la "intención de hacerse poseedor". Esta exigencia armoniza con lo que dispone el último párrafo del artículo 2238, cuando considera que el acto puede no tener esa intención, lo cual sólo habilita un reclamo de daños. En consecuencia, es necesario que el autor de la lesión tenga el propósito de excluir de la posesión a quien la está ejerciendo para convertirse él en poseedor.

Si alguien realiza un pozo, o corta el alambrado con la intención de introducirse en el inmueble del vecino, aunque tal intención no se

conozca, puede ser deducida apreciando los hechos en forma objetiva. En cambio, si alguien destruye el vidrio de la ventana para mortificar al poseedor del inmueble, o por represalia, o por el motivo que fuere, aquí no hay turbación ni desapoderamiento por faltar en el autor del daño la intención de poseer. Ello, claro está, sin perjuicio de la indemnización del daño causado.

De lo que se trata es de determinar si alguien pierde su posesión por la adquisición que realiza otro (para sí o para un tercero) con violencia, o algún otro vicio. A su vez, si los actos no consiguieron ese objetivo, pero el autor de ellos tuvo esa intención, se está ante un caso de turbación, que no es otra cosa que una desposesión frustrada.

d.4) *"Contra la voluntad del poseedor o tenedor"*

Para que haya turbación es necesario que el acto se realice "contra" la voluntad del poseedor (o tenedor). Si éste lo hubiese permitido (v. gr.: autoriza a su vecino a sacar agua, cortar flores, pastoreo del ganado, etc.), no hay turbación. Si el poseedor contrató a una persona para que le construya una pileta de natación, o para que le corte el pasto, no hay turbación. Si hay un contrato y éste no se cumple de acuerdo a lo estipulado, serán procedentes otro tipo de acciones (cumplimiento, daños y perjuicios, resolución, etc.), pero no la acción posesoria.

d.5) *"De los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor"*

Si los actos materiales realizados con intención de poseer y contra la voluntad del sujeto lo privan de su posesión o tenencia (en todo o en parte), hay desapoderamiento. En caso contrario, si como dice el artículo 2238, no resulta una exclusión absoluta (ni siquiera parcial), hay turbación. La "exclusión absoluta", reunidos los demás requisitos, es la línea que separa a la turbación del desapoderamiento.

En consecuencia, es factible afirmar que hay turbación cada vez que se produce una lesión menor al desapoderamiento, entendido éste como privación absoluta de la posesión o de la tenencia.

d.6) *Total o parcial*

La turbación puede ser total o parcial, como se desprende del artículo 2242, que dice que la acción de mantener procede "contra quien lo turba en todo o en parte del objeto".

e) *Concepto de desapoderamiento*

Dice el artículo 1931 que la posesión y la tenencia se pierden, entre otros casos, cuando "otro priva al sujeto de la cosa" (inc. b). El artículo 1921 se refiere a algunos de los medios empleados para que haya desapoderamiento (violencia, clandestinidad o abuso de confianza). En verdad, el concepto de "desapoderamiento" es más amplio, abarcando todos los supuestos en los que se prive al poseedor de su posesión contra su voluntad.

Fuera de ello, no existe diferencia conceptual entre el acto de turbación y el acto de desapoderamiento, diferenciándose sólo por el resultado: si resulta una exclusión absoluta (total o parcial), se estará frente a un supuesto de desapoderamiento total o parcial; si no se da tal exclusión absoluta, se tratará de un caso de turbación.

Así, por ejemplo, si alguien coloca alambres con la intención de hacerse poseedor del inmueble vecino, por el momento hay turbación, pero si en un momento consiguiera impedir al vecino entrar a su inmueble, lo excluye de manera absoluta, se trata de un desapoderamiento.

f) *Variante. Realización de una obra*

Admitido el concepto de turbación y de despojo, cabe señalar que tanto uno como otro género pueden tener una especie, a través de la realización de una obra.

Dice el segundo párrafo del artículo 2241, al tratar la acción de despojo: "Esta acción comprende el desapoderamiento producido por la realización de una obra que se comienza a hacer en el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia".

A su vez, el segundo párrafo del artículo 2242, al referirse a la acción de mantener, señala que "Esta acción comprende la turbación producida por [...] los actos que anuncian la inminente realización de una obra".

Por lo tanto, si la obra ya comenzó en el objeto del poseedor o

tenedor, se considera que hay desapoderamiento. Si aún no comenzó pero es inminente su realización, hay turbación.

f.1) *Obra nueva como despojo*

Se trata de una obra "nueva", ya que el artículo 2241 se refiere a una obra que "se comienza a hacer". La obra nueva viene a ser el medio o el vehículo por el cual se causa una turbación o un desapoderamiento. No es sino una variante de las acciones que previenen y reprimen dichos ataques, pero que requiere una regulación específica, atento al peculiar efecto que produce la sentencia que en el proceso se dicte (remoción de la obra).

En el caso previsto por el artículo 2241 se configura, lisa y llanamente, un despojo (obra que se comienza a hacer en el objeto del poseedor o tenedor). La ubicación de la obra nueva dentro o fuera del objeto determinará que la acción sea juzgada como una acción contra el desapoderamiento o como una de daños, respectivamente.

En efecto, si el vecino realiza una obra que no invade el objeto del poseedor o tenedor, pero causa algún perjuicio, se debe acudir a las acciones tendientes al cese de una actividad dañosa, ya sea preventiva u otra, y al reclamo indemnizatorio del daño, si lo hay. Cuando se invade el terreno ajeno es que tiene interés la acción posesoria.

La obra, además de no estar terminada, tampoco debe estar muy avanzada, pues ése debe ser el sentido de la palabra "comienza" empleada por el Código y para evitar los perjuicios que podría ocasionar la destrucción de una obra con un alto grado de avance.

El concepto de obra nueva debe ser apreciado con criterio amplio, comprensivo de toda clase de obras: construcciones o reconstrucciones de edificios, plantaciones, etcétera. No obstante, debe tratarse de una novedad, sin que se le pueda asignar tal carácter a una mera reparación. Además, puede no tratarse de un inmueble, ya que el artículo 2241 se refiere al "objeto". Así, por ejemplo, podría alguien comenzar una obra en un barco o en un automóvil de un poseedor o tenedor.

Legitimados pasivos pueden ser el autor del despojo y quienes tengan una relación de hecho con el inmueble ajeno en el que se desarrolla la obra.

f.2) *Obra nueva como turbación*

A la vez, el Código protege con la acción posesoria de mantener contra "los actos que anuncian la inminente realización de una obra" (art. 2242, segundo párrafo). Se vio en el comentario anterior que si una obra nueva se hace en el objeto del poseedor o tenedor, éstos pueden iniciar la acción de despojo. Ahora, si la obra ni siquiera comenzó, pero es inminente su realización, la acción es la de mantener. Cabe agregar el supuesto de una obra recién comenzada pero que no invada el objeto del actor; sería un caso de turbación.

g) *Acción de daños y perjuicios*

Finalmente, y en orden a la exigencia en el turbador de la intención de poseer, el artículo 2238, en su última parte, la refuerza al establecer que si el acto no tuviese por objeto hacerse poseedor al que lo ejecuta, la acción será juzgada como indemnización de daño y no como acción posesoria.

Así, por ejemplo, si una persona arroja una piedra y rompe el vidrio de una ventana, con la sola intención de dañar, pero sin ánimo de poseer, puede ser demandado por daños y perjuicios pero no a través de una acción posesoria.

h) *Prescripción*

Según el artículo 2564, inciso b, las acciones posesorias prescriben al año.

i) *Objeto*

Las acciones posesorias están previstas para recuperar o mantener la relación de poder sobre una cosa mueble o inmueble. El Código aclara que puede tratarse de una cosa individualizada o de una universalidad de hecho (arts. 2241, 2242 y 2245).

En el caso de la universalidad de hecho, cabe entender que la acción y la relación de poder recaerán sobre cada una de las cosas que integran el conjunto.

Asimismo, la acción puede tener por objeto toda la cosa, o bien una parte material de ella (art. 2245).

II. *Defensas en el Derecho positivo*a) *El Código Civil y Comercial*

Hay sólo dos acciones, y se indica su naturaleza jurídica (acciones posesorias). Hay una acción de despojo que sirve para los actos de desapoderamiento, y una acción de mantener que es útil cuando hay turbación. En cada una de estas dos únicas acciones puede tener cabida la variante de la obra que se comienza a hacer.

b) *El Código Procesal*

Por razones de orden práctico, se hará aquí un breve repaso de las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Legisla los interdictos en el Libro IV, Título I, y del artículo 606 surge que "Los interdictos sólo podrán intentarse: 1) para adquirir la posesión o la tenencia; 2) para retener la posesión o la tenencia; 3) para recobrar la posesión o la tenencia; 4) para impedir una obra nueva". El interdicto de adquirir aparece legislado en los artículos 607 a 609; el interdicto de retener, en los artículos 610 a 613; el interdicto de recobrar, desde el artículo 614 hasta el 618, y el interdicto de obra nueva, en los artículos 619 y 620. El artículo 621 trata de la caducidad y el 622 de la acción real posterior. El artículo 623 se refiere al trámite de las acciones posesorias y a las relaciones de éstas con los interdictos. El artículo 623 bis es la regulación procesal de la denuncia de daño temido (que el actual Código no menciona) y el 623 ter de la llamada "oposición a la ejecución de reparaciones urgentes".

c) *El Código Penal*

En el Título VI del Libro Segundo describe figuras coincidentes con las conductas que dan lugar al uso en sede civil de los remedios posesorios que se están analizando, bajo la denominación *Delitos contra la propiedad*.

III. Las vías legales para adquirir la posesión

a) *El artículo 2239*

Dice el artículo 2239 del Código que "Un título válido no da la posesión o tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión o a la tenencia no puede tomarla; debe demandarla por las vías legales". Esta norma consagra el principio que veda hacer justicia por mano propia.

a.1) *Prohibición de la justicia por mano propia*

Esta norma tiene su fuente en el artículo 2468 del anterior Código, el que a su vez se basó en el Código de Austria, proscribiendo las vías de hecho y el accionar de propia autoridad, salvo en el caso excepcional en que está autorizada la defensa privada (art. 2240), debiéndose cumplir en éste los requisitos estrictos que se mencionan al efecto de esta posibilidad.

El ordenamiento jurídico repudia las vías de hecho, tanto para el mantenimiento del estado de hecho actual, como para su restablecimiento.

Esta norma se refiere a la persona que tiene derecho a la posesión, o a la tenencia, pero que todavía no la consiguió. No puede hacer justicia por mano propia y debe acudir a las vías legales. Asimismo, quienes ya son poseedores o tenedores, y son turbados o despojados, tampoco pueden hacer justicia por mano propia y, para conservar o recuperar la cosa, igualmente deben recurrir a las vías legales.

a.2) *Derecho a la posesión, derecho de poseer y derechos derivados de la posesión*

Cuando el artículo 2239 alude a quien tiene "derecho a requerir el poder sobre la cosa" se refiere a la persona que cuenta con un título, pero que aún no adquirió la posesión por faltarle el modo; aún no hubo entrega de la cosa, a pesar de que, como puede inferirse de la existencia de un título, alguien se obligó a ello. En tal caso, el sujeto no puede ser reputado poseedor: tiene derecho a la posesión,

un derecho personal, de crédito, a que la cosa le sea entregada por el obligado. Si la entrega no se produce voluntariamente, el adquirente deberá iniciar un juicio ("vías legales") para que se concrete la prometida entrega. La primera de las vías legales a que puede recurrir el adquirente que se halla en esta condición es la que se deriva del contrato o acto jurídico que constituye el título válido al que alude la norma, ya se trate de compraventa, permuta, donación, etcétera. En síntesis, deberá ejercer la acción que tiende al cumplimiento del contrato respectivo.

Una vez que la persona obtiene la posesión (modo), si además cuenta con un título suficiente, adquiere el derecho real, en cuyo caso tiene "derecho de poseer" (*ius possidendi*), denominación que le cabe a los poseedores legítimos (ver art. 1916). Claro que la persona pudo haber sido despojada, en cuyo caso debe recurrir a las acciones pertinentes para que la situación fáctica venga a coincidir con la jurídica.

Otra posibilidad que puede presentarse es la de aquellos que son poseedores, pero sin derecho a serlo, por faltarles el correspondiente título. Estas personas cuentan con los denominados derechos derivados de la posesión (*ius possessionis*), pero carecen del derecho a ser poseedores. Se trata de poseedores ilegítimos. El *ius possessionis* confiere el derecho a seguir poseyendo, mientras el poseedor no sea vencido por otro en un juicio. De ahí que la protección posesoria sea provisional, transitoria, ya que cede cuando el que tiene derecho a poseer, o derecho de poseer (*ius possidendi*), ejerza su derecho en la forma correspondiente.

a.3) *El título válido*

Cuando se refiere a un "título válido" se quiere significar un acto jurídico del cual se deriva un derecho a la posesión. La palabra "título" está empleada en el sentido de causa fuente del derecho real; no se refiere al instrumento. No es necesario que se trate del título suficiente, ya que basta con cualquier acto jurídico que tenga la aptitud de transmitir la posesión.

b) *El interdicto de adquirir*

Resta analizar si a las vías legales mencionadas se puede agregar el interdicto de adquirir legislado en los artículos 607 a 609 del Código Procesal.

Dice el artículo 607 del Código Procesal: "Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá: 1) que quien lo intente presente título suficiente para adquirir la posesión o la tenencia con arreglo a derecho; 2) que nadie tenga título de dueño o usufructuario de la cosa que constituye el objeto del interdicto; 3) que nadie sea poseedor o tenedor de la misma cosa". El artículo 608 establece las distintas alternativas de procedimiento que pueden suscitarse, y el 609 los recaudos para la procedencia de la anotación de litis como medida cautelar.

Se ha sostenido la inutilidad de este interdicto, principalmente por lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 607, en cuanto a la exigencia de que nadie tenga título de dueño o usufructuario de la cosa de que se trata.

Los inmuebles nunca carecerán de dueño, ya que si no pertenecen a los particulares, integrarán el dominio privado del Estado (art. 236, inc. a, del Código Civil y Comercial). Tratándose de cosas muebles en la misma situación jurídica, su posesión se adquiere por medio de un contacto con la cosa (art. 1922, inc. b), que constituye la materialidad de la apropiación, modo de adquirir su dominio (art. 1947, inc. a.i). En el caso de las cosas muebles sin dueño, entonces, resulta inoperante recurrir al remedio judicial.

Finalmente, respecto del adquirente que no entró en posesión de la cosa adquirida, permaneciendo ésta en poder del enajenante, cabe afirmar, sin duda alguna, que este último conserva el carácter de dueño y, por lo tanto, de poseedor legítimo. Ello obsta a la procedencia del interdicto en estudio, y sólo cabe al primero nombrado la acción derivada del contrato que le confirió derecho a la posesión de la cosa, pero no la posesión misma.

IV. Naturaleza jurídica de las acciones posesorias

No son acciones personales, ya que no tienen un deudor determinado y gozan de cierto efecto reipersecutorio.

Por diversos motivos, tampoco parece apropiado asimilar las acciones posesorias a las reales. No tienen efecto *erga omnes*, y no tienen por objeto, en principio, hacer valer un derecho real; más aún, pueden dirigirse con éxito frente al titular de un derecho real. Además, protegen al tenedor, quien por hipótesis es ajeno a la titularidad de un derecho real. De tal modo, bien puede sostenerse que no son ni reales ni personales, sino que constituyen una categoría autónoma de acciones, caracterizadas por una *causa petendi* propia y un régimen específico.

V. Defensa extrajudicial

Se expuso anteriormente que está vedada la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Quien pretenda que tiene derecho a la entrega, o a recobrar, o a mantener una relación de poder, debe inexorablemente acudir a las vías legales, a la justicia.

No obstante, como toda regla, reconoce una excepción. Dispone el artículo 2240 que "Nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. Esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de la posesión".

a) *Legitimación activa*

Pueden intentar esta defensa, cuando concurren los requisitos, los poseedores de cualquier clase (legítimos o no, viciosos o no), los tenedores, e incluso los que guardan con la cosa un vínculo de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad (servidores de la posesión).

b) *Legitimación pasiva*

El requisito de la inmediatez ("sin intervalo de tiempo") excluye los casos de desapoderamiento clandestino —también los casos de abuso

de confianza están excluidos—, aplicándose exclusivamente esta defensa a los supuestos de ataques violentos. Este remedio sólo puede emplearse frente al atacante o autor de la agresión, quedando excluidos los terceros, ya que la respuesta —como se verá— debe ser inmediata.

Además, el artículo 2240 dice “empleo de una fuerza suficiente”, “esta protección contra toda violencia”, lo que respalda la conclusión de que el ataque debe ser hecho por medio de la violencia.

Debe tratarse, aunque la norma no lo dice, de una agresión ilegítima. Los ataques legalmente justificados (v. gr.: orden de lanzamiento dispuesta por un juez) impiden el uso de esta defensa extrajudicial. El artículo comprende a la intimidación o violencia moral.

c) *Tipo de ataque*

El artículo 2240 indica que esta defensa sirve tanto para “mantener o recuperar”, “protegerse”. En consecuencia, la víctima puede resistirse tanto a la turbación como al desapoderamiento.

d) *Casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde*

Entre los requisitos para ejercerla, se exige que no llegue a tiempo la autoridad pública competente para prevenir y reprimir tales hechos. Esta exigencia no se encuentra en el artículo 34, inciso 6°, del Código Penal.

e) *No debe mediar intervalo de tiempo entre el ataque y la defensa*

Debe existir unidad de tiempo y de acción entre el ataque y la defensa; si el poseedor deja transcurrir algún tiempo, por breve que sea, sin ejercer su derecho de repeler la fuerza con la fuerza, más tarde ya no podrá ejercerlo y sólo le quedará el recurso de las acciones posesorias.

Por ende, si una persona es despojada por la fuerza de una cosa, puede intentar impedirlo en forma inmediata. Si el hecho se consumó, no puede horas o días después intentar la restitución de propia autoridad, sino que debe recurrir a las vías legales (art. 2239). La respuesta debe ser inmediata, sin intervalo, esto es, mientras se desarrolla o dura la ofensa.

f) *No se deben exceder los límites de la propia defensa*

Debe haber proporcionalidad entre los medios empleados para el ataque y los empleados para la defensa. Es una cuestión de hecho que quedará reservada al arbitrio prudente del juez, quien deberá hacer mérito también de lo dispuesto en el artículo 34, inciso 6°, apartado b, del Código Penal, que habla de la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Si la persona se excede en la legítima defensa puede incurrir en delito penal.

g) *Inexistencia de responsabilidad*

De conformidad con el artículo 1717, todo hecho u omisión que cause un daño es antijurídico. La excepción a este principio está constituida —como el mismo artículo lo señala— por las causas de justificación, que son circunstancias en las cuales el ordenamiento jurídico otorga un permiso para dañar. En tales casos, el hecho u omisión dañosos son lícitos, y no antijurídicos, sin perjuicio de que en algún caso —como sucede en el estado de necesidad— pueda de todos modos ser procedente el pago de una indemnización (responsabilidad por acto lícito).

El artículo 1718, en el inciso b, se refiere a la legítima defensa.

h) *Incumplimiento de los requisitos*

Si la víctima del ataque recupera o mantiene su relación de poder con la cosa sin cumplir con los requisitos impuestos por el artículo 2240, habrá infringido el principio general que veda hacer justicia por mano propia, de modo que se hallará expuesta a las acciones posesorias (e incluso de daños y perjuicios) del agredido, sin que importe el derecho que pueda asistirle a cada uno de los involucrados. También el agresor puede incurrir en un delito reprimido por las leyes penales.

Además, si el usurpado ataca o turba al usurpador, éste podrá ejercer la defensa privada en su condición de agredido.

VI. Acción de despojo

Cuando se produjo el desapoderamiento, tanto el poseedor como

el tenedor cuentan con la acción posesoria de despojo para recuperar el objeto en cuestión. Dice el artículo 2241, primer párrafo, que "Corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso, contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapoderamiento. La acción puede ejercerse aun contra el dueño del bien si toma la cosa de propia autoridad".

Dice esta norma que la acción es viable "cuando de los actos resulte el desapoderamiento", lo que parece excluir a los actos de "inminente producción", previstos en el artículo 2238, pero lo cierto es que éstos encuentran cabida en la acción de mantener (art. 2242). Hay que recordar que el desapoderamiento requiere la "exclusión absoluta", la que no existe cuando sólo hay una amenaza o fuerte probabilidad de que se concrete.

a) *Legitimación activa*

La acción puede ser intentada por todo tenedor o poseedor, aun vicioso. Agrega el artículo 2245 que "Corresponden las acciones posesorias a los poseedores de cosas, universalidades de hecho o partes materiales de una cosa".

El tenedor puede intentar la acción de despojo, no sólo contra terceros, sino incluso contra el poseedor para el cual tiene la cosa. Si puede demandar, como dice la norma, al "dueño del bien", es claro que puede hacerlo contra el mero poseedor que no sea dueño o titular de un derecho real. Del mismo modo, el poseedor puede demandar a quien posee a nombre suyo (tenedor) cuando éste intervirtió el título y lo despojó por abuso de confianza.

La acción de despojo se confiere a todo poseedor (art. 2241), a los coposeedores (art. 2245) y al tenedor o cotenedor. En cambio, están excluidos quienes están vinculados con la cosa en virtud de una *relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad*, los cuales no son ni poseedores ni tenedores, y para el caso en que esa relación sea violada o atacada, sólo pueden tutelarla por la defensa extrajudicial del artículo 2240.

a.1) *Coposesión*

Dispone el artículo 2245 que "...Cualquiera de los coposeedores puede ejercer las acciones posesorias contra terceros sin el concurso de los otros, y también contra éstos, si lo excluyen o turban en el ejercicio de la posesión común. No proceden estas acciones cuando la cuestión entre coposeedores sólo se refiere a la extensión mayor o menor de cada parte..."

a.1.1) *Demanda contra un tercero*

En la hipótesis de que el autor del ataque sea un tercero (un extraño a la relación de coposesión), es claro que los coposeedores pueden demandarlo. Lo que prevé el artículo 2245 es que uno solo de ellos también puede hacerlo "sin el concurso de los otros". En tal caso, si hubo desapoderamiento, la acción tendrá por objeto recuperar toda la cosa, y no una parte de ella, salvo que el propio interesado limite su pretensión a una parte material de la cosa.

a.1.2) *Demanda contra otro coposeedor*

Agrega el artículo 2245 que las acciones pueden ser también intentadas "contra éstos, si lo excluyen o turban en el ejercicio de la posesión común".

Puede suceder que uno de los coposeedores (o cotenedores) haya alterado y violado sin el consentimiento, y en perjuicio de los otros participantes, el estado de hecho o el destino de la cosa objeto de la posesión común, en forma tal de impedir o restringir el goce que le corresponde a cada uno de los otros. En tal caso, el Código autoriza a cada uno de los perjudicados a demandar al autor de la lesión, para volver todo a su estado anterior, cualquiera sea la lesión causada (turbación o desapoderamiento).

Aclara el artículo 2245 que no proceden las acciones posesorias "cuando la cuestión entre coposeedores sólo se refiere a la extensión mayor o menor de cada parte". Ocurre que este tipo de conflictos exceden el ámbito posesorio.

a.2) *Tenedor*

Si el tenedor es excluido de la tenencia de todo o parte de la cosa, se encuentra legitimado para iniciar la acción posesoria que corresponda.

Aquí, el artículo 2245 agrega que "Los tenedores pueden ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor y pedir que éste sea reintegrado en la posesión, y si no quiere recibir la cosa, quedan facultados para tomarla directamente". Se refiere a un supuesto en el que la situación afecta a ambos, tanto al tenedor como al poseedor, lo que ocurre especialmente cuando hay desapoderamiento.

El tenedor puede pedir que el poseedor "sea reintegrado", aunque este último no haya promovido la demanda. Ahora, si el poseedor "no quiere recibir la cosa", aquél puede tomarla directamente. Su tenencia continuará.

b) *Legitimación pasiva*

En cuanto a la legitimación pasiva, el artículo 2241 dice que la acción se tiene "contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe", "aun contra el dueño del bien".

Por ende, la acción se puede dirigir contra el o los autores del desapoderamiento —si es que tienen la cosa— y sus sucesores universales. Si son varios los autores del despojo, pero la cosa la tiene sólo uno de ellos, la acción puede dirigirse contra él sin necesidad de que se demande a los otros. Para los herederos es indiferente la buena o mala fe, ya que ellos continúan a la persona del causante. Asimismo, se puede intentar la acción contra los sucesores particulares de mala fe, es decir, los que sabían o debieron saber del despojo. En caso de haber varios sucesores, la acción puede entablarse contra el que tenga la cosa en ese momento, ya que no se limita al sucesor del despojante y puede abarcar a sucesores del sucesor. Cabe hacer la salvedad de que si en la cadena aparece un sucesor de buena fe, allí se corta la persecución, la que no renace si la cosa pasa a manos de un sucesor de mala fe. Ello, claro está, sin perjuicio de la acción de daños correspondiente.

MNR

La acción de despojo tiene efectos persecutorios limitados, deteniéndose ante el sucesor particular de buena fe, sin importar el título gratuito u oneroso de la adquisición.

Aclara el artículo 2241 que la acción puede dirigirse, incluso, contra el dueño del bien, "si toma la cosa de propia autoridad". Así, por ejemplo, cuando vence un contrato de locación, el locatario está obligado a restituir la cosa. Si no lo hace, el dueño debe recurrir a las vías legales pertinentes, no puede hacer justicia por mano propia. Si lo hace y expulsa al locatario, este último podría entonces iniciar la acción posesoria para recuperar el objeto. Luego, el dueño deberá acudir a la justicia para hacer valer sus derechos.

c) *Sentencia*

Dice la última parte del artículo 2241 que "La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar la restitución de la cosa o de la universalidad, o la remoción de la obra que se comienza a hacer; tiene efecto de cosa juzgada material en todo cuanto se refiere a la posesión o a la tenencia".

El efecto principal de la condena será, si se hace lugar a la demanda, la "restitución" del objeto, o la "remoción" de la obra que recién se inició. El condenado a la restitución será quien tenga la cosa en su poder —obviamente si fue demandado—, ya que la acción se puede proyectar hacia los sucesores del despojante. En cuanto a los accesorios del inmueble, resulta de aplicación el artículo 1935.

El juez, aunque la norma no lo dice, puede agregar la indemnización del daño causado. De no ser así, habría que iniciar una nueva acción, con el dispendio jurisdiccional que ello implica.

Tampoco lo dice la norma, pero por aplicación de las reglas generales se entiende que existe la posibilidad de una prohibición de innovar (en rigor, medida innovativa) en esta acción, especialmente cuando se trate de una obra que recién comienza, lo cual también surge del Código Procesal, que al final del artículo 619 dice que "El juez podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra".

La sentencia hace cosa juzgada material en este ámbito, esto es en lo que concierne a la posesión o a la tenencia. Ocurre que poste-

riormente sólo puede promoverse la acción real (art. 2273), en el caso de que el vencido se encuentre en condiciones de hacerlo, ámbito en el que podrá discutirse el derecho de poseer. No hay cosa juzgada respecto de hechos posteriores, distintos al que fue tenido en cuenta por el fallo (art. 2276).

d) *Interdicto de recobrar*

Además de la acción posesoria y de la acción reivindicatoria, se completa el cuadro de acciones para recuperar la cosa con este remedio del Código Procesal contra la desposesión. Está legislado en el Libro IV, Título I, Capítulo IV (arts. 614 a 618) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La finalidad de este interdicto es que el poseedor o el tenedor despojados total o parcialmente de una cosa mueble o inmueble, puedan reclamar judicialmente la restitución de esa posesión o tenencia.

Este interdicto caduca al año de producido el despojo (art. 621, CPCCN).

VII. Acción posesoria de mantener

Frente a los actos de turbación existe esta acción para los poseedores, aun viciosos, y para los tenedores. Puede ser empleada en los casos de turbación. Su objeto es retener o conservar la posesión o la tenencia que han sido turbadas.

Si el que realiza la lesión está autorizado por el ordenamiento jurídico para llevarla a cabo, no existe perturbación a los efectos de ejercer esta acción, como ocurre con la notificación de una demanda, un allanamiento, el uso de la fuerza pública, inspecciones dispuestas por la Administración, y con los actos realizados por los particulares en estado de necesidad o en legítima defensa.

a) *Legitimación activa*

Establece el artículo 2242 que "Corresponde la acción de mantener la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso..."

Está claro que se otorga a toda clase de poseedores, sin distinción alguna. Respecto de los tenedores, el artículo tampoco contiene excepciones.

En el caso de haber coposesión, se aplican las mismas reglas expuestas para la acción posesoria de despojo.

b) *Legitimación pasiva*

Al tratarse de una turbación es inconcebible la existencia de sucesores particulares. Por lo tanto, la acción sólo procede contra el autor de la turbación, sus copartícipes y, eventualmente, contra sus herederos, si es que éstos continúan con los actos iniciados por el causante.

Por tal motivo dice el artículo 2242 que la acción procede "contra quien lo turba en todo o en parte del objeto".

c) *Requisitos*

Como ya se dijo, esta acción procede contra actos de turbación, que en un sentido amplio implica cualquier molestia que no llegue a ser un desapoderamiento (v. gr.: el vecino se atribuye una servidumbre que no tiene).

Agrega el artículo 2242 que esta acción protege contra "la amenaza fundada de sufrir un desapoderamiento", de modo que la amenaza habilita a demandar sin necesidad de esperar que el hecho se concrete. Ocurre que la norma tiene una finalidad preventiva. Si el desapoderamiento deja de ser una amenaza y se concreta, hay que acudir a la acción posesoria de despojo.

A la vez, protege contra "los actos que anuncian la inminente realización de una obra". Se vio anteriormente que si una obra nueva se hace en el objeto del poseedor o tenedor, éstos pueden iniciar la acción de despojo. Ahora, si la obra ni siquiera comenzó, pero es inminente su realización, la acción es la de mantener.

d) *Sentencia*

La prueba debe versar sobre el hecho de la posesión o la tenencia invocado por el actor (o los actores), y sobre la verdad o falsedad de

los actos de turbación. La sentencia puede desestimar la acción o condenar al demandado a cesar en sus amenazas o perturbaciones. En la segunda hipótesis el juez debe ordenar al demandado que desista de seguir realizando las molestias, de modo que la situación vuelva al estado de hecho anterior (*statu quo ante*).

Igual que en la acción de despojo, la sentencia hace cosa juzgada material en este ámbito.

e) Prescripción

Esta acción prescribe en el plazo de un año (art. 2564).

f) Interdicto de mantener

Está legislado en los artículos 610 a 613 del Código Procesal. Se suma a la acción prevista por el Código Civil y Comercial para la turbación.

Para la procedencia de este interdicto se requieren las siguientes condiciones: 1) Que quien lo intente se halle en la actual posesión o tenencia de una cosa, mueble o inmueble. 2) Que alguien amenazare perturbarle o lo perturbase en ellas mediante actos materiales (art. 610).

Este interdicto caduca al año de producido el despojo (art. 621).

g) Interdicto de obra nueva

Dice el artículo 619 del Código Procesal que "Cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva. Será inadmisile si aquélla estuviere concluida o próxima a su terminación. La acción se dirigirá contra el dueño de la obra y, si fuere desconocido, contra el director o encargado de ella. Tramitará por el juicio sumarísimo. El juez podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra".

El Código Civil y Comercial también alude en el artículo 2241 a "una obra que se comienza a hacer". El Código Procesal es más permisivo en esta cuestión, pues veda el interdicto cuando la obra "estuviere concluida o próxima a su terminación". Sin embargo, la jurisprudencia es más estricta, y se ha resuelto que el interdicto de obra

nueva constituye el remedio adecuado para proteger la posesión y la tenencia perturbadas por un acto específico, esto es, la obra que se ha comenzado a realizar. Su finalidad inmediata es obtener la suspensión de los trabajos que producen una turbación en la posesión o tenencia. La celeridad en el trámite se justifica porque, si la obra continúa y cuando se inicia el interdicto ya está concluida o próxima a su terminación, la demanda será inadmisile.

El interdicto de obra nueva, al igual que los otros interdictos, tramita por juicio sumarísimo (art. 619).

VIII. Procedimiento judicial

a) Trámite

La regla la sienta el artículo 2246: "Las acciones posesorias tramitan por el proceso de conocimiento más abreviado que establecen las leyes procesales o el que determina el juez, atendiendo a las circunstancias del caso".

Esta norma no establece un trámite para las acciones posesorias, sino que remite a lo que dispongan los códigos procesales locales. Lo que hace es establecer una pauta o regla: debe ser el proceso de conocimiento más abreviado que prevea cada ley local, generalmente el juicio sumarísimo, o el trámite previsto para los incidentes.

La regla no es absoluta, ya que el juez podría apartarse de ella en función de las circunstancias del caso. Así, por ejemplo, podría ser que un caso fuera más complejo que otros, y que el juez para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso decidiera que tramite por juicio ordinario. No será lo usual, pero queda abierta la posibilidad si fuese necesario.

b) Prueba

En el ámbito del juicio posesorio, a diferencia de lo que ocurre con las acciones reales, la prueba versa especialmente sobre hechos, ya que es indiferente la prueba de quien tiene derecho o mejor derecho sobre la cosa. Aquí se trata de evitar la justicia por mano propia y de restablecer la situación a su estado anterior.

El actor debe probar su posesión o tenencia, así como el despojo o la turbación producida, lo que puede incluir la variante de obra que recién comienza.

En primer lugar, hay una regla según la cual la carga de la prueba pesa sobre el actor, lo cual armoniza con las disposiciones generales del Código Procesal y con las propias del ámbito posesorio, donde el demandado posee o tiene la cosa, sin tener nada que probar (art. 1917).

En segundo lugar, debe probar el actor su posesión o tenencia, y el desapoderamiento o la turbación. En cuanto a la fecha en la que el demandado cometió el ataque, teniendo en cuenta que la prescripción no puede ser invocada de oficio y que debe ser opuesta por el demandado, a este último le incumbirá la prueba del tiempo de la lesión, si cuestiona la invocada por el demandante.

En tercer lugar, en este ámbito es inútil la prueba del derecho real, sin perjuicio de que se valoren los títulos a otros efectos (ver arts. 2269 y 2270).

b.1) *Caso de duda*

Dispone el artículo 2243 que "Si es dudoso quién ejerce la relación de poder al tiempo de la lesión, se considera que la tiene quien acredita estar en contacto con la cosa en la fecha más próxima a la lesión. Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor o tenedor el que prueba una relación de poder más antigua". Esta norma se refiere a la prueba en el ámbito posesorio, que es diferente a la del juicio petitorio.

Puede ocurrir que la situación sea dudosa, que no se acredite claramente quién ejercía la relación de poder en el momento de la lesión. Esto puede ocurrir en el supuesto en el que dos personas posean la cosa al mismo tiempo, tratando cada una de ellas de excluir a la otra (v. gr.: dos personas llevan a pastar los animales al mismo campo y permanece en él quien llega primero). Fuera de los casos de coposesión, el Código no admite que dos posesiones concurren al mismo tiempo sobre una misma cosa (art. 1913), lo que impone determinar quién fue el último poseedor. Pero puede suceder que tal prueba no sea posible, en cuyo caso cabe entender que se rechazará la demanda.

Podría plantearse el caso de dos personas que compren la misma cosa, pero no hay que soslayar que la solución de este conflicto pasa también por establecer su buena fe.

La solución legal pasa por acreditar, primero, la relación de poder al momento de la lesión (no la actual) y, en su defecto, la más antigua, prevaleciendo en el litigio quien lo logre. En caso de no ser esto posible por ninguna de las partes, o bien que se pruebe que las dos datan de la misma fecha, el juez debe resolver a favor del demandado, ya que no es factible decidir la cuestión en favor de quien pruebe tener derecho de poseer.

c) *Conversión*

Establece el artículo 2244 que "Si durante el curso del proceso se produce una lesión mayor que la que determina la promoción de la acción, el afectado puede solicitar su conversión en la que corresponde a la lesión mayor, sin que se retrotraiga el procedimiento, excepto violación del derecho de defensa en juicio". Este artículo, con el fin de lograr eficiencia y para evitar el dispendio de la actividad jurisdiccional, permite que la acción de mantener se convierta en la de despojo, si se dan las circunstancias.

Esta última situación recibió adecuada respuesta en el artículo 617 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: "Si durante el curso del interdicto de retener se produjere el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin retrotraer el procedimiento, en cuanto fuese posible..."

d) *Efectos de la sentencia*

Si se trata de una turbación y la sentencia hace lugar a la demanda, debe ordenar el cese de la turbación y adoptar las medidas pertinentes para impedir que vuelva a producirse (art. 2242).

Si se inicia contra un acto de desapoderamiento y la sentencia hace lugar a la demanda, debe ordenar la restitución de la cosa o de la universalidad, o la remoción de la obra que se comienza a hacer (art. 2241).

Tanto en uno como en otro caso, la sentencia tiene efecto de cosa

juzgada material en todo cuanto se refiere a la posesión o a la tenencia. La cosa juzgada, por ende, se limita a los hechos juzgados. En cambio, no tiene ese efecto en lo que respecta a los derechos que puedan tener las partes, pues ello excede el ámbito posesorio. Si posteriormente se inicia una acción real, es allí donde se debatirán las cuestiones de derecho, y la sentencia hará cosa juzgada en forma definitiva.

De allí que si intenta primero la acción real, pierde el derecho a promover la acción posesoria; pero si interpone la acción posesoria puede iniciar después la real (art. 2273). Es que la cosa juzgada en la acción posesoria está limitada a lo que se vincula con la relación de poder.

IX. Daño temido

En el Código derogado, por obra de la reforma de la ley 17.711 (1968), el segundo párrafo del artículo 2499 preveía la llamada acción de daño temido. Decía que "Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares".

No incluye el Código actual a la acción de daño temido del anterior artículo 2499. Esto se explica por dos motivos: a) la alusión a los actos de inminente producción; b) el artículo 1711 regula la acción preventiva.

No obstante, la denuncia de daño temido está prevista por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el artículo 623 bis.

CAPÍTULO XXXIII ACCIONES REALES **MNR**

SUMARIO: A) Disposiciones generales. I. Concepto. II. Enumeración. III. Finalidad de las acciones reales. Ámbito. Lesión que las habilita. IV. Demanda y sentencia. V. Daño. VI. Legitimación activa. B) Acción reivindicatoria. I. Objeto. II. Legitimación pasiva. III. Prueba en el juicio de reivindicación. IV. Prueba cuando se reivindican inmuebles. V. Prueba en la reivindicación de muebles registrables. VI. Prueba en la reivindicación de muebles no registrables. VII. Derecho a reembolso. VIII. Límites de la acción reivindicatoria respecto de cosas muebles no registrables. IX. Límites en materia de cosas registrables. X. Medidas cautelares. XI. Sentencia. C) Acción negatoria. I. Concepto. II. Legitimación pasiva. III. Objeto. IV. Prueba. D) Acción confesoria. I. Concepto. II. Legitimación pasiva. III. Prueba. E) Acción de deslinde. I. Concepto. Naturaleza jurídica. II. Legitimación activa y pasiva. III. Prueba y sentencia. F) Relaciones entre el petitorio y el posesorio. I. Prohibición de acumular. II. Separación entre el posesorio y el petitorio. Independencia de las acciones. III. Prueba. IV. Suspensión de la acción real. V. Cumplimiento previo de condenas. VI. Acciones por un mismo hecho. VII. Acciones por distintos hechos. VIII. Turbaciones o desapoderamientos recíprocos. IX. Hechos posteriores.

A) DISPOSICIONES GENERALES

I. Concepto

Dice el artículo 2247 que "Las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio".

Como se puede apreciar, las acciones reales tienen por objeto la protección de los derechos reales. Cada uno de ellos está provisto de la consiguiente acción real (o de más de una según el ataque), la que lleva ínsita el *ius preferendi* y el *ius persequendi*, aunque con las excepciones y limitaciones impuestas por el ordenamiento legal.

Teniendo en cuenta que el derecho real inviste a su titular de una potestad sobre la cosa que es su objeto, que le permite tenerla, usarla, gozarla y disponer de ella material o jurídicamente, sin intervención de otra persona, el ordenamiento jurídico se ve precisado a dotar a todo titular de las acciones correspondientes para hacer efectivo el ejercicio de su derecho cuando éste es impedido o menoscabado por acción u omisión de otro sujeto. La oponibilidad frente a todo aquel que pretenda desconocer la potestad del titular, carácter esencial del derecho real, constituye el principal fundamento de las acciones reales.

En consecuencia, la oponibilidad *erga omnes* de los derechos reales así como la facultad de persecución que conceden a su titular determinan la existencia de acciones, también de carácter real, cuya finalidad consiste en tutelarlos cuando han sido desconocidos por otro sujeto o de alguna forma se ha menoscabado la potestad que confieren sobre la cosa que es su objeto. Las acciones reales son el medio judicial defensivo de los derechos reales.

La división entre acciones reales (*in rem*) y acciones personales (*in personam*) resalta en las fuentes romanas, que la indican como la división fundamental (*summa divisio*) de las acciones. El significado de esta distinción se vincula estrechamente con la noción que la doctrina moderna elaboró en torno a la distinción entre los derechos reales y los personales. Así como los derechos personales están resguardados por acciones de índole personal, que surgen del contrato o de las otras fuentes de las obligaciones, los derechos reales, como contrapartida, gozan de la tutela de las acciones reales. Las acciones reales se diferencian de las acciones de restitución fundadas sobre una obligación a cargo del demandado, que son personales, porque el actor hace valer un derecho de crédito. Como los derechos personales son relativos, la acción personal sólo puede ser entablada contra quien está obligado al cumplimiento de la prestación; en cambio, al ser los derechos reales absolutos en el sentido de oponibles *erga omnes*, la acción real puede ser deducida contra quien los viole o posea la cosa. Las acciones reales tienen como fundamento de la demanda (*causa petendi*) la lesión de un derecho real, con prescindencia del dolo, de la culpa y de la capacidad del autor del hecho objetivamente antijurídico.

Las acciones reales se distinguen de las acciones posesorias, ya

que éstas apuntan a la conservación o restitución de la posesión o de la tenencia con independencia de quién sea el titular del derecho real, y no precisan otra prueba —en principio— que la de haber poseído o tenido la cosa. También se distinguen de las acciones personales que persiguen la restitución, fundadas en una obligación, ya que el actor hace valer un derecho de crédito, mientras que en la reivindicación se hace valer un derecho real.

La acción reivindicatoria defiende la existencia del derecho real; la negatoria, la libertad, y la confesoria, la plenitud.

Éstos son los efectos principales de cada acción, pero además, por aplicación de los principios generales, se puede reclamar como efecto accesorio la indemnización del daño producido. En algunos casos, la reparación puede ser la única consecuencia (efecto subsidiario), cuando no es posible recuperar el objeto.

a) Método del Código

El Libro Cuarto termina con el tratamiento de las acciones reales. Es un acierto, teniendo en cuenta que en el Código derogado las acciones reales se trataban luego del dominio y del condominio, lo que había sido criticado por la doctrina, ya que dichas acciones protegen a todos los derechos reales, por lo que deben estar al principio o al final, pero no después de algunos derechos y antes que otros.

b) Imprescriptibilidad

Establece el Código que "Las acciones reales son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de prescripción adquisitiva" (art. 2247).

Las acciones reales son imprescriptibles. Ello, claro está, sin perjuicio de la usucapión que pueda invocar el demandado que poseyó durante el tiempo exigido por la ley, y que puede hacer valer por vía de acción o de excepción (art. 2551). Las acciones reales no son pasibles de "prescripción liberatoria".

La imprescriptibilidad de las acciones reales no impide la prescripción liberatoria del reclamo de daños que se formule en forma complementaria o subsidiaria.

II. Enumeración

a) *Enumeradas en el capítulo dedicado a las acciones reales*

Las acciones reales legisladas en este capítulo son la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de deslinde (art. 2247).

b) *¿Otras acciones reales?*

El artículo 2247 dice que las acciones reales que enumera son las legisladas en este capítulo, por lo que puede inferirse que puede haber otras de esta naturaleza. Se puede considerar a la acción de división del condominio de naturaleza real.

Además de las acciones tendientes a obtener la división de las cosas comunes, existen otras dos a las cuales se puede atribuir carácter real, a pesar de no estar enumeradas en el artículo 2247: la acción hipotecaria y la de petición de herencia.

Para ciertos autores, la acción de usucapión también reviste naturaleza real.

III. Finalidad de las acciones reales.

Ámbito. Lesión que las habilita

Este tema es esclarecido por el artículo 2248: "La acción reivindicatoria tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que producen el desapoderamiento.

"La acción negatoria tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que constituyen una turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión.

"La acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión.

"Las acciones reales competen también a los titulares del derecho de hipoteca sobre los inmuebles cuyos titulares han sido desposeídos o turbados o impedidos de ejercer los derechos inherentes a la posesión".

Se trata de "defender" la existencia, plenitud y libertad de los dere-

chos reales, conforme a la naturaleza o gravedad de las lesiones o ataques que puedan haber sufrido sus titulares. La existencia del derecho real se obtiene con la acción reivindicatoria; la plenitud, con la acción confesoria, y la libertad, con la acción negatoria. La "existencia" se ve comprometida en los casos de desapoderamiento; la "libertad", cuando alguien pretende -sin derecho o en exceso- un derecho real sobre la cosa de otro, y la "plenitud", cuando se impide el legítimo ejercicio de ciertos derechos reales (servidumbres) o de derechos inherentes a la posesión.

a) *Acción reivindicatoria*

La acción reivindicatoria es la acción real que tiene por objeto defender en juicio la existencia del derecho real en aquellos casos en que haya mediado desapoderamiento de la cosa mueble o inmueble, y así obtener su restitución, con el objeto accesorio, cuando hubiere lugar, de indemnización del daño causado (ver art. 2250).

El paradigma de las acciones reales es la acción reivindicatoria. En términos generales, puede afirmarse que es la acción que compete a un titular de un derecho real que perdió la posesión contra quien posee la cosa indebidamente.

a.1) *Ámbito*

La acción reivindicatoria compete, en los supuestos de desapoderamiento, a los titulares de los derechos de derechos reales que se ejercen por la posesión (todos menos la servidumbre), y al acreedor hipotecario (art. 2248, último párrafo).

El Código se aparta del sistema estructurado en el Derecho Romano, en el que esta acción estaba reservada al dueño y al condómino; la acción negatoria tutelaba a esos mismos derechos en los supuestos de turbación, y la acción confesoria estaba destinada a los restantes derechos reales, tanto en el caso de privación absoluta como en los de una lesión menor. Además, como en el Derecho Romano justiniano se consideraba que el usufructo, el uso y la habitación eran especies de servidumbres, era justamente la acción confesoria la indicada para los supuestos en los cuales estos últimos se viesan impedidos en su ejercicio.

El Código coincide con el Esbozo de Freitas, donde tanto la acción reivindicatoria como la negatoria se acuerdan para proteger a los de-

rechos reales que se ejercen por la posesión (arts. 3866 y 4004). La novedad es que se agrega al acreedor hipotecario.

En suma, la acción reivindicatoria puede ser intentada cuando el titular de un derecho real sufre un desapoderamiento. Dado que sólo pueden ser víctimas de una desposesión los titulares de derechos reales que son ejercidos por la posesión (poseedores legítimos), es obvio que son justamente éstos quienes pueden intentarla. El titular de una servidumbre no tiene la posesión de la cosa, de modo que mal podría ser "desapoderado"; en consecuencia, es el único que carece de la posibilidad de incoar una acción reivindicatoria. Para él está reservada la acción confesoria. Si bien el acreedor hipotecario tampoco cuenta con la posesión, el Código lo legitima en forma expresa, seguramente teniendo presente su interés en la buena conservación del inmueble desapoderado.

b) Acción negatoria. Concepto

Esta acción protege a diversos titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión frente a quienes alegan ser titulares activos de gravámenes que recaen sobre el inmueble, y su objeto es que cesen las turbaciones que sean consecuencia del ejercicio de tales pretensiones. Teniendo en cuenta que el actor, más que afirmar su derecho, niega la existencia de los pretendidos derechos sobre su inmueble, de allí viene el nombre de la acción.

b.1) *Ámbito*

Al haberse establecido el ámbito de la acción reivindicatoria, la acción negatoria corresponderá a los mismos titulares, cuando se afecte la "libertad" de tales derechos reales (arts. 2247/2248).

Esta acción no difiere de la reivindicación, sino por la extensión de la lesión que el derecho real sufre de parte del demandado. Todo ataque de una importancia menos grave que la privación de la posesión basta para dar la acción negatoria.

El Código pone ejemplos muy claros, específicos del género turbación: la atribución indebida de una servidumbre o de otro derecho inherente a la posesión. Así, por ejemplo, si el vecino se atribuye la servidumbre de paso que en realidad no fue constituida. Puede también

servir para reducir a sus límites verdaderos el ejercicio del derecho real que sí fue constituido (ver art. 2262).

b.2) *Su ejercicio por el acreedor hipotecario*

De acuerdo al último párrafo del artículo 2248, la acción negatoria corresponde "a los titulares del derecho de hipoteca" cuando sus titulares son turbados.

b.3) *El "iura novit curia" y la acción negatoria*

Se han planteado casos en los que el actor promovió la acción real negatoria, y los tribunales modificaron el encuadre jurídico y sostuvieron que la acción correspondiente era la reivindicatoria. Se trata de una aplicación específica del principio *iura novit curia*.

Si se inicia una acción negatoria por un hecho de turbación, y durante el juicio se produce el desapoderamiento, debe admitirse la conversión sin necesidad del inicio de una nueva acción. El Código admite expresamente esta posibilidad en las acciones posesorias (art. 2244).

b.4) *Derechos reales sobre cosas muebles*

Si bien el régimen de la acción negatoria parece pensado para la protección de titulares de derechos reales sobre inmuebles (ver arts. 2262/2263), no es descartable la posibilidad de su ejercicio en defensa de derechos reales que recaigan sobre muebles. De no ser así, cuando se afecte su "libertad" carecerían de protección, lo que es incongruente con la existencia de protección posesoria para todos los objetos. Es por eso que los artículos 2247 y 2248 no se refieren al objeto sino a la protección del derecho real, aunque los artículos 2262 y 2263 sólo se refieran a inmuebles.

c) Acción confesoria. *Ámbito*

Esta acción tiene por finalidad remover el obstáculo al ejercicio de una servidumbre, o el cese de actos que importen violar los límites que el Código impone a los vecinos en el Capítulo 4, Título III, de

este Libro Cuarto. La acción debe su nombre a que procura que el demandado confiese o reconozca los derechos que impidió.

Tutela a los titulares (o cotitulares) de todos los derechos reales sobre inmuebles que se ejercen por la posesión en un supuesto específico: "ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión". Si el acto lesivo no apunta a cuestionar la servidumbre en sí misma (su existencia o su ejercicio), corresponde una acción de daños y perjuicios. Asimismo, puede ejercerse esta acción cuando se afecta otro derecho inherente a la posesión: verbigracia, el vecino hace un ruido que supera la normal tolerancia.

También al acreedor hipotecario, cuando el inmueble sobre el cual recae su derecho de hipoteca, o, mejor dicho, su titular estuviese impedido de ejercer una servidumbre activa o los derechos inherentes a la posesión.

IV. Demanda y sentencia

Para iniciar una acción real se necesita ser titular del derecho real, lo cual debe subsistir al tiempo de la sentencia. El Código sienta la siguiente regla: "Para el progreso de las acciones reales la titularidad del derecho debe existir al tiempo de la demanda y subsistir al tiempo de la sentencia" (art. 2249).

Es evidente que no tiene sentido disponer la restitución de la cosa, el cese de la turbación, o el pleno ejercicio de una servidumbre, en favor de quien no tiene derecho a ello. Carecería de interés práctico.

La solución del artículo 2249 se muestra muy rigurosa, ya que si quien inició la acción no tenía derecho real en ese momento, pero éste se consolida durante el trámite del juicio, el juez deberá rechazar la demanda, lo que constituye un exceso de rigor formal que puede favorecer a un poseedor sin derecho. Quizás sería preferible la eliminación de este artículo.

V. Daño

En las acciones reales es factible también demandar la indemnización del daño, en algunas ocasiones en forma complementaria y en otras en forma sustitutiva.

Dice el artículo 2250 que "El actor puede optar por demandar el restablecimiento del derecho real u obtener la indemnización sustitutiva del daño.

"Si opta por el restablecimiento de su derecho, puede reclamar el resarcimiento complementario del daño.

"Si opta por obtener la indemnización sustitutiva del daño, pierde el derecho a ejercer la acción real".

Las acciones reales tienen un efecto accesorio, cual es la indemnización del daño causado. La existencia de un efecto accesorio implica necesariamente la de uno principal, el cual no puede ser otro que la cesación del ataque que dio lugar a la iniciación de la acción por parte del titular del derecho real.

Este efecto accesorio no se limita tan sólo a la indemnización del daño causado, sino que se extiende a todo aquello que sea consecuencia de la lesión al derecho real de que se trate. Así, por ejemplo, el poseedor de mala fe debe restituir los frutos percibidos (arts. 1935 y cons.), y tanto el poseedor de buena como el de mala fe deben restituir los productos de la cosa (art. cit.).

El Código le permite al actor, si lo desea, optar por una indemnización sustitutiva, en lugar de reclamar el restablecimiento de su derecho. Así, por ejemplo, si fue desapoderado de una cosa mueble que se encuentra en poder de un tercero de mala fe, podría optar por reivindicarla, o bien por reclamarle al despojante todo el daño sufrido (v. gr.: el valor de la cosa, la privación de uso, intereses, etc.).

En algunos supuestos la indemnización del daño será la única posibilidad que le quedará al lesionado y ya no sería, pues, una consecuencia complementaria sino subsidiaria, sustitutiva. Ya no habría opción. Ello acontecerá, entre otros casos, cuando la sentencia se torne de cumplimiento imposible (v. gr.: destrucción de la cosa reclamada, o cuando la ley pone límites al alcance de la reivindicación).

VI. Legitimación activa

a) Titulares de derechos reales

Para el ejercicio de las acciones reales es menester la titularidad del derecho real respectivo.

b) *Cesionario*

El titular de un derecho real sobre una cosa cuya posesión ha perdido por desapoderamiento (se descartan los casos de desprendimiento voluntario) puede intentar la acción reivindicatoria para recuperarla. Ahora bien, puede ocurrir que en lugar de hacerlo por sí mismo, ceda a un tercero los derechos que tenga sobre esa cosa, en cuyo caso habrá cedido al cesionario también la acción reivindicatoria (arts. 1614, 1616).

En esta situación, el cesionario puede incoar contra el poseedor la acción reivindicatoria a pesar de no ser titular de un derecho real, dado que no se le ha hecho la tradición de la cosa, lo cual no era posible, ya que la cosa la posee un tercero distinto del cedente, pues el cesionario ocupa el lugar del cedente y puede ejercer los derechos que le correspondían a éste, quien sí podía reivindicar.

Si se trata de inmuebles, el acto de cesión deberá ser formalizado por escritura pública (arts. 1017, inc. b; 1618, inc. b).

c) *Comprador al que no se le hizo la tradición*

El comprador que cuenta con el título suficiente, pero a quien no se le hizo aún la tradición, no es titular del derecho real.

La cuestión en examen requiere distinguir dos situaciones: que la cosa se halle en poder del vendedor, o que la posea un tercero.

En el primer supuesto, el comprador puede ejercer contra el vendedor la acción que nace del contrato en cuya virtud se obligó a entregarle la cosa. Esta acción, como es sabido, es de naturaleza personal.

El segundo caso es el que ha despertado mayor interés y polémicas, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

La posibilidad de que el comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado la pertinente escritura traslativa de dominio pueda, aunque no se le haya realizado tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercer poseedor del bien, fue objeto de un profundo análisis en la votación de los entonces jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, al pronunciarse el 11 de noviembre de 1958, en acuerdo plenario, en la

ACCIONES REALES
MNR

causa "Arcadini, Roque (suc.) c/Maleca, Carlos". Se afirmó el criterio de que en toda compraventa (lo que puede extenderse a la permuta, donación, etc.) se realiza una "cesión tácita o implícita" de la acción reivindicatoria.

d) *Reivindicación por quien adquirió el derecho real por usucapión*

Las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe, 1999) afirmaron que "no obsta a la acción reivindicatoria que quien es titular por usucapión no haya sido declarado como tal por sentencia, sin perjuicio de que debe necesariamente integrarse la litis con el titular registral".

Esta doctrina es extensible a la acción negatoria y a la acción confesoria.

Por otra parte, en el caso de la usucapión breve, el titular del derecho real que cuenta con justo título (art. 1902) sin duda puede ejercer las acciones reales. Se trata de un titular, que al cabo de un tiempo consolidará su adquisición.

e) *Acreedor hipotecario*

El Código de Vélez permitía que el acreedor hipotecario pudiera entablar la acción negatoria y la acción confesoria, mas no la reivindicatoria. El Código actual habilita a dicho acreedor a intentar también esta última.

f) *Heredero*

El heredero del titular del derecho real, aun cuando no haya tenido nunca la posesión del inmueble, puede intentar las acciones reales. Ello es así porque es sucesor del causante y continuador de su persona, poseedor de aquellas cosas que aquél haya poseído, y cuenta con las acciones de aquél (arts. 2280 y 2337).

g) *Legatario*

El legatario de cosas determinadas es propietario de ellas desde

la muerte del testador (art. 2496), por lo que puede intentar acciones reales sobre la cosa contra terceros, sin que se le pueda oponer que no haya tenido nunca la posesión efectiva del objeto. En este sentido, establece el artículo 2498 que "puede reivindicarla, con citación del heredero", quien debería entregarla (art. 2499).

h) *Cotitulares. Cosa juzgada*

Comienza el artículo 2251 estableciendo el principio: "Las acciones reales competen a cada uno de los cotitulares contra terceros o contra los restantes cotitulares".

h.1) *Contra otro cotitular*

Puede ocurrir que un condómino u otro cotitular se vea privado de la posesión de la cosa por otro copropietario que pretenda excluirlo en el ejercicio de sus derechos. Dispone el artículo 2251 que puede promover una acción "en la medida de la parte indivisa".

En el supuesto examinado—se trata de una hipótesis de interversión de título—, cada uno de los condóminos puede intentar la acción de reivindicación de su parte ideal o indivisa contra el copropietario que los ha excluido de su coposesión. La sentencia que se dicte no dispondrá la restitución de cosa alguna, sino que se limitará a resolver una cuestión interna entre los comuneros, reconociendo el derecho del condómino lesionado a participar en el condominio en pie de igualdad con los restantes.

h.2) *Contra un tercero*

También establece el artículo 2251 que "... Cuando se dirige contra terceros puede tener por objeto la totalidad o una parte material de la cosa, o puede reducirse a la medida de su parte indivisa. Restablecido el derecho sobre la totalidad o parte material del objeto, el ejercicio por cada condómino se circunscribe a su parte indivisa".

Cuando la cosa está en poder de un tercero se plantea el interrogante de si el condómino que inicia la acción reivindicatoria puede reivindicar la totalidad de la cosa sin el concurso de los demás condóminos, o si debe limitarse a reclamar sólo su parte indivisa o una parte material de la cosa.

El Código permite las tres posibilidades.

Por lo tanto, una alternativa es que si el condómino (u otro cotitular) ejerce su derecho sobre una parte material de la cosa (art. 1987), reivindique del tercero esa parte determinada. No obstante, puede reclamar la totalidad de la cosa—lo cual beneficiaría a los otros de tener éxito—, o bien limitarse "a la medida de su parte indivisa".

Se trata de una opción que brinda el Código, aunque parece preferible la recuperación de toda la cosa, ya que su derecho al uso y goce se extiende a toda la cosa (art. 1986), y esto sólo puede satisfacerse permitiéndosele reivindicarla en su totalidad. Además, se crearía una figura híbrida entre el condómino triunfante en la reivindicación y el usurpador, cuya posesión subsistiría sobre las partes de aquellos condóminos que no ejercieron la acción.

h.3) *Coacreedores hipotecarios*

En el caso de que fueran varios los titulares del derecho real de hipoteca, cabe descartar que la acción reivindicatoria se limite a una parte material o indivisa, teniendo en cuenta que los derechos reales de garantía son indivisibles, si no se pactó lo contrario (art. 2191). Distinto sería si la hipoteca recae sobre una parte indivisa (art. 1989), en cuyo caso la acción del acreedor hipotecario no podría ir más allá.

h.4) *Cosa juzgada*

La cosa juzgada extiende sus efectos respecto de todos los que pudieron ejercer su derecho de defensa en juicio, aunque no hayan intervenido en el juicio (v. gr.: si alguno fue citado, no se presentó y fue declarado rebelde). El contenido de la sentencia relativo a la indemnización del daño aprovecha o perjudica sólo a los que han intervenido en el juicio (art. 2251).

B) ACCIÓN REIVINDICATORIA

Ya se expuso anteriormente el concepto de la acción reivindicatoria, que el Código, luego de fijar disposiciones generales a todas las acciones reales, trata en un capítulo por separado regulando diversas cuestiones que suscita su aplicación.

I. Objeto

a) Cosas

La acción reivindicatoria procura recuperar cosas, que sean actualmente existentes, determinadas e individualizadas. Dice el artículo 2252 que "La cosa puede ser reivindicada en su totalidad o en parte material. También puede serlo la universalidad de hecho".

La acción reivindicatoria permite reclamar una cosa concreta y perfectamente identificada, no una cosa distinta, aun de la misma especie y calidad.

Si la cosa se encontrase parcialmente destruida y sólo quedasen sus restos, éstos pueden ser objeto de la reivindicación (art. 2261).

Aclara el artículo 2252 lo que había adelantado el artículo 2251 y reitera el artículo 2261, en cuanto a que se puede reivindicar toda la cosa o una parte material de ella. Hay que tener presente que según el artículo 2163: "La servidumbre puede tener por objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno". También la superficie, el usufructo, el uso y la habitación pueden tener por objeto partes materiales (arts. 2116, 2130, inc. a, 2154, 2158).

Además, cuando se trata de cotitulares, la acción puede reducirse a una parte indivisa de la cosa (art. 2251). En tal caso, el actor deberá individualizar la cosa sobre la que reclama compartir el ejercicio.

También pueden ser objeto de la acción reivindicatoria los títulos valores y los créditos instrumentados.

b) Universalidades

b.1) Universalidad de derecho

Es categórico el artículo 2252 en el sentido de que es reivindicable una universalidad de hecho, de modo que no puede serlo una de derecho, tal como una sucesión cuestionada.

Además, en el artículo 2253 se establece que no pueden ser objeto de esta acción los bienes inmateriales, esto es que no son cosas. Tampoco una universalidad jurídica puede ser objeto de la posesión o de los derechos reales, ya que siempre recaen sobre cosas ciertas y determinadas.

b.2) Universalidad de hecho

La última parte del artículo 2252 permite la reivindicación de una universalidad de hecho. Sin embargo, cabe entender que lo que se reivindica no es la universalidad de cosas (rebaño, biblioteca) sino cada una de las cosas que la componen, y hasta es posible que la acción prospere respecto de unas cosas y no de otras. No hay que olvidar que la universalidad de hecho no puede ser objeto de los derechos reales ni de las relaciones de poder (art. 1927). El objeto lo constituye una cosa cierta y determinada, las partes individuales del conjunto, en palabras del artículo 1927.

No obstante, el texto del artículo 2252 del Código actual parecería indicar que las universalidades de hecho forman una sola cosa, al menos a los fines de la acción reivindicatoria. El texto contiene un error de concepto, ya que menciona a la universalidad de hecho como si se tratara de una sola cosa, cuando en rigor es un conjunto de cosas.

Si no se admitiese que la relación de poder debe ejercerse por separado sobre cada cosa, habría dos posesiones por la misma persona, una sobre la cosa y otra sobre el conjunto, lo que no puede ser aceptado. Además, al tratarse de cosas muebles, quedarían, por un lado, sujetas al régimen de las cosas muebles y, como pertenencias del inmueble, al derecho de las cosas inmuebles, lo que tampoco es concebible.

c) Objetos no reivindicables

Según el artículo 2253: "No son reivindicables los objetos inmateriales, las cosas indeterminables o fungibles, los accesorios si no se reivindica la cosa principal, ni las cosas futuras al tiempo de hacerse efectiva la restitución".

c.1) Objetos inmateriales

Comienza el artículo 2253 por los bienes que no son cosas, los que en su condición de objetos inmateriales susceptibles de valor (art. 16) no pueden ser reivindicados, porque tampoco pueden ser objeto de las relaciones de poder ni del derecho real.

c.2) *Cosas indeterminables o fungibles*

Tal como se señaló, la acción reivindicatoria permite reclamar una cosa concreta y perfectamente identificada, no una cosa distinta, aun de la misma especie y calidad. Debe tratarse de cosas determinadas, individualizables. Por esta razón, el artículo 2253 impide que puedan ser objeto de la acción reivindicatoria las cosas "indeterminables o fungibles".

El dinero, los granos de trigo y, en general, las cosas fungibles no son reivindicables y constituyen meros ejemplos de cosas muebles cuya identidad no puede ser reconocida.

Sin embargo, puede ocurrir que mediante un procedimiento se llegue a su identificación y se produzcan efectos similares a los de una verdadera reivindicación de cosas fungibles si pueden ser identificadas (v. gr.: dinero marcado o guardado en cajas o sacos cerrados), ya que dejan de ser tales y entonces podrían ser reivindicadas.

c.3) *Cosas futuras*

Las cosas, para ser objeto de un derecho real, deben ser actualmente existentes. No puedan serlo las cosas futuras.

Aclara el Código que las cosas no deben ser futuras "al tiempo de la restitución". Por lo tanto, podría promoverse una acción reivindicatoria de una cosa futura y ser procedente si la cosa alcanza a existir al tiempo en el que la restitución debe ser hecha efectiva, luego de dictada la sentencia.

c.4) *Accesorios*

No pueden ser reivindicadas sino juntamente con la cosa principal.

Esto significa que si el titular de un inmueble debe sufrir por alguna razón la reivindicación, no puede pretender quedarse con las cosas muebles accesorias a dicho inmueble escudándose en el régimen emergente del artículo 1895. Ello es así por dos razones: a) las cosas accesorias deben seguir la suerte de lo principal, en este caso, el inmueble reivindicado; b) estas cosas muebles accesorias podrían haber dejado de ser tales para convertirse en inmuebles por accesión (art. 226).

Distinta sería la solución si son separadas, porque desde que

las cosas hasta entonces accesorias son legítimamente separadas, pasan a ser principales (art. 229) y podrán ser reivindicadas ellas mismas.

c.5) *Título valor*

Los títulos valores pueden ser objeto de una acción reivindicatoria (art. 1819).

II. Legitimación pasiva

a) *Poseedor*

El caso típico es que la acción reivindicatoria se dirija contra el poseedor que despojó al titular del derecho real (art. 2255, primer párrafo). Se puede reivindicar la cosa mueble o inmueble contra el autor del despojo. Se trata del caso típico: el titular de un derecho real que intenta la acción contra quien lo privó de la posesión.

El concepto de desapoderamiento debe ser amplio, comprensivo de todas las formas de desposesión, aun cuando no haya habido vicios (violencia, clandestinidad y abuso de confianza).

Planteada la demanda de reivindicación, si el accionado niega ser el poseedor, la demanda no será acogida, a menos que el actor pruebe que el demandado efectivamente posee la cosa. En este supuesto, debe ser condenado a restituirla, en tanto el demandante haya justificado su derecho real o su mejor derecho a la posesión.

Si la cosa ya no está en poder del autor del desapoderamiento, la acción puede dirigirse contra los sucesores; en rigor, contra quien la tenga en su poder.

b) *Tenedor*

Además del poseedor, el artículo 2255 también admite que la acción reivindicatoria pueda intentarse contra un tenedor. Aquí hay que distinguir dos situaciones, que el tenedor posea para un tercero, o para el propio reivindicante.

b.1) *Tenedor que posee a nombre de un tercero*

Podría ocurrir, por ejemplo, que una persona desapodere al titular del derecho real, se convierta en poseedor, y que le alquile la cosa a un tercero (tenedor). El propietario advierte que una persona se encuentra en poder de la cosa, sin saber que es un tenedor, y lo demanda. Dice el artículo 2255, en su segundo párrafo, que "El tenedor de la cosa a nombre de un tercero puede liberarse de los efectos de la acción si individualiza al poseedor. Si no lo individualiza, queda alcanzado por los efectos de la acción, pero la sentencia no hace cosa juzgada contra el poseedor".

No cabe duda de que, en este caso, el demandado representa la posesión de un tercero, y debe nombrarlo. La solución armoniza con el artículo 1940, inciso b, que dice que debe "individualizar y comunicar al poseedor de quien es representante si se lo perturba en razón de la cosa..."

Producida entonces la *nominatio auctoris*, en tiempo oportuno, la acción debe dirigirse contra el verdadero poseedor de la cosa, y el tenedor se libera de los efectos de la acción. Es claro que si miente para dificultar la situación, no hay liberación y puede ser condenado.

Si no produce la declaración, no se ocasiona tal liberación. El juicio de reivindicación seguirá su curso y la sentencia dispondrá la desposesión del demandado y la consiguiente restitución de la cosa al actor. Esta sentencia no será oponible al tercero, verdadero poseedor, porque no ha sido parte en el juicio, quien podrá entablar contra el actor las acciones petitorias o posesorias a que se sienta con derecho. Si obtiene la restitución de la cosa en su favor por medio de un remedio posesorio, el actor en el anterior juicio de reivindicación podrá, a su vez, intentar una nueva acción real, la que se sustanciará ahora con el *verus posesor*.

La demanda de reivindicación dirigida contra el tenedor habrá interrumpido la prescripción adquisitiva (art. 2546).

b.2) *Tenedor que posee a nombre del reivindicante*

El Código concede la acción reivindicatoria también contra el tenedor que representa la posesión del titular del derecho real, es decir,

contra aquel que tiene la cosa en nombre del propio reivindicante, por haber mediado un contrato entre ellos (v. gr.: locación, depósito, etc.). El propietario puede dirigir la acción reivindicatoria contra el tenedor a quien él le confió la cosa y la posee en su nombre, además de la acción personal emergente del contrato.

No se comparte este criterio ya que el titular del derecho real, en esta hipótesis, no perdió la posesión, la sigue ejerciendo a través de su tenedor, y tampoco hubo desapoderamiento. No obstante, ante la claridad del texto legal, sólo cabe respetar lo que dice el Código, a pesar de la aparente anomalía.

b.3) *Demandado que deja de poseer*

Si el poseedor demandado deja de poseer, no puede ser condenado a restituir un objeto que ya no tiene. La acción deberá dirigirse, entonces, contra el nuevo poseedor. Claro que dicho demandado puede ser responsable de los daños que le cause al reivindicante, en especial si obra de mala fe.

A su vez, si alguno se hace pasar por poseedor sin serlo, tampoco podrá ser condenado a restituir, pero sí a indemnizar el perjuicio que cause.

c) *Reivindicación de automotor hurtado o robado*

Dispone el artículo 2255, tercer párrafo, que "Cuando se trata de un automotor hurtado o robado, la acción puede dirigirse contra quien lo tiene inscripto a su nombre, quien debe ser resarcido en los términos del régimen especial". Aquí ya no se trata de un mero poseedor sino de un dueño, dado que lo tiene inscripto a su nombre en el Registro. No obstante, al tratarse de un automotor hurtado o robado, la acción es admisible aun cuando el tercero sea de buena fe.

Si el actor que promueve la acción reivindicatoria alega tener un mejor derecho que el demandado, y lo prueba, una consecuencia de la sentencia será la rectificación del asiento registral (ver. art. 2261). Al ser así, quien goza de la inscripción debe ser citado al juicio a efectos de ser oído y de garantizarle su derecho de defensa.

Sin perjuicio de ello, puede haber otros legitimados pasivos, si es que el automóvil pasó al poder de terceros.

III. Prueba en el juicio de reivindicación

La controversia versa sobre derechos, a diferencia del posesorio, que tiene por fin, como regla, el hecho en sí de la posesión.

Por aplicación de los principios generales sobre la carga de la prueba, el actor debe probar la titularidad del derecho real (conf. art. 2249). Si esta afirmación se aplicase en forma rigurosa, el actor debería probar que la persona que figura en el título como su transmitente era también el verdadero propietario, y así para atrás. Esta exigencia motivó que se considerase a este régimen probatorio como una *probatio diabólica*, de modo que el Código suaviza el rigor por medio de presunciones.

El artículo 2257 se ocupa de reclamos sobre inmuebles; en el caso de las cosas muebles, el Código trata por separado las cosas muebles registrables de las que no lo son (arts. 2257/2258).

En el ámbito procesal, como es sabido, es el actor quien carga con la prueba. Esta regla se encuentra reforzada en el terreno de la acción reivindicatoria, teniendo en cuenta que –por hipótesis– el demandado es poseedor, o representa al poseedor.

Quien inicia la acción reivindicatoria debe, como primera medida, justificar su derecho sobre la cosa objeto de la acción, invocando título de dominio o de alguno de los derechos reales que se ejercen por la posesión, o bien su condición de acreedor hipotecario.

En el supuesto de que el poseedor actual también acredite tener derecho sobre el bien, el reivindicante no sólo debe demostrar su derecho sobre la cosa, sino, además, que el suyo es mejor, puesto que *in pari causa conditio, possidentis melior est*.

IV. Prueba cuando se reivindican inmuebles

Prevé el artículo 2256: "Respecto de la prueba en la reivindicación de cosas inmuebles, se observan las reglas siguientes:

"a) si los derechos del actor y el demandado emanan de un ante-

MNR

cesor común, se presume propietario quien primero es puesto en posesión de la cosa, ignorando la obligación anterior, independientemente de la fecha del título;

- "b) si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores, el título del reivindicante posterior a la posesión del demandado, es insuficiente para que prospere la demanda, aunque el demandado no presente título alguno;
- "c) si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores y el título del reivindicante es anterior a la posesión del demandado, se presume que este transmitente era poseedor y propietario de la heredad que se reivindica;
- "d) si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores, sin que se pueda establecer cuál de ellos es el verdadero propietario, se presume que lo es el que tiene la posesión".

a) Ambos títulos emanan del mismo autor

Cuando ambas partes presentan en el juicio títulos de propiedad, y éstos emanan de la misma persona, se está en presencia de un caso en el que el inmueble ha sido enajenado dos veces por quien era su dueño. Planteado el conflicto entre ambos adquirentes –o sus sucesores–, la solución surge del inciso a, del artículo 2256: "se presume propietario quien primero es puesto en posesión de la cosa, ignorando la obligación anterior, independientemente de la fecha del título".

La solución es el resultado de la aplicación de la teoría del título y modo en la adquisición de los derechos reales, y del principio *prior in tempore potior in jure* (el primero en el tiempo prevalece en el derecho).

Claro que prevalecerá el primero que haya recibido la posesión, con independencia de la fecha del título, siempre y cuando haya sido de buena fe. Como se puede apreciar, no importa la fecha del título, sino la de la adquisición del derecho real de buena fe. Por ende, es posible que aquel cuyo título sea posterior triunfe en el pleito si fue el primero en recibir la posesión y en adquirir el derecho real, si obra de buena fe.

Para la determinación de la buena fe hay que tener en cuenta,

además de la ignorancia de la situación en virtud de una actividad diligente, que el título del contrincante no haya sido registrado con anterioridad a su adquisición.

En suma, debe prevalecer aquel que, de buena fe, obtuvo la prioridad registral. Si no hubo ninguna registración, se aplica lo dispuesto en dicha norma en tanto el primero en adquirir el derecho real sea de buena fe.

El sistema se completa con lo dispuesto por el artículo 756: "*Concurrencia de varios acreedores. Bienes inmuebles*. Si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho:

- "a) el que tiene emplazamiento registral y tradición;
- "b) el que ha recibido la tradición;
- "c) el que tiene emplazamiento registral precedente;
- "d) en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior".

Armonizando ambos textos, si ninguno hubiera recibido la posesión, y si ninguno de los dos hubiese inscripto su título en el Registro, recién ahí será importante la fecha del título, ya que prevalecerá el de fecha cierta anterior. Claro que este último inciso excede el ámbito de las acciones reales, pues no hay derecho real aún, y se resuelve en el terreno de los derechos personales. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que en el caso del inciso b, si uno recibió la tradición cuando ya el otro acreedor gozaba de inscripción registral a su favor, no podrá alegar su buena fe, requisito que impone el propio artículo 756. Debió el inciso c, figurar en segundo lugar.

b) Los títulos emanan de distintos autores

Si el actor y el poseedor presentan títulos que emanan de diferentes antecesores, en primer lugar, el juez deberá examinar cuál de los títulos presentados es mejor o más probable en cuanto al derecho de las partes. Para ello se deben estudiar los títulos de los respectivos antecesores, como si el juicio se planteara entre ellos. Si de ese estudio resulta quién era el verdadero propietario, su sucesor será el vendedor.

Para establecer "cuál de ellos era el verdadero propietario", como indica el inciso d, del artículo 2256, en los incisos b, y c, se asigna especial importancia a la fecha del título. Si el título es de fecha posterior a la posesión del demandado, "es insuficiente". También habrá que valorar la buena fe de cada uno, en función de la existencia, o no, de inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble y, en caso de haber más de una, de cuál obtuvo prioridad.

Si no hubo inscripción, y no resulta posible establecer cuál de los dos ostenta mejor derecho, la contienda se resolverá en beneficio del poseedor actual —generalmente el demandado—, por aplicación del principio *in pari causa melior est conditio possidentis*.

c) El demandado no presenta título

Teniendo presente que dos posesiones iguales y de la misma especie no pueden concurrir sobre la misma cosa (art. 1913), a diferencia de lo que ocurre con los títulos de propiedad que pueden sí ser más de uno, y que la posesión se halla en cabeza del demandado, la única posibilidad para el actor de enfrentar con éxito semejante situación reside en su título y, faltándole este último, de nada podrá valerse para sustentar su derecho. De tal manera, la confrontación jurídica tendrá como adversarios a dos elementos del derecho real: el título frente al modo, o, si se quiere, "derecho a poseer" frente a la "posesión".

El actor en el juicio de reivindicación debe contar con un título suficiente (en ciertos casos podría servir un justo título). El boleto de compraventa no constituye el "título suficiente", ya que no ha sido formalizado por escritura pública como exige el artículo 1017, inciso a.

d) Importancia de la fecha del título

No siempre el título presentado por el actor será suficiente, por sí mismo, para fundar la demanda, ya que éste debe estar munido de otra condición: ser de fecha anterior a la posesión del demandado (inc. c). El régimen probatorio exige del reivindicante no sólo la exhibición de su título, sino también la demostración de ser éste de fecha anterior a la posesión del demandado, y él carga con la prueba.

La solución de la norma es perfectamente lógica, ya que si el título del accionante es posterior a la posesión del tercero, ello implica que el enajenante no ha podido entregarle la cosa porque estaba poseída por otros (arts. 1913 y 1926) y, por ende, que no adquirió el derecho real (art. 1892). Al contrario, si su título es de fecha anterior, se lo presume poseedor y propietario desde esa fecha, lo cual no presenta inconvenientes.

En tal caso "se presume que este transmitente era poseedor y propietario de la heredad que se reivindica" (inc. c, del art. 2256).

Si bien el inciso c, parece referirse al título del reivindicante, cabe interpretar que abarca también a los títulos de sus antecesores, que por hipótesis no fueron los mismos del demandado.

Es decir que si el demandante, en la hipótesis de que la fecha de su escritura sea posterior a la posesión del demandado, invoca el título de su autor, y el del autor de éste, hasta dar con uno que sea de fecha anterior a la posesión de su oponente, y éste no presenta título alguno, juega a favor de aquél la presunción de que el autor de dicho título anterior era poseedor y propietario de la heredad reclamada.

Aunque al reivindicante no le hubiese sido transmitida en ningún momento la posesión de la cosa, a los efectos de la reivindicación tal circunstancia es irrelevante y nada debe probar en ese sentido, por cuanto, en virtud de la cesibilidad de la acción, se la considera tácitamente cedida en cada acto de enajenación que compone la cadena, sin requerirse para ello la tradición. Le basta al accionante probar —por medio de presunciones— que uno de los adquirentes intervinientes en las sucesivas enajenaciones era poseedor y propietario y, por consiguiente, que podía reivindicar, para así, a nombre propio, en calidad de cesionario, hacer suyo el derecho de ejercer la acción que competía a ese antecesor.

e) *Usucapión*

Las reglas expuestas son subsidiarias de una adquisición por usucapión, que siempre prevalece, ya que para su consumación no es necesaria la buena fe. En caso de conflicto entre dos adquirentes por usucapión, debe prevalecer la más reciente.

V. Prueba en la reivindicación de muebles registrables

Sobre esta cuestión el artículo 2257 dispone lo siguiente: "Respecto de la prueba en la reivindicación de cosas muebles registrables, robadas o hurtadas, cuando la registración del demandado es de mala fe, se deben observar las reglas siguientes:

- "a) se presume la mala fe cuando no se verifica la coincidencia de los elementos identificatorios de la cosa de acuerdo al régimen especial y tampoco se constata la documentación y estado registral;
- "b) el reivindicante debe probar su derecho con el certificado que acredita su inscripción en el registro respectivo. El demandado debe justificar de igual manera el derecho que opone;
- "c) si el derecho invocado por el actor no está inscripto, debe justificar su existencia y la rectificación, en su caso, de los asientos existentes. Si el derecho del demandado carece de inscripción, incumbe a éste acreditar el que invoca contra el actor;
- "d) si el actor y el demandado presentan antecedentes que justifican la inscripción registral, emanados de un autor común, es preferida aquella que acredita la coincidencia de los elementos identificatorios registrales exigidos por el régimen especial;
- "e) si el actor y el demandado presentan antecedentes que justifican la inscripción registral derivados de personas distintas, sin que se pueda decidir a quién corresponde el derecho controvertido, se presume que pertenece al que lo tiene inscripto".

a) *Demandado de mala fe*

Dice el artículo 2257 que esta norma se aplica cuando se reivindican cosas muebles registrables, robadas o hurtadas, y "la registración del demandado es de mala fe". No obstante, algunas de ellas también son útiles para resolver problemas cuando se pretenda reivindicar cosas que no fueron robadas o hurtadas, o cuando no hubo registración.

En primer lugar, se establece una presunción de mala fe, lo que

acontece cuando no se verifican los elementos identificatorios (v. gr.: número de motor y de chasis si se trata de un automotor), y tampoco se constata la documentación y estado registral.

Si no hay registración, no hay buena fe (art. 1895, segundo párrafo), pero aun habiendo inscripto, el adquirente puede ser de mala fe.

b) *Prueba*

El actor carga con la prueba: debe probar su derecho real, o bien que tiene un mejor derecho que la otra parte. Sin embargo, esta norma impone requisitos tanto al actor como al demandado.

El artículo 2257 parte de la base de que ambos tienen una inscripción registral a su favor, situación que no se presenta fácilmente en la práctica, pero que puede suceder. Así, por ejemplo, una persona es dueña de un auto e inscribió su título en el Registro, luego le es robado, y un sujeto distinto —maniobras mediante— inscribe a su nombre.

En tal caso, ambos deben justificar su derecho mediante el certificado que expide el Registro.

Ahora bien, si uno de ellos no hubiese inscripto, puede justificar su derecho por otros medios. Así, por ejemplo, actos jurídicos formalizados en instrumentos privados o públicos, declaratoria de herederos, adquisición en subasta, posesión, entre otros.

c) *Autor común*

Tal como está redactado el inciso c, la hipótesis alude a que el actor y el demandado presentan antecedentes que emanan de un autor común. Como se vio al comentar el artículo 2256, en el caso de los inmuebles triunfa aquel que primero recibió la posesión, si es de buena fe (inc. a). Aquí la solución es diferente, "es preferida aquella que acredita la coincidencia de los elementos identificatorios registrales exigidos por el régimen especial".

Ahora, lo que no dice esta norma es qué ocurre si ninguno de los dos tiene este tipo de diferencias o irregularidades. Cabe entender que debe ser preferido aquel que inscribió primero, para que la situación

guarde similitud con la prevista para los inmuebles, la que además es de plena lógica. Así también lo prevé al artículo 757, inciso a.

d) *Autores distintos*

Aquí la situación se resuelve en forma similar a la prevista para los inmuebles. En primer lugar, hay que dilucidar cuál de ellos o de sus antecesores tiene mejor derecho. Si esto no es posible, triunfa aquel que lo tiene inscripto a su favor. Cabe suponer que si el actor prueba el robo o el hurto, es muy probable que pueda así justificar su mejor derecho. Más difícil será resolver cuando haya habido desprendimiento voluntario.

VI. *Prueba en la reivindicación de muebles no registrables*

Sobre esta cuestión se expide el artículo 2258 en los siguientes términos: "En la reivindicación de cosas muebles no registrables:

- "a) si las partes derivan sus derechos de un antecesor común, prevalece el derecho de la que primero adquiere el derecho real;
- "b) si las partes derivan sus derechos de distintos antecesores, prevalece el derecho que se derive del antecesor más antiguo. Sin embargo, siempre prevalece el derecho que se remonta a una adquisición originaria, aunque sea más reciente;
- "c) si la cosa mueble es transmitida sin derecho y a título gratuito, procede la reivindicación si el objeto se encuentra en poder del subadquirente, aunque éste sea de buena fe".

a) *Ámbito de aplicación*

Cabe recordar que para las cosas muebles no registrables rige el sistema previsto por el artículo 1895, que confiere el derecho real —e impide reivindicar— al poseedor de buena fe y a título oneroso, si la cosa no fue hurtada o perdida. Por lo tanto, la reivindicación está limitada a: 1) subadquirente de mala fe; 2) subadquirente de buena fe pero a título gratuito; 3) tercero de buena fe, sea o no a título oneroso, que adquirió una cosa hurtada o perdida. El segundo supuesto es con-

templado, innecesariamente, por el inciso c, del artículo 2258. Es consecuencia de lo previsto en el artículo 1895.

b) *Antecesor común*

Prevé el inciso a, del artículo 2258 que si actor y demandado derivan sus derechos de un antecesor común, prevalece el primero en adquirir el derecho real, esto es, quien primero recibió la tradición. Habría que agregar que ello es así siempre que sea de buena fe y a título oneroso. Así lo prevé el artículo 757, inciso b, que debe ser armonizado.

c) *Antecesores distintos*

El Código prevé que debe investigarse primero cuál antecesor tenía mejor derecho, en el inciso e, del artículo 2257 para las cosas muebles registrables, y en el inciso d, del artículo 2256 para los inmuebles. En cambio, para las cosas muebles no registrables, dispone que prevalece aquel que derive su derecho del antecesor más antiguo. Por ende, habrá que remontarse para atrás y advertir cuál de los dos antecesores tuvo el derecho real con anterioridad.

d) *Otras pruebas*

Teniendo en cuenta que, por regla, el actor carga con la prueba, podrá acudir a diversos medios de prueba: recibos, facturas de compra o de arreglos de la cosa mueble que se quiere reivindicar, constancias de tarjetas de crédito, e incluso testigos. Claro que esto también será conveniente para el demandado, quien también podría tener interés en acreditar que la cosa le fue entregada voluntariamente. Si el demandado es tenedor, puede probar que aún no venció el plazo o que no hay motivo para concluir la causa de la tenencia.

e) *Acreeedor frustrado*

El acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios sufridos (art. 758).

VII. Derecho a reembolso

Por regla, quien reivindica una cosa mueble robada o perdida nada debe pagarle al vencido, aun cuando sea de buena fe y a título oneroso, salvo en los supuestos de excepción que regula el artículo 2259.

Dice el artículo 2259: "Si se reivindica un objeto mueble no registrable robado o perdido de un poseedor de buena fe, éste no puede reclamarle al reivindicante el precio que pagó, excepto que el objeto se haya vendido con otros iguales en una venta pública, o en casa de venta de objetos semejantes, o por quien acostumbraba a venderlos.

"Si se trata de una cosa mueble registrable robada o perdida, y la inscripción registral se obtiene de buena fe, el reivindicante debe reintegrar al reivindicado el importe abonado.

"En caso de reembolso, el reivindicante tiene derecho a repetir el pago contra el enajenante de mala fe".

a) *Reivindicación de cosas no registrables robadas o perdidas y reembolso al demandado*

Ello ocurre cuando la cosa se hubiese vendido con otras iguales, en una venta pública, o en una casa de venta de objetos semejantes, o por un individuo que acostumbraba vender cosas semejantes.

Así, por ejemplo, si a una persona le roban su reloj, y éste es vendido por el ladrón a un joyero, quien a su vez lo vende en su joyería a un tercero de buena fe, éste no podrá repeler la acción reivindicatoria del propietario, ya que el artículo 1895 no se aplica a las cosas robadas, pero sí tendrá derecho —siempre que sea de buena fe— a que se le restituya el precio que pagó por el reloj en función de lo dispuesto por el artículo 2259. Se considera que quien compra la cosa en un lugar donde se venden otras iguales o semejantes no pudo advertir la ilegitimidad del título del transmisor, fue víctima de un error invencible. Además, el reembolso del precio, como carga del propietario reivindicante, es una medida de protección del tráfico.

De todas formas, en el ejemplo anterior, el propietario que reivindica podrá recuperar la suma que debió reembolsar al poseedor reclamándosela al joyero, pues se la compró al ladrón y entonces cabe suponer su mala fe (art. 1919, inc. b).

b) *Supuestos en los que procede el reembolso*

El artículo 2259 establece que el subadquirente de buena fe de la cosa robada o perdida tiene derecho al reembolso cuando "el objeto se haya vendido con otros iguales en una venta pública, o en casa de venta de objetos semejantes, o por quien acostumbraba a venderlos".

Que la cosa se hubiese vendido con otras iguales significa que "esté en venta", ofrecida, con otras iguales, aunque haya sido adquirida individualmente. Además, no es necesario que sean "iguales", ya que es suficiente que se la haya ofrecido junto a otras "semejantes".

Cuando alude a "venta pública", el concepto también es amplio, comprendiendo lugares destinados a la venta al público (instituciones oficiales, subastas, ferias, mercados, etc.). La "casa de venta de objetos semejantes" alude a casas de comercio que se dedican a artículos del ramo (v. gr.: joyería).

Por último, se prevé la venta realizada por persona que "acostumbraba a venderlos".

c) *Contenido del reembolso*

El comprador que sufre la reivindicación de la cosa robada o perdida, y que adquirió en las condiciones referidas, tiene derecho a que el reivindicante le restituya "el precio que pagó". Además, cabe admitir que el reivindicado tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles, y de las mejoras introducidas en la cosa, para evitar un enriquecimiento sin causa.

d) *Situación del que vende la cosa robada o perdida junto a otras semejantes*

Tal como se expuso, el titular del derecho real que reivindica una cosa robada o perdida debe reembolsarle el precio pagado al poseedor de buena fe que la adquirió en un lugar o a una persona que acostumbra vender cosas iguales o semejantes. No obstante, el reivindicante puede repetir lo pagado contra quien le vendió a dicho subadquirente. Esto es lo que confirma el artículo 2259 en su último párrafo: "el reivindicante tiene derecho a repetir el pago contra el enajenante de mala fe".

Dice la norma que procede la repetición si el enajenante es de mala fe.

e) *Sucesor de quien tiene derecho al reembolso*

Cabe interpretar que si bien el último no adquirió en un lugar donde se venden cosas semejantes, también tiene derecho al reembolso por asistirle la garantía de evicción, que le permitiría citar al juicio a su vendedor, quien sí tenía derecho a ello.

f) *Cosas muebles registrables*

Dice el segundo párrafo del artículo 2259 que "Si se trata de una cosa mueble registrable robada o perdida, y la inscripción registral se obtiene de buena fe, el reivindicante debe reintegrar al reivindicado el importe abonado".

El demandado que pretenda el reembolso debe contar con inscripción registral a su favor y, además, ser de buena fe.

Lo que no queda claro es si, además, para tener derecho al reembolso es necesario que se haya adquirido en una venta pública, o en casa de venta de objetos semejantes, o a persona que acostumbra vender este tipo de cosas, como se exige para las cosas muebles no registrables.

Cabe pronunciarse por la afirmativa. En primer lugar, la regla es que se pueden reivindicar las cosas robadas o perdidas sin tener que desembolsar suma alguna, salvo casos de excepción, en los que el adquirente es víctima de lo que se llama error invencible. De no ser así, habría que pagar en casi todos los casos, y la reivindicación se desnaturalizaría.

En segundo lugar, otra regla general dice que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas (art. 399), de modo que el reembolso debe ser la excepción.

En tercer lugar, no se advierten motivos para colocar en mejor situación al adquirente de cosas muebles registrables de aquel adquirente de cosas muebles no registrables. Tampoco en el ámbito de los inmuebles, cuando es factible la reivindicación, el reivindicante debe

pagar el precio al demandado. Así, por ejemplo, en el caso del acto inoponible, nada debe desembolsar (arts. 392, 396, 2260).

Por último, esta norma debe ser armonizada con lo previsto en los regímenes especiales. Así, en materia de automotores, si el rodado hubiese sido adquirido en venta pública o en un comercio dedicado a la venta de automotores, debe ser resarcido del precio pagado (art. 4º, segunda parte, decreto 6582/58).

VIII. Límites de la acción reivindicatoria respecto de cosas muebles no registrables

En el capítulo dedicado a las cosas muebles se vio que, por aplicación del artículo 1895, no se le puede reclamar la cosa mueble al subadquirente de buena fe y a título oneroso de una cosa mueble no registrable, que no sea hurtada o perdida.

En sentido concordante, establece el artículo 2260, en su primera parte, que "La acción reivindicatoria de una cosa mueble no registrable no puede ejercerse contra el subadquirente de un derecho real de buena fe y a título oneroso excepto disposición legal en contrario; sin embargo, el reivindicante puede reclamarle todo o parte del precio insoluto".

a) *Reclamo del saldo insoluto*

No procede la acción reivindicatoria contra el tercero adquirente de una cosa mueble no hurtada ni perdida, cuando es de buena fe y a título oneroso. Sin perjuicio de ello, el que pretende reivindicar puede reclamarle a dicho tercero "todo o parte del precio insoluto".

Al final del primer párrafo del artículo 2260, se trata el caso de una persona que podía ser demandada por reivindicación, y le transmitió el dominio de la cosa a otro, pero aún no percibió el precio, o recibió sólo una parte de él. En estas condiciones, prevé dicha norma que el reivindicante le puede reclamar al nuevo adquirente el precio, o lo que quede a pagar. Se trata de una acción directa, y es otra forma de resarcir al reivindicante que ya no puede recuperar la cosa mueble. Constituye una excepción al principio del efecto relativo de los contratos.

Puede suceder que todo o la parte del precio que reciba el reivindicante no satisfaga todo el daño sufrido, en cuyo caso subsiste la posibilidad de demandar al enajenante para que indemnice el perjuicio.

b) *Exclusión de las cosas hurtadas, robadas o perdidas*

Si la cosa mueble fue hurtada, robada o perdida, el subadquirente sufrirá la reivindicación aun cuando haya adquirido a título oneroso y de buena fe.

c) *Otros casos de reivindicación*

También pueden ser reivindicadas las cosas muebles que no hayan sido hurtadas o perdidas si el tercero es de mala fe, o si es de buena fe pero adquirió a título gratuito (art. 2258, inc. c).

d) *Muebles de la vivienda familiar*

En cuanto a las cosas muebles comprendidas en el régimen matrimonial prevé el artículo 462 que "Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión.

"En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber conocido el acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial".

Una disposición similar existe respecto de los muebles indispensables para la vivienda familiar, en el caso de las uniones convivenciales (art. 522).

e) *Títulos valores*

La acción reivindicatoria se detiene frente a un adquirente de buena fe y a título oneroso, aun cuando el título contenga firmas falsas o de personas inexistentes (arts. 1819 y 1823).

IX. Límites en materia de cosas registrables

La acción reivindicatoria, en materia de inmuebles, o de cosas muebles registrables, compete contra el autor del desapoderamiento, y contra sus sucesores en la posesión. También procede contra quien obtuvo la cosa del reivindicante en virtud de un acto bilateral que resulta privado de eficacia.

Distinta es la situación de los terceros que adquirieron de un enajenante obligado a restituir.

Así, por ejemplo: Juan es dueño de un inmueble. Pedro mediante violencia lo obliga a vendérselo. Se trata de un acto ineficaz, por lo que Juan puede demandar su nulidad y recuperar el inmueble. De esto no hay duda. El asunto se complica si Pedro se lo vende a un tercero (v. gr.: Diego), ya que la reivindicación de Juan dependerá de la buena o mala fe de dicho subadquirente.

a) *El principio*

Está enunciado en el artículo 399: "Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas". Asimismo, la acción reivindicatoria, por su naturaleza, tiene efectos *erga omnes*.

Estas reglas contienen varias excepciones legisladas en el propio Código en forma expresa y para casos particulares. Es inaplicable para las cosas muebles no registrables, las cuales se rigen por otro principio, el del artículo 1895. Otra excepción se encuentra en los actos de disposición realizados por el heredero aparente a favor de terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso (art. 2315).

La aplicación a ultranza del principio según el cual no es posible transmitir un derecho mejor que el que se tiene conduciría a privar al tercero que haya obrado de buena fe, por un error invencible —*error communis facit ius*—, de un derecho adquirido sobre la base de un título que en apariencia sea válido, lo que resultaría no sólo injusto sino perjudicial para el tráfico.

La seguridad jurídica dinámica es aquella que protege a los adquirentes.

b) *Efectos respecto de terceros en cosas registrables*

Prevé el Código que "Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso.

"Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho" (art. 392).

El efecto principal de la nulidad es volver las cosas al estado anterior al acto declarado nulo y, en consecuencia, las partes habrán de restituirse lo que mutuamente se entregaron en virtud del acto ineficaz (art. 390).

No obstante dicho principio, por aplicación de la teoría de la apariencia del acto, quedan exceptuados de la obligación de restituir y a resguardo de la acción de reivindicación, los terceros subadquirentes de buena fe y a título oneroso de bienes inmuebles o de muebles registrables. La referida excepción no se aplica a los actos a título gratuito, con prescindencia de la buena o mala fe del subadquirente ni a los actos realizados sin la intervención del titular del derecho. Este último supuesto es el que se conoce tradicionalmente como enajenación *a non domino*.

Al quedar a salvo los derechos de los terceros de buena fe y a título oneroso, a pesar del acto nulo, se produce una importante excepción al principio del *nemo plus iuris*. Se produce, a su vez, un freno al amplio alcance de la acción reivindicatoria.

b.1) *El tercero debe adquirir de quien está legitimado para transmitir de acuerdo a los asientos registrales*

Es obvio que quien desea adquirir un inmueble debe, en primer lugar, averiguar quién es su propietario, y esa información la debe obtener del Registro. Si el tercero pretende adquirir el derecho de quien no figura como titular inscripto, la operación no podrá concretarse, y se advertirá su mala fe, ya que incurrió en un evidente error

de derecho. Lo mismo se puede decir si el tercero adquiere de la persona que figura inscrita como usufructuaria, ya que no tiene poderes de disposición sobre el inmueble.

b.2) *El tercero debe desconocer la inexactitud del Registro*

La buena fe, en principio, consiste en el desconocimiento de la inexactitud del Registro. Así, por ejemplo, si alguien hubiese adquirido un inmueble en virtud de un acto ineficaz (v. gr.: por haber actuado con violencia) y luego se lo transmite a un tercero que sabía lo ocurrido, este último no puede ser reputado de buena fe. Esta idea es trasladable a cualquier vicio o irregularidad que contenga el acto y que sea conocido por el tercero.

Es importante señalar que nuestro sistema adhiere al criterio subjetivo de la buena fe, que concede relevancia decisiva al conocimiento o desconocimiento de aquello que sucedió fuera del Registro en discordancia con sus constancias, ya que la sola circunstancia de que el dominio esté inscripto a nombre del propietario aparente no significa tener por acreditado de modo irrefragable la buena fe del tercer adquirente. Ello porque la buena fe requerida por el artículo 392 no es la "buena fe registral".

Así, por ejemplo, una persona grava su inmueble con una hipoteca, ésta no es inscrita, y luego le vende el inmueble a otra persona que conocía la constitución de aquélla. Si se aplicara un criterio objetivo, el tercero estaría protegido ya que su enajenante figura como titular registral y la hipoteca no sería informada por el Registro, a pesar de su mala fe. En cambio, para el criterio subjetivo, el conocimiento de la realidad jurídica tiene una importancia fundamental. No hay motivo para que el adquirente de mala fe se pueda aprovechar de la legitimación registral del doble transmitente; para dicho tercero debe ser oponible el derecho real que, si bien no es informado por el Registro, conocía o haya podido conocer obrando con diligencia. De no ser así, estaría la puerta abierta para los terceros que, en connivencia con el constituyente, se propusieran defraudar al acreedor.

b.3) *El tercero debe actuar con diligencia (estudio de títulos)*

Como se adelantó, para modelar la buena fe no basta con la pu-

blicidad registral. A ésta debe unirse, para confirmar la ignorancia de lo sucedido fuera del Registro, una actitud diligente, cuidadosa, que demuestre que el tercero adquirente hizo todo lo que estaba a su alcance para averiguar la bondad de la situación.

En un principio, la buena fe implica apariencia jurídica, creer en lo que es aparente, aun cuando ello no coincida con la realidad; ésta es la buena fe creencia. Pero la buena fe exige también obrar sin culpa, con diligencia, sin haber cometido errores inexcusables, como cabe esperar del hombre medio, y sin tener dudas.

La buena fe consiste en la ignorancia del adquirente de que la titularidad de su causante está viciada, o no existe ya en él, o que si bien existe no está legitimado para disponer con determinado alcance, o que no existen ciertos derechos reales o gravámenes y, correlativamente, la creencia de que es dueño de la cosa y puede transmitir su dominio. Se parte de la base de que todo lo que ignora el tercero, obviamente, no fue informado por el Registro. En estas hipótesis, para admitir la ignorancia del tercero (desconocimiento que debe ser verdadero, al medirse la buena fe con criterio subjetivo), descartado el error de derecho, cabe exigirle el despliegue de una conducta diligente realizada con el objeto de cerciorarse de la inexistencia de los referidos vicios, limitaciones, etcétera. Se impone al tercero, para ser de buena fe, cierta obligación de diligencia que demuestre que, una vez realizada, no conoció ni estuvo a su alcance conocer la irregularidad existente.

Esa actividad diligente consiste en el estudio de títulos, o sea, el examen idóneo de los antecedentes del derecho transmitido, lo que en muchos casos permitiría conocer vicios u otro tipo de irregularidades que el Registro no informa y no purifica. De tal forma, si el estudio no se realiza y, si de haberse realizado los vicios hubiesen sido advertidos, el tercero es considerado de mala fe por causa de su negligencia. Ahora, si el estudio no se realizó, pero haberlo hecho no hubiera revelado la existencia de vicios que no son manifiestos, el tercero —a pesar de no haber sido diligente— puede ser reputado de buena fe, en tanto no se demuestre que tenía conocimiento efectivo de la situación.

La realización de esta actividad está a cargo del notario que inter venga en el otorgamiento de la escritura pública necesaria. El estudio de títulos tiene su fundamento en: a) refuerza la seguridad jurídica;

b) los escribanos son los profesionales más idóneos en la preparación de los actos derivados de la contratación inmobiliaria; c) el estudio de títulos es un tema emplazado dentro de la trascendencia de la escritura pública; d) los usos y costumbres muestran que los escribanos realizan este estudio. El Código lo dice expresamente (art. 1902, último párrafo).

b.4) Cosas muebles registrables

En el caso de las cosas muebles registrables, será indispensable constatar la coincidencia de los elementos que identifiquen a la cosa, cuando así está previsto (v. gr.: marca en el ganado, número de motor y de chasis en los rodados, etc.).

c) Los actos "a non domino"

Además de la nulidad, existe otra causal de ineficacia del acto jurídico que es la inoponibilidad (art. 382). Las situaciones de hecho que caracterizan a esta clase de actos son múltiples, variadas, frecuentes y de indudable trascendencia práctica. Generalmente se trata de escrituras públicas de enajenación en las cuales se ha producido una sustitución de personas en el disponente del derecho. Aquí puede darse el caso de dolo o connivencia del escribano interviniente o de su negligencia. Puede tratarse también de la falsificación material de un testimonio u oficio judicial, e inclusive de una estafa procesal.

Así, por ejemplo, Juan es dueño de un inmueble. Pedro, mediante documento de identidad falso, se hace pasar por Juan y engaña a Diego, a quien le vende un inmueble. Diego está persuadido de haberle comprado al verdadero dueño, es de buena fe y pagó el precio correspondiente. No obstante, no goza de la protección prevista para los terceros de buena fe y a título oneroso, ya que dicho régimen no ampara los casos de no intervención del verdadero titular.

En estas situaciones, si quien ha resultado titular del derecho en virtud de ese acto falsificado lo transmite onerosamente a un tercero de buena fe, no queda éste a cubierto de la acción de reivindicación del propietario que no ha intervenido (última parte del artículo 392).

En la misma línea, dispone el artículo 396 que "El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley".

Ocurre que la excepción prevista en el artículo 392 se aplica a los actos nulos, y no para los actos inoponibles, también llamados inexistentes, en los cuales no hay autoría del verdadero propietario, aunque los terceros sean de buena fe y a título oneroso. Es lo que dice también el segundo párrafo del artículo 2260: "El subadquirente de un inmueble o de una cosa mueble registrable no puede ampararse en su buena fe y en el título oneroso, si el acto se realiza sin intervención del titular del derecho".

Quien adquiere de la persona que no es el verdadero titular, que no está legitimada para transmitir, tiene un justo título y puede escapar a la acción reivindicatoria, si es de buena fe, si se consuma la prescripción breve de diez o de dos años según se trate de inmuebles o de cosas muebles registrables (arts. 397, 1898, 1902, 2254).

Si la persona que cuenta con un justo título le transmite la cosa registrable a otro, este nuevo adquirente se encuentra en una situación similar (art. 399). Si se dan las circunstancias, podrá sumar el tiempo de su posesión a la de su antecesor (art. 1901) para alcanzar el plazo exigido por el Código para la prescripción breve.

d) Reivindicación contra el adquirente en virtud del acto nulo

El artículo 392 es claro en el sentido de que la acción reivindicatoria procede contra el actual poseedor, aunque fuere de buena fe que la hubiese tenido del reivindicante, por un acto nulo. Es una consecuencia de lo previsto en el artículo 390: "La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto".

Aquí no se trata de terceros subadquirentes sino de la situación planteada entre quienes fueron parte del acto jurídico nulo o anulado judicialmente. Quien adquirió en estas condiciones, aun cuando lo haya

hecho de buena fe (v. gr.: había un vicio no manifiesto que no pudo ser advertido), no puede escapar a la acción reivindicatoria del enajenante. Esta disposición se aplica tanto cuando se trata de inmuebles o muebles registrables como de cosas muebles no registrables, ya que también la regla sentada por el artículo 1895 rige para los subadquirientes.

Cabe sostener una solución similar cuando la cosa mueble registrable se obtuvo por robo o hurto.

X. Medidas cautelares

Existen diversas normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen interés en el juicio de reivindicación.

a) Medidas preliminares

Cuando se persigue la reivindicación de una cosa mueble, antes de iniciar el juicio, o en cualquier estado de éste, el actor puede pedir como medida preliminar que se la exhiba (art. 323, inc. 2º, CPCCN). Se trata de una medida preparatoria más que de una medida cautelar.

A su vez, el inciso 6º del referido artículo prevé otra diligencia con el objeto de que se conozca el carácter en el que ocupa la cosa la persona que haya de ser demandada por reivindicación, mientras que el inciso 9º contempla la posibilidad de que se realice una mensura judicial, lo que puede ser útil para determinar si debe iniciarse una acción reivindicatoria o una de deslinde.

b) Medidas precautorias

La "anotación de litis" (art. 229, CPCCN) es una medida aplicable cuando la reivindicación versa sobre inmuebles o cosas muebles registrables, pues se trata de inscribir en el Registro la existencia del pleito.

El "embargo preventivo" está autorizado expresamente por el artículo 210, inciso 4º, CPCCN, en tanto puede pedirlo "La persona que haya de demandar por acción reivindicatoria [...] mientras dure el juicio, y siempre que se presentaren documentos que hagan verosímil la pretensión deducida".

MNR

El artículo 221 del CPCCN agrega al "secuestro" de las cosas muebles "cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante..."

También se podría obtener una "prohibición de innovar".

XI. Sentencia

Prómovida la acción reivindicatoria hay dos posibilidades, que el juez rechace la demanda, o que haga lugar a ella. "Si se admite la demanda, el juez debe ordenar la restitución del objeto, parte material de él o sus restos. En cuanto a las reglas de cumplimiento de la sentencia, se aplican las normas del Capítulo 3 del Título II de este Libro..." (art. 2261).

Esta norma se refiere, en primer lugar, a la restitución de la cosa por parte del demandado vencido.

Además, deben arreglarse entre las partes las cuestiones referentes a los frutos, mejoras, productos, riesgos, etcétera, para lo cual se aplican las disposiciones del Código ubicadas en el Título II, Capítulo 3, del Libro Cuarto, que se refieren a los derechos y obligaciones del poseedor de buena y de mala fe.

Agrega dicha norma que "Si se trata de una cosa mueble registrable y media inscripción a favor del vencido, debe ordenarse la rectificación del asiento registral" (art. 2261).

C) ACCIÓN NEGATORIA

I. Concepto

Se expuso el concepto, la legitimación activa y la finalidad de la acción negatoria en el apartado A.

II. Legitimación pasiva

Dispone el artículo 2262 que "La acción negatoria compete contra cualquiera que impida el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, arrogándose sobre él alguna servidumbre indebida. Puede también tener por objeto reducir a sus límites verdaderos el

ejercicio de un derecho real". Este artículo complementa al artículo 2248, que había fijado el ámbito de la acción negatoria.

No se debe reducir la legitimación pasiva al supuesto de quien se arroga sobre el inmueble alguna servidumbre indebida. Es decir, el ámbito propio de la acción requiere que otro pretenda tener un *jus in re*, citándose a la servidumbre como el supuesto más común, pero no excluyente de otros que puedan presentarse. El segundo párrafo del artículo 2248 confirma esta idea.

Lo que podría denominarse el límite superior de la acción negatoria aparece nítido: si el ataque es de tal magnitud que produce una exclusión absoluta, un desapoderamiento, se está en el ámbito de la reivindicación. En cambio, no lo es tanto el límite inferior: ¿Cuál es la entidad mínima que debe tener la agresión para habilitar la acción real? Debe trascenderse la pretensión de ejercer una servidumbre, pero quien ha de ser demandado debe haber ejecutado al menos un acto que importe "el ejercicio de un derecho real" (art. 2248).

En términos más simples, esta acción procede cuando el ataque es menos grave que el desapoderamiento: turbación.

También reducir a sus límites verdaderos el ejercicio de un derecho real, lo que ocurriría, por ejemplo, si el demandado tiene una servidumbre de paso, que le permite pasar de mañana y a pie, pero lo hace durante todo el día, a pie, a caballo y en auto.

Como efecto complementario, se puede reclamar y obtener la reparación de los perjuicios ocasionados (art. 2250).

III. Objeto

Si bien el artículo 2262 alude a un "inmueble", no se puede descartar la viabilidad de una acción negatoria respecto de una cosa mueble (v. gr.: turbación en un automotor).

IV. Prueba

El Código distribuye la carga de la prueba, teniendo en cuenta que el derecho real se presume libre de cargas (arts. 1888, 1941). Dice en este sentido el artículo 2263 que "Al demandante le basta probar su

derecho de poseer o su derecho de hipoteca, sin necesidad de probar que el inmueble no está sujeto a la servidumbre que se le quiere imponer o que no está constreñido por el pretendido deber inherente a la posesión".

Lo primero que debe acreditar el actor es la titularidad del derecho real; en cambio, no necesita demostrar la inexistencia del gravamen que pretende imponerle el demandado, ya que el derecho real se presume libre de cargas y gravámenes (arts. 1888 y 1941), estando a cargo de quien pretende tener un derecho sobre la cosa de otro, la prueba de tal pretensión.

Sin perjuicio de lo expuesto, el actor, además de su derecho real, deberá acreditar la perturbación.

El demandado que, por ejemplo, ejerce una servidumbre puede reconvenir pidiendo que se declare la existencia del gravamen o que el actor cese de impedirle su ejercicio, lo que implicará una acción confesoria.

Si se trata de un acreedor hipotecario, éste debe probar "su derecho de hipoteca", y el derecho de poseer del titular del fundo afectado.

D) ACCIÓN CONFESORIA

I. Concepto

Se expuso el concepto, la legitimación activa y la finalidad de la acción confesoria en el apartado A.

II. Legitimación pasiva

Según el artículo 2264, "La acción confesoria compete contra cualquiera que impide los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente sus servidumbres activas". Esta norma complementa al artículo 2248, que había fijado el ámbito de la acción confesoria.

Cabe recordar que esta acción tutela a los titulares (o cotitulares) de todos los derechos reales sobre inmuebles que se ejercen por la posesión (también al acreedor hipotecario) en un supuesto específico: "ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión" (art. 2248). Si el acto lesivo no apunta a cuestionar

la servidumbre en sí misma (su existencia o su ejercicio), corresponde una acción de daños y perjuicios. Asimismo, puede ejercerse esta acción cuando se afecta otro derecho inherente a la posesión, constituido por las limitaciones al dominio (art. 1932), verbigracia, el vecino hace un ruido que supera la normal tolerancia.

La amplitud con que está concebido el artículo 2264 ("contra cualquiera") abre un amplio espectro de posibilidades en este punto. Así, por ejemplo, en una servidumbre de sacar agua, la acción se tendría contra el propietario del fundo sirviente que impidiera sacar agua o el paso para llegar a la fuente; y también contra el usufructuario, o el locatario de ese inmueble en las mismas circunstancias.

En cuanto a los límites impuestos al dominio en el Capítulo 4, Título III, del Libro Cuarto, cabe recordar que son deberes que alcanzan no sólo a titulares de derechos reales sino también a poseedores y tenedores, pues se trata de efectos de las relaciones de poder. Por ende, estos sujetos podrían ser demandados aun cuando no sean titulares de algún derecho real.

Así, por ejemplo, si un locatario produce un ruido que excede la normal tolerancia, puede ser sujeto pasivo de esta acción real.

III. Prueba

Aquí también se distribuye la carga de la prueba, teniendo en cuenta que el derecho real se presume libre de cargas (arts. 1888 y 1941). Prevé el artículo 2265: "Al actor le basta probar su derecho de poseer el inmueble dominante y su servidumbre activa si se impide una servidumbre; y su derecho de poseer el inmueble si se impide el ejercicio de otros derechos inherentes a la posesión; si es acreedor hipotecario y demanda frente a la inacción del titular, tiene la carga de probar su derecho de hipoteca".

Así, cuando se trate de alguien a quien se le impida ejercer los derechos inherentes a su posesión (p. ej., los derivados de relaciones de vecindad), al actor le bastará con acreditar su derecho de poseer (*ius possidendi*, derecho real). Si la lesión sufrida consiste en ser impedido de ejercer una servidumbre, el demandante deberá agregar el título de adquisición de esta última, ya que la existencia de una ser-

vidumbre, o su extensión, no pueden presumirse (arts. 1888, 1941, y concs.). Finalmente, en el supuesto de ejercicio por el acreedor hipotecario, éste deberá justificar su derecho de hipoteca mediante el instrumento público respectivo y, además, el derecho de poseer del titular del fundo gravado (para lo cual sería suficiente la escritura de constitución de la hipoteca), si se tratara del primer caso, adicionando el título de la servidumbre en el segundo.

E) ACCIÓN DE DESLINDE

I. Concepto. Naturaleza jurídica

La acción de deslinde se remonta a la histórica *actio finium regundorum* del Derecho Romano (Digesto 10, 1, 1 y 2).

Se puede definir al deslinde como el derecho que corresponde al propietario de una finca a cercarla, colocar mojones o hitos para distinguirla de las fincas colindantes (art. 1944). El problema se presenta cuando los límites son confusos, y no hay acuerdo entre los colindantes para fijarlos.

La finalidad de la acción es determinar, separar los puntos cuyos linderos estuviesen confundidos, por esto las propiedades deben ser contiguas, colindantes.

Dice el artículo 2266 que "Cuando existe estado de incertidumbre acerca del lugar exacto por donde debe pasar la línea divisoria entre inmuebles contiguos, la acción de deslinde permite fijarla de manera cierta, previa investigación fundada en títulos y antecedentes, y demarcar el límite en el terreno.

"No procede acción de deslinde sino reivindicatoria cuando no exista incertidumbre sino cuestionamiento de los límites".

a) Incertidumbre sobre el límite

En tanto haya "incertidumbre" sobre el lugar exacto del límite, resulta procedente esta acción para delimitar la zona respecto de la cual ambos vecinos manifiestan sus dudas acerca de la línea divisoria. El objeto de la acción es que los límites confundidos se fijen claramente, luego de una investigación. La investigación se basa en títulos y antecedentes.

Dice este artículo que cuando los límites están cuestionados no es la de deslinde la acción que corresponde, sino la de reivindicación.

b) *Presupuestos para el ejercicio de la acción de deslinde*

El artículo 2266 agrega otro presupuesto ineludible para la procedencia del deslinde: la contigüidad de los inmuebles.

Los fundos deben ser contiguos, ya que no cabe hablar de deslinde si estuvieran separados por otro fundo ajeno a la cuestión, por un camino público o por un accidente geográfico.

Si bien el artículo no lo dice, surge del artículo siguiente, el 2267, que la confusión se da normalmente entre dos inmuebles no edificados, cualquiera que fuera su ubicación, ya en la campaña, ya en una ciudad o poblado. Opuestamente, en los terrenos edificados, las cuestiones limítrofes serán dirimidas según el condominio de muros o medianería. Dice el artículo 2267 que debe tratarse de "un inmueble no separado de otro por edificios, muros, cercas u obras permanentes".

Además, los inmuebles no deben pertenecer al dominio público.

c) *Imprescriptibilidad*

Le cabe a la acción de deslinde la disposición del artículo 2247, que consagra la imprescriptibilidad de las acciones reales.

II. Legitimación activa y pasiva

Prevé el artículo 2267 que "El titular de un derecho real sobre un inmueble no separado de otro por edificios, muros, cercas u obras permanentes, puede exigir de los colindantes, que concurren con él a fijar mojones desaparecidos o removidos o demarcar de otro modo el límite divisorio. Puede citarse a los demás poseedores que lo sean a título de derechos reales, para que intervengan en el juicio..."

a) *Legitimación activa*

La legitimación activa está concebida con gran amplitud como que —en principio— abarca a cualquiera que sea titular de un derecho real

que recaiga sobre un inmueble no edificado, inclusive los acreedores hipotecarios y titulares de una servidumbre activa.

Cuando accione el titular de un derecho real sobre la cosa ajena, la sentencia que se dicte no será oponible al propietario, salvo que se lo cite al juicio, a instancia de cualquiera de las partes. También pueden ser citados otros poseedores legítimos, si los hay.

b) *Legitimación pasiva*

La legitimación pasiva no ofrece dificultades. En todos los casos, se debe demandar al dueño del fundo contiguo. La legitimación pasiva también es amplia, aunque es evidente que no pueden ser omitidos el dueño o los condóminos, en definitiva "colindantes", como dice el artículo. De tal forma, si se demanda a un usufructuario, debe ser citado al juicio el dueño, como sugiere la norma en la frase final del primer párrafo.

c) *La acción de deslinde contra el Estado. Distintos supuestos*

Agrega el artículo 2267 que "La acción puede dirigirse contra el Estado cuando se trata de bienes privados. El deslinde de los bienes de dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa".

d) *Deslinde contractual*

El artículo 2267 se refiere a una acción judicial pero, es obvio, nada impide que los interesados lleguen a un acuerdo privado sobre la cuestión limítrofe. Deberá ser formalizado en escritura pública.

III. Prueba y sentencia

Dispone el Código que "Cada una de las partes debe aportar títulos y antecedentes a efectos de probar la extensión de los respectivos derechos, en tanto el juez debe ponderar los diversos elementos para dictar sentencia en la que establece una línea separativa. Si no es posible determinarla por los vestigios de límites antiguos, por los títulos ni por la posesión, el juez debe distribuir la zona confusa entre los co-

lindantes según, fundadamente, lo considere adecuado" (art. 2268). Este artículo indica cuáles son los medios de prueba preferidos para resolver esta cuestión, y cuáles son las facultades del juez.

a) *La carga de la prueba*

En la acción de deslinde está implícita una suerte de acuerdo entre las partes, que hace mérito de la confusión de los límites, razón por la cual se entiende que es una de esas acciones en las cuales cada una de las partes es a la vez demandante y demandado, y debe por consiguiente probar su derecho.

Si ninguna de las partes prueba su aserto, el juez igual debe decidir. Deberá tener muy presente los datos catastrales.

Los títulos constituyen un medio de prueba muy importante.

En cuanto a la posesión, es importante evaluar el modo en el que fue adquirida. Esto porque si alguno poseyó despojo mediante, y hubo una posesión viciosa, el conflicto conducirá a una acción reivindicatoria más que a la de deslinde.

b) *Deslinde judicial*

El artículo 2268 se refiere al deslinde judicial, lo cual remite a las leyes de procedimiento.

A su vez, dicho artículo menciona solamente como pruebas a los vestigios antiguos, los títulos, y a la posesión. Se debe considerar en el primer grado de prelación a los títulos. Si con estos últimos no es posible definir la cuestión, se pasará a los vestigios, y en defecto de éstos, se acudirá a la posesión, porque *in pari causa melior est conditio possidentis*.

Cada una aportará títulos y antecedentes. Es probable que el juez designe un perito agrimensor para interpretarlos.

c) *Facultades del juez*

El Código muestra su interés en el sentido de que la cuestión limítrofe debe quedar resuelta. Aquí no se trata de rechazar una demanda y que las cosas queden como antes, pues no se debe olvidar la especial

situación de las partes en este proceso (recíprocamente actoras y demandadas). La ley es clara: el juez debe dividir la parte confusa entre los litigantes.

La división no tiene que ser, necesariamente, igualitaria. Esto queda a criterio del juez.

F) RELACIONES ENTRE EL PETITORIO Y EL POSESORIO

I. Prohibición de acumular

Lo dice con claridad el artículo 2269: "No pueden acumularse las acciones reales con las acciones posesorias". Esto significa que mientras tramitan las acciones posesorias, las acciones reales deben esperar que aquéllas terminen. No pueden tramitar en forma paralela.

Si se opta por iniciar acciones reales, ya no será posible iniciar acciones posesorias. Se puede ir de menor a mayor.

II. Separación entre el posesorio y el petitorio. Independencia de las acciones

El principio es el de la separación entre ambas clases de procesos, lo que surge del artículo 2269, y se complementa con lo que establecen los artículos que lo siguen. El artículo 2273 dice que "El titular de un derecho real puede interponer la acción real que le compete o servirse de la acción posesoria; si intenta la primera, pierde el derecho a promover la segunda; pero si interpone la acción posesoria puede iniciar después la real".

Dice el artículo 2271 que establecido el juicio posesorio, el petitorio no puede tener lugar, antes de que "la instancia posesoria haya terminado", lo que no es sino un corolario del artículo 2269, que sienta el principio de la no acumulación, y del artículo 2273 que establece la prelación: se pierde la acción posesoria cuando en primer término se intenta la acción real, lo que no ocurre en el caso inverso.

III. Prueba

Dispone el artículo 2270 que "En las acciones posesorias es inútil

la prueba del derecho real, mas el juez puede examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión".

En consecuencia de lo expuesto, el demandante en el juicio posesorio no tiene que probar su derecho, si es que lo tiene. En principio, para triunfar le basta con acreditar su relación de poder y la lesión de que ha sido objeto (desapoderamiento o turbación).

Tampoco el demandado puede reconvenir u oponer excepciones propias del juicio petitorio, es decir, fundadas en un derecho de poseer (v. gr.: que es dueño de la cosa).

IV. Suspensión de la acción real

Dispone el artículo 2271 que "Iniciado el juicio posesorio, no puede admitirse o continuarse la acción real antes de que la instancia posesoria haya terminado". Es una consecuencia de la separación del petitorio y del posesorio y de la no acumulación de acciones que son independientes (arts. 2270 y sus conchs.).

Esta norma establece la prioridad del juicio posesorio cuando es iniciado antes que la acción real. Cabe aclarar que esto es así cuando se trata del mismo hecho.

No obstante, el juez del petitorio puede adoptar medidas cautelares. Por ende, si se inicia el juicio petitorio, su trámite debe ser suspendido hasta tanto finalice el posesorio.

V. Cumplimiento previo de condenas

Prevé el artículo 2272 que "Quien sea vencido en el juicio posesorio, no puede comenzar la acción real sin haber satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas en su contra". Se trata de un requisito para iniciar la acción real luego de concluida la instancia posesoria.

El artículo 2272 es una consecuencia de lo anterior, sobre todo de la disposición del artículo 2271. La ley se refiere a quien sea vencido, lo que puede ocurrir con el actor o el demandado. Claro que si se trata del último, debe restituir la posesión o la tenencia al demandante o cesar en su turbación, satisfaciendo también las condenaciones accesorias (costas, daños y perjuicios), para que se le habilite la vía petitoria. En cambio, para el actor, las condenaciones serán menores.

VI. Acciones por un mismo hecho

MNR

El tema es considerado por el artículo 2273 de la siguiente forma: "El titular de un derecho real puede interponer la acción real que le compete o servirse de la acción posesoria; si intenta la primera, pierde el derecho a promover la segunda; pero si interpone la acción posesoria puede iniciar después la real".

a) *Opción entre acciones posesorias y acciones reales*

El artículo 2273 se refiere al titular de un derecho real. Si es turbado o despojado en su posesión, puede optar entre ejercer la acción posesoria o la acción real correspondiente.

El titular del derecho real (salvo el acreedor hipotecario) puede optar entre la acción posesoria o la real porque cuenta con ambas. En cambio, el poseedor sin derecho de poseer, es decir que no es titular de un derecho real, sólo puede defenderse a través de las acciones posesorias. No puede optar por una tutela de la que carece. Tampoco tiene la opción el tenedor.

b) *Opción por la acción posesoria*

Si el turbado o desapoderado opta por la acción posesoria, subsiste entonces la posibilidad de ejercer la acción real, para lo cual será necesario que la instancia posesoria se encuentre terminada (art. 2272). Ocurre que en la instancia posesoria sólo se discuten las situaciones de hecho, sin que se examinen los derechos de las partes, razón por la que el Código autoriza al vencido a promover una instancia distinta, en la que se decida el fondo de la cuestión con los efectos de la cosa juzgada definitiva. En la instancia posesoria se deciden cuestiones en forma provisional; la cosa juzgada es material, pero sólo en lo que tiene que ver con la relación de poder (arts. 2241/2242).

El artículo 2273 tiene en miras que el turbado o desapoderado que inicia la acción posesoria sea vencido, es decir que su demanda sea rechazada, en cuyo caso le permite plantear la cuestión en el juicio petitorio. Sin embargo, puede suceder que dicho poseedor lesionado triunfe en su acción posesoria, en cuyo caso ya no tendrá interés en promover la acción real, pero es el demandado vencido quien tiene

la posibilidad de utilizar la acción real (obviamente si tiene o cree tener derecho de poseer). Esto significa que la solución es la misma cualquiera sea el resultado del juicio.

c) *Opción por la acción petitoria*

Esta opción sólo la tiene quien cuente con derecho de poseer, haya usado o no la acción posesoria. La consecuencia de optar directamente por la acción real es que "se pierde el derecho a promover la segunda".

La solución legal ha sido objeto de distintas explicaciones: a) la opción por la acción real importa una renuncia a la acción posesoria. Se trata de la antigua máxima *electa una via non datur regresus ad alteram*; b) implica el reconocimiento de la posesión del demandado; c) significa reconocer que no se tiene derecho a las acciones posesorias; d) no se puede acudir a remedios de carácter provisional; si el demandante es vencido en el petitorio es porque obviamente no tenía *ius possidendi*, por lo que mal puede pretender luego el *ius possessionis*.

Cabe considerar que hay razones de mayor peso y sentido práctico. La sentencia que se dicte en el juicio petitorio, de trámite ordinario, no es provisional sino definitiva, luego de admitirse con amplitud la prueba y el ejercicio del derecho de defensa. Se discuten los derechos de las partes y la sentencia hace cosa juzgada. Al ser así, mal puede luego acudirse a una acción de trámite más sencillo y de efectos más limitados, cuando ya todo está decidido. La verdadera razón de ser de la solución legal debe encontrarse en el instituto de la cosa juzgada.

d) *Inconstitucionalidad del artículo 623 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*

La segunda parte del artículo 623 del CPCCN dispone que "Deducida la acción posesoria o el interdicto, posteriormente sólo podrá promoverse acción real". Es inconstitucional la última parte del artículo 623 arriba transcrito, al seccionar tutelas que brinda el Código Civil y Comercial, desbordando la esfera de atribución de facultades entre la Nación y las jurisdicciones locales.

De acuerdo al Código Civil y Comercial (ley nacional) es posible promover la acción posesoria, y todavía las partes tienen a su disposición la acción real. De acuerdo al artículo 623, segunda parte, del Código Procesal (ley local), después de promovido un interdicto sólo cabría la posibilidad de deducir la acción real. Evidentemente, el Código Procesal ha eliminado defensas previstas por la ley de fondo, lo que justifica que se cuestione su constitucionalidad.

Salvo que se interprete que los interdictos y las acciones posesorias son lo mismo, que los primeros son la regulación procesal de las segundas, pero no hay elementos para arribar a esa conclusión, máxime si se tiene en cuenta que el actual Código Civil y Comercial es posterior al procesal.

VII. Acciones por distintos hechos

Según el artículo 2274: "El demandante en la acción real no puede iniciar acciones posesorias por lesiones anteriores a la promoción de la demanda, pero sí puede hacerlo el demandado". La opción hecha por el actor no perjudica al demandado.

a) *Situación del actor que optó por el petitorio*

Hay que advertir que el artículo 2274 refuerza la idea de que se pierde la acción posesoria "por lesiones anteriores a la promoción de la demanda" petitoria. Esto significa que, iniciado el juicio petitorio, no se pierde la posibilidad de iniciar el juicio posesorio por "hechos posteriores" a la deducción de dicha demanda (art. 2276).

b) *Situación del demandado en el petitorio*

Por hechos o ataques posteriores a la interposición de la demanda, ambos, demandante y demandado en el juicio petitorio, tienen acciones posesorias. Sin embargo, para el demandado, la situación es distinta. Él no ha promovido la acción real y no puede verse entonces privado de la acción posesoria, porque aquélla la haya intentado el actor, de modo que también puede ejercer acciones posesorias por turbaciones anteriores al juicio petitorio.

VIII. Turbaciones o desapoderamientos recíprocos

En el caso de lesiones recíprocas se prevé también la necesidad de cumplir previamente con la sentencia para luego iniciar acciones por hechos anteriores. Dice el artículo 2275: "Si los hechos constituyen turbaciones o desapoderamientos recíprocos, quien es condenado en la acción posesoria y cumple con la sentencia de restitución, puede a su vez entablar o continuar la acción posesoria o real respecto del hecho anterior".

Así, por ejemplo, alguien es desapoderado. En lugar de iniciar la acción posesoria, recupera la cosa por las suyas haciendo justicia por mano propia. El despojado le inicia la acción posesoria y lo vence, por lo que debe restituir la cosa. No obstante, le queda la posibilidad de iniciar ahora la acción posesoria por el hecho anterior, que es el primitivo desapoderamiento por el que debió demandar en lugar de recobrar la cosa de propia autoridad. La misma solución cabe si en vez de un desapoderamiento sufrió una turbación, y luego despoja al que lo turbó.

IX. Hechos posteriores

La promoción de la acción real no impide la iniciación de una acción posesoria si se trata de hechos posteriores. Así lo establece el artículo 2276: "La promoción de la acción real no obsta a que las partes deduzcan acciones de defensa de la posesión y la tenencia por hechos posteriores".

CAPÍTULO XXIV PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA MNR

SUMARIO: I. Antecedentes históricos. II. Introducción. III. Concepto. Fundamentos. IV. Diferencia con la prescripción liberatoria. V. Modo originario. VI. Elementos. VII. Sujetos. VIII. Objeto. IX. Renuncia. X. Suspensión. XI. Dispensa. XII. Interrupción. XIII. Prescripción breve. XIV. Prescripción larga. XV. La ley de regularización del dominio.

I. Antecedentes históricos

La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los derechos reales. Su origen no es reciente. La primera manifestación de esta particular forma de adquirir un derecho real se remonta a las Leyes de Manú (traducción popular de Manava-Dharma-Sastra), las que fueron recopiladas entre los años 1280 y 880 a. C.

Entre los antecedentes de la usucapción, no puede soslayarse el tratamiento que recibió en el Derecho Romano, y cabe destacar que a través del paso del tiempo, el criterio sobre la materia ha evolucionado desde la ley de las XII Tablas (año 451 a. C.).

Sobre la *usucapio* se decía: "es la agregación del dominio mediante la continuación de la posesión por el tiempo determinado en la ley" (Tabla VI, D. 41, 3, 3).

En la época clásica, se encontraban dos casos en los que no era necesaria ni la buena fe ni el justo título. Se trataba de la *usucapio pro herede lucrativa* y de la *usureceptio*.

Con Justiniano, desaparecida la distinción entre las cosas *manici* y *nec mancipi*, y entre los dominios quiritalio y bonitalio, se funden

la antigua *usucapio* del *ius civile* y *longi temporis praescriptio* de las provincias. Se da el nombre de *usucapio* a la vinculada a las cosas muebles, para las cuales se exigía una posesión de tres años, mientras que la *longi temporis praescriptio*, para los inmuebles, requería diez años entre presentes y veinte entre ausentes; ambas con título y buena fe. Más tarde se contempló la *praescriptio longissimi temporis*, para la cual se requería posesión por treinta o cuarenta años, aunque fuere de mala fe.

A través de Las Partidas fue que esta institución se introdujo en el Derecho patrio.

II. Introducción

El Código se ocupa de definir a la prescripción adquisitiva como uno de los modos de adquirir derechos reales. Dice el artículo 1897 que "La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley".

Se conoce a este modo de adquirir también con el nombre de *usucapion*, que significa adquirir algo (*capere*) por el uso (*usus*), la posesión.

Es un modo de adquirir derechos reales, por actos entre vivos y de manera gratuita.

Hay dos clases de prescripción: 1) la larga, que requiere la posesión durante el plazo de diez o de veinte años (art. 1899); 2) la breve, en la que el plazo es de diez o de dos años (art. 1898), y además se necesita contar con justo título y buena fe. Los plazos más breves, en cada una, sólo se aplican en la adquisición de cosas muebles, cumplidos ciertos recaudos.

Las normas que regulan la prescripción son de orden público, no pueden ser modificadas por una convención (art. 2533).

III. Concepto. Fundamentos

La *usucapion* es una institución por medio de la cual el transcurso del tiempo opera para la adquisición o consolidación de un dere-

cho y, como contrapartida, como la pérdida de ese derecho para el anterior titular de ese determinado derecho real.

Como se verá más adelante, no se limita a la adquisición del dominio, sino que puede utilizarse para adquirir cualquiera de los derechos reales que se ejercen por medio de la posesión, menos la prenda y la anticresis, porque al tratarse de derechos de garantía no admiten como fuente la prescripción, sino únicamente la convención de partes.

El artículo 2565 establece como regla general que se pueden adquirir por prescripción los derechos reales principales. Los derechos reales principales son todos, menos la hipoteca, la prenda y la anticresis, que son accesorios (art. 1889).

Surge la duda con respecto a las servidumbres positivas, ya que también son derechos reales principales y se ejercen por medio de actos posesorios concretos (art. 1891). El primer uso es modo suficiente de adquisición de tales servidumbres (art. 1892, quinto párrafo). Me inclino por la respuesta afirmativa.

Varios son los fundamentos de este instituto, pues pueden darse argumentos de carácter social o económico, lo cual demuestra su importancia.

Obsérvese, por ejemplo, que una cosa abandonada no beneficia a nadie. Por ese motivo, la ley pretende que ésta sea aprovechada económicamente y que pueda ser utilizada por quien la necesite o, simplemente, por quien quiera darle un destino útil, aun cuando se trate de su interés particular, aunque sea en desmedro del verdadero propietario, siempre que éste —se insiste— haya hecho abandono o se haya desinteresado de la cosa.

En esos términos, una situación de hecho se transforma en una situación de derecho.

No puede soslayarse que un inmueble que estaba deshabitado y es ocupado por quien no es su dueño, puede representar una ventaja para las arcas del Estado, si ese individuo comienza a abonar los impuestos y tasas que graven la cosa.

¿Pero la sola desocupación de la cosa produce la pérdida del derecho que se tenía sobre ella? No, ya que el dominio no se extingue por el no uso (art. 1942). A ello debe agregarse una actividad positiva del

prescribiente, quien debe cumplir con ciertos recaudos, esto es, poseer la cosa con ánimo de dueño durante el tiempo indicado por la ley. Aquí se aprecia el equilibrio entre los derechos del dueño, por un lado, y la llamada función social de la propiedad, por el otro.

La prescripción es un respaldo al poseedor que trabaja la tierra, que la explota en beneficio propio o de la sociedad y, a la vez, una especie de sanción al propietario que no la hace producir.

Es un elemento catalizador de las relaciones sociales. Ofrece seguridad a las relaciones jurídicas, garantiza la paz social, despeja dudas otorgando certeza.

IV. Diferencia con la prescripción liberatoria

a) *Distintas posturas*

Se discute si la usucapión (o prescripción adquisitiva) y la prescripción liberatoria son dos institutos diferentes, o si se trata del mismo, pero examinado desde distintos ángulos. Esta discusión escapa al ámbito doctrinario, pues ha llevado a que se legisle la cuestión de manera diferente en distintos ordenamientos, según se adopte una u otra postura.

No obstante, todos los autores coinciden en que entre ellos hay muchas semejanzas. Por ejemplo, nadie desconoce que el tiempo es un elemento fundamental en ambos, y que las causales de suspensión e interrupción también son las mismas.

b) *Metodología del Código Civil y Comercial*

En el Código Civil y Comercial, la prescripción adquisitiva y la liberatoria están reguladas, en general, en forma conjunta:

El Libro Sexto se titula *Disposiciones comunes a los derechos personales y reales*. El Título I, Capítulo 1, contiene *Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva*, y luego trata "normas generales" (Sección 1ª), y se establecen reglas comunes a ambas especies, en lo tocante a los supuestos de suspensión (Sección 2ª) y a los de interrupción (Sección 3ª), la dispensa (Sección 4ª) y las disposiciones procesales aplicables a ambos tipos (Sección 5ª). Luego, en el

Capítulo 2 se ocupa de la prescripción liberatoria, y en el Capítulo 3 dedica un solo artículo a la prescripción adquisitiva (art. 2565), remitiendo a los artículos 1897 y siguientes.

Como puede observarse, el tratamiento de ambas especies es en general conjunto, separando las normas específicas para su inclusión en capítulos diferenciados.

c) *Balance*

Existen muchas similitudes entre la prescripción adquisitiva y la liberatoria; en especial, la necesidad de transcurso del tiempo. A ellas cabe agregar que el régimen legal establece los mismos principios en lo que atañe a su posibilidad de renuncia o al momento procesal oportuno para plantear la prescripción esgrimida. También coinciden en que no pueden pronunciarse de oficio, sino que la prescripción siempre se decreta a pedido de parte.

Sin embargo, no se puede desconocer que la prescripción liberatoria tiene lugar en el ámbito de los derechos personales, en tanto que la adquisitiva en el de los reales; que en la adquisitiva se requieren mayores plazos que en la liberatoria; que la determinación de la competencia es diferente; y que la posesión no se exige en la liberatoria.

Se han señalado algunas de las diferencias que existen entre la prescripción adquisitiva y la liberatoria. Sin embargo, lo relevante es que ambas producen las mismas consecuencias. Adviértase que tanto una como otra generan la pérdida de un derecho. En la adquisitiva, el anterior titular de un derecho real, lo perderá y no podrá reclamar su devolución, en tanto que en la liberatoria, el acreedor perderá el derecho a perseguir el cobro de un crédito a su favor. Además, ambas también generan la adquisición de un derecho. En la adquisitiva, se adquiere el derecho real que perdió el anterior titular; por su parte, en la liberatoria, el deudor adquiere el derecho a que no se le reclame más una determinada obligación.

Consecuentemente, la metodología utilizada por el Código Civil y Comercial ha sido acertada al tratar a ambas especies de manera conjunta, e indicando en forma separada aquellas particularidades que hacen a cada una de ellas.

V. Modo originario

Se discute si se trata de un modo de adquirir originario o derivado.

En la prescripción larga, habrá que analizar si existe título y, de ser así, sus caracteres. Es claramente originario cuando mediere violencia, clandestinidad o abuso de confianza, ya que en estos casos no sólo no existe título sino que la intención del propietario no fue la de transmitir su derecho, pues quien persigue la prescripción es su contrádictor, pretendiendo que su posesión triunfe sobre la de aquél (conforme lo dispuesto por el art. 1913, no pueden concurrir sobre una misma cosa, dos posesiones iguales y de la misma naturaleza). La solución se complica en el supuesto en que se haya firmado un boleto de compraventa. Si bien, en principio, la intención es transmitir la cosa —y generalmente se transmite la posesión por este medio—, dicho instrumento no es título suficiente, ni siquiera puede considerárselo como justo título para transmitir, motivo por el cual sólo podrá adquirirse la cosa por usucapión larga; por ende, al no transmitirse el dominio, no puede hablarse de modo derivado de adquisición, aunque es dable aclarar que el paso del tiempo fijado para la usucapión larga servirá para consolidar la transmisión. Suscita alguna duda el caso previsto en el artículo 1899, párrafo tercero, pues aquí la cosa mueble registrable fue entregada por el titular registral.

Lo concreto es que la doctrina mayoritaria, a la que se adhiere, a pesar de las enseñanzas de algunos clásicos franceses, sostiene que la usucapión larga es un modo originario de adquirir el dominio, ya que no hay nexo entre el anterior dueño y el nuevo propietario. El usucapiente no recibe su derecho de un *tradens*, salvo en el caso especial antes mencionado previsto en el artículo 1899, párrafo tercero.

Que sea un modo originario no significa que el poseedor reciba la cosa libre de gravámenes, ya que la sentencia no tiene efecto retroactivo. La suerte de tales cargas dependerá de diversos factores que deben ser apreciados en cada caso concreto. Es originario porque el adquirente no deriva su derecho del anterior dueño.

Sin embargo, las opiniones se dividen cuando se trata de la usucapión breve. Para algunos se trata también de un modo originario (Borda), mientras que otros sostienen lo contrario, afirmando que hay

un nexo entre el antecesor y el sucesor que se visualiza en la necesidad de contar con justo título y buena fe (Laquis).

Parece más convincente la primera de las posturas ya que en la prescripción decenal también el adquirente prescinde de la titularidad de su antecesor en tanto su título emana de quien no estaba legitimado para transmitir. Además, se necesita de la posesión y de la buena fe para consolidar la situación. Esta idea parece ser la predominante en la doctrina italiana (Pugliese, Bianca). Cabe hacer la salvedad, como dijimos, del especial caso de la transmisión por parte de un incapaz.

VI. Elementos

La prescripción larga se apoya en dos elementos fundamentales: a) la posesión; b) el tiempo. La prescripción breve suma otros dos recaudos: a) el justo título; b) la buena fe.

a) La posesión

En el Código se regulan dos relaciones de poder, la posesión y la tenencia. La tenencia es inútil para adquirir por prescripción, se necesita ser poseedor (ver art. 1909).

La posesión puede incluso ser de mala fe, lo que es indiferente. Lo que exige el Código es que sea "ostensible y continua" (art. 1900).

La posesión es ostensible (pública) cuando no es clandestina (ver art. 1921). El Código pretende que el titular del derecho real tenga la posibilidad de conocer la posesión que se ejerce en su contra, dado que tiene derecho a oponerse a ella.

Además, la posesión tiene que ser continua y no interrumpida. La continuidad, esto es, la realización de actos posesorios en forma sucesiva, continuada, depende del propio poseedor, aunque hay que tener en cuenta la presunción de continuidad que establece el artículo 1930. En cambio, la interrupción no depende de la omisión del poseedor sino de un acto positivo, que puede ser realizado por el propietario o por un tercero (v. gr.: demanda —art. 2546—), y aun ese acto puede emanar del propio poseedor, como cuando reconoce el derecho del propietario sobre la cosa (ver art. 2545).

Para que el poseedor pueda adquirir el derecho real en perjuicio de quien hasta ese momento era su titular, debe probar tal posesión. La prueba se concreta, esencialmente, en la demostración de haber realizado actos posesorios (art. 1928) sobre la cosa durante el tiempo requerido. La jurisprudencia suele ser estricta en la valoración de la prueba, si se tiene en cuenta que está en juego el derecho de propiedad de quien por el momento es el dueño.

a.1) El "animus". Alcances

Para que se adquiera la posesión debe existir en cabeza de quien la detente el *corpus* y el *animus domini*; debe comportarse como si fuera el verdadero propietario, esto es, sin reconocer en otra persona el derecho de propiedad, aun cuando carezca de derecho para ello.

Corresponde recordar que no sólo se puede adquirir el derecho real de dominio por prescripción, sino que este instituto también sirve para adquirir otros derechos reales. En estos casos, se valorará la intención del poseedor, y de ella se derivará la adquisición de un determinado derecho real, por ejemplo, el de usufructo.

a.2) Posesión ostensible

Ostensible, del latín *ostendere*, según el *Diccionario* de la Real Academia Española significa "que puede manifestarse o mostrarse", o "claro, manifiesto, patente".

La posesión es ostensible cuando ella es la exteriorización del uso normal de la cosa, conforme a su naturaleza y a su destino; cuando el poseedor no intenta ocultar a nadie su posesión. No sería tal cuando es clandestina.

El carácter público de la posesión, y su exteriorización unívoca, es imprescindible para que el verdadero titular del derecho real sobre la cosa pueda darse cuenta de que un tercero está ejerciendo sobre ella actos de posesión, a fin de poder repelerlos en su caso.

En esos términos, ¿cuándo se considera pública una posesión?

Lo importante no es que sea efectivamente conocida por el propietario o anterior poseedor, ya que basta con que éstos hayan tenido la posibilidad de conocer la nueva posesión. Lo indicado precedente-

mente adquiere relevancia en cuanto a las acciones que se pueden hacer valer para conservar o recuperar una cosa.

Lo contrario de la posesión ostensible es la posesión clandestina, por lo que si bien puede adquirirse la posesión de una cosa por clandestinidad, mientras dure con estas características no podrá considerarse para el cómputo del tiempo fijado por la ley para usucapir, motivo por el cual deberá purgarse el vicio.

Para poder usucapir no basta el conocimiento o la posibilidad de conocimiento por el propietario desposeído, pues es necesario que la posesión sea ostensible, manifiesta, para todos, dado que la adquisición por usucapición se configura no sólo contra el anterior propietario, sino contra todos los terceros. No debe olvidarse que el derecho real adquirido por usucapición es regularmente oponible a todos.

a.3) Posesión continua

El artículo 1900 exige también que la posesión sea "continua". La continuidad, esto es, la realización de actos posesorios en forma sucesiva, continuada, depende del propio poseedor, aunque hay que tener en cuenta la presunción de continuidad que establece el artículo 1930.

La continuidad de la posesión se traduce en la realización por parte del poseedor de actos posesorios cumplidos con regularidad, como los haría el verdadero propietario.

Consiste en la sucesión regular de los actos de posesión, a intervalos suficientemente cortos como para que no existan lagunas. No se exige el manejo o uso constante de la cosa, minuto tras minuto.

Dado que el artículo 1930 presume la continuidad, la prueba de ser discontinua la posesión estará a cargo de quien la afirme.

a.4) Posesión ininterrumpida

La ininterrupción significa que no haya interferencias de parte de terceros en el goce de la posesión. Así como la continuidad depende —en principio— del propio poseedor, la interrupción puede ser causada por el propio poseedor, o por terceros (v. gr.: reconocimiento, demanda de reivindicación del verdadero dueño). La discontinuidad su-

pone una *omisión* del poseedor, mientras que la interrupción supone un *hecho positivo* del poseedor o de un tercero.

Las Leyes de Partidas ya contemplaban este requisito de la posesión, al entender que la posesión no interrumpida por más de 30 años, daba derecho al poseedor para ampararse aun contra el propietario que se la demandase.

b) *El tiempo*

b.1) *Plazos*

Al ser la usucapión un modo de adquisición de derechos reales, debe establecerse como condición que la inacción del propietario y la voluntad del usucapiente se extiendan por un período determinado de tiempo. El artículo 1897 es de carácter general, limitándose a la referencia "durante el tiempo fijado por la ley".

Por su parte, el artículo 1898 se refiere a los supuestos en los que se adquiriera un inmueble o una cosa mueble con buena fe y justo título, indicando que se requieren "diez años", si se trata de un inmueble, y de "dos" para un mueble. A ésta se la denomina comúnmente prescripción breve, corta.

A su turno, el artículo 1899 regula la usucapión de cosas inmuebles por la posesión continua de veinte años, y de diez años para un caso especial de adquisición de cosas muebles registrables. Es la denominada prescripción larga o extraordinaria.

Por último, el artículo 2254 está relacionado a la prescripción de ciertas cosas muebles, los automotores hurtados o robados inscriptos, señalando que el plazo es de dos años si hubo posesión de buena fe.

No es necesario que todo el período estipulado por la norma sea cumplido por el usucapiente, pues también puede aprovecharse de la posesión de sus antecesores. Para que esto sea viable, deberán cumplirse los requisitos necesarios para la accesión de posesiones (art. 1901).

b.2) *Inicio del cómputo*

El inicio del cómputo de la prescripción adquisitiva está dado por el inicio de la posesión; de ahí la necesaria interrelación que debe

existir entre estos dos elementos. Ésta es la regla general, mientras que dispone el artículo 1898 que "Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título". Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1903, primera parte, y procurando interpretar ambas normas, cabe entender que esto rige para las cosas muebles cuya registración sea constitutiva.

Bajo determinadas circunstancias, el inicio de la posesión se presume: así, el artículo 1914 del Código Civil y Comercial dispone que "Si media título se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título..."

Como resulta del artículo 1903, tal presunción admite prueba en contrario. Siendo posible la accesión de posesiones, la presunción rige no sólo con relación al título que presente el poseedor, sino también respecto del título de su antecesor.

Se resalta la importancia de determinar la fecha en que se adquirió la posesión, para que a partir de ese momento se compute el plazo de dos, diez o veinte años, según las condiciones que reúne el usucapiente o el título que éste posea. No obstante, puede resultar innecesaria la determinación del día exacto en que se inició la posesión, por ejemplo, cuando ésta se extendió por un plazo muy superior al indicado en la norma.

Otra cuestión a determinar es cuándo empieza a contarse el tiempo que corre contra quien tiene *derechos condicionales o a plazo*. El hecho de que el perjudicado por la prescripción tenga un derecho sujeto a plazo o a condición suspensiva no impide que se consuma la usucapión.

b.3) *Cómputo del tiempo*

Si bien nuestro Código Civil y Comercial no contempla específicamente esta cuestión en la sección dedicada a la prescripción, resulta de aplicación la norma de carácter general resultante del artículo 6°.

c) *Unión de posesiones*

Según el artículo 1901: "El heredero continúa la posesión de su causante. El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus

antecesor, siempre que derive inmediatamente de las otras. En la prescripción breve las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico". Esta norma se refiere a la accesión de posesiones, diferenciando el caso de la sucesión universal del de la sucesión a título particular.

La accesión, o suma de dos o más posesiones, tiene una enorme importancia cuando se trata de arribar al número de años necesario para adquirir por usucapión.

c.1) *Caso de sucesión universal*

Los herederos no hacen sino continuar la persona del difunto: ellos no comienzan una nueva posesión, continúan sólo la posesión de su autor, y la conservan con las mismas condiciones y las mismas calidades: si era de buena fe, continúa como tal, aunque el heredero llegare a saber que la heredad pertenecía a otro.

De ahí que el heredero tenga la posibilidad de adquirir por usucapión las cosas poseídas por el causante, o se pueda defender con las acciones posesorias o reales, al igual que lo hubiera podido hacer dicho causante, si la posesión de él sufrió alguna turbación o despojo.

Teniendo en cuenta que el artículo 1901 se refiere al heredero, cabe incluir a los legatarios de cuota y a los cesionarios de herencia, que también son sucesores universales, y excluir de esta solución al legatario de cosa cierta.

c.2) *Sucesión particular. Unión de posesiones*

Los sucesores particulares no continúan la posesión de su autor; no hay identidad jurídica en las personas; no representan a su autor; no suceden en sus obligaciones. El autor del sucesor puede tener una condición totalmente diferente, que impida unir la posesión del uno a la del otro. Hay dos posesiones distintas, que en ciertos casos tienen la posibilidad de unirse.

Es posible que un poseedor de mala fe (porque conocía la ilegitimidad de su posesión) transmita por venta u otro título la cosa a un tercero. Nada impide que éste pueda ser reputado de buena fe, pues aquí la calificación se hace en la persona del sucesor.

Ahora bien, así como la posesión del sucesor singular constituye un hecho independiente de la posesión del antecesor, el Código posibilita que si se dan determinadas condiciones, ambas posesiones puedan unirse o sumarse, lo que recibe el nombre de "unión o accesión de posesiones".

Si la sucesión es a título universal, no es necesario recurrir a esta figura, ya que el heredero ocupa el lugar de su causante. En cambio, en la sucesión a título particular, la figura presenta interés en tanto puede ser útil para completar el tiempo necesario para adquirir por prescripción.

c.3) *Requisitos de la unión de posesiones*

Para que pueda operarse la accesión de posesiones debe satisfacerse un requisito: que proceda la una de la otra inmediatamente. El artículo 1901 permite más de una unión ya que usa el plural (sus antecesores, otras), pero debe haber un encadenamiento sucesivo. Una persona no podría unir su posesión a la del antecesor de su antecesor, sin unir también la del segundo.

En el caso de la prescripción breve, ambas deben ser de buena fe, pero además se exige que las posesiones estén ligadas por un "vínculo jurídico". Es claro que si no existiera ese vínculo jurídico, el justo título no podría invocarse buena fe. Si se trata de cosas muebles registrables, debe haber inscripción registral si ésta es constitutiva.

En cambio, para la larga, sería suficiente que un antecesor entregase la cosa al poseedor actual, aun cuando no se satisfagan formalidades.

El artículo 1901 dice que "el sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores", y cuesta apreciar una "sucesión particular" cuando hay desapoderamiento. Dice dicha norma: cuando "deriva inmediatamente", lo que excluye al despojo.

VII. Sujetos

Artículo 2534: "La prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario.

"Los acreedores y cualquier interesado pueden oponer la prescripción, aunque el obligado o propietario no la invoque o la renuncie".

a) *¿Quiénes pueden invocar la prescripción?*a.1) *Las personas humanas*

El citado artículo 2534 establece que "La prescripción opera a favor y en contra de todas las personas..."

Como la prescripción es una institución que interesa al orden público (art. 2533), en lo que hace a su régimen nuestro Código puso expresamente en un pie de igualdad ante todo a las personas humanas capaces de hecho y de derecho, a los incapaces de hecho sometidos a la pertinente representación y a las personas jurídicas privadas.

Cuando un incapaz de derecho (se les prohíbe el ejercicio de ciertos actos o la adquisición de algunos derechos) para adquirir igualmente adquiere (por sí o por representante—en su caso—), el acto debe reputarse ineficaz. No obstante, cabe remarcar que la nulidad o anulación del acto no resulta óbice a la adquisición por prescripción, toda vez que al que ha poseído durante el tiempo exigido por la ley, no puede oponérsele ni la falta de título, ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión.

Los incapaces de hecho pueden adquirir la posesión por medio de sus representantes legales (padres, tutores o curadores; arg. arts. 100, 101, 1922, inc. a, Cód. Civ. y Com.).

a.2) *Las personas jurídicas*

Las personas jurídicas actúan a través de sus representantes legales, y bien pueden adquirir o perder bienes por usucapión. En el primer caso, habrá que ver cuáles son sus fines y objeto.

a.3) *El Estado*

Las personas jurídicas pueden ser privadas o públicas, y entre estas últimas se encuentra el Estado (nacional, provincial, municipal).

Dispone el artículo 237 que "Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales".

El Estado podría adquirir por prescripción, y los bienes que se encuentran en su dominio privado son susceptibles de ser adquiridos por este medio, quedando fuera los del dominio público.

El inciso e, del artículo 236 dice que pertenecen al dominio privado del Estado (nacional, provincial, municipal) los que éste adquiera "por cualquier título". La expresión "cualquier título" abarca, sin duda, a la prescripción.

En cuanto a la instrumentación, hay que remitirse a lo previsto en las leyes 20.396 y 21.477.

Como excepción, se puede mencionar el supuesto en el que leyes nacionales encierran una declaración expresa de imprescriptibilidad. Se ha aceptado que el Estado adquiera por prescripción inmuebles expropiados, cuando les ha dado un destino distinto del que motivó la expropiación o, lisa y llanamente, no les ha dado destino alguno.

a.4) *La Iglesia*

Como el artículo 146, en su inciso c, incluye a la Iglesia Católica entre las personas jurídicas de carácter público, ésta también puede adquirir cosas por medio de la prescripción.

La norma sólo contempla a la Iglesia Católica. En lo que atañe a las iglesias pertenecientes a otras religiones o cultos, éstas pueden llegar a ser personas privadas, correspondiéndoles, en consecuencia, el régimen legal en materia de usucapión aplicable a las personas jurídicas de carácter privado.

b) *¿Contra quiénes se puede prescribir?*

En principio, sujetos pasivos de la usucapión son los mismos que pueden ser sujetos activos. No obstante, corresponde hacer los siguientes comentarios.

b.1) *Las personas humanas*

El Código reconoce a los incapaces que carecieran de representación legal el beneficio de la dispensa.

Dice el artículo 2550: "El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción, y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos.

"En el caso de personas incapaces sin representantes el plazo de seis meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante..."

Ello así, la prescripción corre contra los incapaces que tengan representantes legales, en tanto que cuando carecieren de éstos se aplicará lo dispuesto por el artículo 2550, esto es, habilitar a los jueces a liberar o dispensar de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de 6 meses.

Si la usucapión fue comenzada contra el causante, sigue corriendo después contra sus herederos y legatarios. Contra los herederos, porque ellos continúan la persona del difunto y lo suceden tanto en la propiedad como en la posesión, y contra los legatarios, porque éstos reciben la cosa con todas sus cargas y sus vicios y en el estado en que se halle.

b.2) *Las personas jurídicas*

Tal como lo señala el artículo 2534, todas las personas pueden adquirir o sufrir los efectos de la prescripción, de modo que las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares.

b.3) *El Estado*

Los particulares pueden adquirir por prescripción los bienes privados del Estado, esto es, los enumerados por el artículo 236 del Código, no así los de carácter público (arts. 235 y 237).

El dominio público del Estado es inalienable, mientras no ocurra la desafectación —que requiere un acto positivo estatal—, momento a partir del cual el bien entrará en el comercio, pudiendo ser enajenado y susceptible de adquisición por prescripción.

b.4) *La Iglesia*

La prescripción adquisitiva también corre contra la Iglesia Católica, y con mayor razón aún respecto de los templos y cosas religiosas de las iglesias disidentes, o de otras religiones.

No obstante, la jurisprudencia ha puesto límites. Así, resolvió la Corte Suprema que si el bien inmueble se encuentra directa y media-

tamente vinculado a la finalidad propia del Obispado en los términos del canon 1254.2 del Código Canónico, es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable, mientras no se lo desafecte o se autorice su enajenación de acuerdo con la legislación canónica.

VIII. Objeto

Dispone el artículo 1897 que la prescripción es el modo de adquirir "una cosa".

Como regla general pueden prescribirse todas las cosas cuyo dominio (u otro derecho real permitido) o posesión puede ser objeto de una adquisición. Ello en tanto una norma no disponga lo contrario, como ocurre con el derecho de superficie, donde no se admite la prescripción larga, o como en la prenda, que se ejerce por la posesión pero no se puede adquirir tal derecho por usucapión.

La posesión es uno de los elementos de la prescripción, y como sólo pueden poseerse las cosas, es lógico que el Código haya hecho dicha diferenciación; por ende, los bienes que no son cosas no pueden usucapirse. Pero esta regla no puede ser definitiva, teniendo en cuenta que el propio Código deja abierta la puerta para que, por excepción, ciertos bienes puedan ser objeto de los derechos reales.

Debe tratarse de cosas susceptibles de ser poseídas y de ser adquiridas por algún derecho real principal (arg. art. 2565).

La cosa debe ser cierta, determinada, actualmente existente y susceptible de tener un valor. No dice el Código que la cosa sea cierta y determinada, y actualmente existente, pero son recaudos que cabe exigir, salvo supuestos de excepción.

Quedan excluidas del régimen de los derechos reales las cosas del dominio público (ver art. 237). En consecuencia, no podrán usucapirse las cosas que pertenezcan al dominio público del Estado.

a) *Partes comunes en propiedad horizontal*

Entre las cosas que no pueden usucapirse también deben incluirse a las partes necesariamente comunes de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal (ver art. 2041). Resultaría contrario a

toda lógica intentar la usucapión de un ascensor, o de una escalera, o de una azotea, pues se encuentran sometidos a una copropiedad de indivisión forzosa a la cual los propietarios han renunciado de manera indefinida a pedir su división al adherir al reglamento de propiedad horizontal. Claro que pueden admitirse supuestos de excepción.

Así, por ejemplo, se admitió la prescripción adquisitiva del baño ubicado en el patio común de la propiedad horizontal, incoada por el consorcio ante la acción de reivindicación iniciada por un propietario, pues se encuentra acreditado que dicha dependencia no estaba comunicada con la unidad del reclamante y era utilizada de modo habitual y continuo por personal del edificio, proveedores y visitantes sin necesidad de pedir permiso, todo lo cual demuestra que no existió una simple tolerancia del reivindicante.

b) Partes de una cosa

No sólo pueden usucapirse superficies totales de un inmueble o mueble, sino también parte de ellos. Por ejemplo, cuando se posee una superficie de terreno superior a la indicada en el título, o en el supuesto en que el prescribiente intente adquirir la parte indivisa del inmueble que le corresponde a un coheredero o a un condómino.

c) El caso de las islas

Al referirse a los bienes públicos del Estado, el artículo 235 del Código Civil y Comercial incluye en su inciso d, a "las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares".

Como estas especies de cursos de agua pertenecen al dominio público, se puede arribar a la conclusión de que las islas son del dominio público cuando se forman en aguas públicas, y que son de los particulares cuando se encuentran en aguas que pertenecen a ellos.

Al ser así, pueden adquirirse por prescripción aquellas islas que no estén formadas o se formen en aguas públicas, pues los bienes del

dominio público del Estado están fuera del comercio y, por ende, son imprescriptibles, salvo que sean desafectados por ley.

Generó algunas posturas encontradas el alcance del citado inciso: "...cuando ellas no pertenezcan a particulares", del viejo artículo 2340, que ahora repite en forma parecida el artículo 235.

IX. Renuncia

Señala el artículo 12 del Código Civil y Comercial que "Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público".

Además, expresamente se establece que "La prescripción ya ganada puede ser renunciada por las personas que pueden otorgar actos de disposición. La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores o coposeedores no surte efectos respecto de los demás. No procede la acción de regreso del codeudor renunciante contra sus codeudores liberados por la prescripción" (art. 2535).

El motivo por el cual se puede renunciar a una prescripción ya ganada surgía de la nota al artículo 3965 del Código derogado: "Renunciar a una prescripción cumplida es renunciar al objeto mismo que la prescripción ha hecho adquirir y por consiguiente, puede hacerlo el que tenga capacidad para enajenar. Pero renunciar con anticipación a la prescripción, es derogar por pactos una ley que interesa al orden público y autorizar convenciones que favorecen el olvido de los deberes de un padre de familia, fomentando la incuria en perjuicio de la utilidad general. Si se permitiesen tales renunciaciones, vendrían a ser de estilo en los contratos y la sociedad quedaría desarmada, desde que se le quitaba su más firme apoyo".

Es posible renunciar a una prescripción cumplida, pues por tratarse de un derecho adquirido, no está en juego el interés público, sino el particular (el eventual perjuicio sólo recaería en el patrimonio del renunciante).

Lo que se encuentra prohibido es renunciar al derecho de prescribir para el futuro, así como a una prescripción en curso, aunque en esta segunda alternativa cabe aclarar que la renuncia se puede aplicar al pasado (esto es, al plazo cumplido), pero no para el futuro.

No obstante, la prohibición es relativa, pues si bien la renuncia a prescribir para lo futuro estaría vedada, a través del reconocimiento, por parte del poseedor, del derecho de la persona contra la cual se prescribe —que es uno de los casos de interrupción de la prescripción: artículo 2545 del Código Civil y Comercial—, se arribaría al mismo resultado, el poseedor pasaría a ser tenedor y, en consecuencia, estaría imposibilitado para prescribir, ya que no podría darse el elemento fundamental de la prescripción: la posesión. Salvo que mediara una interversión de título que lo erigiera en poseedor y le permitiera, a partir de ese momento, comenzar a prescribir.

En cuanto a quiénes pueden renunciar, el artículo 2535 se refiere a todas "las personas que pueden otorgar actos de disposición".

Si se intenta la renuncia por medio de representante, deberá contarse con un poder con facultades expresas (conf. art. 375, inc. i).

Nuestro Código fija una norma en beneficio de terceros, pues en el artículo 2534 establece que "...Los acreedores y cualquier interesado pueden oponer la prescripción, aunque el obligado o propietario no la invoque o la renuncie". Con ella se persigue evitar el fraude a acreedores.

Es un típico caso de acción pauliana, debiendo los acreedores acreditar el perjuicio que la renuncia les ha causado, pudiendo intentar la inoponibilidad de esa renuncia. La vía adecuada es la acción revocatoria.

X. Suspensión

a) *Concepto. Efectos*

La suspensión de la prescripción se crea para proteger a ciertas personas que no tienen posibilidad de defender sus derechos debidamente, lo que hace que el tiempo no corra mientras dura esa situación. Cuando el inconveniente desaparece, la prescripción reanuda su curso.

Dice el artículo 2539 que "La suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura pero aprovecha el período transcurrido hasta que ella comenzó".

Así, por ejemplo, Juan hace cuatro años que posee un inmueble. Se produce una causa de suspensión que dura dos años. Los primeros

MNR

cuatro años no se pierden, de modo que una vez desaparecida la causa de la suspensión, se sigue contando el plazo. El séptimo año sería el quinto computable.

En ese sentido, hay mucha diferencia entre la suspensión y la interrupción de la prescripción. La suspensión no toca la posesión y sólo hace suspender momentáneamente los efectos de su continuación, mientras que la interrupción borra la posesión que le ha precedido y hace que la prescripción no pueda adquirirse sino en virtud de una nueva posesión.

Las causas de suspensión están enumeradas en la Sección 2ª del Capítulo 1, Título I, Libro Sexto (arts. 2541 a 2543). Ellas son: a) la interpelación fehaciente; b) el pedido de mediación; c) las acciones entre cónyuges durante el matrimonio; d) entre convivientes, durante la unión convivencial; e) entre las personas incapaces y con capacidad restringida y sus padres, tutores o curadores, durante la responsabilidad parental, la tutela o la curatela; f) entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes de sus órganos de fiscalización, mientras continúan en el ejercicio del cargo; g) a favor y en contra del heredero beneficiario, mientras dura su calidad de tal, respecto de los reclamos que tienen por causa la defensa de derechos sobre bienes del acervo hereditario.

La suspensión es aplicable tanto a la prescripción larga como a la breve.

b) *¿Quiénes pueden invocar la suspensión?*

La suspensión de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles (conf. art. 2540). Por regla, su efecto es relativo.

Por ende, un motivo de suspensión no puede beneficiar o perjudicar a todos por igual, pues la regla es que la prescripción corre contra todas las personas, mientras no medie una causal de suspensión. Así, por ejemplo, hay dos poseedores en vías de usucapir. A uno de ellos se lo cita a mediación, lo que suspende la prescripción en curso, pero no para el otro poseedor que no fue citado. Para este último el plazo siguió corriendo.

c) *Interpelación fehaciente*

Prevé el artículo 2541 que "El curso de la prescripción se suspende, por una sola vez, por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción".

Por lo tanto, si el titular del derecho real sobre la cosa que está siendo poseída por otro lo interpela en forma fehaciente, la prescripción en curso se detiene por seis meses.

El artículo exige que la interpelación sea efectuada en forma "fehaciente".

La interpelación consiste en un requerimiento de reintegro de la cosa que debe emanar del titular del derecho real y estar dirigida al poseedor.

d) *Mediación*

Dice el artículo 2542: "El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero.

"El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes".

Es perfectamente posible suspender en dos oportunidades diferentes el plazo de la prescripción por aplicación de los artículos 2541 y 2542 del Código Civil y Comercial: una, por el proceso de mediación y, otra, por intermedio de una "interpelación fehaciente", anterior a la mediación. La justificación de esta postura se funda en la distinta finalidad de las normas en juego y en la inteligencia de que el llamado a mediación no es sinónimo de una "interpelación fehaciente".

A su vez, la suspensión se produce tanto cuando la mediación previa es obligatoria, como cuando lo es por pedido voluntario de alguna de las partes. La finalidad de la norma es que existiendo la posibilidad de solucionar el problema en instancias amigables, el acreedor no se vea obligado a promover la demanda judicial para no perder su derecho.

Cabe recordar que las acciones reales que se pueden intentar contra el poseedor, así como la de usucapión, en la Ciudad de Buenos Aires, están sujetas a la mediación previa obligatoria impuesta por la ley 26.589.

La solución del Código tiene efectos en aquellas jurisdicciones en las cuales la mediación es anterior a la demanda. En provincias como Córdoba, en las cuales la mediación se produce luego de trabada la litis, la solución no tiene efectos pues la prescripción ya se encuentra interrumpida por la promoción de la demanda judicial.

Se sigue un sistema similar al previsto en la ley 26.589.

e) *Menores y demás incapaces*

Dice el artículo 2550 que "El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción, y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos.

"En el caso de personas incapaces sin representantes el plazo de seis meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante..."

Por ende, para que el juez pueda liberar al titular del derecho real incapaz de una usucapión cumplida, deberán darse los siguientes requisitos: 1) que la prescripción adquisitiva se haya cumplido durante un impedimento o dificultad del propietario; 2) que la prescripción se haya perseguido contra un incapaz; 3) que en dicho momento, el incapaz carezca de representante legal; 4) que el incapaz haga valer sus derechos en el plazo de seis meses, desde que cesa la incapacidad o desde que acepta el cargo el representante.

Hay que aclarar que técnicamente éste no es un supuesto de suspensión, sino de dispensa.

Así las cosas, cabe preguntarse: ¿cuándo debe iniciarse el cómputo de los seis meses si carecen de representante?

De lo dispuesto por el artículo 2550 se desprende que debe iniciarse una vez cesado el impedimento. Pero si lo que se pretende es determinar el momento exacto para empezar a contar los seis meses, el juez de-

berá analizar cada supuesto en particular. Si se trata de un menor de edad, la cuestión es sencilla: el plazo correría desde que se cumplen los 18 años.

Para el supuesto de personas con alteraciones mentales, de cese de la incapacidad en el intervalo de tiempo al que hiciéramos referencia más arriba, el tiempo se computa desde que la sentencia de cese es notificada al causante, en tanto que ante la hipótesis de nombramiento de representante del incapaz, el tiempo debería contarse desde que el curador o tutor aceptó el cargo, salvo que no se hayan cumplido los plazos indicados por el juzgado para tal acto (comúnmente, cinco días desde la notificación), o se advierta alguna maniobra dilatoria en contra de terceros.

El artículo 2550 habla de incapaces; por ende, el beneficio no puede extenderse a los emancipados (pues a éstos se los considera plenamente capaces). Sí, según las circunstancias, podrá extenderse a aquellos con capacidad restringida (ver art. 32).

En el caso de los menores, los seis meses deben contarse desde las cero horas del día en que cumplen los 18 años.

f) *Matrimonio*

Otra causal de suspensión del curso de la prescripción es la contemplada por el artículo 2543, inciso a, del Código Civil y Comercial. La mencionada norma establece que "El curso de la prescripción se suspende: a) entre cónyuges, durante el matrimonio".

El fundamento de esta causal de suspensión es evitar que la paz conyugal sea alterada, aunque también evitar el fraude a terceros. Resultaría sumamente incómodo que los cónyuges debieran demandarse o formularse reclamos para evitar que se opere la prescripción a favor del otro.

La norma dice "durante el matrimonio". Producida la nulidad o el divorcio, o la muerte de uno de los cónyuges, no se suspende el tiempo de la usucapión. En estos casos ya no hay matrimonio.

Cabe entender que tampoco se suspende durante la separación de hecho, pues si el fundamento de esta causal de suspensión es evitar la perturbación de la vida familiar, esta consecuencia no deseada tampoco tendría lugar en aquellos casos en que ya se produjo la separación de hecho de los esposos.

g) *Unión convivencial*

Dispone el artículo 2543 que "El curso de la prescripción se suspende [...] b) entre convivientes, durante la unión convivencial". Por su parte, el Código regula las uniones convivenciales en los artículos 509 y siguientes.

Teniendo en cuenta que el Código impone ciertos deberes y derechos a los convivientes que reúnan determinados requisitos, así como un régimen de asistencia, es evidente que ha querido evitar, como sucede con el matrimonio, que se generen situaciones incómodas si se vieran obligados a demandarse o formularse reclamos para evitar que se opere la prescripción.

Esta causal de suspensión cesa cuando se extingue la unión convivencial. Las causales están previstas en el artículo 523.

h) *Cosas comprendidas en una sucesión*

Establece el artículo 2543 que el curso de la prescripción se suspende: "...a favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada, respecto de los reclamos que tienen por causa la defensa de derechos sobre bienes del acervo hereditario".

Como puede verse, el artículo habla de los "derechos sobre bienes" del acervo hereditario, y por consiguiente la suspensión establecida comprende los derechos reales cuyo ejercicio tendría por resultado disminuir el activo hereditario. Quedan, pues, suspendidas las acciones de reivindicación o confesorias de servidumbre, que el heredero beneficiario habría podido ejercer contra la sucesión, o la sucesión contra él.

En lo tocante al momento en que la usucapión se suspende, cabe considerar que esto se produce con la apertura de la sucesión, o sea desde la muerte del causante (art. 2277).

i) *Padres, tutores y curadores*

Respecto a esta causal, es de aplicación el artículo 2543, inciso c, que prevé la suspensión de la prescripción "entre las personas incapaces y con capacidad restringida y sus padres, tutores, curadores o apoyos, durante la responsabilidad parental, la tutela, la curatela o la medida de apoyo".

El criterio aquí aplicado por el Código es similar al utilizado en referencia a los esposos y a los convivientes, esto es, evitar el conflicto de intereses entre representante y representado. Si el usucapiente es designado como tutor o curador del menor o incapaz titular del derecho real cuya adquisición se persigue, el curso de la prescripción debe suspenderse hasta que la tutela o curatela finalicen. Por su parte, si el tutor quisiera usucapir una cosa de su representado, el plazo sólo podrá computarse una vez finalizada la tutela.

j) *Administradores*

Prevé el artículo 2543, en el inciso d, que se suspende la prescripción "entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes de sus órganos de fiscalización, mientras continúan en el ejercicio del cargo".

Las razones son similares a las ya expuestas, teniendo en cuenta la situación incómoda y de desprotección si quienes representan a la persona jurídica debieran demandarse a sí mismos, o bien ellos demandarla para evitar que se consuma la prescripción.

XI. Dispensa

Esta figura está prevista en el artículo 2550 en los siguientes términos: "El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción, y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos.

"En el caso de personas incapaces sin representantes el plazo de seis meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante.

"Esta disposición es aplicable a las sucesiones que permanecen vacantes sin curador, si el que es designado hace valer los derechos dentro de los seis meses de haber aceptado el cargo".

No se trata de una causal de suspensión de la prescripción, sino que consiste en una dispensa de la prescripción cumplida.

Los impedimentos para el ejercicio de la acción pueden tener su origen en un hecho o en el derecho, pero en ambos casos la imposibilidad de actuar debe ser absoluta. También deben ser imprevisibles o insuperables, y su apreciación debe ser juzgada con la misma vara que se utiliza para tener por configurada la fuerza mayor.

El beneficio concedido por el artículo 2550 también puede ser opuesto cuando el propietario se viera imposibilitado de demandar por maniobras dolosas del poseedor usucapiente o de alguna otra persona.

Así, por ejemplo: Juan hace 19 años que posee un inmueble. Pedro, su propietario, lo puede demandar por reivindicación antes de que se cumpla el plazo de 20 años. Resulta que Pedro es secuestrado durante 2 años y se cumple el plazo para la adquisición por prescripción. El día que es liberado ya está cumplido el término pero si demanda dentro de los 6 meses, el juez puede dispensar la usucapción cumplida.

XII. Interrupción

A diferencia de la suspensión que, momentáneamente, detiene el curso de la prescripción, que luego se reanuda, la interrupción hace que se borre, que se pierda el tiempo transcurrido hasta ese momento. Si la causal desaparece, hay que volver a iniciar el cómputo. Prevé el artículo 2544 que "El efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo".

Verbigracia, si Juan hace 5 años que posee y reconoce un mejor derecho en Pedro, esto interrumpe la prescripción y se pierden esos 5 años. Si luego posee nuevamente, deberá contar un nuevo plazo.

El Código enumera cuatro causales, para las que deberán tenerse en cuenta a la o las personas de quienes provienen: si la interrupción proviene de la promoción de una petición judicial, de una solicitud de arbitraje o de un reclamo administrativo (arts. 2546/2548), las causales provendrán del acreedor o titular del derecho real; si es por reconocimiento de deuda o del derecho (art. 2545), del deudor o poseedor. No se puede descartar que la solicitud de arbitraje emane de un compromiso de ambos, en cuyo caso la interrupción estará generada por ambas partes.

a) *Interrupción por petición judicial contra el poseedor*a.1) *Recaudos para la procedencia*

El artículo 2546 dispone que "El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable".

Como puede advertirse, el legislador no ha querido que un error sobre la competencia o en la interposición de la demanda o una incapacidad subsanable influyan sobre el efecto interruptivo de una demanda.

Si bien la petición no modifica la situación del poseedor desde el punto de vista fáctico, pues sigue poseyendo, a partir de aquélla conocerá la oposición formal del actor. La cosa pasará a ser litigiosa. La iniciación del proceso, hasta que se dicte la sentencia, abre un paréntesis en la vida de la usucapión.

No se utiliza el término "demanda", sino uno más amplio que comprende todas aquellas peticiones judiciales que importen una clara manifestación de voluntad del titular del derecho de mantenerlo vivo, de no abandonarlo. Se aplica tanto a la prescripción adquisitiva como a la liberatoria.

El planteo puede efectuarse mediante una reconvención, pero también se han aceptado otros actos procesales que produzcan la misma consecuencia, como ser la traba de una medida cautelar, la promoción de un juicio de desalojo en lugar de la reivindicación, etcétera. Lo relevante en cuanto a este punto es que mediante la petición efectuada a un juez se intente mantener vivo el derecho.

También se asignó efecto interruptor a la solicitud de carta de pobreza para promover una demanda, al pedido de concurso o quiebra del deudor o la verificación del respectivo crédito, a la apertura del juicio sucesorio del obligado a instancia del acreedor, a los trámites preparatorios de la vía ejecutiva, etcétera.

En cambio, en general, se ha desconocido efecto interruptor a las

gestiones particulares, como el hecho de labrarse un acta de comprobación de daños, o a trámites de asesoramiento, o al otorgamiento de un poder para accionar judicialmente. Y lo mismo sucede en principio con los reclamos administrativos, salvo cuando ellos han sido establecidos como un trámite que necesariamente debe preceder a la demanda judicial (art. 2548).

El artículo 2546 continúa diciendo: "...aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente..."

Obsérvese que el Código acepta taxativamente algunos defectos que pueden presentar los reclamos efectuados contra el poseedor, como ser la presentación ante juez incompetente, o que la demanda sea propuesta con algún defecto legal y aunque el demandante carezca de capacidad legal para presentarse en juicio (incapacidad de hecho).

Lo que debe primar es la demostración de la voluntad del propietario de reclamar por su derecho sobre una cosa en tiempo oportuno.

En esa inteligencia, la demanda interpuesta ante un juez incompetente interrumpe, por cuanto de todas maneras constituye una formal exteriorización de la voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho.

La demanda "defectuosa" también es interruptiva, pues como lo explicaba Vélez Sársfield en su nota al artículo 3986 del Código derogado: "Aunque la demanda sea nula, prueba la diligencia del que la interpone".

Por aplicación del artículo 2546, la demanda dirigida contra una persona cuyo nombre no se indica, pero se la individualiza por su calidad de dueño (en lo relativo a la usucapión corresponde referirse a ocupante) de determinada cosa, también interrumpe la prescripción, siempre que sea éste con quien finalmente se trabase la *litis*.

Ha de quedar comprendida la demanda que se rechaza por haberse errado al elegir la acción, extendiéndose dicho concepto a todo acto que evidencie que el reclamante no ha abandonado la acción y que su propósito no es dejarla perecer, lo cual, de por sí, constituye una manifestación de voluntad idónea, suficiente para interrumpir la prescripción.

Una demanda incompleta, con defectos y omisiones, deducida con la sola finalidad de interrumpir la prescripción, es idónea para el logro de dicho objetivo, atento a que puede ampliarse y completarse *a posteriori*, antes de la notificación de su traslado a la parte accionada. Los alcances, importancia y trascendencia de los "defectos" de la demanda, para decidir si se cumple o no la finalidad de la ley, quedan librados a la apreciación del juez.

Por último, es del caso destacar que la demanda también puede tener efecto interruptivo aunque se dirija contra quien posee para el usucapiente. El artículo 2546 establece que la petición judicial puede dirigirse contra "su representante en la posesión".

a.2) Efectos

La interrupción de la prescripción se produce por toda petición judicial, generalmente con la interposición de la demanda, resultando irrelevante la fecha de su notificación.

Sin embargo, la interrupción puede quedar sin efecto si el demandante desiste de ella, o si se decretó la caducidad de instancia (conf. art. 2547).

Ahora bien, si se da alguna de las causales enumeradas precedentemente, la interrupción se tiene por no sucedida y, consecuentemente, la posesión que transcurrió desde la interposición de la demanda hasta que se dispuso alguna de las posibilidades contempladas por el artículo citado, debe computarse a favor del usucapiente, quien por la indicada razón no ha visto alterado el curso de su prescripción.

Por último, dispone el primer párrafo del artículo 2547 que "Los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión, con autoridad de cosa juzgada formal". Debe ser una sentencia irrecurrible, que resuelva sobre el fondo del asunto, es decir, que cause cosa juzgada respecto al derecho del accionante.

Si la demanda de reivindicación es acogida favorablemente, el efecto interruptivo conseguido al promoverla se consolida definitivamente, ya que el actor tiene a su favor una figura más fuerte: la cosa juzgada. Por el contrario, si la demanda es rechazada, y se hace lugar a la demanda o reconvención de usucapión, el efecto interruptivo pierde

MNR

relevancia ya que ahora es el contrincante quien goza del beneficio de la cosa juzgada y, se supone, de la consiguiente adquisición del derecho real. Lo concreto es que hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, el efecto interruptor se mantiene, y su suerte dependerá del resultado final del pleito.

El artículo 2547 se refiere a "la resolución que pone fin a la cuestión". No son tales las que resuelven cuestiones incidentales que se plantean a lo largo del litigio, pero obviamente no impiden que se mantenga el efecto interruptor hasta la sentencia definitiva.

a.3) Supuestos en los que cesan los efectos de la interrupción

Conforme al artículo 2547, último párrafo, "La interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia".

La norma transcripta se refiere, en primer lugar, al desistimiento de la acción. No obstante, quien desiste del proceso puede iniciar una nueva demanda para interrumpir la usucapión en curso, siempre que no se haya cumplido el tiempo indicado por la ley. Si el titular del derecho real desiste del derecho, ya no puede demandar, por lo que es irrelevante el problema de la interrupción.

El citado artículo también hace referencia a la caducidad de la instancia. En cuanto a sus efectos, habrá que diferenciar el momento en que se declara la caducidad.

Puede ocurrir que la demanda se interponga antes de finalizado el tiempo necesario para usucapir, pero que se decrete, de oficio o a petición de parte, la caducidad de la instancia una vez alcanzado aquel recaudo. En esta hipótesis, el anterior propietario no tendrá éxito si inicia una nueva demanda para interrumpir la usucapión en curso, pues el derecho real ya ha sido adquirido por otra persona (el usucapiente). Adviértase la importancia que puede tener esta circunstancia en el ámbito de la responsabilidad profesional del abogado.

Por el contrario, puede ocurrir que la caducidad sea declarada en pleno curso de la prescripción. En este caso, el propietario podrá iniciar una nueva demanda interruptiva de la usucapión.

a.4) *No es necesaria la notificación de la demanda interruptiva*

La sola interposición de la demanda basta para interrumpir la prescripción, sin que resulte necesaria su notificación, lo que no está exigido ni expresa ni tácitamente en la norma.

a.5) *Demanda presentada en las dos primeras horas del primer día hábil subsiguiente al vencimiento del término de prescripción*

El artículo 124, tercer párrafo, del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación establece que "El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas del despacho".

Frente a tal disposición cabe preguntarse si tendría eficacia interruptiva una acción iniciada vencido el término legal de prescripción, pero dentro de las dos primeras horas del despacho del inmediato día hábil, que ha sido establecido en algunas normas procedimentales.

Dispone el artículo 2546 ya citado que tiene efecto interruptivo la petición aunque sea deducida "en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable".

b) *Interrupción por reconocimiento*

Según el artículo 2545: "El curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe". Se trata de una causal de interrupción motivada en un acto positivo del poseedor usucapiente. Ésta se produce ante su reconocimiento del mejor derecho de la otra parte.

En este caso, la posesión se interrumpe porque se pierde el *animus domini*, extremo que representa un requisito ineludible para que la usucapión pueda prosperar. Ante tal reconocimiento, quien poseía pasa a poseer por otro, pasa a ser un "tenedor".

Troplong aclara la cuestión en los siguientes términos: "toda la diferencia está en que se renuncia a una prescripción cuando está ad-

quirida, y que se interrumpe una prescripción cuando no se ha cumplido". De tal forma, si el reconocimiento se produce cuando la prescripción ya se cumplió, se trataría en rigor de una renuncia.

El reconocimiento puede ser expreso o tácito (art. 733).

c) *Interrupción por solicitud de arbitraje*

Otra causal de interrupción de una usucapión en curso es la indicada por el artículo 2548: "El curso de la prescripción se interrumpe por la solicitud de arbitraje. Los efectos de esta causal se rigen por lo dispuesto para la interrupción de la prescripción por petición judicial, en cuanto sea aplicable".

Esta causal es similar al caso de petición judicial. Se supone que el titular del derecho real (no el poseedor), en lugar de iniciar una petición judicial solicita la constitución de un tribunal arbitral o la intervención de un árbitro para mantener vivo su derecho.

Es difícil imaginar que esta situación se presente en la hipótesis de que un poseedor está poseyendo con la posibilidad de adquirir por prescripción. Ocurre que el titular del derecho real que ha sido privado de la posesión, debe acudir a la justicia y no a un árbitro, en principio incompetente para estas cuestiones. Esta causal podrá tener mayor campo en la prescripción liberatoria.

Podría suceder, como preveía el Código anterior, que tanto el titular del derecho real como el poseedor que pretende adquirir por prescripción, decidan juntos someter sus diferencias a la decisión de uno o más árbitros.

Es claro el efecto interruptor, pues si para ello basta con la sola petición del titular del derecho, con mayor razón todavía si la petición la formulan los dos en forma conjunta.

Si el juicio arbitral no se llevare a cabo, o iniciado se abandonare, la causal de interrupción queda sin efecto alguno, generando como consecuencia que el poseedor "interrumpido" puede haber adquirido el derecho real sobre la cosa, pues si ínterin mantuvo la posesión de la cosa, todo ese tiempo se cuenta para su prescripción.

d) *Alcance subjetivo*

Establece el artículo 2549 que "La interrupción de la prescripción

no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles”.

La interrupción no aprovecha sino al que ha entablado la demanda, solicitado el arbitraje o respecto de quien reconoció el derecho ajeno (conf. art. 2549). Su efecto es relativo (no absoluto).

Al seguirse el criterio expuesto precedentemente, si uno solo de los propietarios interpone la demanda, la interrupción sólo a él lo beneficiará, pero la usucapión continuará su curso en relación con los otros copropietarios; como contrapartida, la interrupción que se ha causado contra uno solo de los coposeedores no puede oponerse a los otros.

XIII. Prescripción breve

Para que se configure la usucapión breve, corta u ordinaria deberá contarse con una posesión *animus domini*, ostensible y continua, durante diez años para inmuebles o dos años para cosas muebles, con justo título y buena fe en la adquisición (art. 1898).

Para la procedencia de la prescripción en estudio, la posesión sólo podrá adquirirse por transmisión.

Si bien el justo título y la buena fe son dos condiciones distintas, no por ello son independientes. El que quiere prescribir, debe probar su justo título, pero el justo título hará presumir la buena fe.

Ante la vigencia del artículo 399, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor o más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere. Ante una irregularidad del título, la única alternativa para sanearla es la usucapión, y si el usucapiente cuenta con justo título y buena fe, podrá consolidar su derecho en un plazo menor (diez o dos años).

a) Justo título

Si el otorgante es incapaz o no está legitimado para tal fin, habrá “justo título”. El justo título se asemeja al título suficiente en cuanto al concepto: es el acto jurídico idóneo para transmitir un derecho real (v. gr.: compraventa, permuta, etc.) y, además, reúne la forma requerida, pero tiene una falla en los recaudos de fondo que lo diferencian. Ocurre

que el justo título emana de una persona no legitimada para transmitir (v. gr.: venta de cosa ajena) o que no tenía capacidad para otorgar el acto (v. gr.: enfermedad mental). Si el adquirente actuó de buena fe, ignorando el defecto, el Código le permite consolidar su situación luego de diez o de dos años de posesión.

El supuesto de hecho puede estar dado por títulos materialmente falsificados, poderes falsos, testamentos apócrifos, etcétera. El supuesto de la escritura falsificada no está comprendido dentro de los alcances del artículo 392 del Código, que protege a subadquirentes de buena fe y a título oneroso.

Como ha hecho notar Allende, el adquirente en virtud de un justo título es propietario (si hubo tradición) y, como todos los propietarios, lo es *erga omnes*, con una limitación, que es la persona del anterior propietario que no intervino en la transmisión. La cosa está ya adquirida con título y buena fe. La prescripción en tal caso no hace más que consolidar la adquisición hecha, poniendo al que la ha obtenido al abrigo de toda acción de reivindicación.

En suma, en la usucapión corta o breve, la cosa llegó a poder del usucapiente por una transferencia hecha por quien no es su propietario (*non domino*); se trata de un acto inoponible. Para que sea posible la adquisición, la posesión debe estar acompañada de un título (*iusta causa usucapionis*) y de la buena fe. Si el título proviene del verdadero propietario, pero por algún motivo es nulo, no se trata del justo título requerido para este modo de adquisición. En tal caso, será necesaria la usucapión larga, o la prescripción liberatoria de la acción de nulidad según los casos, sin perjuicio de los derechos de terceros subadquirentes (arts. 392 y concs.).

Además, en materia de cosas muebles, de acuerdo al artículo 1895, la protección que brinda esa norma no se aplica cuando la cosa es hurtada o perdida, de modo que al subadquirente de buena fe, expuesto a la reivindicación del verdadero dueño, le queda la posibilidad de esta prescripción breve de dos años.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, es dable señalar que podría llegar a no ser necesario cumplir con los plazos de posesión establecidos para esta clase de usucapión, si antes cesan las incapacidades y el acto es ratificado, o cuando la venta es efectuada *a non domino*, y la

transmisión es ratificada por el verdadero propietario. No hay que descuidar que el artículo 1885 prevé la *convalidación*.

b) Buena fe

Sobre el concepto de buena fe se remite al capítulo respectivo. Cabe aclarar que la buena fe no es necesaria después del momento de la adquisición (*mala fides superveniens non nocet*).

La buena fe es un recaudo adicional, ya que puede haber justo título sin buena fe. El primero es un elemento objetivo, mientras que la buena fe es subjetiva. Claro que si no hay título, está descartada la buena fe. Si no hay buena fe, sólo queda el recurso de la prescripción larga.

El artículo 1918 da un concepto clásico de buena fe, consistente en que el poseedor se encuentre persuadido de la legitimidad de su adquisición, luego de un error excusable. Debe ser complementado con el artículo 1902.

c) Tiempo

Tal como se expuso anteriormente, el poseedor con justo título y buena fe es propietario frente a todos, *erga omnes*, salvo el anterior propietario, quien puede reivindicar la cosa. El adquirente en estas condiciones está expuesto a la reivindicación ya que, al no ser la transmisión *a non domino* un caso de acto nulo o anulable, no puede invocar la protección del artículo 392.

No obstante, si el titular con justo título se mantiene en la posesión de la cosa durante al menos diez años (pueden necesitarse más si hubo alguna causal de suspensión o interrupción), en ese caso podrá consolidar su situación y repeler dicha acción real. Si se trata de cosas muebles hurtadas o perdidas, el plazo es de dos años.

El plazo corre desde que se inicia la posesión, lo que se presume que ocurrió en la fecha del justo título (art. 1903). Si se trata de cosas muebles registrables y la inscripción es constitutiva, se presume su comienzo desde la inscripción del justo título en el Registro que corresponda. Si bien el artículo 1898, última parte, es categórico, teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 1903 y 1914, cabe interpretar

que se trata de una presunción que admite prueba en contrario, esto es, que la posesión comenzó antes o después. El artículo 1903 dice expresamente que esto es así "salvo prueba en contrario".

d) Situación del sucesor singular del adquirente con justo título

El adquirente con justo título y buena fe, está expuesto a la acción reivindicatoria hasta tanto se consolide la situación por el transcurso del plazo de dos o de diez años. Es posible que antes de cumplirse dicho plazo, aquél le enajene la cosa a un tercero. El subadquirente queda colocado en la misma posición que su antecesor y que, por lo tanto, sólo podrá evitar la reivindicación consumada la prescripción corta.

Podrá unir su posesión a la de su antecesor para alcanzar el plazo exigido.

e) Situación del subadquirente de cosa mueble con título gratuito

El subadquirente de una cosa mueble no hurtada ni perdida puede repeler la acción reivindicatoria del verdadero propietario si es de buena fe y a título oneroso. Si el reivindicante prueba que su adquisición fue a título gratuito podrá recuperar la cosa (art. 1895).

Resulta que el artículo 1898 contempla el caso del poseedor de buena fe de cosas hurtadas o perdidas, con lo que pueden surgir dudas respecto al poseedor de esa clase cuando se trata de cosas que no son hurtadas, robadas o perdidas. En estas condiciones, a pesar de la omisión, cabe inferir que el subadquirente a título gratuito está incluido implícitamente en las previsiones del artículo 1898, de manera que puede consolidar su situación al cabo de dos años de posesión. De lo contrario, habría que interpretar que puede adquirir por prescripción larga al cabo de veinte años de posesión, por aplicación del artículo 1899, pero ello es descartable, pues se lo equipararía con el poseedor de mala fe. Máxime al tratarse de un poseedor de buena fe de cosas que ni siquiera son hurtadas o perdidas, aunque haya adquirido a título gratuito.

Cabe interpretar que el artículo 1898 protege a todos los poseedores de buena fe excluidos del artículo 1895.

Además, el artículo 1899, que regula la prescripción larga de veinte años, dice que se aplica si "no existe justo título o buena fe".

Pero el pago realizado en diversas oportunidades y con mucha anterioridad a la iniciación del proceso por usucapión constituye un insuperable elemento objetivo de convicción. La ley 14.159 no exige que esos pagos sean efectuados mes a mes, ni durante dilatados períodos, sino que, al igual que los actos posesorios que enuncia el Código, lleven al convencimiento del juzgador.

e) Efectos de la sentencia

Dispone el artículo 1905 que "La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo.

"La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión".

Establece la norma, siguiendo una opinión doctrinaria, que la sentencia carece de efectos retroactivos. Ocurre que cada caso debe ser examinado por separado.

El hecho de ser un modo originario de adquisición no significa que el adquirente por usucapión no deba respetar los derechos reales que el propietario anterior hubiese constituido sobre la cosa (v. gr.: una servidumbre), que son oponibles *erga omnes*, si no se extinguieron por el no uso o por la propia posesión del adquirente. Por ende, si se trata de una hipoteca, el nuevo dueño deberá respetarla, aunque sólo responderá con el inmueble y no con todo su patrimonio. Obsérvese que según el artículo 1905 la sentencia no tiene efecto retroactivo.

La fecha de adquisición del derecho real la fijará el juez, para lo que tendrá en cuenta el momento en el que considere acreditado el plazo legal de prescripción.

Sin perjuicio de lo dicho, como la sentencia que declara adquirido el dominio por usucapión debe ser inscripta a los efectos de su oponibilidad a todos los terceros que no tengan la posibilidad de conocer extrarregistralmente tal adquisición, se plantea también el problema de saber desde qué momento juega tal oponibilidad una vez registrada dicha sentencia. Y así podría sostenerse que la adquisición

por prescripción tiene efectos retroactivos a la fecha del dictado de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a la fecha en que efectivamente se inscribe dicho documento en el Registro de la Propiedad Inmueble, a la fecha en que se cumplió el plazo de la prescripción vicinal o al momento en que comenzó la posesión que condujo a la adquisición por prescripción.

El problema no es grave, si se recuerda que el juez ordenó la anotación de la litis.

e.1) Efectos de la sentencia respecto de los derechos reales constituidos por el anterior propietario

Como se expuso anteriormente, la sentencia que declara adquirido el derecho real por prescripción no tiene efecto retroactivo a la fecha de comienzo de la posesión. Mariani de Vidal, Kiper y Goldenberg, respecto de los derechos reales constituidos por el propietario y por el usucapiente, señalan que no es conveniente sentar principios generales al respecto, sino que en virtud de las distintas modalidades que en su ejercicio presentan los derechos reales sobre cosa ajena, resulta conveniente examinar por separado los efectos que produce la adquisición del dominio por prescripción con relación a cada uno de ellos. Por lo tanto, proponen las siguientes soluciones:

- 1) La prescripción adquisitiva cumplida en favor de un tercero tiene por efecto extinguir el derecho real de usufructo constituido por el anterior propietario, con anterioridad al momento en que comenzó la posesión del adquirente, y de impedir definitivamente el nacimiento de dicho derecho real cuando fuese contratado por el dueño anterior con posterioridad al inicio de la posesión del tercero. En el primero de los supuestos será condición previa la citación a juicio del usufructuario para que haga valer sus derechos (art. 18, Constitución Nacional). Las reglas antedichas son también aplicables respecto de los derechos reales de uso, habitación, superficie y anticresis.
- 2) La prescripción adquisitiva cumplida en favor de un tercero no tiene por efecto extinguir las servidumbres constituidas por el anterior propietario, en tanto la constitución de dicho derecho real hubiese sido inscripta en el registro o su existencia conocida

por el poseedor. Ello sin perjuicio de la posibilidad de la extinción de la carga por el no uso durante el plazo legal.

- 3) Son válidos los derechos reales constituidos por el poseedor con justo título; en cambio, por el juego de las normas registrales, no los puede constituir el poseedor usucapiente que carezca de dicho acto jurídico.
- 4) Para determinar la suerte de las hipotecas constituidas, ya por el anterior propietario, ya por el usucapiente en caso de consumarse ese modo de adquirir el dominio, cabe distinguir las siguientes hipótesis: a) por el propietario antes de comenzar la posesión que llevó a la usucapición; b) por el propietario luego de comenzada dicha posesión, pero antes de cumplirse el término para prescribir; c) por el poseedor durante el tiempo de su posesión que finalmente lo condujo a la consolidación del dominio; d) por el poseedor luego de haber transcurrido el término para prescribir, pero sin contar con la pertinente prueba documental que emana de la sentencia de la ley 14.159, ni con su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.

En el supuesto 4.a, la hipoteca conservará su pleno valor por tratarse de un derecho real, es decir, oponible *erga omnes*.

Para la solución de los restantes casos debe, a su vez, distinguirse si se trata de prescripción adquisitiva breve o larga.

En caso de prescripción adquisitiva breve, el supuesto b, no podrá presentarse por el juego de las normas sobre Registro de la Propiedad Inmueble; en cuanto al supuesto c, la hipoteca será válida.

En caso de prescripción adquisitiva larga, los supuestos c, y d, no podrán presentarse, precisamente por el juego de las normas registrales antes aludidas, y en cuanto a la especie b, la hipoteca será válida por esa misma razón. Ello es así, salvo conocimiento efectivo del acreedor hipotecario sobre la existencia del usucapiente.

e.2) Efectos respecto de los frutos

Hay quienes postulaban el efecto retroactivo de la sentencia, y ahora critican la solución del Código que niega tal efecto. Como argumento expresan que el poseedor que triunfe, y adquiera el de-

MNR

recho real por prescripción, de todos modos deberá restituir los frutos, lo que le puede resultar sumamente oneroso, a pesar de haber tenido éxito.

No comparto semejante argumento, pues cabe entender que el poseedor que triunfa frente al anterior propietario, y adquiere el derecho real por usucapición, nada debe restituir. Debe restituir si pierde el juicio y se admite la reivindicación, pero no en caso contrario. Esto surge claramente del último párrafo del artículo 1935, cuando dice que "los frutos pendientes corresponden a quien tiene derecho a la restitución de la cosa". Esto es, si se restituye la cosa, entonces habrá que restituir los frutos percibidos de mala fe; si no hay restitución, por haberse dictado sentencia admitiendo la prescripción, nada hay que restituir.

f) Efectos del fallo cuando la prescripción se hizo valer por vía de excepción

Tanto la prescripción larga como la corta pueden hacerse valer en un juicio por vía de excepción. Por ejemplo, el propietario inicia contra el poseedor la acción reivindicatoria, y éste opone la excepción de prescripción, que obstará al progreso de la acción. Pero, en este caso, el juez en su sentencia sólo rechaza la acción del reivindicante, en el supuesto de que acogiese la excepción de prescripción, pero no declara adquirido el derecho real por parte del demandado. Para que esto haga el juez, el usucapiente, frente a la acción reivindicatoria, debe reconvenir por usucapición.

Cuando la prescripción adquisitiva se hace valer por vía de excepción, el demandado, sin desconocer los hechos constitutivos de la demanda, opone, sin embargo, a su progreso, a su vez, el hecho extintivo de la prescripción. Él sólo debe probar el hecho extintivo (del derecho del actor), es decir, la prescripción, y nada más (Papaño, Kiper, Dillon y Causse).

No necesita el demandado que opone esta excepción agregar la documentación que exige la ley 14.159 cuando se demanda por usucapición. Se suscita entonces el problema de saber si la sentencia definitiva que se dicte en tal proceso forma estado sobre la adquisición y correlativa extinción del derecho real de dominio, si con-

secuentemente es idónea como título de dominio en sentido instrumental y si como tal debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Distintas son las opiniones que han sido vertidas para dar respuesta a estos interrogantes, aunque desde ya se destaca que en el estado actual de la doctrina y jurisprudencia se considera casi unánimemente que el excepcionante que triunfa, no obstante haber acreditado en el juicio de reivindicación que es poseedor veintañal, debe promover con posterioridad la acción de prescripción adquisitiva de la ley 14.159 si pretende ser tenido como titular del dominio del inmueble prescripto y contar con un título, en el sentido instrumental, negociable en el comercio jurídico.

Por lo tanto, la sentencia que hace lugar a la excepción, ni es declarativa ni constitutiva de tal adquisición y como tal, al no importar la formación de un documento que declare o constituya derecho real alguno sobre inmuebles, es inaplicable el artículo 2º, inciso a, de la ley 17.801 y no debe inscribirse.

Claro que el peligro de sentencias contradictorias y el consecuente escándalo jurídico está latente. Para remediar esta situación, proponen Mariani de Vidal, Kiper y Goldenberg que, con posterioridad a la sentencia definitiva, y ya firme, que hace lugar a la excepción y rechaza la reivindicación, el excepcionante vencedor, en el mismo juicio reivindicatorio y como trámite de la ejecución de sentencia, pida ante el propio juez que la dictó una declaración judicial concreta acerca de la adquisición del dominio por prescripción, oportunidad en la que el peticionario también deberá acompañar el plano de mensura del inmueble objeto de la decisión judicial.

g) *La prescripción y los derechos reales de disfrute*

El usufructo, el uso y la habitación y las servidumbres positivas son derechos reales que pueden ser adquiridos de este modo, y correlativamente también perdidos. Además, se pueden extinguir por el no uso durante diez años (arts. 2152, inc. c, 2155, 2159, 2182, inc. b), lo que también ocurre con la superficie (art. 2124), aunque éste es un derecho real sobre cosa propia (art. 1888).

h) *La prescripción como freno a la acción de reducción*

Conforme el régimen del Código de Vélez, la acción de reducción con los expresados efectos reipersecutorios prescribía a los diez años contados a partir de la muerte del donante (conf. arts. 3955 y 4023 del Código Civil). No obstante, se entendía que transcurrido el plazo de prescripción veintañal desde la fecha de formalización de la donación, podría oponerse la usucapión como excepción al progreso de la acción reivindicatoria, tornando el título inobservable luego de dicho lapso.

El Código actual prevé lo siguiente: Artículo 2458: "*Acción reipersecutoria*. El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima".

Artículo 2459: "*Prescripción adquisitiva*. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901".

XV. La ley de regularización del dominio

a) *Objetivo de la ley*

La ley 24.374, sancionada y promulgada en setiembre de 1994, tuvo por objeto regularizar la situación de aquellos ocupantes de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente, que acrediten la posesión durante tres años con anterioridad al 1º de enero de 1992, y su causa lícita. Posteriormente, la ley 27.718 se refirió al 1º de enero de 2009.

El objetivo principal de esta ley es ofrecer una solución a aquellas personas de escasos recursos, adquirentes de inmuebles destinados a vivienda, pero que no han podido por diversos motivos obtener un título de propiedad, esto es, regularizar su situación. Las causas por las que se encuentran en tal situación pueden ser muy variadas, algunas imputables a los compradores y otras a los vendedores. En el primer grupo es posible imaginar que los compradores no hayan pagado el saldo de precio —seguramente establecido en cuotas— o los impuestos

a su cargo, la existencia de numerosas cesiones del boleto originario o solamente de la posesión, etcétera. En cuanto a los vendedores, es posible que se ignore su paradero, o que hayan muerto y existan complicaciones sucesorias, que las firmas intermediarias hayan desaparecido, que los loteos no hayan terminado, que la división bajo el régimen de la propiedad horizontal no se encuentre concluida, etcétera. Algún autor sostuvo que el cuadro es "caótico", y que puede ser aún más complicado en razón de problemas de usurpaciones, documentación fraguada, dificultades para acceder a la justicia y hasta de "prejuicios".

Se justifica el régimen también en las disposiciones de la Constitución Nacional tendentes a proteger la vivienda. En efecto, el artículo 14 bis asegura el "acceso a una vivienda digna", pero aquí también hay que tener presente que la Constitución protege además el derecho de propiedad y establece que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley (art. 17). De tal forma, la protección que el legislador otorgue a los adquirentes no puede ir en desmedro del derecho de propiedad de los titulares, ya que ambos preceptos deben ser compatibilizados.

En suma, la situación que pretende remediar esta ley es la de numerosos adquirentes, generalmente con boleto de compraventa y posesión, pero que no son dueños por no contar con el título suficiente. En la mayoría de los casos han comprado la "casa habitación permanente", o bien el terreno y luego construyeron sobre él. Se trata de poseedores, los que pueden ser "originarios" o "continuadores", si es que hicieron tradición a otros. Pero en ningún caso han adquirido el dominio. Además, suele tratarse de personas con escasos recursos económicos.

Si bien es cierto que en los casos señalados los compradores pueden acudir al juicio de escrituración, o adquirir el dominio al cabo de veinte años de posesión por medio de la prescripción adquisitiva, teniendo en cuenta las complicaciones que pueden rodear a cada situación, la ley referida pretende tornar más simple el procedimiento con el objeto de regularizarlas.

b) *Beneficiarios*

Artículo 1º: "Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres (3) años con anterioridad al 1º de enero de 2009, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación.

"En las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y produzcan".

Artículo 2º: "Podrán acogerse al régimen, procedimientos y beneficios de esta ley, en el orden siguiente:

- "a) Las personas físicas ocupantes originarios del inmueble de que se trate;
- "b) El cónyuge supérstite y sucesores hereditarios del ocupante originario que hayan continuado con la ocupación del inmueble;
- "c) Las personas, que sin ser sucesores, hubiesen convivido con el ocupante originario, recibiendo trato familiar, por un lapso no menor a dos años anteriores a la fecha establecida por el artículo 1º, y que hayan continuado con la ocupación del inmueble;
- "d) Los que, mediante acto legítimo fuesen continuadores de dicha posesión".

Puede apreciarse que para invocar la aplicación de este régimen legal no se requiere ser poseedor legítimo; más aún, los poseedores legítimos, por ser titulares del derecho real respectivo, no requieren de este sistema que nada les puede aportar. La ley está destinada a poseedores ilegítimos, aun de mala fe, pero que no sean viciosos. No hay que confundir posesión legítima con "causa lícita". De esta manera, quedan excluidos del sistema los intrusos, usurpadores y otros ocupantes ilegales.

Además de los requisitos enunciados, el beneficiario debe satisfacer dos recaudos de tipo negativo: 1. No ser propietario o poseedor de otro inmueble apto para satisfacer sus necesidades de vivienda (art. 4º, inc. a). 2. Que el inmueble no supere las características fijadas en la reglamentación (art. 4º, inc. b).

c) *El procedimiento para acogerse a los beneficios de la ley 24.374*

Para acogerse a este sistema, quienes resulten beneficiarios deben iniciar un trámite administrativo ante la respectiva autoridad de aplicación. En la Capital Federal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo demás, le corresponde determinar a cada provincia la autoridad de aplicación en sus respectivos territorios (art. 5°).

Agrega el artículo 6° que "c) Cuando la solicitud fuese procedente, se remitirán los antecedentes a la Escribanía de Gobierno o las que se habilitasen por las jurisdicciones respectivas, la que requerirá los antecedentes dominiales y catastrales del inmueble. No contándose con estos antecedentes se dispondrá la confección de los planos pertinentes y su inscripción;

"d) La Escribanía citará y emplazará al titular del dominio de manera fehaciente en el último domicilio conocido y sin perjuicio de ello lo hará también mediante edictos que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial y un diario local, o en la forma más efectiva según lo determine la reglamentación, emplazándose a cualquier otra persona que se considere con derechos sobre el inmueble, a fin de que deduzcan oposición en el término de 30 días;

"e) No existiendo oposición y vencido el plazo, la escribanía labrará una escritura con la relación de lo actuado, la que será suscripta por el interesado y la autoridad de aplicación, procediendo a su inscripción ante el registro respectivo, haciéndose constar que la misma corresponde a la presente ley;

"f) Si se dedujese oposición por el titular de dominio o terceros, salvo en los casos previstos en el inciso g), se interrumpirá el procedimiento;

"g) Cuando la oposición del titular del dominio o de terceros se fundare en el reclamo por saldo de precio, o en impugnaciones a los procedimientos, autoridades o intervenciones dispuestas por esta ley, no se interrumpirá el trámite, procediéndose como lo dispone el inciso e), sin perjuicio de los derechos y acciones judiciales que pudieren ejercer;

"h) Si el titular del dominio prestase consentimiento para la trans-

misión en favor del peticionante, la escrituración se realizará conforme a las normas de derecho común, siendo de aplicación las exenciones y beneficios previstos por el artículo 3°, los que se otorgasen en la reglamentación, y las que se dictasen en las respectivas jurisdicciones".

d) *Efectos de la inscripción*

Otorgada la escritura de relación que prevé el artículo 6°, inciso e, este instrumento debe ser inscripto en el Registro correspondiente a la ubicación del inmueble. Las consecuencias que produce la inscripción surgen del artículo 8°: "se convertirá de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez años".

En primer lugar, la inscripción registral, como sucede con todos los actos jurídicos que deben anotarse, hace que el título sea oponible a terceros interesados de buena fe.

Además, en el caso de esta escritura tan particular, se "convertirá de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez años". Esto no significa que aquélla sea un justo título, sino que produce —con algunas diferencias— los mismos efectos, en especial, la necesidad de que transcurran diez años de posesión para que el derecho se consolide. Tampoco significa que el que cuenta con la escritura de relación inscripta cuente con un dominio imperfecto, ya que no se dan tales similitudes, ni siquiera hay dominio.

La primera respuesta que viene a la mente es que frente al verdadero propietario no es dueño de la cosa. Ello por una razón muy simple: el poseedor con justo título es dueño frente a todos menos frente al verdadero propietario; por ende, el adquirente de la ley 24.374 no puede estar en una mejor posición. De esta conclusión se infiere otra: el dueño del inmueble que lo prometió en venta aún sigue siéndolo.

La cuestión más difícil es determinar si este adquirente, al contar con la escritura de relación inscripta, podría ser reputado propietario del inmueble frente al resto de la sociedad, tal como si tuviera un justo título. Cabe pensar que esto no es factible, por la sencilla razón de que los derechos reales se adquieren con la concurrencia del título (suficiente o justo) y la tradición. Si bien por hipótesis hubo tradición, aún no habría título, en el sentido de causa idónea para la transmisión

del derecho real. En suma, el beneficiario que se acogiera a este régimen y lograra cumplir con los distintos pasos previstos no sería dueño ni titular de ningún derecho real sobre el inmueble, sino al cabo de diez años. Seguiría siendo titular de un derecho personal, pero con fuerte oponibilidad, al contar con las ventajas que derivan de la inscripción registral. También su situación habría mejorado en el sentido de que contaba con un contrato formalizado en un instrumento privado, mientras que ahora contaría con un instrumento público.

CAPÍTULO XXV

PUBLICIDAD REGISTRAL INMOBILIARIA

MNR

SUMARIO: I. Introducción. II. Distintos sistemas. III. Sistema actual. IV. Principios registrales. V. Documentos registrables. VI. No convalidación. VII. Plazo general de presentación. Retroprioridad. Certificados. VIII. Calificación registral. IX. Inscripciones y anotaciones provisionales y preventivas. X. Anotación de las modalidades del negocio. XI. Prioridad. Pactos sobre rango. XII. Anotaciones personales. XIII. Rectificación de asientos. XIV. Cancelación de las inscripciones. XV. Caducidad de las inscripciones. XVI. Catastro.

I. Introducción

Los derechos reales se distinguen por su carácter absoluto; esto es, su oponibilidad *erga omnes*. Precisamente de allí surge la necesidad de que haya alguna manera de dar publicidad a su constitución, modificación o extinción, habida cuenta de que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad tienen el deber jurídico de respetar la relación trabada entre la persona y la cosa a raíz de la existencia del derecho real. Además del deber de respetar, ciertos terceros llamados interesados tienen una necesidad especial de conocer la situación.

La publicidad importa hacer saber a los integrantes de la comunidad la existencia del derecho real de que se trata, sin que sea decisivo si éstos han tomado o no conocimiento efectivo de dicha circunstancia.

Todos los derechos reales descansan sobre la base de la certeza respecto de su existencia, de suerte que los sistemas que favorezcan esta certeza son trascendentes para la economía de una comunidad. Por ello, se entiende que el sistema registral constituye la más acabada expresión de publicidad.

II. Distintos sistemas

Existen distintos sistemas de publicidad inmobiliaria que pueden ser divididos en registrales y no registrales. Aquí interesan los primeros:

a) De la transcripción

La inscripción, en este sistema, cumple limitados efectos respecto de terceros, pues los vicios de los actos traslativos no quedan eliminados con el acto de la inscripción. Por lo general se sigue el método de "registro personal", de manera que las búsquedas de los titulares del dominio deben hacerse por el nombre de las personas; no corresponde a cada inmueble un folio determinado, y la continuidad respecto de las transmisiones de dominio, o constituciones de derechos reales —que se asientan por orden cronológico— se obtiene por vía de notas marginales de remisión, aunque no se descarta el de "folio real".

La transcripción significa que se incorpora íntegro el documento registrado. La otra cara es la de una sintética referencia de los datos relativos al inmueble que permitan su individualización, así como los identificatorios de la persona que transmite y de la que adquiere el derecho real.

b) De los libros territoriales

Este método, en cambio, exige la inscripción para perfeccionar la transmisión del dominio. La preferencia de los derechos reales está determinada por el orden de las inscripciones. Utiliza el sistema del "folio real", que atribuye una hoja, cuaderno, carpeta, etcétera, a cada inmueble, en los que se asientan todas las transferencias de dominio o constitución de derechos reales, habiendo también índices auxiliares.

c) Sistema Torrens

Originario de Australia, se extiende a otros países e, inclusive, se proyectó alguna vez introducirlo en el nuestro. Su creador, Robert Richard Torrens, propuso un sistema para sanear la gran cantidad de títulos con vicios que existían en Australia, su país. Se considera que en toda transmisión, el dominio del inmueble pasa de la propiedad

del transmitente a la de la Corona, y de ésta a la del adquirente (considerando esta última adquisición como originaria y por lo tanto libre de vicios). Se completa el sistema con una indemnización de elevado monto que, funcionando a modo de seguro, cubría los reclamos de los perjudicados por la convalidación.

d) Sistema alemán

El Código Civil alemán plasmó una larga evolución para llegar a ser uno de los sistemas registrales más perfectos que se conocen, donde se inscribe el acuerdo mediante el cual quien figura en el Registro como titular conviene con otra persona en que determinado derecho se inscriba a su nombre. Cuando una persona tiene un derecho inscripto a su favor en el Registro se presume que a él le corresponde, lo que conduce al "principio de la fe pública registral", según el cual las inscripciones del Registro se reputan verdaderas (aun cuando no lo sean en la realidad) y sin admitirse prueba en contrario, para todo aquel que de buena fe y por acto voluntario, aunque sea a título gratuito, adquiera derechos reales sobre determinado inmueble, poniéndolo a cubierto de acciones reivindicatorias. La fe pública registral se encuentra regulada en los artículos 892 y 893 del Código Civil alemán.

Parte de desvincular el negocio causal de la transmisión del dominio. Este último es el *acto abstracto* que, así, separado de su causa originaria (por ejemplo, compraventa), no se ve afectado por los vicios de que adolezca el negocio: éstos se repararán por vía indemnizatoria. El principio del consentimiento es el otro elemento esencial del sistema. Significa que la situación registral sólo variará a pedido de quien sea titular, y ese requerimiento evita al Registro la incursión en la causa de la transmisión.

e) Sistema francés

En el Código Civil francés se consagró la tradición como forma de publicidad, reservando la registración solamente para las donaciones e hipotecas. Sin embargo, en 1855 se crea el Registro Inmobiliario, para hacer oponibles a terceros los actos de disposición de inmuebles,

ya que "el propietario no es propietario respecto de terceros si no hace transcribir sus títulos en un registro especial y público establecido para ese efecto".

f) España

En España rige la Ley Hipotecaria de 1861 y sus posteriores modificaciones. Sirvió de antecedente a la ley argentina.

Es un sistema *convalidante impuro*, pues la convalidación no deviene sólo de la inscripción del derecho, sino que se logra con la registración sumada a otros elementos *previstos en la propia ley registral*. Estos elementos son la buena fe, la onerosidad del negocio causal, el respeto del tracto sucesivo, y la exigencia de que, en caso de existir, el vicio o nulidad del título no resulte manifiesto. Esto se infiere a partir del artículo 34 de la Ley Hipotecaria española. Vale aclarar que, si bien el artículo 33 de la Ley Hipotecaria expresa un principio similar a nuestro artículo 4º, declarando que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, el mencionado artículo 34 de la misma ley, a renglón seguido, establece supuestos de convalidación emanados de la propia ley.

El sistema español a tenor de la norma del artículo 34 establece que, cuando concorra la buena fe del adquirente, que hubiera su derecho por título oneroso del titular anteriormente registrado comprobándose el tracto encadenado, y si el título de su derecho no presentase nulidades manifiestas, no podrá ser perturbado por ninguna causa y será mantenido en su adquisición una vez que haya inscripto su derecho.

g) Otras clasificaciones

Según la forma en que se procesen los datos, los registros pueden ser personales o reales. En los primeros, las inscripciones toman como referencia el nombre del titular, mientras que los segundos, a la cosa sobre la que se transmiten derechos.

Según los efectos, los registros pueden ser declarativos o constitutivos. En los declarativos el derecho real ya fue adquirido, y la inscripción sólo se requiere para la publicidad, mientras que en los segundos la inscripción hace nacer el derecho real.

También se los divide en convalidantes y no convalidantes. En los segundos, la inscripción sana los vicios que pueda tener el acto jurídico (sistema germánico). El sistema argentino no es convalidante.

III. Sistema actual

Es de suma importancia lo dispuesto por el artículo 1893: "La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente.

"Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso.

"Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real.

"No pueden prevalecerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real".

Por ende, en lo que respecta a inmuebles, la inscripción en el Registro es necesaria para la oponibilidad a terceros interesados de buena fe; es *declarativa*. Lo atinente a todo lo que tiene que ver con el sistema está regulado, desde antes de la sanción de este Código, por la ley 17.801.

Tal inscripción opera "para su publicidad" y "oponibilidad a terceros" (art. 2º), aunque "Las partes, sus herederos y los que han intervenido en la formulación del documento [se refiere al que asigna la titularidad del derecho real], como el funcionario autorizante y los testigos en su caso, no podrán prevalecerse de la falta de inscripción, y respecto de ellos el derecho documentado se considerará registrado" (art. 20).

Se trata de una ley complementaria del Código Civil y Comercial (art. 5º, ley 26.994 y Anexo II de dicha ley). El régimen de la Ley del Registro de la Propiedad Inmueble en la Capital Federal está reglamentado por el decreto 2080/80 (t. o. 1999, decreto-ley 466/99).

Las provincias no pueden dictar normas locales que contraríen el sistema previsto en el Código o en dicha ley, o excedan la regulación

del funcionamiento administrativo de los Registros, y tendrán que adecuarse y respetar los principios registrales adoptados, sin incluir los no aceptados por la ley nacional.

Se trata de un registro real (de *res*: cosa) ya que toma como base la cosa sobre la que recae el derecho, en lugar de la persona del titular. Por este sistema cada inmueble está matriculado con su correspondiente número de orden y se le asigna una hoja especial llamada "folio real", en la que se asienta toda constitución, transmisión o extinción de los derechos reales que tengan por objeto el inmueble en cuestión, y su consulta permite conocer el estado jurídico de dicha cosa.

a) Registro de documentos

Como ya se dijo, se trata de un registro cuyos efectos son declarativos, no constitutivos.

Es un registro de documentos y no de derechos. Los documentos inscribibles suelen ser identificados con el nombre de títulos, que son los documentos materialmente elaborados en soporte papel, que contienen la expresión del negocio jurídico causa de la constitución, modificación, transmisión, declaración o extinción del derecho real. Título en sentido *sustancial* (o material para alguna doctrina) refiere al acto jurídico con entidad suficiente para causar la mutación del derecho real; es la causa mediata del derecho, y como tal se abstrae tanto del papel que lo soporta como de su registración. Título en sentido *formal* (o instrumental) es el documento plasmado en el soporte papel que provoca la registración, y debe ser hecho en la forma instrumental que requiera la ley de fondo para el título sustancial. Genera, transcurrido el *iter inscriptorio*, el momento definido como asiento o toma de razón, a partir del cual, la oponibilidad del derecho es plena. A partir de allí, el derecho *declarado* será dotado de la publicidad máxima que prevé el sistema de publicidad actual de los derechos reales.

Como se vio en otro capítulo, *la sentencia que admite la adquisición del derecho real por prescripción* también tiene vocación registral. Esto significa que también se inscriben las adquisiciones originarias, no sólo las derivadas.

b) No convalidante

Los *sistemas no convalidantes* son aquellos en los que la registración genera a favor de su titular una presunción *iuris tantum* atributiva del derecho registrado, cuyo efecto principal es la publicidad en sí misma con los efectos tasados por la ley (oponibilidad plena), pero que en modo alguno puede sanear los vicios de que adoleciera el acto jurídico causa de la adquisición, transmisión, modificación, declaración o extinción del derecho real. La inscripción no convalidante ofrece al titular del derecho registrado una protección defensiva y no agresiva, que le da cierta inmunidad, basada en la apariencia jurídica, pero que puede eventualmente perderse o modificarse por situaciones anteriores a la registración que no lo libera hacia el futuro de posibles nulidades que causen la pérdida del derecho por una situación del pasado. La inscripción no mejora, aumenta, empeora o disminuye el valor de los títulos, pues su finalidad no es dotarlos de eficacia, sino simplemente publicitarlos.

Expresamente surge del artículo 4°: "La inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes".

La situación de eventual convalidación legal del derecho emana del artículo 392 que dispone dejar a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso.

c) Otras características

Se pueden mencionar: 1) protección de los negocios en gestión (o sea, todavía no celebrados) mediante la reserva de prioridad indirecta, cuya naturaleza es la de una anotación preventiva (art. 25); 2) instauración de la técnica del folio real para todos los registros del país (art. 10); 3) como principio general el Registro recibe documentos (arts. 2° y 3°), es decir, títulos con la forma de escritura pública (mayormente) o algún otro instrumento público judicial o administrativo (excepcionalmente, instrumentos privados con firmas certificadas: art. 3°, último párrafo); 4) se establecen límites a las facultades de calificación del registrador.

d) *El folio real*

El folio real consiste en una ficha o tarjeta (soporte gráfico) de gran tamaño que contiene la descripción física del inmueble, su ubicación, el número por el cual lo designa el Registro (matrícula), la identificación según el Catastro (nomenclatura catastral), la designación (según título o plano), los antecedentes dominiales y los derechos reales sobre la cosa.

Los asientos registrales se dividen en *inscripciones* y *anotaciones*, que no son lo mismo.

e) *Inscripción facultativa*

Se trata de un tema controvertido pero cabe inclinarse por la postura que afirma que la inscripción registral es facultativa. Claro que no hacerla trae importantes consecuencias. Lo cierto es que los derechos reales se adquieren fuera del Registro.

Por otro lado, la omisión puede generar la responsabilidad del notario.

f) *Formas de publicidad*

Dispone el artículo 21 de la ley 17.801 que "El Registro es público para el que tenga interés legítimo en averiguar el estado jurídico de los bienes, documentos, limitaciones o interdicciones inscriptas. Las disposiciones locales determinarán la forma en que la documentación podrá ser considerada sin riesgo de adulteración, pérdida o deterioro".

El Registro suministra información a través de informes, consultas, copias de asientos (*publicidad formal*), o certificados (*publicidad material*). La *publicidad formal* se refiere a la que está disponible para la sociedad (v. gr.: pedido de informe); es la divulgación de lo registrado, mientras que la *material* se vincula con el proceso necesario para la inscripción de un documento. En esta última tienen relevancias los certificados (arts. 22 a 25), lo que será examinado más adelante.

El Registro es público para el que tenga "interés legítimo" en averiguar el estado jurídico de los bienes (art. 21).

La posibilidad de conocer o *publicidad formal*, entonces, no resulta

indiscriminada, sino que está disponible solamente para el que la necesite. Existen distintos medios: la exhibición, la consulta, el informe, y el certificado. Los efectos de cada uno de ellos varían según su finalidad.

IV. Principios registrales

a) *Rogación*

El artículo 6° de la ley 17.801 consagra el llamado Principio de Rogación o Instancia. Este principio indica que el procedimiento registral, cuya conclusión es el momento llamado toma de razón, solamente puede ser iniciado a instancia de parte y mediante solicitud o petición dirigida al registrador para que éste ponga en marcha el procedimiento que lleve a la inscripción. El registrador no puede actuar de oficio, ni siquiera frente al conocimiento real de la existencia, de una mutación que tenga vocación registral; debe abstenerse de toda actividad si no es a solicitud de algún sujeto legitimado.

Una vez efectuada la rogación, el registrador, a quien va dirigida, no puede sustraerse de sus efectos ni negar la apertura del proceso administrativo, salvo cuando el documento ingresado con la rogatoria no sea uno de los previstos en el artículo 2° de la ley. El Registro no puede negar la inscripción de documentos con vocación registral, sino simplemente comprobar su registrabilidad y sus formas extrínsecas. Teniendo en cuenta los efectos jurídicos que la ley asigna a la publicidad inmobiliaria, a cargo del Estado, el servicio registral es inexcusable y su prestación constituye para la administración pública una obligación.

El proceso administrativo registral comienza con la petición de inscripción por quien se encuentre legitimado para hacerlo. Su solicitud procederá aun contra la voluntad expresa de otros sujetos a quienes la rogación pueda desplazar o perjudicar.

No cualquier sujeto está legitimado para rogar la inscripción o solicitar información del Registro, sino solamente aquellos a quienes la ley atribuye un interés legítimo. En tal sentido, dispone el artículo 6° que "La situación registral sólo variará a petición de:

- "a) El autorizante del documento que se pretende inscribir o anotar, o su reemplazante legal;

"b) Quien tuviere interés en asegurar el derecho que se ha de registrar.

"Cuando por ley local estas tareas estuvieren asignadas a funcionarios con atribuciones exclusivas, la petición deberá ser formulada con su intervención".

Si bien la inscripción es *facultativa*, no obligatoria, su omisión por parte del notario interviniente puede generarle responsabilidad personal.

La rogación siempre debe hacerse juntamente con la presentación del título formal, es decir, acompañada del documento portante del derecho o situación jurídica registrable. Es una consecuencia del llamado principio de presencia documental.

b) Principio de especialidad

Este principio se vincula con la determinación precisa de los sujetos, objeto y causa de la relación jurídica que ingresa en el Registro, a fin de provocar una mutación en el asiento correspondiente.

Cabe advertir, en primer lugar, que "Los inmuebles respecto de los cuales deban inscribirse o anotarse los documentos a que se refiere el artículo 2º, serán previamente matriculados en el Registro correspondiente a su ubicación. Exceptúanse los inmuebles del dominio público" (art. 10). Se recuerda que el artículo 2º menciona, en lo que aquí interesa, los actos que constituyan, declaren, modifiquen, transmitan o extingan derechos reales (inc. a).

El artículo 10 de la ley 17.801 adopta inequívocamente el método registral real, tomando como elemento determinante del ordenamiento la finca, el inmueble, como la mejor forma de individualizar y clasificar los asientos, en miras de lograr una publicidad con mayor efectividad, evitando la dispersión de la información y facilitando la expedición de informes y certificaciones, situación que permite un resultado más completo a la hora de asignar efectos de la publicidad inmobiliaria. El inmueble constituye así el centro de atracción de las demás circunstancias que justifiquen ser publicitadas, tales como la titularidad de derechos, las restricciones o gravámenes, la afectación a regímenes especiales, etcétera.

b.1) Matriculación

El artículo 10 fija, con rango de norma nacional, la técnica registral en sentido estricto, adhiriéndose a la llamada técnica del folio real, mandando que cada inmueble deba "inmatricularse", entendiéndose tal actividad como la incorporación al Registro mediante la apertura de una matrícula para cada inmueble. La matrícula, unidad de identificación registral, constituye entonces un concepto abstracto destinado a permitir la individualización de los inmuebles; generalmente identificada con un número que la singulariza, al que puede adicionarse la identificación de la ubicación geográfica zonal dentro del ejido de cada partido; corresponde a una ordenación lógica dispuesta en cada jurisdicción local de acuerdo a la división del suelo.

El artículo practica una exclusión: los inmuebles de dominio público propiedad del Estado.

Cuando se trata de un derecho real sobre cosa propia, y luego se constituye otro de la misma índole (v. gr.: superficie) o una desmembración, corresponderá la apertura de una *nueva matrícula* registral. Siguiendo este razonamiento, por ejemplo, en el derecho de *tiempo compartido* o en el de *sepultura*, deberán crearse tantas matrículas como derechos hayan nacido. Ésa será la única forma de mantener un tracto sucesivo claro y completo respecto de cada titularidad.

b.2) Especialidad del objeto

El inmueble es el elemento principal, soporte de la base real del sistema, por lo que la referencia a la descripción de la cosa es ineludible. Y también resulta imprescindible establecer el contacto entre el Registro de la Propiedad Inmueble y el Catastro, como generador de la existencia de la cosa objeto de los derechos. Para que exista el inmueble como cosa susceptible de derechos, es previo al momento de su nacimiento un plano generador. De allí que la referencia a la designación catastral y la identificación del plano de origen del inmueble constituyan elementos esenciales de las breves notas necesarias para la descripción de la finca. De este plano generador de la cosa pueden resultar registrables otras circunstancias de trascendencia real, tales como la existencia de restricciones administrativas, o servidumbres.

b.3) *Especialidad de los sujetos*

Es necesario consignar los datos personales de los titulares de los derechos, lo que también deberá hacerse mediante la técnica de la inscripción. Dice el artículo 12 que el asiento de matriculación "expresará el nombre del o de los titulares del dominio, con los datos personales que se requieran para las escrituras públicas. Respecto de las sociedades o personas jurídicas se consignará su nombre o razón social, clase de sociedad y domicilio".

b.4) *Especialidad del título causal*

Finalmente, se establece la necesidad de identificar, también mediante la técnica de inscripción, el título causal. Dice el artículo 12 que "Se hará mención de la proporción en la copropiedad o en el monto del gravamen, el título de adquisición, su clase, lugar y fecha de otorgamiento y funcionario autorizante, estableciéndose el encadenamiento del dominio que exista al momento de la matriculación. Se expresará, además, el número y fecha de presentación del documento en el Registro".

Este título, el necesario para la adquisición del derecho real, constituye uno de los documentos inscribibles mencionados en el artículo 2º de la ley. Podrá tratarse de un documento de origen notarial o judicial.

c) *Principio de legalidad*

Dispone el artículo 8º: "El Registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los sistemas respectivos".

En este artículo encuentra recepción el conocido principio registral de legalidad. El proceso registral integralmente considerado, los documentos inscribibles y los efectos generados por la publicidad registral, es decir, el sistema como un conjunto debe ser *adecuado a derecho*, pues lo legal es lo adecuado a la ley.

En su aspecto sustancial el principio de legalidad se aprecia por su resultado: si el procedimiento de inscripción se ha cumplido de acuerdo a derecho, "legalmente", y el registrador ha examinado en

ejercicio de la función calificadoradora el documento a inscribir, se genera una presunción de que el derecho inscripto o la situación jurídica registrada son "legales", es decir, ajustados a derecho, por haber cumplido con los requisitos impuestos por la ley en cuanto a su forma y, por lo tanto, reflejan la realidad extrarregistral. Los asientos se presumen exactos y concordantes con la realidad jurídica exterior.

La apariencia que genera la registración, dotando a la mutación registrada de oponibilidad, hace menester que el documento inscripto sea revisado en sus aspectos formales o extrínsecos, debiendo negarse la inscripción a los que presenten vicios instrumentales que puedan causar la privación de sus efectos. Por eso el principio de legalidad da nacimiento necesariamente a la función calificadoradora, ya que no se concibe que el registrador actúe ajustando su conducta a derecho, intervenga legalmente, si procede a dar posición registral a un documento defectuoso. El registrador es responsable de hacer efectivo este principio, y para él se impone como un derecho y a la vez como un deber consistente en analizar el documento inscribible.

La actividad del registrador no es sólo mecánica, no se trata de un buzón que recibe todo lo que se le deposita. Por el contrario, debe verificar que la petición y que los documentos que se le presentan cumplan con los recaudos legales. Presentado el trámite pueden suceder distintas respuestas: a) que el documento se inscriba; b) que la inscripción sea rechazada; c) que se anote provisoriamente hasta tanto se subsanen ciertos defectos; d) que se anote condicionalmente, al estar la toma de razón subordinada a la presentación de otros documentos que cuentan con prioridad.

d) *Principio de prioridad*

El *ius preferendi* (además de conferir privilegio) indica que quien es primero en el tiempo, es mejor en el derecho, es decir que goza de una prioridad. El derecho de preferencia, en lo que respecta a inmuebles, está estrechamente ligado a la publicidad registral ya que quien resulte titular registral en primer término, u obtenga la anotación de medidas cautelares en su favor (prioridad directa), inscriba su título en el plazo previsto en este artículo 5º (prioridad indirecta) o reserve

la prioridad para la celebración de un negocio mediante certificado (retroprioridad) prevalecerá sobre el que adquiriera su derecho o posición registral con posterioridad. Tendrá prioridad.

Reviste fundamental importancia la fecha de presentación en el Registro y su efecto retroactivo. No obstante, las partes pueden alterar este orden estableciendo de común acuerdo un orden diferente. Así, por ejemplo, quien está en primer lugar podría cambiar su posición con quien está segundo (permuta de rango).

e) *Tracto sucesivo*

Prevé el artículo 14 de la ley 17.801 que los asientos que se hagan en el folio real "se llevarán por estricto orden cronológico que impida intercalaciones entre los de su misma especie y en la forma que expresa el artículo 12, en cuanto fuere compatible, con la debida especificación de las circunstancias particulares que resulten de los respectivos documentos, especialmente con relación al derecho que se inscriba". Agrega el artículo 15: "No se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente. De los asientos existentes en cada folio deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular de dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones".

La enunciación expresa del orden cronológico es una de las claves de funcionamiento del sistema de publicidad registral inmobiliaria. Dispone la ley que los asientos se realizarán cronológicamente, en un orden que respete absolutamente la prioridad en el tiempo. También dispone que esta cronología no debe admitir la posibilidad de intercalación posterior de anotaciones e inscripciones en espacios inadecuados, evitando la posibilidad de confundir la ubicación del asiento con los efectos que se generan.

El principio de tracto sucesivo indica que debe existir una perfecta correlación entre el titular registrado, quien es el legitimado para disponer o gravar el derecho, y sobre quien puedan disponerse medidas cautelares o restricciones de tipo judicial, y su sucesor a registrar. De donde, sólo procederá la registración de un derecho, en tanto devenga

como *tradens*, del titular actual registrado, para generar la inscripción del nuevo titular, que será el *accipiens*. Esto en cuanto a las transferencias de derechos y, en tal sentido, no se podrá registrar la constitución de un derecho desmembrado; por ejemplo, si no es constituido por el titular del derecho real legitimado para ello.

La serie de anotaciones e inscripciones obrantes en la matrícula, sin solución de continuidad, deberán reflejar la historia del inmueble, sus distintas titularidades y los gravámenes o interdicciones que sobre él pesaron.

El tracto, entonces, implica una sucesión perfecta y continua de titulares, a modo de una cadena cuyos eslabones constituyen las titularidades temporalmente desplegadas. Así sucede cuando el dominio se transfiere de un titular a otro u otros, ya sea por un acto dispositivo traslativo de la propiedad a favor de un sucesor particular, tales como las ventas, permutas, daciones en pago, donaciones, etcétera, contratos de efectos traslativos, por acto entre vivos, o cuando la transferencia opere por causa de muerte a favor del sucesor universal y mediante la institución de la sucesión.

e.1) *Continuidad registral*

El encadenamiento a que refiere el artículo 15 entre el transmitente y el adquirente, que supone la transferencia del derecho real de dominio entre ambos, constituye el llamado tracto sucesivo material y permite conocer el historial de las sucesivas titularidades de dominio, permitiendo remontarse, si no al origen mismo del dominio, al momento de mayor antigüedad en la registración que, dada la evolución y tiempo de vigencia de los registros, es más que suficiente para poder estudiar los títulos causales de cada transferencia para abonar un título como perfecto. En este encadenamiento registral se encuentra el llamado tracto sucesivo formal, o adjetivo. La precisión de las inscripciones y la presunción de su veracidad imponen entonces la coincidencia entre el tracto material y el formal. El tracto sucesivo importa la exigencia de la previa inscripción del derecho en cabeza de su disponente, ya que no se admite el ingreso al Registro de un documento en el que no sea él quien resulte el disponente.

e.2) *Excepciones previstas para el principio de tracto sucesivo. Tracto abreviado*

Establece el artículo 16 que "No será necesaria la previa inscripción o anotación, a los efectos de la continuidad del tracto con respecto al documento que se otorgue en los siguientes casos:

- "a) Cuando el documento sea otorgado por los jueces, los herederos declarados o sus representantes, en cumplimiento de contratos u obligaciones contraídas en vida del causante o su cónyuge sobre bienes registrados a su nombre;
- "b) Cuando los herederos declarados o sus sucesores transmitieren o cedieren bienes hereditarios inscriptos a nombre del causante o de su cónyuge;
- "c) Cuando el mismo sea consecuencia de actos relativos a la partición de bienes hereditarios;
- "d) Cuando se trate de instrumentaciones que se otorguen en forma simultánea y se refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque en las respectivas autorizaciones hayan intervenido distintos funcionarios.

"En todos estos casos el documento deberá expresar la relación de los antecedentes del dominio o de los derechos motivo de la transmisión o adjudicación, a partir del que figure inscripto en el Registro, circunstancia que se consignará en el folio respectivo".

En este artículo la ley prevé diversas situaciones en las que no se requiere al disponente el requisito de la previa inscripción de un derecho para lograr la registración de un documento. Es una simplificación del proceso de inscripción por aplicación del principio de economía procesal, que caracteriza a todas las normas formales o de procedimiento. En vez de practicarse dos o más asientos, en uno solo se concentran diversos actos dispositivos.

La existencia de estas excepciones no implica la inaplicabilidad del principio de tracto sucesivo, sino el traslado de la legitimación a la fase inmediatamente anterior del negocio, ya que la circunstancia de no requerir la previa inscripción de un titular, para considerarlo legitimado para disponer, no supone la inexistencia del tracto, sino por el contrario que la verificación de su cumplimiento se traslada al

acto de documentarse el acto dispositivo, ya sea de naturaleza judicial o notarial. Así, la continuidad se manifiesta encadenada no en las inscripciones, sino en los propios documentos con vocación registral. En su faz registral el tracto sigue siendo sucesivo, pero se encuentra comprimido en una única actividad inscriptora.

En el primer grupo de supuestos, frente a la disposición de los bienes de la herencia, se traducen tres situaciones diferentes:

La primera, coincidente con el inciso a, refiere a los actos dispositivos otorgados en cumplimiento de una obligación contraída por el causante, cuando fuera él el titular registral del derecho, o su cónyuge. La circunstancia más común es la que se presenta cuando el dueño del inmueble promete la venta mediante boleto, pendiente la escrituración. Producido su fallecimiento, persiste vigente la obligación de otorgar la correspondiente escritura la que deberá ser cumplida por el juez o, en su caso, por los herederos declarados o sus representantes.

La segunda hipótesis refiere a los actos otorgados por los herederos. La particular redacción del inciso merece alguna referencia. Comienza otorgando la posibilidad del tracto abreviado a los herederos declarados, o sus sucesores, sin establecer qué clase de sucesores son los habilitados para este mecanismo. Queda claro que los herederos declarados del titular registral no necesitan inscribir los bienes a su nombre para disponer y lograr la inscripción de ese acto dispositivo; y en cuanto a los sucesores, la doctrina entiende que el inciso refiere a los herederos del heredero, permitiéndose la acumulación del tracto comprimido en más de un proceso sucesorio.

La tercera posibilidad se vincula con los documentos otorgados como consecuencia o que resulten relativos a la partición de bienes de la herencia. Por ejemplo, producido el fallecimiento del causante, se tramita su sucesión, dictándose la correspondiente "declaratoria de herederos". Los declarados resuelven en el expediente adjudicar los bienes, sin otorgarse las hijuelas, pero habiéndose homologado dicha adjudicación. Luego un heredero, adjudicatario pero no titular registral, resuelve la venta del bien adjudicado. Se entiende que el acto a inscribir por tracto comprimido es consecuencia de un acto relativo a la partición, que le sirve de antecedente. Aquí, la legitimación se hará relacionando en el texto del documento tanto la declaratoria de herederos como la

adjudicación y el dominio se inscribirá directamente a nombre del adquirente, claro incluyendo el reflejo registral de ambos actos, la declaratoria y la adjudicación.

El cuarto inciso del artículo 16 prevé la situación de las instrumentaciones simultáneas. El supuesto en cuestión permite adecuar las exigencias del tracto sucesivo a la realidad negocial. Se habilita por este medio la transferencia del dominio o la constitución de otros derechos reales sobre un mismo inmueble cuando se refieran a negocios jurídicos simultáneos, otorgados o no por el mismo funcionario público. Es posible entonces que un sujeto adquiera el dominio de un inmueble y simultáneamente lo transfiera, o constituya sobre él otro derecho real en beneficio de un tercero, siempre atendiendo al requisito de la simultaneidad. Lo importante de estos negocios consiste en que la legitimación en cuanto a la titularidad de los derechos se deriva de los documentos otorgados, y es en ellos donde se cumple el encadenamiento del tracto, verificándose que el último titular devenga en tal por obra de su antecesor.

Una posición, que califica la enumeración del artículo 16 como enunciativa, considera que este artículo no describe actos específicos, sino clases de actos, y que, en cuanto los supuestos que pudieran acudir a la omisión de la previa inscripción permitan una simplificación de trámites innecesarios, sin perjudicar derechos de terceros, nada obsta a su utilización. Algunos de los supuestos no contemplados expresamente y de utilización regular del tracto abreviado, lo constituyen el otorgamiento de actos de disposición de bienes gananciales una vez disuelta la sociedad conyugal por divorcio, la hipoteca por los herederos declarados, entre otros.

f) Principio de exactitud, legitimación y fe pública registral

El principio registral relacionado con la convalidación de las situaciones o derechos registrados se conoce como la fe pública registral. Conforme a este principio, y en provecho de terceros adquirentes de buena fe, la ley reputa exacto el contenido de los asientos aun en los supuestos en los que fueran inexactos, sin admitir prueba en contrario. Así, el sistema registral alemán lo adopta enteramente, como el español,

tal como resulta del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. En palabras de Roca Sastre, la fe pública registral asegura al tercero adquirente protegido la existencia, titularidad y extensión de los derechos reales inscriptos.

En el Quinto Congreso Internacional de Derecho Registral (Roma, 1982), se declaró que "constituye un principio universalmente aceptado del derecho registral que el Registro se presume exacto e íntegro". La cuestión radica en el alcance de tal presunción.

Nuestro sistema registral inmobiliario no ha consagrado el principio de fe pública registral sino en grado de presunción de legitimidad, lo que expresa la recepción de otro de los principios registrales conocido como de legitimación.

La buena fe no depende sólo de lo publicitado, sino de que el tercero que conoce un derecho o situación registral debe necesariamente para acreditar su buena fe, estudiar y revisar tanto los títulos constitutivos del derecho, como los expedientes que originan las medidas cautelares restrictivas.

Los asientos registrales se presumen veraces, esto es, se presume que el derecho real inscripto existe y que son ciertas las anotaciones vinculadas al inmueble en cuestión. Se trata de una presunción *iuris tantum*, ya que es posible demostrar lo contrario. Quien afirme la inexactitud, es decir, que lo informado por el Registro no coincide con la realidad extrarregistral, carga con el *onus probandi*. En principio, lo que exterioriza el Registro se presume verdadero, lo cual es lógico ya que, si no fuese así, de poco serviría el Derecho registral.

Debe admitirse la vigencia del principio de exactitud ya que, de lo contrario, la publicidad registral no tendría razón de ser. Es una especie de garantía que el ordenamiento jurídico debe proporcionar. Esta presunción cede sólo cuando el interesado pruebe la mala fe del tercero. No debe prevalecer la realidad registral por sobre la jurídica, cuando media mala fe del que pretende beneficiarse con ella.

f.1) Consecuencias

Los derechos reales pueden estar frente al Registro en alguna de las siguientes situaciones: a) *secundum tabulas*: existe una perfecta

concordancia entre la realidad jurídica y lo que informa el Registro; b) *contra tabulas*: hay una discordancia entre la realidad jurídica y lo que surge de las constancias registrales, ya sea por nulidad o extinción de los derechos inscriptos, ya por existir en la realidad gravámenes reales que no constan en los asientos; c) *extra tabulas*: esta situación comprende a las fincas que nunca tuvieron acceso a los libros registrales.

Las consecuencias de este principio, que presume la veracidad de las constancias registrales hasta tanto se demuestre lo contrario, son diversas. Por un lado, desde el punto de vista sustantivo, al titular inscripto se lo trata como si realmente fuese titular, y se le reconoce la facultad de disponer con plena eficacia jurídica; se considera que el derecho real existe, y que existe de acuerdo a las constancias del asiento; también se considera que es verdadera la causa por la cual el titular inscripto obtuvo su derecho (v. gr.: compraventa, donación, partición, etc.). Como contrapartida, cabe presumir la inexistencia de los derechos cuya cancelación informa el Registro. La presunción, en algún caso, puede jugar en contra del titular ya que, por ejemplo, podrá ser demandado como propietario del inmueble si figura inscripto como tal, aun cuando haya transmitido el derecho. Por otro, desde el punto de vista procesal, al titular inscripto se lo libera de la carga de la prueba, ya que estará a cargo de quien sostenga la inexactitud registral.

De la armonización de los artículos 2º, 20 y 22 de la ley 17.801 surge que: a) los derechos reales no inscriptos son inoponibles a terceros de buena fe; b) esto permite arribar a la conclusión de que lo no registrado no perjudica a terceros; se trata de la protección de sentido negativo que impera también en España y que traduce la vigencia del principio de presunción de completitud o integridad registral.

En lo que hace al tercero que adquiere del titular inscripto, la protección definitiva no la encuentra en el Registro, sino en la regulación de los efectos de las nulidades, en especial en las reglas sentadas por el artículo 392 del Código Civil y Comercial. Ello, claro está, si es de buena fe (la que se presume) y a título oneroso. Esto no significa desconocer la importancia que tiene la obtención de los certificados que emite el Registro ni la importancia que tiene la actuación del tercero que se apoyó

MNR

en ellos, pero su protección definitiva dependerá de que no se demuestre su mala fe, ya sea porque conocía la discordancia entre la realidad registral y la extrarregistral, ya porque debió conocerla si hubiese actuado con diligencia y cuidado (v. gr.: estudio de títulos).

V. Documentos registrables

El artículo 2º de la ley 17.801 establece que, a los efectos de su oponibilidad a terceros, deben inscribirse en el Registro "los siguientes documentos:

- "a) Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles;
- "b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares;
- "c) Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales".

a) Títulos

Establece el inciso a, del artículo 2º que son documentos inscribibles: "Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles". No se refiere solamente a las escrituras públicas celebradas entre partes, sino que es comprensivo de los documentos de naturaleza judicial, que contienen y documentan actos judiciales (v. gr.: subasta), o de naturaleza administrativa, es decir que expresen actos administrativos. Para resultar inscribibles estos actos deben constituir, transferir, declarar, modificar o extinguir derechos reales sobre inmuebles. Quedan comprendidos en este inciso todos los documentos que sirvan de título a un derecho real, o sean título de su extinción o modificación, así como aquellos que resultan meramente declarativos de él.

La palabra documento está empleada en sentido amplio, equivalente a título, que comprende tanto la cuestión material como la formal.

b) Medidas cautelares

En cuanto a las medidas cautelares, generan en beneficio del que solicitó su traba una preferencia a la hora de satisfacer su crédito y, en

consecuencia, es especialmente importante con relación a ellas la prioridad registral, ganada a partir de que se asuma la posición o rango.

c) *Leyes especiales*

Finalmente, en cuanto al inciso c, que otorga vocación registral a los documentos "...establecidos por otras leyes nacionales o provinciales", la inclusión del inciso pudo obviarse, ya que los incisos a, y b, contienen todos los supuestos de documentos registrables o situaciones con vocación registral. Además, resulta obvio que cuando una ley especial disponga la vocación registral de un documento, aun cuando no existiera este inciso c, entraría por cualquiera de los otros dos. Si una ley provincial confiere vocación registral a un documento, deberá ser consistente y no contradictoria con la propia ley 17.801 y con las normas de fondo o sustanciales.

Como ejemplo puede citarse la ley 14.005, prevista para situaciones de venta a plazos y en protección de los derechos de los compradores con boletos de compraventa; la ley 24.374, que dispone el régimen de la regularización dominial, o el artículo 1234 del Código, que dispone la registración del contrato de leasing. Se puede apreciar que, entonces, por excepción pueden ingresar al Registro derechos personales e instrumentos privados.

Por lo demás, diversas leyes locales se refieren a la inscripción de actos tales como la declaratoria de herederos, la cesión de derechos hereditarios e, incluso, de boletos de compraventa, como prevé la ley 6435 de la Provincia de Santa Fe.

d) *Requisitos que deben reunir los documentos*

Dispone el artículo 3º: "Para que los documentos mencionados en el artículo anterior puedan ser inscriptos o anotados, deberán reunir los siguientes requisitos:

- "a) Estar constituidos por escritura notarial o resolución judicial o administrativa, según legalmente corresponda;
- "b) Tener las formalidades establecidas por las leyes y estar autorizados sus originales o copias por quien esté facultado para hacerlo;

- "c) Revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismo o con otros complementarios en cuanto al contenido que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente de título al dominio, derecho real o asiento practicable.

"Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscriptos o anotados los instrumentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano público, juez de paz o funcionario competente".

Se trata, en general, de instrumentos públicos aunque, por excepción, la última parte del artículo 3º permite la inscripción de "instrumentos privados" si alguna ley lo dispone y las firmas están certificadas. Así ocurre, por ejemplo, con los boletos de compraventa previstos en la ley 14.005, o cuando en alguna provincia se autoriza su inscripción.

Otro caso se encuentra en el propio Código, ya que el artículo 1679, último párrafo, establece que cuando cesa un fiduciario y los bienes registrables son transmitidos a un nuevo fiduciario, es forma suficiente —entre otros— el instrumento "privado autenticado".

e) *El caso del boleto de compraventa*

La duda surge de la lectura del artículo 1170 del Código, cuyo texto es el siguiente: "El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si:

- "a) el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos;
- "b) el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento del precio con anterioridad a la traba de la cautelar;
- "c) el boleto tiene fecha cierta;
- "d) la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria".

El Código se propone claramente ampliar los efectos del boleto de compraventa, permitiendo su oponibilidad no sólo en el concurso o la quiebra (lo que se regula en el artículo siguiente) sino ante terceros individuales que tienen derechos sobre el bien adquirido y trabaron

medidas cautelares (no acreedores hipotecarios), y precisando los recaudos que se exigen para ello. El inciso d, en tanto alude a la publicidad registral, como una alternativa, parece abrir la puerta a la posibilidad de que tales contratos sean inscriptos. De ser así, se estará dando publicidad a un derecho personal, ya que no hay derecho real posible. La mera inscripción del boleto de compraventa no implica la publicidad posesoria, ya que se trata de un hecho, que habrá que comprobar.

Algunas provincias, en sus normas locales (v. gr., ley 10.295, art. 3°, ap. V, y Disposición Técnico Registral 2/2013, Provincia de Buenos Aires), permiten la inscripción registral del boleto, por lo que bien puede interpretarse que el artículo 1170 se refiere a esas leyes especiales que lo autorizan, sin sentar una regla general que parece no armonizar con la ley 17.801.

En definitiva, si bien la cuestión no surge con claridad del Código, pienso que es saludable la inscripción del boleto en el Registro, lo que puede evitar muchos inconvenientes. En cambio, puede traer muchos problemas asignar el mismo valor a la publicidad posesoria.

VI. No convalidación

El referido principio de legitimidad o legitimación se enlaza con lo que dispone el artículo 4° de la ley 17.801, según el cual “la inscripción no convalida el título ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes”. El Registro se limita a publicitar los actos tal como son, sin purificar los vicios que pudiesen contener. Según esta norma, si por circunstancias relativas a una calificación ineficaz un título viciado hubiera alcanzado emplazamiento registral y provocado un cambio en la titularidad, ello no obsta a la subsistencia del vicio ni mejora el título inválido. La toma de razón de un título en semejantes condiciones tan sólo prueba que el título existe y que está registrado.

Esta concepción de la ley argentina confirma el apartamiento del principio de fe pública registral, ya que no es posible confiar ciegamente en lo que informa el Registro cuando la propia ley advierte que es

potencialmente posible que ingrese un título con vicios y que en ese caso el título sigue en esas condiciones. Si bien el registrador realiza una calificación del título, cualquiera sea la postura sobre las facultades que se le reconozcan (sólo las formas o también el fondo), lo cierto es que sólo puede examinar lo que surja del título (arts. 8° y 9°, ley 17.801). No puede ir más allá del documento y de las constancias registrales; si el vicio no es manifiesto, el Registro lo inscribirá y al hacerlo habrá ingresado un título viciado, cuyo vicio no es saneado por la inscripción.

VII. Plazo general de presentación.

Retroprioridad. Certificados

a) Plazo para inscribir una escritura pública

En el caso más común, de celebración de un acto jurídico que constituya, transmita, extinga o modifique un derecho real, lo cual debe ser formalizado por escritura pública (art. 1017, inc. a, Cód. Civ. y Com.), deben seguirse diversos pasos.

Dispone el artículo 5° de la ley 17.801 que “Las escrituras públicas que se presenten dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde su otorgamiento, se considerarán registradas a la fecha de su instrumentación”. El asunto es sencillo: si hoy se otorga la escritura y se la inscribe dentro de dicho plazo, se considera que fue registrada el día de hoy, lo que es muy importante por los efectos que ello implica, y no desde la fecha de su toma de razón o la de ingreso del documento al Registro. Si se la inscribe luego de vencido dicho plazo —lo que es posible— los efectos frente a terceros surgirán desde la fecha de la anotación.

Es decir que la preferencia del derecho se manifiesta desde el momento del otorgamiento del acto, desplazando incluso a los terceros que hubieran ingresado alguna pretensión al Registro de la Propiedad después de la fecha de otorgamiento y antes de la de ingreso al Registro del título en cuestión. A esta asignación retroactiva de efectos se la denomina *prioridad indirecta*.

Claro que el asunto no es tan lineal, pues para que la escritura pública goce de *prioridad indirecta*, debe ser otorgada con el beneficio

de la retroprioridad (arts. 22 y ss.); si no lo tiene, su prioridad será *directa*, contada desde el ingreso al Registro. Esto se explicará a continuación.

b) *Retroprioridad*

Si dos personas deciden celebrar una compraventa sobre un inmueble, como es sabido el acto debe ser otorgado por escritura pública. Las partes se ponen de acuerdo en el precio y en otros detalles, pero la escritura pública no puede otorgarse en ese instante, lleva un tiempo mínimo. El escribano debe averiguar sobre la situación jurídica del inmueble, hacer el estudio de títulos, etcétera. El comprador corre el riesgo de que el vendedor sufra un embargo, que enajene dos veces el inmueble, etcétera. Por eso, la ley pone en funcionamiento un mecanismo para evitar semejantes complicaciones, permitiendo que se reserve la prioridad. El notario pide en el Registro un "certificado" que, como se verá, le asegura que la situación no se verá alterada si actúa dentro de ciertos plazos.

Son normas fundamentales en este andamiaje los artículos 22 a 25 de la ley 17.801. Dicen lo siguiente:

"Artículo 22 – La plenitud, limitación o restricción de los derechos inscriptos y la libertad de disposición, sólo podrá acreditarse con relación a terceros por las certificaciones a que se refieren los artículos siguientes.

"Art. 23 – Ningún escribano o funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles, sin tener a la vista el título inscripto en el Registro, así como certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas.

"Los documentos que se otorguen deberán consignar el número, fecha y constancias que resulten de la certificación.

"Art. 24 – El plazo de validez de la certificación, que comenzará a contarse desde la cero hora del día de su expedición, será de quince, veinticinco o treinta días según se trate, respectivamente, de documentos autorizados por escribanos o funcionarios públicos con domi-

cilio legal en la ciudad asiento del Registro, en el interior de la provincia o territorio, o fuera del ámbito de la provincia, territorio o Capital Federal.

"Art. 25 – Expedida una certificación de las comprendidas en los artículos anteriores, el Registro tomará nota en el folio correspondiente, y no dará otra sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia más el del plazo que se refiere el artículo 5°, sin la advertencia especial acerca de las certificaciones anteriores que en dicho período hubiere despachado.

"Esta certificación producirá los efectos de anotación preventiva a favor de quien requiera, en el plazo legal, la inscripción del documento para cuyo otorgamiento se hubiere solicitado".

Como se dijo, el notario que estará a cargo del otorgamiento de la escritura pública debe solicitar que el Registro le expida un "certificado" (art. 23).

La expedición del certificado solicitado por el notario para un determinado negocio jurídico se asienta en el Registro, constituyéndose en una anotación preventiva, y al expedir nuevas certificaciones, publica que hay una operación en trámite. Las leyes y reglamentos notariales exigen que los certificados se encuentren agregados en el protocolo del escribano autorizante del acto.

Estos certificados tienen un plazo de validez de 15, 25 o 30 días, según se trate de documentos autorizados por escribanos con domicilio legal en la ciudad asiento del Registro, en el interior de la provincia o fuera de ella, o en la Capital Federal, conforme con el artículo 24. Se cuentan por días *corridos*.

El plazo significa que cualquier nueva inscripción queda relegada en el Registro, hasta tanto haya vencido el plazo del certificado. Si se produce otra inscripción, por ejemplo un embargo, el Registro lo inscribe, pero con la prevención de que ya hay una reserva de prioridad, o sea que se inscribe condicionalmente, puesto que un tercero que pidió la preanotación recibe la protección del Registro.

La reserva de prioridad generada mediante el certificado permite dotar al negocio de una seguridad particular cuya base consiste en la

garantía de inmutabilidad de la situación registral. Únicamente en caso de que el acto jurídico negocial no se instrumente en el plazo del certificado, se perderá la inmunidad, quedando como definitivos los actos anotados o inscriptos condicionalmente, como el referido embargo.

Este efecto que tienen los certificados en el Registro, en algunos casos es denominado *cierre o bloqueo registral*, aunque no es tal, ya que no impide la entrada de otros actos, sino que mantiene la prioridad del acto jurídico negocial de que se trata, siempre que se instrumente dentro de su plazo de validez y se inscriba dicho instrumento en el Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días de su fecha.

Esta retroprioridad no puede aplicarse a los instrumentos privados, ni a cualquier instrumento público, sino a las escrituras públicas, por cuanto llevan un ordenamiento cronológico que les da fecha cierta desde su origen, lo que no ocurre con los primeros. La reserva de prioridad que dan los certificados opera como anotación preventiva.

El sistema de retroprioridad se pone en marcha con el certificado del artículo 22. Solicitado un certificado, se produce una anotación preventiva en favor del solicitante para celebrar el negocio dentro de los 15, 25 o 30 días. Si el acto se otorga dentro de dicho lapso, quedarán desplazados todos los terceros que hubiesen pretendido una posición registral. Si el acto no se otorga en plazo de vigencia de la certificación, los terceros ganan la posición y subordinan el negocio a sus derechos.

c) *Escrituras simultáneas*

Así, por ejemplo, cuando en una compraventa se garantiza el saldo de precio con una hipoteca. Por cuestiones de economía procesal se admite el otorgamiento de más de un acto apoyado en el mismo certificado.

d) *¿Puede cederse?*

El certificado debe ser utilizado para el negocio por el cual fue solicitado, no para uno diferente. Así, por ejemplo, si se solicitó un

certificado para constituir una hipoteca, no es factible usarlo para una transferencia de dominio. Si esto ocurre, dicha transmisión no gozará de la reserva de prioridad.

e) *Afectación de la vivienda*

El artículo 244 del Código Civil y Comercial dispone que la afectación del bien destinado a vivienda al régimen de protección se debe inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble de acuerdo a las formas previstas en las reglas locales, y que "la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario".

Dos variantes son posibles. La constitución por acta administrativa reúne en un solo acto dos momentos, el de la constitución y el de la registración, produciéndose una prioridad directa desde la toma de razón en el Registro, pero cuando la afectación se realiza por escritura pública, los efectos de la retroprioridad otorgada por el certificado son aplicables.

Por último, hay que tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad Inmueble dictó la Disposición Técnico Registral 4/15, del 29 de julio de 2015, con vigencia a partir del 1° de agosto de ese año.

VIII. Calificación registral

Cuando se presenta un título ante el Registro con el objeto de ser inscripto, dicho documento es sometido a un análisis previo para determinar si cumple con los recaudos necesarios. El Registro no es un mero "buzón" que se limita a recibir la documentación que se le presenta, sino que realiza una importante actividad de control. Esto es lo que se denomina *calificación registral* (o principio de legalidad). No obstante, si el documento padece algún vicio, la inscripción no lo purifica, sino que hace presumir que el título inscripto, que pasó la calificación, es bueno.

El control de legalidad del documento que realiza el registrador se hace efectivo a través de la función calificadora a fin de lograr la menor cantidad de inexactitudes registrales. Se puede definir la cali-

ficación como "una función registral, típicamente jurídica, que consiste en el examen de los documentos presentados a inscribir o anotar, por lo que de ellos resulta y por su confrontación con los asientos respectivos tendiente a establecer si reúnen los requisitos necesarios para su registración definitiva o si, por no reunirlos, deben ser registrados provisionalmente, o condicionados por la existencia de prioridades que los afectan, o rechazados por no tratarse de documentos registrables, dentro de los límites establecidos por la ley".

a) Límites de la función calificadora

De acuerdo al artículo 8° de la ley 17.801: "El Registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, atendiéndose a lo que resultare de ellos y de los asientos respectivos".

La forma extrínseca o forma en sentido estricto, a que se refiere el artículo 8° de la ley 17.801, está constituida por las solemnidades que, según las leyes, deben observarse en la formación de los documentos mencionados en los artículos 2° y 3° de dicha ley. En lo que respecta a las escrituras públicas, dichas solemnidades están prescriptas en los artículos 299 a 309 del Código.

La función calificadora se ejerce sobre todos los documentos ingresados al Registro, sea cual fuera su naturaleza y finalidad. Calificará los documentos notariales, judiciales y administrativos ingresados, verificando *ab initio* el cumplimiento de las formalidades extrínsecas, tanto en lo referido a la competencia material como la territorial que detente el funcionario autorizante; también verificará el cumplimiento de los requisitos de formación del documento y sus copias, comprobando con los medios que estime convenientes, y siempre como actividad interna del Registro, la legitimidad del soporte papel utilizado, folios de actuación notarial, folios de seguridad notariales o judiciales y el cumplimiento de las legalizaciones que sean necesarias para la circulación de los documentos. Todas estas atribuciones conforman el aspecto extrínseco del documento y la fuente legal de la función calificadora se encuentra expresamente en el artículo 8° de la ley.

MNR

b) Resultado de la calificación

Establece el artículo 9° que "Si observare el documento, el Registro procederá de la siguiente manera:

- "a) Rechazará los documentos viciados de nulidad absoluta y manifiesta;
- "b) Si el defecto fuere subsanable, devolverá el documento al solicitante dentro de los treinta días de presentado, para que lo rectifique. Sin perjuicio de ello lo inscribirá o anotará provisionalmente por el plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha de presentación del documento, prorrogable por períodos determinados, a petición fundada del requirente. Si esto no estuviere de acuerdo con la observación formulada, deberá solicitar el Registro que rectifique la decisión. Esta solicitud implica la prórroga del plazo de la inscripción o anotación provisional si antes no se hubiere concedido. Cuando la decisión no fuese rectificada podrá promoverse el recurso o impugnación que correspondiere según la ley local, durante cuya sustanciación se mantendrá vigente la inscripción o anotación provisional".

Indica al registrador el camino a seguir en cada supuesto. Tal como surge del inciso a, si el documento contiene un negocio afectado por una nulidad absoluta y manifiesta, lo rechazará. Si de la calificación resulta que no hay observación alguna que formular, el documento se inscribirá o anotará en forma definitiva.

En caso de formular observaciones, conforme al tipo de nulidad, defecto o vicio que afecte al documento, procederá a dejar constancia de las observaciones formuladas devolviendo el documento para su subsanación.

c) Extensión y límites de la función calificadora

Está claro que el Registro puede observar las formas extrínsecas de un documento (art. 8°) y rechazar aquellos que padezcan "de nulidad absoluta y manifiesta" (art. 9°, inc. a).

Dentro de las consecuencias que la ineficacia de los actos genera, la ley declara que las nulidades absolutas no son confirmables, es

decir que no pueden ser subsanadas por ningún medio, dado el interés jurídico protegido, de orden público y que tiene en mira el interés general (ver arts. 386/7).

La nulidad debe ser manifiesta, ostensible, pues si no lo fuera, el registrador nunca podría tomar conocimiento de ella ya que sólo cuenta en su labor con los documentos que los rogantes acercan. Téngase presente que los actos nulos de nulidad absoluta, cuando ésta no sea ostensible, son de imposible calificación y, en consecuencia, serán inscriptos.

Así la función calificadora se extiende también a algunos aspectos del negocio jurídico documentado, al acto jurídico causal o título en sentido sustancial o material, además del formal, ya que si éste presentara un vicio cuya entidad lo enrolase en las nulidades absolutas, aun en ausencia de esta norma, el registrador debería negar la registración por imperio del *principio de legalidad*. La nulidad absoluta a la que se refiere la norma no es sólo la instrumental.

d) *El asentimiento conyugal y la calificación registral*

El problema se suscita porque pueden presentarse, entre los dos extremos referidos en el punto anterior, situaciones intermedias, con matices, sobre las cuales discute la doctrina si puede examinarlas el registrador o si ello excede sus facultades.

Sobre la prestación del asentimiento conyugal exigido por el derogado artículo 1277 del Código Civil, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, en fallo plenario, dirimió el tema con motivo de decisiones contrapuestas adoptadas por distintas salas de ese tribunal, en sendos recursos de recalificación planteados contra resoluciones del director del Registro de la Propiedad Inmueble de esa jurisdicción.

En el fallo plenario, la mayoría sostuvo que existen en la propia ley registral disposiciones que obligan al registrador a desarrollar una actividad calificadora, con lo cual "se quiebra el carácter inmovible de la afirmación que el registrador nunca puede penetrar en el fondo del acto". En tal sentido, cita el artículo 15, sobre la legitimación registral del disponente, y los artículos 30 a 32, en lo relativo al

control de que no existan anotaciones personales registradas que limiten la capacidad del disponente. Es en la calidad no manifiesta u ostensible del vicio, y no en las formas extrínsecas, donde se halla la limitación que tiene el registrador en su labor calificadora. Si las nulidades por defecto de forma, por ser nulidades instrumentales, pueden dar origen a nulidades absolutas, el artículo 9° carecería de sentido, ya que no podría haber "defecto subsanable" en cuanto a las formas.

En esta decisión, la minoría señaló que los únicos defectos subsanables son aquellos de los cuales pueda adolecer el testimonio de la escritura, que es lo que llega al Registro, ya que la escritura matriz no podría rectificarse sino por una escritura complementaria. Además, señaló que admitir una extralimitación en la función calificadora del registrador impediría que los actos tuviesen efecto respecto de terceros, lo que no se remediaría con una inscripción provisional porque al caducar ésta el efecto enervante sucedería igual (27-7-77, "Feldman").

Para un enfoque, la falta de asentimiento del cónyuge, si bien no es una cuestión vinculada a las formas extrínsecas sino al contenido del acto, sería un defecto subsanable que el registrador puede observar (Moisset de Espanés, entre otros).

En cambio, para una visión diferente, la legalidad de los títulos, validez de los negocios jurídicos que son su objeto y capacidad de los otorgantes en relación con los antecedentes registrales no integran la función atribuida al registrador por el ordenamiento. Se interpreta que el artículo 9° de la ley 17.801 se refiere exclusivamente al documento y no al contenido o a la validez del acto jurídico, pues si así lo hubiera querido el legislador, debió insertarlo dentro de los elementos calificables enunciados en el artículo 8°. Además, se tiene en cuenta que la falta de asentimiento implica —para algunos— una nulidad relativa, mientras que para otros se trata de un caso de inoponibilidad.

e) *Estado civil del acreedor hipotecario*

En una oportunidad el Registro observó la escritura de constitución de una hipoteca en la que no se había consignado el estado civil del acreedor hipotecario, y la cuestión fue llevada a la justicia, donde se

revocó la decisión administrativa (CNCiv., sala H, 24-3-95, "Solari Costa, Osvaldo c/Registro de la Propiedad Inmueble", E. D. 169-338. En contra: CNCiv., sala F, 15-9-95, E. D. 169-342).

f) *Resoluciones judiciales*

En oportunidades se han planteado conflictos derivados de una decisión judicial que se ordena inscribir en el Registro, pero el registrador observa por algún motivo. Se discute si esto es posible o si el Registro sólo debe cumplir la resolución de un juez dictada en una causa judicial.

g) *Recursos registrales*

El inciso b, del artículo 9° de la ley 17.801 en su párrafo primero dispone que si el requirente "...no estuviere de acuerdo con la observación formulada, deberá solicitar al Registro que rectifique la decisión. Esta solicitud implica la prórroga del plazo de la inscripción o anotación provisional si antes no se hubiere concedido. Cuando la decisión no fuese rectificada podrá promoverse el recurso o impugnación que correspondiere según la ley local, durante cuya sustanciación se mantendrá vigente la inscripción o anotación provisional".

Además la norma dispone, en su párrafo segundo, que "...La reglamentación local fijará los plazos máximos dentro de los cuales deben sustanciarse los recursos".

En la Ciudad de Buenos Aires está prevista también la posibilidad de entablar un recurso de apelación ante el director del Registro si es denegado el de recalificación y, finalmente, un recurso judicial ante la Cámara Nacional en lo Civil (ver arts. 39 y ss., decreto 2080/80).

IX. Inscripciones y anotaciones provisionales y preventivas

a) *Inscripción o anotación provisional*

Frente a un documento que pretende ser inscripto el registrador sólo puede proceder a: a) inscribir o anotar (según el caso); b) observar, o c) rechazarlo. Incluso se podrían subsumir estas dos últimas cate-

gorías en una sola, y reformular la última afirmación diciendo que el Registro puede o bien registrar definitivamente, o bien registrar provisoriamente un documento; en este último supuesto, en función de una objeción -subsana o insubsana- realizada respecto del instrumento cuya registración se pretende, y que obsta o impide -según el caso- la toma de razón definitiva de aquél.

Si una vez ejercida la calificación, el registrador concluyese que el documento presenta una *observación subsana*, por imperio de lo dispuesto en el inciso b, del artículo 9° debe generar una inscripción o anotación que se denomina *provisional*, cuyo efecto es asegurar en beneficio de este documento la inmutabilidad de la situación registral por el plazo de ciento ochenta días, generando una nueva reserva de la prioridad, o una prórroga automática de la prioridad ganada. Inmediatamente procederá a la devolución del documento al rogante para que éste proceda a subsanar las observaciones formuladas mediante los procedimientos de subsanación que resulten aplicables ya sea mediante la confirmación, rectificación o complementación, o para que proceda por la vía recursiva prevista.

Si en el lapso de vigencia de esta registración provisional el defecto se subsana, el documento se inscribirá o anotará definitivamente, caducando la inscripción provisoria por los efectos generados como consecuencia de la inscripción o anotación definitiva. En caso de no haberse subsanado el defecto en el plazo de vigencia de la inscripción provisional, ésta caduca perdiéndose los efectos de la reserva, la prioridad ganada o reservada, avanzando en el rango las anotaciones o inscripciones posteriores que gozarán de rango preferente, salvo los supuestos de prórroga.

b) *Inscripciones y anotaciones preventivas*

Hay que tener presente que según el artículo 18 de la ley 17.801: "...el Registro procederá de la siguiente forma:

- "a) Devolverá los documentos que resulten rechazados, dejando constancia de su presentación, tanto en el Registro como en el documento mismo. La forma y tiempo de duración de esta anotación serán los que rigen respecto de la inscripción provisional;

"b) Si al solicitarse la inscripción o anotación existieren otras de carácter provisional, o certificaciones vigentes, o esté corriendo respecto de éstas el plazo previsto en el artículo 5º, aquélla se practicará con advertencia de la circunstancia que la condiciona;

"c) Cuando la segunda inscripción o anotación obtenga prioridad respecto de la primera, el Registro informará la variación producida".

Por su parte, dispone el artículo 33 de dicha ley que "De acuerdo con la forma que determine la reglamentación local, el Registro practicará inscripciones y anotaciones provisionales en los casos de los artículos 9º y 18, inciso a) y las anotaciones preventivas que dispongan los jueces de conformidad con las leyes".

En cuanto a las anotaciones preventivas que dispongan los jueces, se trata de asientos provisionales y transitorios que tienen por fin, ya consignar la existencia de un procedimiento judicial, ya garantizar los resultados de un juicio, ya publicar situaciones jurídicas aún no consolidadas. Las anotaciones preventivas podrán ser definitivas, provisionales o condicionadas.

Las anotaciones preventivas de origen judicial son las distintas medidas cautelares que pueden ordenar. Estas anotaciones preventivas comparten la característica de ser caducables, producen una prelación temporal y excluyente.

c) *Diferencia entre inscripción provisional y condicionada*

El artículo 18, en los incisos b, y c, se refiere a la *condicionada*, que no es igual a la *provisional* ya que hay diferencias. La primera corresponde a la rogatoria de inscripción de un documento que, habiendo merecido reparos por la calificación del registrador, sólo llega a obtener un emplazamiento registral provisional sujeto al plazo de ciento ochenta días prorrogables que la ley le confiere (art. 9º, inc. b), hasta tanto se subsanen los defectos que motivaran la observación. El documento al cual se le asigna una inscripción condicionada, pasó la calificación del registrador y tiene vocación ganada para una inscripción definitiva, pero ésta no puede concretarse por cuanto existe una

situación registral de prioridad en curso que, precisamente, condiciona la toma de razón de aquél. Si en ejercicio de la prioridad reservada el documento al cual le aprovechaba tiene emplazamiento registral definitivo, la inscripción condicionada desaparecerá como si nunca hubiera existido.

Es un caso usual la inscripción condicionada de un embargo que afecta la disponibilidad de un inmueble en particular, cuando a su respecto se expidió un certificado con reserva de prioridad.

X. Anotación de las modalidades del negocio

La segunda parte del artículo 33 de la ley 17.801 dice que "El cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias que resulten de los documentos inscriptos, así como las modificaciones o aclaraciones que se instrumenten con relación a los mismos se harán constar en el folio respectivo por medio de notas aclaratorias, cuando expresamente así se solicite".

XI. Prioridad. Pactos sobre rango

Establece el artículo 19 de la ley 17.801 que "La prioridad entre dos o más inscripciones o anotaciones relativas al mismo inmueble se establecerá por la fecha y el número de presentación asignado a los documentos en el ordenamiento a que se refiere el artículo 40. Con respecto a los documentos que provengan de actos otorgados en forma simultánea, la prioridad deberá resultar de los mismos. No obstante las partes podrán, mediante declaración de voluntad formulada con precisión y claridad, substraerse a los efectos del principio que antecede estableciendo otro orden de prelación para sus derechos, compartiendo la prioridad o autorizando que ésta sea compartida".

Por su parte, el artículo 40 dice que "El Registro, por los procedimientos técnicos que disponga la reglamentación local, llevará un sistema de ordenamiento diario donde se anotará la presentación de los documentos por orden cronológico, asignándoles el número correlativo que les corresponda".

a) *Forma de la asignación de la prioridad*

El principio de prioridad indica que el documento que primero ingresa al Registro y logra su inscripción o anotación, con el cierre de su asiento, tiene preferencia a cualquier otro que ingrese posteriormente, aun cuando su título fuera de fecha anterior. Así funciona la prioridad confrontando lo registrado con lo que pretende posteriormente una inscripción o anotación referida al mismo inmueble.

Existen distintas formas de asignación de prioridad, conforme sea el procedimiento que la ley asigne para la confrontación de lo inscripto con lo que pretenda una registración posterior. Estas distintas formas se designan como prioridad directa, prioridad indirecta y retroprioridad.

La llamada *prioridad directa* consiste en la obtención de la posición registral teniendo en cuenta la fecha de ingreso del documento al Registro.

La *prioridad indirecta* es aquella que retrotrae los efectos de la registración a un momento anterior al del ingreso del documento al Registro, tal como lo dispone el artículo 5° de la ley 17.801, al disponer que ingresado un documento notarial dentro de los cuarenta y cinco días de su otorgamiento, sus efectos se retrotraen al de la fecha de su otorgamiento.

Finalmente, la llamada *retroprioridad* crea un sistema mediante el cual, además de aplicarse la *prioridad indirecta*, previo al otorgamiento del acto se ha generado un asiento provocado por la expedición de una certificación, que protege el negocio a documentar y cuya finalidad no es retrotraer los efectos, sino desplazar a los terceros que pretendan inscribir o anotar documentos que se opongan o sean incompatibles con aquel que está en vías de ejecución.

Para la asignación de prioridad, el artículo 19 establece un sistema sencillo, apoyado en el texto del artículo 40. La prioridad entre dos o más registraciones relativas al mismo inmueble se establece con dos parámetros: la fecha de ingreso del documento al Registro y el número asignado al trámite correspondiente. Entre dos situaciones registrables, prevalecerá en primer término la que hubiese iniciado el procedimiento antes, con fecha anterior; y entre dos iniciadas el mismo día, prevalecerá la que detente el número menor. Es el llamado *asiento de presentación*,

preliminar o preparatorio, que constituye una anotación en sí misma e indica el comienzo del proceso registral.

En cuanto al supuesto de otorgamiento simultáneo de actos, cuando dos negocios jurídicos, referidos al mismo inmueble, por el mismo o distinto funcionario, sean documentados en forma simultánea, la prioridad resultará del contenido de los documentos.

b) *El rango y la autonomía de la voluntad: pactos sobre rango*

El sistema de la ley 17.801 establece que el que inscribió primero, aprovechando de la retroprioridad, ocupa un lugar preferente a los derechos que se inscriben posteriormente. Ocupa un *rango* determinado. Dicho titular estará en primer grado, y los sucesivos lo estarán en segundo, tercer grado, etcétera. Rige entre nosotros el llamado *rango de avance o progresivo*, que implica que extinguido el derecho real preferente, el que le sigue pasa al primer lugar. El rango no es fijo, como sucede en el Derecho alemán.

Concluye el artículo 19 estableciendo la posibilidad de abstraerse de los efectos de la prioridad, así como del modo de su asignación previsto en la ley, por voluntad de las partes. En el caso de las hipotecas que graven un mismo inmueble, sin dudas, será mejor el derecho que detenta el acreedor de primer grado que el de segundo, teniendo en cuenta que el cobro íntegro o no de su acreencia dependerá del valor de la cosa y la cobertura íntegra del crédito garantizado en primer lugar. Por eso la ley admite la posibilidad de negociar esa posición, sustrayéndose por convenio del orden de prioridad registral asignado de conformidad con el sistema de la ley, mediante declaración de voluntad formulada con precisión y claridad. Esta declaración de voluntad se conoce como *pactos sobre rango*.

A pesar del orden público que rige esta materia, aquí se le da una importante cabida a la autonomía de la voluntad. Una disposición similar se encuentra en el artículo 2223 del Código Civil y Comercial para la prenda, aunque este derecho no es registrable.

b.1) *Permuta de rango*

Consiste en el cambio de posición entre dos derechos ya inscriptos.

Ejemplo de ello es la convención celebrada entre dos acreedores hipotecarios que permutan sus rangos, mediante convenio sujeto a las mismas formalidades que las requeridas para la constitución del derecho real de hipoteca. El resultado de esta permuta será que la hipoteca de segundo rango avanzará a la posición de primero, y la primera descenderá al segundo lugar. Este convenio puede celebrarse también entre acreedores hipotecarios que no resulten sucesivos, es decir, el primero con el tercero, o el segundo con el cuarto, siempre que no se perjudiquen los derechos de los rangos intermedios, quienes deberán otorgar su conformidad. La permuta de rango sólo implica la cesión de la posición, pero el contenido del derecho no se altera, ni cambia su titularidad.

El artículo 19 sólo menciona con claridad la posibilidad de compartir el rango, pero no hay inconveniente en que se permuten, reserven o pospongan. El propio artículo dice que las partes pueden sustraerse del principio de prioridad "estableciendo otro orden", concepto más amplio.

También es posible la alteración del rango entre dos derechos reales diferentes. Así, por ejemplo, si un usufructo se constituye antes que una hipoteca y tiene prioridad, podrían ambos titulares convenir la permuta, o haberse reservado una posposición, en cuyo caso, si se remata el inmueble, no habría que respetar el derecho del usufructuario. Esto ha sido utilizado en ocasiones, pues es lógico deducir que un inmueble dado en usufructo difícilmente sea aceptado por un acreedor hipotecario.

b.2) Posposición de rango

Se produce cuando, existiendo un derecho registrado y con rango ganado, cede su prioridad en beneficio de otro, no inscripto aún, que al registrarse ocupará la posición dejada por el cedente. En consecuencia, el acreedor que detentaba la prioridad desciende y el que accede a la registración con posterioridad ocupa la mejor posición. Existiendo más de un tercero registral con rango adquirido, la posposición requerirá la conformidad de todos, pues no es posible perjudicar los derechos de terceros.

En la permuta ambos derechos ya se encuentran inscriptos, mientras que en la cesión referida el beneficiado se inscribe después.

b.3) Reserva de rango

Esto significa que, por ejemplo, al constituir una hipoteca (o en un acto posterior), el titular pueda reservar el derecho de constituir, posteriormente, otra de rango preferente, expresando el monto de dicha reserva. Esta situación no se asimila a la llamada hipoteca del propietario del Derecho alemán, pues no constituye una reserva que pueda aprovechar al titular del inmueble, sino solamente a un tercero acreedor hipotecario cuya hipoteca se constituya con posterioridad; pero si la hipoteca posterior no se constituye, ninguna postergación se presentará para el titular de la hipoteca inscrita.

b.4) Rango compartido

Puede darse el supuesto de existir más de un acreedor con el mismo rango, en cuyo caso, concurrirán a prorrata. La primera de las hipótesis es la que se presenta al constituir una hipoteca en beneficio y seguridad de una obligación de varios acreedores. En este caso, los acreedores garantizados comparten la posición y sus efectos. Puede darse también mediante la constitución simultánea de dos hipotecas en las que sus acreedores, emanados sus derechos de títulos diversos, consientan compartir el rango. Y puede darse también el supuesto de una hipoteca previa, inscrita, cuyo acreedor consienta compartir su rango con una hipoteca de constitución posterior (similar a la reserva). Siempre, claro está, dejando a salvo los derechos de terceros.

b.5) La postergación

La postergación consiste en el cambio entre derechos del mismo rango, en el sentido de que unos se pospongan a otros.

b.6) Forma

Cuando la prioridad recae en un derecho real sobre un inmueble, la forma será la escritura pública. En cuanto a otros documentos, como los de origen judicial, por aplicación del principio de accesoriedad en la forma, se considera que la convención deberá ser homologada judicialmente, y registrada por la misma vía que la empleada para la

registración del documento que cuenta con la prioridad pospuesta, permutada o compartida. No se considera posible la situación de la posposición, dado que no existe medida judicial que permita tal supuesto.

En cuanto a los certificados, se plantea una situación más compleja, debido a su propia naturaleza, finalidad y efectos. No se considera viable la posibilidad de ceder la retroprioridad causada en un certificado, cuando habiendo sido solicitado por un notario, éste ceda sus efectos a favor de otro para que otorgue una escritura protegida por los efectos de la retroprioridad.

Finalmente, en todos los casos se requerirá la conformidad de todos aquellos cuyos derechos puedan ser afectados por la alteración al principio de prioridad.

XII. Anotaciones personales

El artículo 30 de la ley determina cuáles serán las secciones que tendrá este Registro para anotar: "La declaración de la inhibición de las personas para disponer libremente de sus bienes" (inc. a). Esta anotación se explica porque está acorde con lo que establece el inciso b, del artículo 2º, al indicar que son documentos registrables los que dispongan inhibiciones.

Agrega: "Toda otra registración de carácter personal que dispongan las leyes nacionales o provinciales y que incida sobre el estado o la disponibilidad jurídica de los inmuebles" (inc. b). Esta disposición está directamente relacionada con la registración de las cesiones de derechos hereditarios, por ejemplo.

En el artículo 31 se establece que, cuando fuera procedente, se correlacionará la anotación personal con el folio del inmueble que corresponda.

Así y en la medida en que resulte compatible, "...les serán aplicables las disposiciones establecidas en esta ley para la matriculación de inmuebles o inscripción del documento que a ello se refiera".

El artículo 32 contiene una regulación especial para los oficios judiciales que se le cursen al Registro de la Propiedad por los que se ordene la registración de las inhibiciones o interdicciones de las personas físicas. Estos oficios deberán contener, además de los datos que

el Código Procesal indique, el número del documento nacional de identidad de la persona de que se trate y "...toda otra referencia que tienda a evitar la posibilidad de homónimos".

Si no se consigna el número del documento nacional de identidad, la anotación será provisional, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 9º, "...salvo que por resolución judicial se declare que se han realizado los trámites de información ante los organismos correspondientes, sin haberse podido obtener el número del documento identificatorio".

a) Secciones del Registro

El Registro de la Propiedad, como órgano de la administración pública, se ordena internamente en secciones o áreas, como lo dispongan las leyes locales, atendiendo a las mínimas exigencias establecidas en los Capítulos VI y X de la ley nacional. La ley 17.801 dispone que el Registro debe formar y organizar una sección diferenciada, ajena a la sección de las registraciones reales, destinada a la anotación de situaciones personales. En cuanto al método de registración, será alfabético, por tratarse de un tipo de registro personal y no real, donde el elemento principal de los asientos gira en torno al sujeto, sea persona física o jurídica.

b) Crítica a lo previsto en el inciso b, del artículo 30

Opina Villaró que no se comprende la redacción del inciso b, ya que "fuera de la inhibición, o de las interdicciones de origen político, comercial (ley 24.522, régimen de concursos y quiebras), o civil, no parece haber otras registraciones personales que incidan sobre la disponibilidad o el estado de los inmuebles..."

c) Inhibición

Por su naturaleza constituyen medidas cautelares substitutivas del embargo o de otras cautelares destinadas a la preservación de los derechos de quien las solicita, que tienen por finalidad impedir la realización oponible a terceros de actos dispositivos sobre derechos o bienes registrables. Dadas estas características, la inhibición general

de bienes no es una medida cautelar dirigida contra la persona en sí misma, sino contra su capacidad dispositiva sobre ciertos bienes y cosas.

Conforme lo dispongan los códigos procesales locales, ésta es la vía adecuada, además, para publicitar otras situaciones personales limitativas de la capacidad dispositiva, tales como la declaración de incapacidad, la inhabilitación o inhabilidad de determinadas personas. Provenientes de procesos judiciales generalmente en los que se dictamina acerca de la capacidad de los sujetos, su registración suele admitir la misma forma que la dispuesta para las inhibiciones generales de bienes producidas en procesos de naturaleza puramente patrimonial.

d) *Otras registraciones personales*

El inciso b, del artículo 30 abre el campo de acción para la creación, dentro del Registro de la Propiedad, de otras secciones destinadas a la anotación de diversas circunstancias personales. Algunos de los supuestos son los *registros de titularidad o índices de titulares*, llevados alfabéticamente; su principal función es la posibilidad de hacer conocer la existencia de bienes inmuebles inscriptos a nombre de las personas y su trascendencia consiste en evitar el dispendio procesal de solicitar la inhibición general de bienes sobre un sujeto que resulta titular de bienes inmuebles determinados y conocidos en el mismo registro.

Existe también una sección destinada a la anotación de las *cesiones de herencia*, ordenada alfabéticamente por el nombre del causante del sucesorio, que reviste el carácter de una registración especial.

Un tema particular lo constituye el supuesto de inscripción de la declaratoria de herederos, práctica procesal que se ha difundido. Esta situación ha generado la costumbre de considerar concluidos los trámites sucesorios antes de la partición. Se considera de buena práctica que, cuando los herederos resuelvan conservar los bienes de la herencia en condominio, y en la forma en que les corresponde por sus llamados a la herencia, en lugar de solicitar la inscripción de la declaratoria de herederos se proceda a confeccionar las hijuelas correspondientes, constituyendo válidamente así, el condominio.

e) *Anotaciones personales con reflejo en el folio real*

El Registro de la Propiedad, organizado bajo los principios rectores impuestos por la ley nacional en análisis, se estructura sobre la base del elemento patrimonial de mayor permanencia, que es la finca, el inmueble. Ésa es su base principal, y todas las demás, tales como el ordenamiento diario, los procedimientos de publicidad formal y las anotaciones personales deben remitirse necesariamente a ella. Es por esa razón que la primera parte del artículo 31 dispone que, en cuanto fuere procedente, las anotaciones personales deben relacionarse con aquellas matrículas con las que se vean vinculadas. Esa vinculación estará dada por los dos elementos tomados como base para la registración: el inmueble, en cuanto al registro inmobiliario en sí, y el sujeto titular, en cuanto elemento de ordenación de la anotación personal.

Muchos de los Registros locales han adoptado —como se dijo—, a partir de una práctica procesal difundida en el campo de los procesos sucesorios, la costumbre de inscribir con relación a los inmuebles la declaratoria de herederos.

XIII. Rectificación de asientos

En el artículo 34 de la ley 17.801 se define la inexactitud registral en estos términos: "Se entenderá por inexactitud del Registro todo desacuerdo que, en orden a los documentos susceptibles de inscripción, exista entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral".

Dice este artículo 35, distinguiendo dos situaciones posibles: "Cuando la inexactitud a que se refiere el artículo precedente provenga de error u omisión en el documento, se rectificará, siempre que a la solicitud respectiva se acompañe documento de la misma naturaleza que el que la motivó o resolución judicial que contengan los elementos necesarios a tal efecto. Si se tratare de error u omisión material de la inscripción con relación al documento a que accede, se procederá a su rectificación teniendo a la vista el instrumento que la originó".

a) *Rectificación de la inexactitud*

El artículo 35 contiene los mecanismos de subsanación registral

aplicables frente a los distintos supuestos de inexactitud. Existen distintos tipos de inexactitud, y entonces la ley contiene diversas formas de subsanación, que son los métodos disponibles para encausar la publicidad, haciendo coincidir la realidad material con lo registrado. Si la inexactitud que se produce reconoce como causa una mutación en la realidad exógena, es decir, cuando se trata de las llamadas inexactitudes normales, no resultan aplicables los supuestos de este artículo, sino que la forma de corregir la publicidad, enderezarla y hacerla coincidir con la realidad será mediante la inscripción o anotación de un nuevo documento que contenga este cambio en la realidad material. Cuando un inmueble ha sido enajenado, y su titular ha transferido el dominio, la inexactitud no se subsana rectificando el asiento anterior, sino generando un nuevo asiento en el que se atribuya la titularidad a su adquirente.

En cambio, cuando se trata de inexactitudes de las llamadas *anormales*, es necesario establecer un mecanismo de subsanación que la ley llama *rectificación*. En tal sentido, en el IV Congreso Nacional de Derecho registral se declaró que la subsanación o rectificación es el procedimiento mediante el cual se provoca la concordancia entre la realidad registral y la extrarregistral.

El artículo 35 prevé la situación de la inexactitud ocurrida en el proceso negocial, claro que en forma limitada, pues se circunscribe a manifestar la forma de subsanación de los errores u omisiones del documento, y la ocurrida en el proceso de inscripción.

En cuanto a la inexactitud por defecto del negocio, si se trata de un vicio congénito que prive de efectos al acto documentado e inscripto; sea por una nulidad absoluta o relativa, deberá promoverse el correspondiente proceso judicial que la declare, y como consecuencia se procederá a las registraciones que correspondan. Si el error u omisión, en cambio, es solamente documental, pero queda a salvo la validez y plenitud del acto documentado, el artículo 35 dispone que deberá procederse a su rectificación.

Teniendo en cuenta la clase de error cometido en el proceso de publicidad, el artículo plantea dos supuestos: cuando el error proviene del documento o cuando el error proviene del proceso de inscripción.

En el primer caso, dice la primera parte del artículo, se rectificará,

con la debida rogación, acompañando otro documento de la misma naturaleza que tenga efectos subsanatorios, o por resolución judicial que contenga los elementos necesarios al efecto.

Pueden darse casos de errores u omisiones *materiales o ideológicas*. Si se trata de un error material, por ejemplo, consignación errónea en una medida en la descripción del inmueble objeto del acto, o error material en el traslado de la matriz al testimonio, la situación podrá subsanarse por nota marginal inserta por el autorizante del documento, o por la rectificación y salvado del documento; reingresará así para rectificar el asiento el mismo documento ahora salvado de sus errores.

La segunda parte del artículo 35 prevé la situación de los errores en el procedimiento registral, presumiendo que no existe defecto alguno en el documento registrado. En este caso, el interesado, legitimado para la rogación, deberá reingresar el mismo documento para que el Registro tome razón en forma correcta. En estos casos, la rectificación puede originar también una anotación marginal que se insertará en la matrícula del inmueble y cuyo autor será el funcionario del Registro.

b) *Cuestión de la legitimación*

Tal como resulta del artículo 6º, la situación registral sólo variará a petición del autorizante del documento o de quien tuviera interés legítimo en asegurar el derecho que se ha de registrar. El principio de rogación inhibe entonces al propio registrador para intervenir de oficio, ya que su actividad solamente puede desplegarse cuando se la ruega.

En cuanto al tema de la rectificación de los asientos, se presenta entonces un problema que reconoce dos interpretaciones doctrinarias. La primera sostiene que, producido el error, solamente podrá rectificarse cuando las personas legitimadas, a la luz del artículo 6º, procedan a rogarla. Nada obsta a que la rectificación se opere a pedido del titular registrado de los derechos, acompañando el mismo documento cuya registración se pretende rectificar, un tercero, simultáneamente con la rogación de otra registración respecto del mismo inmueble. Pero siempre es menester la rogación y la conformidad del titular registrado. La segunda sostiene que además de los legitimados para la rogación, el propio registrador podrá proceder, por sí mismo, a rectificar el error

en cualquier tiempo, sin necesidad de rogación expresa, siempre que lo advierta mientras conserve los títulos o documentos registrados, o si hubieren reingresado; es decir, mientras mantenga la presencia documental; la misma conducta se habilita al registrador frente a los errores contenidos en las minutas acompañadas para inscribir o anotar un documento, ya que, advertido el error en ella, el registrador podrá rectificarlo. Esta posición es la mayoritaria en la materia.

XIV. Cancelación de las inscripciones

Las circunstancias que incidan sobre la vigencia de lo inscripto o anotado registralmente debe tener reflejo en el folio respectivo. Así lo expresa el artículo 14, al establecer que luego de ser matriculado un inmueble, en el folio respectivo se registrarán las cancelaciones o extinciones que correspondan.

El modo genérico "cancelación" para dejar sin efecto lo que en el folio se hubiere consignado puede producirse, mediando la pertinente solicitud, cuando resulte del documento que se lleva al Registro: a) el cambio de titularidad por actos entre vivos o por causa de muerte; b) la extinción del derecho que provocó el asiento de su titularidad (p. ej., condominio, usufructo, servidumbres, hipoteca); c) la reunión en uno de titularidades incompatibles registradas en distintos asientos en el mismo folio (confusión); d) la decisión judicial que así lo disponga, y e) resulte de una disposición legal (art. 36, párrafo primero).

La última parte del artículo 36 agrega: "La cancelación podrá ser total o parcial según resulte de los respectivos documentos y se practicará en la forma determinada por la reglamentación local".

a) Necesidad de rogación y consentimiento.

Cancelación implícita y expresa

Los primeros supuestos contenidos en este artículo se refieren a las cancelaciones de inscripciones y anotaciones que se producen, bien por voluntad de las partes, bien por decisión judicial o por causa legal; en tanto que el artículo 37 se refiere a los supuestos de privación de los efectos de los asientos ya operados por la caducidad generada por el mero transcurso del tiempo.

La cancelación de los asientos es, a su vez, un asiento, cuya finalidad es extinguir formalmente los efectos de aquel al que se refiere. Por eso se lo identifica como registración *negativa y accesorio*.

En materia de cancelación de asientos y tal como lo dispone el artículo 36, rige el principio de rogación. Ésta debe ser formulada como en toda la actividad del Registro, por presentación de solicitud, acompañada por el documento en que conste la extinción del derecho registrado.

Existen dos formas de cancelación, tácitamente referidas en el artículo, conforme sea la naturaleza del asiento que se extingue. La primera es la denominada *cancelación implícita*, aquella que, respetando el principio de tracto, priva al asiento previo de eficacia en virtud de la confección de un nuevo asiento que asigna el derecho y la posición o rango a favor de otro titular. La inscripción de un nuevo titular de dominio supone la transferencia del derecho de su antecesor registral, a favor del nuevo titular, siempre respetando el tracto sucesivo, sea o no por el sistema de inscripción abreviada.

La segunda forma de cancelación es la *expresa*, cuya finalidad y rogación se dirigen directamente a privar de efectos al derecho o situación inscripta, sin atribuirlo a un nuevo titular.

La cancelación de un asiento puede reconocer distintas causas. Por el consentimiento del titular, orden judicial o por causa de la ley.

Cuando la cancelación se dispone por consentimiento del titular de un derecho inscripto, con la rogación deberá acompañarse documento en el que conste dicho consentimiento. El artículo 2204, inciso a, del Código así lo dispone con relación al derecho real de hipoteca.

Puede generarse un asiento de cancelación por *orden judicial*. Estos casos reconocen dos grupos: uno constituido por los supuestos en los que, discutido o ejercido judicialmente el derecho real de que se trate, como resultado del proceso el juez disponga su cancelación. Los procesos de reivindicación en cuanto al dominio; los procesos que entienden sobre la nulidad de los actos jurídicos de constitución, transmisión o modificación de derechos reales sobre inmuebles; los procesos de ejecución hipotecaria. En todos ellos puede decretarse judicialmente la cancelación de los derechos reales inscriptos. El otro

grupo es el integrado por los supuestos en que, por orden judicial, se dejan sin efecto las medidas cautelares dispuestas y registradas en los procesos respectivos.

Finalmente, la cancelación del asiento puede reconocer su causa en la ley. La confusión es la situación jurídica en virtud de la cual un mismo sujeto resulta titular de derechos opuestos. Si bien el supuesto clásico y mencionado en los textos se refiere a la hipoteca, se entiende que la misma situación se produce con relación a todos los derechos reales que generan una desmembración. Si el acreedor hipotecario deviene titular del inmueble, la hipoteca se extingue por confusión; si el usufructuario deviene nudo propietario, reunirá el dominio desmembrado. Otro supuesto de cancelación legal se produce por el acaecimiento de la muerte del titular de un derecho vitalicio, como el usufructo. Un supuesto particular lo constituye la cancelación de la hipoteca causada en la ejecución del inmueble hipotecado.

b) *Cancelación total y parcial*

Es el supuesto que describe la última parte del artículo 36, y consiste en la generación de un asiento cancelatorio que no priva de vigencia a todo el asiento que afecta, sino sólo lo modifica, privándolo parcialmente de sus efectos. La cancelación será total cuando extinga por completo los efectos del asiento al que se refiere.

La cancelación parcial de asientos se produce del mismo modo y en los mismos casos en que se produce la cancelación total, pero con una diferencia de intensidad; de la anotación o inscripción cancelada, una parte pierde su vigor, pero la parte no afectada continúa generando sus efectos propios. Los casos más usuales son los referidos a la extinción o transmisión parcial de un derecho registrado. En caso de enajenación de parte indivisa del dueño de la cosa a un tercero, a más de nacer el derecho real de condominio, se asentará la transmisión con un nuevo asiento referido sólo a la parte indivisa transferida, quedando subsistente el anterior asiento pero con relación a una porción menor, generándose además la modificación en el asiento con relación a las proporciones del condominio.

XV. Caducidad de las inscripciones

MNR

Dispone el artículo 37 de la ley 17.801: "Caducan de pleno derecho y sin necesidad de solicitud alguna, por el transcurso del tiempo que expresa este artículo o por el que, en su caso, establezcan las leyes especiales:

- "a) La inscripción de la hipoteca, al vencimiento del plazo legal si antes no se renovare;
 - "b) Las anotaciones a que se refiere el inciso b) del artículo 2º, a los cinco años, salvo disposición en contrario de las leyes.
- "Los plazos se cuentan a partir de la toma de razón".

a) *Caducidad de inscripciones y anotaciones*

No hace falta ninguna conducta de parte del Registro de la Propiedad para que la caducidad prevista se opere y prive de efectos, en consecuencia, a las anotaciones o inscripciones caducas.

Pasado el tiempo, la caducidad deja *ope legis* sin valor alguno el asiento, con efectos automáticos, sin que sea menester ni solicitud del interesado ni la elaboración de asiento alguno. Se produce la extinción jurídica de los efectos de lo inscripto o anotado, aun cuando materialmente el asiento permanezca inalterado.

El artículo prevé dos supuestos. El primero es la caducidad de la inscripción del derecho real de hipoteca que se produce al vencimiento del plazo legal, establecido en veinte años, conforme a lo previsto por el artículo 2210 del Código Civil y Comercial. Cabe recordar que no es lo mismo la caducidad de la inscripción que la extinción del derecho. El segundo supuesto de caducidad es el de las medidas cautelares, documentos dotados de vocación registral por lo que dispone el inciso b, del artículo 2º, que opera a los cinco años de su toma de razón.

Por otro lado, la omisión de reinscribir una medida cautelar puede generar la responsabilidad del abogado.

b) *El caso de la anotación de litis*

Dada la finalidad especial de esta medida cautelar, consistente en publicitar la propia situación de litigio sobre la cosa objeto de la re-

gistración, una vez anotada su efecto es que el tercer adquirente, o el tercero registral en su caso, no puedan alegar buena fe, subordinando sus derechos al resultado del juicio publicitado.

La doctrina registral se dividió entonces en dos interpretaciones. Una posición sostiene que por su específica finalidad, la anotación de litis no caduca por el lapso transcurrido de cinco años desde su anotación, si el proceso que la originó no está resuelto, pues su vigencia debe extenderse hasta la terminación del juicio. Otra postura no encuentra ninguna excepción a lo previsto por el artículo 37 y, por tal razón, las anotaciones de litis como cualquier otra medida cautelar, incluso las genéricas de contenido especialmente dispuesto por el juez, caducan por el transcurso de cinco años.

c) *Caducidades especiales no incluidas en la enumeración*

Existen, además de las previstas en este artículo, otras caducidades reguladas en la ley. Se trata de las inscripciones y anotaciones provisionales, de las condicionadas y de los certificados.

Según el artículo 9º, inciso b, producida una observación en el trámite de inscripción, el registrador devolverá el documento al rogante para la subsanación del defecto, procediendo a anotarlo o inscribirlo provisionalmente, por ciento ochenta días. Si transcurrido dicho lapso el documento no ha reingresado para su inscripción definitiva, los efectos de esta inscripción provisoria caducan, perdiéndose entonces la prioridad. En cuanto a las inscripciones condicionadas, dispone el artículo 18, inciso a, que el documento rechazado será inscripto en forma provisional, con los efectos del artículo 9º. De todos modos, dado que la inscripción o anotación condicional queda a la espera de la resolución de una situación registral que goza de prioridad, cabe entender que en caso de resolverse esa cuestión pendiente, sea cual fuere la suerte de la inscripción condicionada, ésta caducará o se convertirá en definitiva. Con relación al certificado de ley, dispone el artículo 24 que el plazo de reserva de prioridad que produce será de quince, veinticinco o treinta días, dentro de los cuales el escribano que lo hubiera solicitado deberá otorgar el acto. Transcurrido dicho lapso, si el acto no fue otorgado, los efectos de la prioridad ganada caducan *ipso iure*.

XVI. Catastro

a) *Introducción*

Se entiende por catastro el inventario o catálogo de los bienes inmuebles sobre los cuales el Estado ejerce la soberanía política. Presupone la individualización geodésica en el territorio nacional de dichos inmuebles. De manera que para realizar un catastro resulta necesario hacer un relevamiento de toda la superficie terrestre del país. Esa tarea fue puesta a cargo del Instituto Geográfico Militar, encomendada por la ley 12.696 del año 1941, repartición que efectúa trabajos geodésicos y levantamientos topográficos, sobre cuya base elabora la cartografía oficial.

El Catastro constituye un inmejorable inventario de la riqueza inmueble del país. Es un registro de identificación física, jurídica y económica de inmuebles y, como tal, además de un soporte indispensable del sistema tributario local, provincial y nacional, es un banco de datos imprescindible para la elaboración de diversas políticas económicas y sociales, tales como las de desarrollo regional, agropecuaria, planificación urbanística, perfeccionamiento de redes viales, entre otras, y va mucho más allá de una concepción exclusivamente fiscal.

Así como el Catastro tiene por base la geodesia, el Registro de la Propiedad Inmueble se sustenta en el certificado catastral (art. 12, ley 17.801). Por ello, la ley 26.209 alude al certificado expedido por la autoridad administrativa catastral a fin de ser presentado ante dicho Registro. No hay duda de la correspondencia entre la nomenclatura respectiva y la matrícula del dominio, porque ambas deben coincidir entre sí.

Teniendo en cuenta que los Registros de la Propiedad tienden a dar certeza sobre la situación jurídica de los inmuebles, su eficacia está vinculada con la exactitud de los datos físicos que surjan del catastro. Hay una estrecha relación entre ambos registros.

Lo atinente al catastro está regulado por la ley 26.209. Se prevé que la inscripción del plano de mensura "no subsana ni convalida los defectos de los documentos" (art. 7º, *in fine*). Concuerda así con el carácter declarativo de la matrícula obrante en el Registro Público de la Propiedad Inmueble (arts. 2º y 4º, ley 17.801).

La ley les confiere a los catastros de las diferentes provincias y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la administración de "...los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción" (art. 1º). Se completa esta disposición con lo que establece su artículo 2º, en cuanto hace depender de las leyes locales que se sancionen la designación "...de los organismos que tendrán a su cargo los catastros territoriales y ejercerán el poder de policía inmobiliario catastral".

b) *Policía inmobiliaria catastral*

Dispone el artículo 3º de la ley 26.209 que "El poder de policía inmobiliario catastral comprende las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que las legislaciones locales asignen a los organismos mencionados en el artículo anterior:

- "a) Practicar de oficio actos de levantamiento parcelario y territorial con fines catastrales;
- "b) Realizar la georeferenciación parcelaria y territorial;
- "c) Registrar y publicitar los estados parcelarios y de otros objetos territoriales legales con base en la documentación que les da origen, llevando los correspondientes registros;
- "d) Requerir declaraciones juradas a los propietarios u ocupantes de inmuebles;
- "e) Realizar inspecciones con el objeto de practicar censos, verificar infracciones o con cualquier otro acorde con las finalidades de esta ley;
- "f) Expedir certificaciones;
- "g) Ejecutar la cartografía catastral de la jurisdicción; confeccionar, conservar y publicar su registro gráfico;
- "h) Formar, conservar y publicar el archivo histórico territorial;
- "i) Interpretar y aplicar las normas que regulen la materia;
- "j) Establecer estándares, metadatos y todo otro componente compatible con el rol del catastro en el desarrollo de las infraestructuras de datos geoespaciales".

c) *Concepto técnico legal de parcela*

La ley 26.209 se refiere a la regulación del denominado "estado parcelario" de los inmuebles, su constitución y verificación de su subsistencia en los artículos 4º a 14.

Según el artículo 4º: "A los efectos de esta ley, denominase parcela a la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico, registrado en el organismo catastral".

Agrega el artículo 5º: "Son elementos de la parcela:

"I. Esenciales:

- "a) La ubicación georeferenciada del inmueble;
- "b) Los límites del inmueble, en relación a las causas jurídicas que les dan origen;
- "c) Las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble.

"II. Complementarios:

- "a) La valuación fiscal;
- "b) Sus linderos.

"Dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble".

La ley 26.209 efectúa la distinción entre el simple objeto territorial y la parcela. Entre estos conceptos habría, según el criterio legal, una diferencia de género a especie. Mientras objetos territoriales son todos los inmuebles medianamente demarcados en el mundo jurídico o de los hechos, la parcela exige en cambio la existencia de todos los elementos esenciales determinantes establecidos en el artículo 5º. No todo objeto territorial constituye una parcela, ya que para que pueda hablarse de tal es menester que este objeto territorial manifieste todos sus elementos esenciales (de ahí su denominación). La carencia de algunos de los elementos complementarios, en cambio, no le quitaría el carácter de parcela.

Agrega el artículo 7º que "El estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de aplicación del plano de mensura y demás documentación correspondiente al acto de levantamiento

parcelario ejecutado. En el plano deberán constar los elementos que permitan definir la parcela, según lo establecido en el artículo 5° de la presente ley y lo que establezcan las legislaciones locales. La registración no subsana ni convalida los defectos de los documentos”.

d) La certificación catastral

Así como lo hace el Registro de la Propiedad Inmueble, también las Direcciones de Catastro de cada jurisdicción expiden certificaciones que permiten conocer el estado parcelario y la situación catastral de determinada parcela. Es un paso obligatorio en la transmisión-constitución de derechos reales. Además, sin este certificado, no se podrá inscribir el título en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Dispone la ley 26.209 lo siguiente:

“Artículo 11 – El estado parcelario se acreditará por medio de certificados que expedirá el organismo catastral en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Para la expedición de certificados catastrales en oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y/o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté determinado y/o verificado y que no haya expirado el plazo de su vigencia.

“Art. 12 – En los actos por los que se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente. No se requerirá la certificación catastral para la cancelación de derechos reales, y constitución de bien de familia, usufructo, uso y habitación, e inscripción de embargos y otras medidas cautelares.

“Art. 13 – A los efectos de las inscripciones de los actos citados en el artículo 12 de la presente ley en el Registro de la Propiedad Inmueble, se acompañará a la documentación correspondiente el certificado catastral, sin cuya presentación no procederá la inscripción definitiva”.

CAPÍTULO XXVI

PRIVILEGIOS

MNR

SUMARIO: I. Antecedentes históricos. II. Concepto. III. Método del Código. IV. Fundamento. V. Naturaleza jurídica. VI. Clasificación. VII. Caracteres. VIII. Extensión y cómputo. IX. Subrogación real. X. Privilegios especiales. XI. Extinción.

I. Antecedentes históricos

Presenta una deficiente reglamentación el Código Civil francés. Igual predicamento debe serle atribuido a la ley belga del 16 de diciembre de 1851, de autoría de Martou. A título ejemplificativo, la clasificación contenida en la obra legislativa consistía en: 1) privilegios generales: afectaban a bienes muebles e inmuebles; 2) privilegios especiales: recaían sobre bienes muebles o inmuebles determinados; 3) en la hipótesis de insuficiencia de bienes muebles, cobraban los acreedores con privilegio general antes que las preferencias inmobiliarias y créditos hipotecarios; 4) privilegios consagrados en leyes especiales.

Vélez Sársfield abrevó en las mentadas fuentes, lo que se refleja en las notas a los artículos 3883, 3884, 3887, 3890, 3920 y 3988 del Código derogado. Instauró de acuerdo al artículo 3878 de su Código Civil privilegios sobre muebles e inmuebles. También tuvo en cuenta a la referida ley belga, y al Proyecto español de 1851 de García Goyena.

El Código de Vélez se ocupaba de los privilegios y del derecho de retención en la Sección II del Libro IV, bajo el título *Concurrencia de los derechos reales y personales contra los bienes del deudor común*. Este criterio metodológico encontró su antecedente en las ideas de Freitas.

Vélez Sársfield se separó netamente de las ideas imperantes al respecto en esa época, ya que el Código francés legisla los privilegios juntamente con las hipotecas.

II. Concepto

Sabido es que, como regla, "el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores". Cuando un deudor tiene varios acreedores, pero su patrimonio es importante y tiene la solvencia para afrontar todas sus deudas, el problema es menor. En cambio, si su patrimonio es insuficiente para atenderlos a todos satisfactoriamente, la cuestión de los privilegios cobra relevancia. Es que primero cobrarán los acreedores privilegiados y luego lo harán los demás, llamados quirografarios, a prorrata (principio de igualdad). Incluso, si hay varios acreedores privilegiados, algunos pueden tener preferencia sobre otros, ya que en este ámbito no rige el principio de igualdad.

El actual Código Civil y Comercial define en el artículo 2573 al privilegio como "la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario y el supuesto de subrogación real en los casos que la ley lo admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas tales por la ley".

En pocas palabras, el privilegio es una prerrogativa que tiene un acreedor para cobrar su crédito antes que otros acreedores del mismo deudor. Esta ventaja, más que un derecho del acreedor, es una cualidad de su crédito, y tiene interés cuando hay más de un acreedor. Si el deudor tiene un solo acreedor, la cuestión de privilegios no es tan importante.

La Corte Suprema ha resuelto en diversas oportunidades que, por aplicación del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, se trata de una materia que le compete regular al Congreso nacional.

III. Método del Código

Existen disposiciones relativas a los privilegios en otros códigos

o leyes. Podemos mencionar en tal sentido el Código de Minería, el Código Aeronáutico, la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Navegación, entre otras.

Esta dispersión en la legislación sobre los privilegios trae serios inconvenientes, en especial, porque en todo ese complejo normativo no existe uniformidad de tratamiento del tema, hasta el extremo de que hay créditos que son o no privilegiados según el Código o la ley que los consagre.

El actual Código Civil y Comercial regula a los privilegios en el último Libro, el Sexto, bajo el título *Disposiciones comunes a los derechos personales y reales*. El Título II se divide en dos capítulos: el primero alude a las disposiciones generales y el segundo a los privilegios especiales. El método adoptado fue el de Freitas.

IV. Fundamento

Para fundar este instituto se han hecho referencias generales que se apoyan en la equidad, ya que se evita que alguien se enriquezca a expensas de otro, como ocurre en el caso de quien hizo gastos de conservación en la cosa. Se ha dicho que procura evitar desigualdades de hecho, o bien que de esta manera se favorece también al deudor en tanto le permite obtener crédito.

V. Naturaleza jurídica

Cabe recordar que desde hace tiempo en la doctrina se planteó una viva polémica sobre la naturaleza jurídica del privilegio. Así, autores entendían que el privilegio era un derecho real. Por el contrario, la doctrina mayoritaria, sostenía que el privilegio es un derecho personal, puesto que el mismo no crea una relación directa e inmediata entre el acreedor y la cosa.

No se trata de un derecho autónomo, sino de una de las facultades comprendidas en algunos derechos de créditos cuando la ley concedió tal facultad —preferencia— en atención a la naturaleza misma del crédito. En esa línea se señaló que los privilegios no son en realidad ni derechos personales ni reales, puesto que no constituyen derechos subjetivos

contra el deudor, sino meras cualidades, propiedades o modos de ser de ciertos créditos que les permiten ser pagados con preferencia a otros pero que carecen de autonomía.

El Código actual sigue esta última tendencia, la cual tiene en consideración más al crédito que al acreedor; a la calidad, facultad o cualidad, que al derecho. Se ha inclinado el legislador por considerarlo una cualidad de un crédito.

VI. Clasificación

a) *Generales y especiales*

La clasificación más importante los divide en *generales y especiales*. Son generales cuando pueden recaer sobre todos los bienes del deudor (v. gr.: del Fisco por impuestos), mientras que los especiales recaen sobre bienes determinados (v. gr.: hipoteca). Dispone el artículo 2580 del Código que "Los privilegios generales sólo pueden ser invocados en los procesos universales", como sucede en el caso de los concursos. En cambio, el privilegio especial puede hacerse valer, además de la ejecución colectiva, en el caso de que otro acreedor haya iniciado una ejecución contra un bien determinado. En este último supuesto funciona la subrogación real (art. 2584).

Los privilegios especiales están previstos en los artículos 2582 a 2586 del Código. La Ley de Concursos y Quiebras 24.522, en su artículo 241, da una enumeración de los créditos con esta prioridad o preferencia de cobro. La extensión de la preferencia por estos créditos se limita al capital, con las excepciones del artículo 242 de la LCQ, mientras que el orden de estos privilegios está dado por los incisos del artículo 241 de la LCQ, salvo el crédito del retenedor que nació antes de los restantes créditos especiales, en cuyo caso los desplaza; a prorrata, si concurren créditos en un mismo inciso y los bienes son insuficientes, y, como excepción, los incisos 4° y 6° del artículo 241 (hipoteca, prenda y leyes especiales), que concurren conforme surge de sus respectivos ordenamientos.

Otra clasificación posible distingue entre privilegios sobre inmuebles o sobre muebles.

b) *Asiento del privilegio*

Tal como surge del artículo 2573, el asiento del privilegio lo constituye la cosa, o bien un conjunto de cosas que quedan afectadas al cobro del acreedor.

En principio, la cosa debe estar en el patrimonio del deudor, salvo disposición en contrario. Si se desplazase a otro, entraría a operar el fenómeno de la *subrogación real*, lo que significa que la preferencia se hará valer sobre el valor obtenido.

Esta regla no es exacta, ya que en el caso de la hipoteca, el acreedor puede perseguir la cosa enajenada por el deudor contra un tercero que no revista esa calidad. Este derecho de persecución no es un atributo del privilegio, sino que deriva del derecho real al que va unido un privilegio especial.

El privilegio especial del crédito laboral tiene su asiento sobre mercaderías, materias primas y maquinarias, que se encuentren en el establecimiento y sean de propiedad del empleador.

c) *Cosas inembargables*

El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas tales por la ley (art. 2573, última parte).

Por un lado, el inmueble afectado como vivienda no puede ser embargado por ciertos créditos (art. 249). Tampoco es ejecutable el derecho real de uso (art. 2160). Por regla, no son embargables las sepulturas (art. 2110).

Hay que tener muy en cuenta el artículo 744.

A este panorama hay que sumar los objetos que sean declarados inembargables por otras leyes.

d) *Ámbito de aplicación del Código*

Como ya se advirtió, dispone el artículo 2580 del Código que "Los privilegios generales sólo pueden ser invocados en los procesos universales". Por tal motivo, el Código sólo se ocupa de los privilegios especiales, los que se pueden invocar en las ejecuciones individuales.

VII. Caracteres

a) *Origen legal*

No hay privilegio sin ley que lo establezca (art. 2574), no hay privilegio que se pueda crear por contrato.

Si la creación de privilegios dependiera de la voluntad de las partes, habría mucha inseguridad y se correría el riesgo de que la suerte de los acreedores dependiera en gran medida de la voluntad del obligado.

b) *Accesorio*

Los privilegios son accesorios de una obligación principal, que en el caso es el crédito. De allí que si el crédito se extingue o se transmite, el privilegio también se extingue o se transmite.

Esta característica tiene aplicación en la posibilidad de cesión del crédito y su privilegio (art. 2576) y de subrogación (art. 2584).

c) *Excepcional*

La regla es la igualdad de los acreedores, quienes reciben el nombre de "quirografarios" y concurren a prorrata entre sí, excepto disposición expresa en contrario de la ley (art. 2581). La existencia de un crédito privilegiado es la excepción, ya que lo normal es que el crédito no goce de privilegio alguno.

Al ser así, debe ser restrictiva la interpretación de los privilegios, limitada a los términos de la ley.

En caso de duda sobre la existencia, extensión o rango de un privilegio, se estará por su inexistencia o por su extensión y/o rango limitados.

d) *Indivisible*

Dispone el artículo 2576 que "Los privilegios son indivisibles en cuanto al asiento y en cuanto al crédito, independientemente de la divisibilidad del asiento o del crédito..."

La preferencia de cobro que confiere el privilegio sobre un bien que constituye el asiento del privilegio, total o parcial, perdura intacta mien-

tras subsista impago (total o parcialmente) el crédito privilegiado. Los privilegios afectan íntegramente la cosa o cosas sobre las que se asientan.

Tal como se vio al tratar las garantías reales, todas y cada una de las cosas o partes de ellas afectadas al pago de una deuda quedan sujetas al cumplimiento hasta tanto la deuda y cada parte de ella haya sido satisfecha.

e) *Renunciable*

Se prevé en el artículo 2575 que el acreedor puede renunciar a su privilegio, y que el acreedor y el deudor pueden convenir la postergación de los derechos del acreedor respecto de otras deudas presentes o futuras, en cuyo caso los créditos subordinados se rigen por las cláusulas convenidas, siempre que no afecten derechos de terceros. El citado artículo agrega que la posibilidad de renuncia o postergación no se aplica a los créditos laborales. Ello permite que entre a jugar la autonomía de la voluntad en cuanto al rango, como acontece con las garantías reales.

f) *Objetividad*

Esto significa que la preferencia que otorga la ley a ciertos créditos no tiene vinculación con los sujetos que son titulares, sino con la naturaleza misma de la prestación realizada por el acreedor y que ha sido la causa del nacimiento del crédito.

VIII. Extensión y cómputo

a) *Extensión*

El privilegio se extiende al capital adeudado, pero no a los intereses, ni a las costas, ni a otros accesorios del crédito, excepto disposición legal expresa en contrario (art. 2577). Lo que prevé el Código coincide con el artículo 242 de la Ley de Concursos.

Esto es así salvo disposición legal en contrario. Precisamente, en el artículo 2583, se aclara que determinados créditos tienen una extensión mayor, como ocurre, por ejemplo, con la hipoteca, prenda y anticresis (ver también art. 2183).

b) *Cómputo*

Se especifica en el artículo 2578 que el plazo de los privilegios debe correr en forma retroactiva a partir del reclamo judicial, salvo disposición en contrario. Tal sería el término inicial. Así, si se concede un privilegio en relación con un determinado lapso (v. gr.: el privilegio de las remuneraciones debidas al trabajador por seis meses, conf. art. 2582, inc. b), éste se cuenta retroactivamente desde el reclamo judicial, excepto disposición legal en contrario.

No aclara el artículo 2578 si el "reclamo judicial" involucra al pedido de instancia de mediación.

IX. Subrogación real

El artículo 2584 del Código expresamente prevé la "subrogación real". Dice que "El privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyen los bienes sobre los que recae, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la subrogación real". Esta solución ya la había previsto el Código para los derechos reales de garantía (art. 2194).

Hay que advertir que el privilegio se trasladará "sobre los importes", y no sobre las cosas que sustituyan al asiento originario.

X. Privilegios especiales

El Código deriva los privilegios generales a la legislación de los concursos, de modo que únicamente se ocupa de los privilegios especiales que se harán valer en las ejecuciones individuales, pues, los generales caen en el ámbito de los procesos universales.

a) *Enumeración*

El Código se ocupa de enumerarlos en el artículo 2582. Teniendo en cuenta que los privilegios son excepcionales y de interpretación restrictiva, cabe concluir que se trata de una enumeración taxativa. Son créditos dotados de privilegio, que se suman a los ya contemplados en otras normas (v. gr.: Ley de Navegación).

b) *Extensión*

Según el artículo 2583: "Los privilegios especiales se extienden exclusivamente al capital del crédito, excepto en los siguientes casos:

- "a) los intereses por dos años contados a partir de la mora, de los créditos laborales mencionados en el inciso b) del artículo 2582;
- "b) los intereses correspondientes a los dos años anteriores a la ejecución y los que corran durante el juicio, correspondientes a los créditos mencionados en el inciso e) del artículo 2582;
- "c) las costas correspondientes a los créditos enumerados en los incisos b) y e) del artículo 2582;
- "d) los créditos mencionados en el inciso f) del artículo 2582, cuya extensión se rige por los respectivos ordenamientos".

XI. Extinción

Tal como se vio al tratar los derechos reales de garantía, que son accesorios de un crédito, también los privilegios pueden extinguirse por vía directa o indirecta.

a) *Causas directas*

Una vía directa es la *renuncia*, ya que el propio Código establece la posibilidad, con excepción de los créditos laborales. En principio no se requiere formalidad alguna, pero cuando se renuncie a un derecho real de garantía que tenga por asiento un inmueble, resultará necesaria la escritura pública (art. 1017, inc. a).

Otra causa puede ser la *destrucción o pérdida de la cosa* asiento del privilegio. Si la destrucción es parcial, subsiste en la parte remanente.

Si la cosa es enajenada y sale del patrimonio del deudor, en principio se extingue el privilegio, salvo cuando el acreedor cuente con el *ius perseguendi*, como sucede —por ejemplo— con la hipoteca.

Otra causa es la *confusión*, que se produce cuando el acreedor se convierte en dueño de la cosa que era el asiento del privilegio.

b) *Vía indirecta*

La vía indirecta se configura en las hipótesis de extinción del crédito. Si se acaba la obligación por el motivo que sea, se extingue el privilegio por su carácter accesorio.

CAPÍTULO XXVII

DERECHO DE RETENCIÓN

MNR

SUMARIO: I. Concepto. II. Naturaleza jurídica. III. Caracteres. IV. Requisitos. V. Objeto. VI. Ejercicio. VII. Atribuciones del retenedor. VIII. Obligaciones del retenedor. IX. Efectos. X. Extinción.

I. Concepto

Establece el artículo 2587 que "Todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor, hasta el pago de lo que éste le adeude en razón de la cosa".

El *ius retentionis* es un derecho o facultad cuya actuación depende exclusivamente de la voluntad del que puede ejercitarlo, sin necesidad del auxilio o intervención del poder público. Este derecho no importa acción o ataque sino defensa, pero defensa pasiva, que se traduce en el mantenimiento de la situación existente, de ahí que el Código lo caracterice como la facultad que se acuerda a una persona para "conservar en su poder la cosa", hasta que se le pague.

Se trata, en definitiva, de un remedio al que puede recurrir el acreedor con el objeto de compeler al deudor a pagar la deuda, de modo que mientras no se verifique este pago, aquél podrá retener la cosa que fue su objeto.

a) *Fundamento*

El derecho de retención tiene su fundamento y finalidad en la po-

sibilidad de acudir a la vía de hecho —autorizada por la ley—, a fin de asegurar el cumplimiento de lo que le es debido, reteniendo la cosa para garantizar un derecho amenazado ante una posible violación, evitando de esta manera que se altere el equilibrio entre partes.

Se trata de evitar que quien se beneficia por la actividad de otro (sea conservando, mejorando o generando una cosa para aquél) obtenga ese beneficio sin satisfacer previamente a quien lo produjo.

b) *Diferencias con la suspensión de cumplimiento*

Existen algunas semejanzas entre las dos figuras ya que en ambas es necesaria la existencia de personas que sean, respectivamente, deudor y acreedor. No obstante, hay distinciones.

Se pueden marcar las siguientes diferencias: en el derecho de retención lo que se rehúsa es la entrega de una cosa que es propiedad del otro, en la suspensión (ver art. 1031) basta con que la obligación derive de un contrato bilateral, cualquiera sea la naturaleza de la prestación del demandado; en el primero se exige la condición de conexión entre la deuda y la cosa, en la suspensión se exige la conexión o la correlación de las obligaciones y su cumplimiento simultáneo que configuran una relación sinalagmática; en el derecho de retención se rehúsa la entrega, aun en caso de contratos unilaterales; el derecho de retención es una excepción, la suspensión puede ejercerse como acción.

El derecho de retención supone créditos recíprocos y/o conexos, pero éstos son independientes entre sí, por cuanto no es el uno la causa jurídica del otro. En cambio, la suspensión presupone una relación sinalagmática y, por tanto, créditos no sólo recíprocos y conexos, sino de los cuales es el uno causa jurídica del otro; porque si entre los dos créditos faltase la relación de causalidad, no existiría la relación sinalagmática y, por lo mismo, la suspensión carecería de fundamento.

Cabe también señalar que el derecho de retención, mientras subsiste, interrumpe el curso de la prescripción extintiva del crédito al que accede (art. 2592, inc. e).

c) *Quiebra del acreedor de la restitución*

El artículo 131 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras sus-

pende el derecho de retención y lo sustituye por un privilegio (art. 241, inc. 5°).

El Código, en el artículo 2592, inciso f, dispone que en caso de concurso o quiebra del acreedor de la restitución, la retención queda sujeta a la legislación pertinente. Por lo tanto, sería de aplicación lo previsto en la Ley de Concursos.

II. Naturaleza jurídica

Antes de la sanción del Código actual, la doctrina se dividió al tratar de establecer la naturaleza jurídica de esta figura. Se sostuvo que se trataba de un derecho real, de un derecho personal, que es un atributo del crédito, y de una excepción procesal.

Para Llambías, el derecho de retención no es una institución de derecho sustantivo, sino una *excepción procesal de carácter dilatorio*, que tiende a mantener la situación de hecho existente hasta tanto el actor se allane a cumplir satisfaciendo su crédito al retenedor. De tal suerte no lo considera un derecho autónomo, sino un simple medio procesal cuya función sería tutelar un derecho personal creditorio a través de un medio negativo.

La teoría de Llambías se muestra como la más sólida.

III. Caracteres

a) *Accesorio*

No se lo concibe separado del crédito preexistente al que garantiza, mediando respecto a aquél una cierta relación de accesoriedad. Por ende, extinguido el crédito principal, declarada su nulidad o transmitido el mismo, el derecho de retención que lo accede sigue su suerte. No admite transmisión autónoma ni su cesión para garantizar otro crédito, es inseparable del crédito por el cual se ejerce (art. 2592, inc. b). Si no fuera así, se perdería la conexidad que debe existir entre el crédito y la cosa retenida.

b) *Facultativo*

Es una potestad, una facultad del acreedor ejercer o no el derecho de retención en función de su propio interés. Nada obsta a que el acreedor renuncie a ejercerlo en forma expresa o tácita, devolviendo la cosa.

El ejercicio de la retención es unilateral, sin necesidad de concurrencia de ninguna otra voluntad e incluso contra la voluntad del deudor.

c) *No subsidiario*

Para el efectivo ejercicio del derecho de retención es indiferente que el acreedor carezca de otras vías idóneas para satisfacer su interés, pudiendo articular cualquiera de las vías que le otorga el ordenamiento en forma paralela con el derecho de retención.

d) *Indivisible*

Este carácter está consagrado expresamente en el artículo 2592: "Efectos. La facultad de retención: a) se ejerce sobre toda la cosa cualquiera sea la proporción del crédito adeudada al retenedor".

Por ende, si el deudor pagare parte de la obligación, no podría reclamar que se le devolviese parte del objeto retenido, sino que toda la cosa está afectada de manera indivisible al cumplimiento de la obligación garantizada con el derecho de retención.

No debe confundirse el supuesto de que una persona ejerza diferentes retenciones sobre distintas cosas, pues se estaría en presencia de varias retenciones, y la indivisibilidad sólo corre cuando la retención es única frente a un grupo de cosas.

e) *Transmisible*

El derecho de retención es transmisible por sucesión *mortis causa* y por acto entre vivos, en forma inseparable del crédito al que accede (art. 2592, inc. b).

f) *Sustituible*

Según el artículo 2589: "...El juez puede autorizar que se sustituya

el derecho de retención por una garantía suficiente". La intención del legislador es evitar abusos. Cualquiera que tenga interés legítimo respecto de la cosa retenida puede solicitarle al juez la sustitución. Así, por ejemplo, estarían legitimados el dueño de la cosa, otro acreedor, etcétera.

Del pedido habrá que dar vista al acreedor. El juez "puede" autorizar la sustitución, no está obligado a hacerlo.

g) *Actúa principalmente como excepción*

En la práctica, en general, se ejerce por vía de excepción procesal articulada en juicio por el retenedor frente a quien pretende la restitución de la cosa, la que es deducida al momento de trabarse la litis.

También puede ser invocado por vía de acción.

IV. Requisitos

a) *Relación de poder con la cosa*

Quien pretenda ejercer el derecho de retención se encuentra en poder de una cosa ajena. Dice el artículo 2587 que "puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor"; si la puede conservar es porque ya la cosa se encuentra bajo su custodia. El segundo párrafo del artículo 2587 dice que el acreedor tiene la "detentación" de la cosa, y el artículo 2590, inciso a, se refiere a la "posesión o tenencia" de la cosa.

b) *Acreedor de una obligación cierta y exigible*

En primer lugar, el que ejerce la retención debe ser acreedor. En segundo lugar, debe tratarse de un crédito cierto y exigible contra el propietario de la cosa (art. 2587). No es necesario que sea líquido.

c) *Conexidad entre el crédito y la cosa*

El Código impone, como es lógico, el requisito del *debitum cum re junctum* que exige la concurrencia de una conexidad objetiva. Debe tratarse de una deuda aneja a la cosa, se exige que la deuda sea por razón de esa misma cosa.

Es clásico el ejemplo de quien lleva el automóvil al taller y no paga el arreglo. Hasta tanto el deudor no pague, el tallerista puede retener el vehículo. Se trata de un crédito vinculado a la cosa. Ahora, si el mecánico es acreedor del dueño del auto por otras causas, no tiene derecho a retener el auto.

d) *Modo de obtención de la cosa*

Dispone el segundo párrafo del artículo 2587 que "Tiene esa facultad sólo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos. Carece de ella quien la recibe en virtud de una relación contractual a título gratuito, excepto que sea en el interés del otro contratante".

El Código descarta a quien obtuvo la cosa por medios ilícitos. Así, por ejemplo, no podría invocar esta facultad quien obtuvo la cosa por desapoderamiento, lo que significa ser un poseedor vicioso (art. 1921).

Tampoco puede beneficiarse con el derecho de retención quien mantiene una relación con la cosa en virtud de un contrato a título gratuito, ya que no hubo prestación a su cargo (art. 967), "excepto que sea en el interés del otro contratante".

V. Objeto

Dispone el artículo 2588 que "Toda cosa que esté en el comercio puede ser retenida, siempre que deba restituirse y sea embargable según la legislación pertinente".

La doctrina mayoritaria sostuvo que el derecho de retención no puede recaer sobre créditos, bienes inmateriales por excelencia, aun cuando su ejercicio sea posible sobre los títulos o instrumentos que los establecen. Ocurre que si no se trata de cosas, será difícil establecer la relación directa entre el crédito y el objeto retenido, pero si esto ocurre, no se puede descartar. El Código reconoce la prenda sobre créditos instrumentados (art. 2219), por lo que —al menos en el plano teórico— no se puede hoy ser tan tajante.

Entre otros, en el artículo 2587 se alude a una cosa que el acreedor "debe restituir al deudor"; en el artículo 2590, inciso b, se menciona que hay un depósito; en el artículo 2593 se dice que el derecho de

retención se extingue si se produce la confusión de la calidad de retenedor y propietario de la cosa. Por ende, aunque el Código no lo exige, la regla es que debe tratarse de una cosa *ajena*, total o parcialmente (v. gr.: condominio). No obstante, pueden presentarse situaciones excepcionales en las que se ejerza sobre una cosa propia, como sucedería si el locador hace una mejora que está a cargo del inquilino y éste no la paga.

Además, requiere el Código que la cosa *se encuentre en el comercio*. No sería posible retener, por ejemplo, una cosa del dominio público.

Asimismo, se exige que la cosa sea *embargable*. Ocurre que las cosas inembargables están fuera del poder de agresión del acreedor, y el derecho de retención es una manera de agredir los bienes del deudor. La inembargabilidad puede surgir del Código (ver art. 744) o de otra norma legal.

VI. Ejercicio

"El ejercicio de la retención no requiere autorización judicial ni manifestación previa del retenedor..." (art. 2589). Se trata de una facultad que puede ser ejercida extrajudicialmente; en el supuesto de ser hecha valer en un juicio, el demandado lo opondrá como cualquier otra defensa.

El derecho de retención tiende solamente a paralizar la acción de quien reclama la restitución de la cosa sobre la que se ejercita, hasta que aquél pague; es decir que se lo opone sólo para conservar una situación de hecho ya existente, lo cual evidencia que su misión es defender y no atacar.

VII. Atribuciones del retenedor

a) *Acciones*

Establece el artículo 2590 que "El retenedor tiene derecho a: a) ejercer todas las acciones de que dispone para la conservación y percepción de su crédito, y las que protegen su posesión o tenencia con la cosa retenida..."

a.1) *Acciones respecto del crédito*

La persona que ejerce el derecho de retención tiene un crédito vinculado con la cosa que retiene (v. gr.: mecánico que arregló un automóvil). Por lo tanto, es acreedor y ello lo faculta, al margen de la retención, a conservar y a utilizar todos los medios legales a su alcance para percibir el crédito. Ejercer el derecho de retención no significa renuncia alguna a cobrar la obligación de parte del deudor, ni lo libera a este último de cumplir.

En caso de que el deudor no satisfaga voluntariamente el crédito, el cobro debe ser judicial. La calidad de retenedor no atribuye la facultad de vender por propia mano la cosa retenida sin recurrir al embargo judicial y subasta en el marco de un proceso, pese a lo que suelen advertir en carteles y notas en boletas los sastres y demás comerciantes dedicados a la reparación de zapatos o de productos eléctricos o electrónicos.

a.2) *Acciones posesorias*

El acreedor que ejerce la retención tiene una relación de poder sobre la cosa retenida. En la hipótesis de sufrir turbaciones o desamparamiento, puede iniciar las acciones posesorias correspondientes para mantener o recuperar su posesión o tenencia. Además, si concurren las circunstancias, puede valerse de la defensa extrajudicial prevista en el artículo 2240.

b) *Cobrar un canon*

Establece el artículo 2590 que tiene derecho a "percibir un canon por el depósito, desde que intima al deudor a pagar y a recibir la cosa, con resultado negativo" (inc. b).

Si las partes no se ponen de acuerdo sobre el monto del canon, lo fijará un juez.

c) *Percibir los frutos naturales*

Dice el inciso c, del artículo 2590 que puede "percibir los frutos naturales de la cosa retenida, pero no está obligado a hacerlo. Si opta

por percibirlos, debe dar aviso al deudor. En este caso, puede disponer de ellos, debiendo imputar su producido en primer término a los intereses del crédito y el excedente al capital". Una situación similar prevé el Código en el artículo 1226 respecto del locatario.

El retenedor no está obligado, pero sí puede percibir los *frutos naturales* que devengue la cosa. Si opta por hacerlo, debe dar aviso al deudor, y luego puede disponer de ellos.

El artículo 2590 se limita a los frutos naturales. No puede el retenedor percibir frutos civiles, pues ello significaría la explotación de la cosa, y no tiene derecho a ello, salvo pacto en contrario (art. 2591, inc. a).

VIII. *Obligaciones del retenedor*a) *No usar la cosa*

Dispone el artículo 2591 que "El retenedor está obligado a: a) no usar la cosa retenida, excepto pacto en contrario, en el que se puede determinar los alcances de dicho uso, inclusive en lo relativo a los frutos..."

La regla es que el retenedor no puede usar la cosa. La retención constituye una mera garantía, no importa un título susceptible de justificar el aprovechamiento del bien que se debió restituir. Ocurre que la cosa sigue siendo de su dueño, y el retenedor debe conservarla para luego restituirla. Sin perjuicio de lo expuesto, se puede pactar lo contrario.

Se señala que la regla del no uso debe circunscribirse dentro de sus justos límites. Si la cosa retenida produjese, por ejemplo, frutos naturales, el retenedor faltaría a sus deberes de conservación si no los percibiese —aun si debiese adelantar los gastos que a tales efectos fuesen necesarios— porque sería un abuso de derecho perjudicar así al propietario sin propio beneficio.

b) *Conservar la cosa y efectuar las mejoras necesarias*

El artículo 2591, en el inciso b, obliga al retenedor a "conservar la cosa y efectuar las mejoras necesarias a costa del deudor".

La retención impone deberes de guarda y conservación. Si no lo hace con diligencia, puede ser responsable de los daños que sufra la cosa. Por ello debe realizar las "mejoras necesarias", que son aquellas que procuran conservar la cosa en buen estado. Tales erogaciones pueden ser reclamadas al deudor.

c) *Restituir la cosa*

Como es lógico, al concluir la retención por alguna causa, el retenedor debe restituir la cosa a su propietario (art. 2591, inc. c). Generalmente ello sucederá si el deudor paga, pero puede darse algún otro supuesto de extinción del derecho de retención, como la renuncia.

d) *Rendir cuentas*

En la hipótesis de que el retenedor decida percibir los frutos naturales (no está obligado a hacerlo) o que las partes pacten algo respecto de los frutos, el retenedor debe rendir cuentas al deudor de cuánto hubiera percibido en concepto de frutos (art. 2591, inc. c).

IX. Efectos

a) *Facultades del deudor*

Por regla, la cosa retenida por el acreedor es de propiedad del deudor. De ahí que el Código le permita al propietario ejercer algunas de sus facultades. Dice que la facultad de retención "no impide al deudor el ejercicio de las facultades de administración o disposición de la cosa que le corresponden, pero el retenedor no está obligado a entregarla hasta ser satisfecho su crédito" (art. 2592, inc. c).

Será difícil que el deudor pueda disponer de la cosa que está en poder del acreedor, ya que para transmitir o constituir un derecho real debe hacerse la tradición, y el acreedor que la retiene no está obligado a devolverla hasta tanto vea cumplida la obligación. No obstante, puede acudir a la *traditio brevi manu* (art. 1892). Sí será factible la transmisión del dominio de una cosa mueble registrable cuando la inscripción en el Registro es constitutiva, pues para ello

no hace falta la entrega. Además, podría constituir el deudor una servidumbre o una hipoteca.

Si se transmite la cosa retenida, a los sucesores del dueño les será oponible el derecho de retención, pues -por hipótesis- debieron tener conocimiento de la situación.

b) *Facultades de otros acreedores*

Dispone el artículo 2592, inciso d, que la retención "no impide el embargo y subasta judicial de la cosa retenida, por otros acreedores o por el propio retenedor. En estos casos, el derecho del retenedor se traslada al precio obtenido en la subasta, con el privilegio correspondiente".

Como ocurre en otros casos, incluso con los derechos reales de garantía, el derecho se traslada al precio obtenido en la subasta, con el privilegio que corresponda. Se trata de un caso de *subrogación real*. No puede el acreedor retener el dinero obtenido en el remate, sino que debe cobrar y, en su caso, hacer valer su privilegio.

En cuanto al privilegio, el artículo 2582, inciso a, se refiere a quien hizo gastos de construcción, mejora o conservación de una cosa y, específicamente, el inciso d, de dicha norma contempla a "lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre ésta o sobre las sumas depositadas o seguridades constituidas para liberarla". De haber otros acreedores con privilegio, el orden lo fijan los artículos 2582 y 2586, inciso b.

c) *Interrupción de la prescripción*

Dispone el artículo 2592, inciso e, que la retención, "mientras subsiste, interrumpe el curso de la prescripción extintiva del crédito al que accede".

X. Extinción

El artículo 2593 enumera diversas causas que extinguen la retención:

a) *Extinción del crédito garantizado*

El derecho de retención es *accesorio* de un crédito, por lo que extinguido el primero se debe acabar el segundo.

La extinción puede producirse por el pago del crédito cualquiera que lo haga, incluso el tercero adquirente de la cosa en subasta promovida por un acreedor del mismo deudor. El efecto extintivo se produce a consecuencia del pago íntegro. El pago parcial no extingue parcialmente la retención porque la facultad se ejerce indivisiblemente sobre toda la cosa. Claro que si la cosa fue subastada se acaba dicho derecho, que se ejerce sobre el precio obtenido.

Además del pago, el crédito puede extinguirse por otros medios (novación, compensación, transacción, confusión, renuncia, remisión de la deuda e imposibilidad de pago).

b) *Pérdida total de la cosa retenida*

Si la cosa se pierde o se destruye, ya no puede subsistir dicha facultad por carecer de objeto. La pérdida debe ser total. Si fuere parcial, el derecho de retención subsiste en la parte que aún se conserva, ya que es indivisible.

c) *Renuncia*

Es la renuncia del derecho de retención, no del crédito.

d) *Entrega o abandono voluntario de la cosa*

Este inciso podría quedar subsumido en el anterior, ya que la entrega de la cosa al dueño o abandonarla voluntariamente son formas de renunciar a la facultad de retener. Aclara el inciso d, que el derecho "no renace aunque la cosa vuelva a su poder".

e) *Confusión de las calidades de retenedor y propietario de la cosa*

Así, por ejemplo, si el acreedor compra la cosa que está reteniendo o la hereda, no tendría sentido el derecho de retención.

f) *Causas imputables al retenedor*

Por último, el artículo 2593, en el inciso f, menciona como causales de extinción a la "falta de cumplimiento de las obligaciones del retenedor o si incurre en abuso de su derecho".

g) *Otras causas*

La enumeración del artículo 2593 no es completa. Así, por ejemplo, se ha omitido el supuesto de la sustitución por la garantía suficiente a que alude el artículo 2589 o el caso de la subasta de la cosa (art. 2592, inc. d).

BIBLIOGRAFÍA

- ABELLA, Adriana, *Derecho Inmobiliario Registral*, Zavalla, Buenos Aires, 2008.
- *El régimen jurídico inmobiliario argentino*, en L. L. 2011-B-847, y en *Revista del Notariado*, N° 905, p. 69.
- *El tracto sucesivo en la práctica registral*, en D. J. 2005-3-1137.
- *Ley 26.356. Sistemas turísticos de tiempo compartido*, en *Revista del Notariado*, N° 904, p. 141.
- *Sistemas turísticos de tiempo compartido*, 55 Seminario Teórico Práctico "Laureano A. Moreira", convocado por la Academia Nacional del Notariado, junio de 2008, en *Revista Notarial*, N° 960, p. 855.
- ABELLA, Adriana y MARIANI DE VIDAL, Marina, *Clubes de campo y barrios cerrados. El problema de la admisión*, en L. L. 2007-F-1363.
- *La ley 26.356 sobre tiempo compartido y el acreedor hipotecario*, en L. L. 2009-B-889.
- ABREUT DE BEGHER, Liliana, comentario al artículo 2088, en BUERES, Alberto (dir.), *Código Civil y Comercial de la Nación. Analizado, comparado y comentado*, Hammurabi, Buenos Aires, 2015, t. 2.
- *El derecho de tiempo compartido inmobiliario con destino turístico: un nuevo derecho real*, en E. D. del 23-4-2008, N° 11.992.
- *El derecho real de propiedad comunitaria indígena*, en L. L. 2013-E-1292.
- *La propiedad comunitaria indígena. Comentario del Anteproyecto de Código*, en L. L. del 7-6-2012.
- *La propiedad indígena*, en *Lecciones y Ensayos*, N° 90, 2012, ps. 55-97.
- *Propiedad indígena: ¿Un nuevo derecho real?*, inédita.
- ABREUT DE BEGHER, Liliana e ITURBIDE, Gabriela, *Reflexiones sobre el nuevo derecho real de superficie forestal*, en L. L. Online.
- ABREVAYA, Alejandra, *Cuestiones de competencia en la ejecución hipotecaria*, en E. D. del 22-7-99.
- *Ejecución hipotecaria*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999.

ACQUARONE, María (coord.), *Estudio de títulos. Cláusula de títulos perfectos. Buena fe y diligencia del adquirente a título oneroso. Responsabilidad*, en *Revista del Notariado*, N° 775, ps. 137 y ss.

ACUÑA ANZORENA, Arturo, *El derecho de retención*, en L. L. 14-386.

ADROGUÉ, Manuel, *La atribución de la propiedad de la vivienda económica en la ley 24.374*, en L. L. 1995-B-934.

— *Régimen jurídico de los sepulcros. Convenios sobre utilización de los mismos*, en L. L. 148-534.

ALEGRIA, Héctor, *La securitización y el fideicomiso*, en *Campus*, N° VII, agosto de 1985, ps. 10 y 11.

— *Las garantías "autoliquidables"*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 2, *Garantías*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1993, p. 149.

ALLENDE, Guillermo, *Derecho de aguas: con acotaciones hidrológicas*, Budeba, Buenos Aires, 1971.

— *La posesión*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1959.

— *Panorama de derechos reales*, La Ley, Buenos Aires, 1967.

— *Sepulcros. Aspectos jurídicos fundamentales*, en L. L. 124-821.

— *Tratado de enfiteusis y demás derechos reales suprimidos o restringidos por el Código Civil*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964.

ALSINA ATIENZA, Dalmiro A., *Existencia innegable de obligaciones reales en el Derecho argentino*, en J. A. 1964-IV-24.

— *Los derechos reales en la reforma del Código Civil*, en J. A. 1969-466-71.

ALTAMIRANO, Eduardo, *Actualidad en Derecho Civil y del Consumidor*, en L. L. C. 2014-513.

ALTERINI, Atilio, *Estudio de títulos*, en L. L. 1980-B-809.

ALTERINI, Jorge H., *Acciones reales*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000.

— *Certificados registrales. Reserva de prioridad y medidas judiciales*, en *Revista Notarial*, N° 949, p. 617.

— *Derecho real de superficie*, en *Revista del Notariado*, N° 850, ps. 16 y ss.

— *Derechos de los consorcistas*, en E. D. 68-800.

— *El derecho de daños en los límites del dominio*, en BUERES, Alberto J. y KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (dirs.), *Responsabilidad por daños en el tercer milenio*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997.

— en LAFAILLE, Héctor, *Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales*, 2ª ed. act. y ampl. por Jorge H. Alterini, La Ley-Ediar, Buenos Aires, 2010, t. III, N° 1116 ter.

ALTERINI, Jorge H., en LLAMBÍAS, J. J. y ALTERINI, J., *Código Civil anotado*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, t. IV-A.

— *Fideicomiso y letras hipotecarias*, en *Temas de Derecho Privado*, separata de la *Revista del Notariado* 1997-IX-73 a 76.

— *Importancia del estudio de títulos*, en *Gaceta del Notariado de la Provincia de Santa Fe*, N° 88, 1982.

— *Inconsistencia y esterilidad de la categoría de la posesión viciosa*, en *Anticipo de Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires*, marzo de 2004, Año XLVIII, Segunda Época, Número 41.

— *Las luces como restricciones y límites al dominio y como servidumbres*, en L. L. Online, AR/DOC/574/2012; L. L. 131-418.

— *Las medidas cautelares genéricas y la reserva de prioridad*, en *Anales de la Academia Nacional del Notariado* 2004-135.

— *Modos de adquisición del dominio de automotores*, en *Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional*, ps. 115 y ss.

— *Primeras consideraciones sobre los derechos reales en el Proyecto de Código*, en *Academia Nacional de Derecho*, 2012 (septiembre), p. 1; L. L. 2012-E-898.

— *Rango hipotecario: reserva, permuta, posposición, coparticipación*, en *Revista del Notariado*, N° 720, p. 1997.

— *Responsabilidad de los consorcistas por deudas del consorcio (enfoque dinámico de la personalidad del consorcio)*, en E. D. 56-729.

— *Responsabilidades de los consorcistas*, en *Temas de responsabilidad civil*, p. 294.

— *Usufructo*, en *Revista del Notariado*, N° 809, p. 475.

ALTERINI, Jorge H. y ALTERINI, Ignacio, *Pluralidad de regímenes para los derechos reales de garantía de créditos determinados (cerrados) e indeterminados (abiertos)*, en L. L. del 5-10-2015.

ALTERINI, Jorge H.; CORNA, Pablo; ANGELANI, Elsa y VÁZQUEZ, Gabriela, *La hipoteca ante las inoponibilidades en la quiebra*, en L. L. 2000-25.

ALTERINI, Jorge H.; CORNA, Pablo y VÁZQUEZ, Gabriela, *Propiedad indígena*, Educa, Buenos Aires, 2005.

ALTERINI, Jorge H. y VÁZQUEZ, Gabriela, *Reafirmación de la personalidad del consorcio y su capacidad para adquirir bienes*, en L. L. 2007-C-1076.

ÁLVAREZ JULIÁ, Luis, *Hipoteca post mortem*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 2010-2, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 119.

ANDORNO, Luis, *El derecho de superficie*, en J. A. 1985-III-653.

— *El derecho de superficie forestal en el ordenamiento jurídico positivo argentino*, en D. J. 2002-2-150.

— *Los derechos reales en el nuevo Código Civil del Brasil, con particular referencia al derecho de superficie*, en Zeus del 15 y 16-4-2002.

— *Superficie forestal*, en J. A. 2003-III-1147.

ANDORNO, Luis y MARCOLÍN DE ANDORNO, Marta, *Ley Nacional Registral Inmobiliaria 17.801*, Hammurabi, Buenos Aires, 1999.

ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto, *La acción de reivindicación de marcas en el Derecho argentino*, en E. D. 169-1235.

ARANGIO RUIZ, Vincenzo, *Instituciones de Derecho Romano*, trad. de José M. Caramés Ferro, Depalma, Buenos Aires, 1952.

ARAZI, Roland (dir.), *Medidas cautelares*, 2ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1999.

AREÁN, Beatriz, *Derechos Reales*, 6ª ed. ren. y ampl., Hammurabi, Buenos Aires, 2003, t. 1.

— en BUERES, Alberto (dir.) y HIGHTON, Elena (coord.), *Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Hammurabi, Buenos Aires, t. 6-B.

— *Juicio de usucapión*, Hammurabi, Buenos Aires, 2007.

ARGAÑARÁS, en SALVAT, *Derechos Reales*, t. I, nota 53.a; t. II, p. 530.

ARJONA, Guajardo y FAJARDO, José Luis, *El principio de especialidad*, en DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (coord.), *Derechos Reales*, Heliasta, Buenos Aires, 2008.

ÁRRAGA PENIDO, Mario, en KIPER (dir.), *Código Civil comentado. Derechos Reales*, t. III, comentario a arts. 3109; 3162; 3163.

— *Medianería: clasificación de muros*, en L. L. Online 1978-C-778.

— *Servidumbre legal de tránsito*, en L. L. 1982-A-944.

— *Servidumbres atípicas*, en L. L. 1985-C-199.

BAGLIETTO, GRINBERG y PAPAÑO, *Medianería*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1976.

BATLLE VÁZQUEZ, Manuel, *La propiedad de casas por pisos*, Narfil, Valencia, 1973.

BEAUDANT, Charles, *Cours de Droit Civil français*, Paris, 1938.

BELLOTTI, Mirta Liliana, *Las cosas muebles del Estado general o de los Estados particulares. El artículo 2415 del Código Civil*, en D. J. 2001-3-217.

BELLOTTI, Mirta Liliana, *Los bienes, las cosas y el objeto de los derechos reales en el proyecto de Código Civil*, en L. L. 2000-C-1145.

BENDERSKY, Mario, *El deber de contribución a las expensas comunes en la propiedad horizontal y las obligaciones contractuales asumidas por terceros con los dueños*, en L. L. 124-896.

— *Las asambleas de propietarios en el régimen de propiedad horizontal*, en L. L. 92-868.

BENSEÑOR, Norberto y CERÁVOLO, Ángel, *La facultad calificadora del Registro de la Propiedad Inmueble y sus límites*, en L. L. 2010-E-94, y en *Revista del Notariado*, N° 901, p. 213.

BERTONE, Luis y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, 1984, t. I.

BIANCA, Massimo, *Diritto Civile*, t. 6, *La proprietà*, Giuffrè, Milano, 1999.

BIBILONI, Juan, *Anteproyecto de reformas del Código Civil*, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1940, t. III.

BONANNI, Mariano, *Subrogación real del bien de familia*, en L. L. 2001-B-1154.

BONO, Gustavo, *Calificación registral: compatibilidad de los documentos que acceden al registro. Algunas bases para su procesamiento*, en L. L. C. 1997-463.

— *La demanda de desalojo como demanda interruptiva de la prescripción adquisitiva*, en L. L. Gran Cuyo 2007-276.

BONO, Gustavo y PUERTA DE CHACÓN, Alicia, *La garantía real de máximo frente al principio de especialidad en el Proyecto de Código*, en L. L. 2012-E-1233.

BORDA, Alejandro, *La compraventa en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012*, en RCyS 2013-II-14.

— *La reforma de 1968 al Código Civil*, Perrot, Buenos Aires, 1971, N° 278.

BORDA, Guillermo A., *Derechos Reales*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975; 1992, t. I.

— *El Código Civil de la República Argentina, con su explicación y crítica bajo la forma de notas*, Imprenta Coni, Buenos Aires, 1881, t. II.

— *La reforma del Código Civil. Propiedad*, en L. L. 31-1027.

— *La sustitución de un bien de familia (necesidad de una reforma legislativa)*, en L. L. 1992-E-487.

— *Tratado de Derecho Civil argentino. Parte general*, t. I.

— *Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. I; t. II, N° 1162.

BORDA, Guillermo A., *Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales*, 2ª ed. act. y ampl., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. I.

— *Tratado de Derecho Civil. Sucesiones*, 9ª ed. act. por Delfina M. Borda, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. I, N° 597.

BOTASSI, Alfredo, *Cementerios públicos y privados*, en L. L. 1981-C-1056.

BUERES, Alberto y MAYO, Jorge, *Los actos de emulación, el abuso del derecho y el exceso a la normal tolerancia entre vecinos*, en *Revista de Derecho de Daños*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, N° 2005-2, ps. 99 y ss.

BURTÍN, Daniel y HUMPHREYS, Ethel, *¿Obra nueva, innovación, abuso del derecho?*, en L. L. 2000-B-129.

BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, *Teoría general de la responsabilidad civil*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1984.

CADOCHÉ DE AZVALINSKY, Sara, *Bien de familia*, en MÉNDEZ COSTA, Josefa y D'ANTONIO, Daniel, *Derecho de Familia*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1982.

CAFFERATTA, Néstor, *El derecho real de superficie y su impronta ambiental*, en J. A. 2003-III-1169.

CALEGARI DE GROSSO, Lydia E., *El derecho real de superficie forestal. Ley 25.509*, en J. A. 2002-III-1295.

— *El derecho real de superficie forestal. Un microsistema dentro de la legislación forestal*, en J. A. 2003-III-1178.

— *Estudios sobre usucapión*, Némesis, Buenos Aires, 1988.

— *La hipoteca revertida y las desventajas de su instrumentación*, en J. A. 2007-III-1059.

— *Usucapión*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.

CALVO, Carlos, *Manual práctico de la propiedad horizontal*, Buenos Aires, 1973.

CÁMARA, Héctor, *Prenda con registro o hipoteca mobiliaria*, Ediar, Buenos Aires, 1984.

CARMINIO CASTAGNO, José Carlos, *Hipoteca por el condómino*, en *Revista del Notariado*, N° 722, p. 419.

CARZOLIO, Mario, *Las inexactitudes registrales. Rectificación de asientos. Modos*, en *Revista del Notariado*, N° 835, p. 843.

CASABÉ, Eleonora, *Calificación registral en las hipotecas constituidas en sede judicial*, en *Revista del Notariado*, N° 882, p. 115.

CASABÉ, Eleonora, Seminario sobre la estructura jurídica de los clubes de campo y barrios cerrados, en *Revista del Notariado*, N° 903, enero/marzo de 2011, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, ps. 155-158.

CASELLA, Esther Solana, *¿Es posible celebrar un contrato de prenda con desplazamiento cuyo objeto sean cuotas de una Sociedad de Responsabilidad Limitada?*, en D. J. del 27-3-2013.

CAUSSE, Federico, *Deber y exención de contribuir a las expensas*, en L. L. 1996-D-1.

— *Hipoteca y cláusulas (supuesto de locación)*, en L. L. 1998-B-681.

— *Titulos de propiedad*, en L. L. 1996-A-1354.

CAUSSE, Federico y ALMEYRA, Miguel, *El interdicto de retener dentro del régimen horizontal*, en L. L. 1996-C-168.

CAUSSE, Federico y CAUSSE, Jorge, *Actualidad en la jurisprudencia sobre la propiedad horizontal*, en L. L. 1997-B-988.

CAUSSE, Jorge Raúl, *Hipoteca y crédito*, en E. D. 88-914.

— *Ley nacional de catastro*, en L. L. 2007-B-1143.

— *Reformulación del régimen de la propiedad horizontal*, en L. L. del 11-3-2011.

— *Urbanizaciones privadas: barrios cerrados y clubes de campo*, 2ª ed., Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005.

CAUSSE, Jorge y PAPAÑO, Ricardo, ponencia presentada en el VII Congreso Internacional de Derecho Registral, Rfo de Janeiro, 1987, en el tema *La propiedad con titularidad temporal compartida. Su registración*.

CAUSSE, Jorge y PÉREZ CLOUET, María José, *Descentralización de atribuciones provinciales a las municipalidades para la convalidación de urbanizaciones privadas. Decreto 1727/2002*, en L. L. B. A. 2002-1175.

CAUSSE, Jorge y RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, José, *Las urbanizaciones en la Provincia de Buenos Aires. Reglamentación del decreto 947/2004. Disposición 349/05 de la Dirección Provincial de Catastro Territorial*, en L. L. Supl. Esp. *Emprendimientos Inmobiliarios*, 2006 (julio), p. 102, y en L. L. B. A. 2005-1289.

— CAUSSE, Jorge y TRANCHINI DE DIMARCO, Marcela, *Tiempo compartido. Reflexiones en torno a su proyectado régimen legal*, en L. L. 1986-D-1121.

CAZEAUX, Pedro y TRIGO REPRESAS, Félix A., *Derecho de las Obligaciones*, 3ª ed., Platense, La Plata, 1991, t. III, N° 1787.

CERÁVOLO, Ángel Francisco, *Donaciones inoficiosas. Propuesta de modificación del Proyecto de Código*, en L. L. del 8-11-2012.

CERÁVOLO, Ángel Francisco, *La prescripción como figura jurídica con efectos subsanatorios de ineficacias escriturarias*, en L. L. 2008-A-692.

CERIANI CERNADAS, Juan Cruz, *El reiterado menoscabo del derecho en la propiedad horizontal. Cerramientos de balcones*, en *Revista del Notariado*, N° 839, ps. 823-828.

— *No siempre se trata de demoler lo construido*, en *Revista del Notariado*, N° 865, ps. 283-291.

CIFUENTES, Santos, *Código Civil comentado y anotado*, La Ley, Buenos Aires, t. IV.

— *El bien de familia. Fundamentos y naturaleza jurídica*, en L. L. 108-1050.

CIFUENTES Santos y SAGARNA, Fernando A., *Código Civil comentado y anotado*, La Ley, Buenos Aires, t. IV.

CLERC, Carlos, *El derecho de dominio y sus modos de adquisición*, Depalma, Buenos Aires, 1982.

COGHLAN, Antonio, *Teoría general de Derecho Inmobiliario Registral*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1984.

COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henry, *Curso elemental de Derecho Civil*, trad. española, Madrid, 1928, vol. II, t. II.

COLMAN LERNER, Horacio, *Clubes de campo y barrios cerrados*, en *Revista del Notariado*, N° 908, p. 71.

COLOMBO, Carlos y KIPER, Claudio, *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*, La Ley, Buenos Aires, t. II, comentario al art. 207.

COLQUHOUN, Margarita, *Procedencia del interdicto de obra nueva en el régimen de la propiedad horizontal*, en L. L. 1990-E-386.

— *Uso y goce de las cosas comunes en la propiedad horizontal (prohibición de realizar obras nuevas sin autorización)*, en L. L. 1991-C-424.

COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, *La relación jurídica y los derechos sobre derechos*, en L. L. 2014-D-1018.

CÓRDOBA, Lucila Inés, *La personalidad del consorcio en el Proyecto de Código Civil y Comercial*, en L. L. 2012-D-1092.

CORNA, Pablo, *Conjuntos inmobiliarios*, en *Análisis del Proyecto de nuevo Código Civil y Comercial 2012*, <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/conjuntos-inmobiliarios-pablo-corna.pdf>.

CORNEJO, Américo Atilio, *Asambleas de consorcio*, en L. L. 2015-B, del 10-3-2015.

— *Derecho Registral*, Astrea, Buenos Aires, 1994.

CORNEJO, Américo Atilio, *El derecho real de superficie en el Proyecto de Unificación Civil y Comercial*, en L. L. 1987-D-1121.

— *Elementos para una noción de obligación real*, en L. L. 1988-C-894.

COSSARI, Maximiliano N. G., *La mediación en la propiedad horizontal*, en D. J. del 28-6-2006, p. 607.

COSSARI, Nelson G. A., *Condominio y partición nociva*, en L. L. 2004-B-1051.

— *Daños por molestias intolerables entre vecinos*, Hammurabi, Buenos Aires, 2006.

— *Derecho real de superficie forestal. Necesidad de reformas*, en E. D. del 21-10-2003, p. 4.

— *El concepto de comunidad de derechos*, en L. L. 2008-C-941.

— *Tiempo compartido. Impacto de la ley 26.356 sobre el sistema de derechos reales*, en L. L. 2008-F-1266.

— *Usucapición: estrategias del demandado para evitar el cumplimiento del plazo durante el transcurso del proceso*, en D. J. del 10-11-2010, p. 11.

COSSARI, Nelson y LUNA, Daniel, *La denominada hipoteca inversa o revertida. Mutuos hipotecarios exigibles post mortem*, en L. L. 2007-F-941.

— *Las urbanizaciones privadas y el derecho real de propiedad horizontal*, en E. D. Supl. del 25-9-2003.

— *Propiedad horizontal: responsabilidad civil de los integrantes del consejo de administración*, en D. J. 2004-3-609.

COSSARI, Nelson y LUVERÁ, Miguel Ángel, *Derecho real de superficie forestal*, en L. L. Litoral 2002-690.

— *El consorcio de propietarios: Su aptitud para ser titular de unidades funcionales*, en L. L. 2005-A-973.

— *Propiedad horizontal: techo edificable y tráfico inmobiliario*, en *Revista del Notariado*, N° 880, p. 64.

COSSIO Y DEL CORRAL, Alfonso, *Instituciones de Derecho Hipotecario*, Bosch, Barcelona.

COSTANTINO, Juan Antonio, *La propiedad horizontal en el Proyecto de Código*, en L. L. 2013-A-591.

— *Las medidas autosatisfactivas en el régimen de la propiedad horizontal y vida consorcial*, en J. A. 1998-III-688.

COSTANTINO, Juan Antonio y ROSALES CUELLO, Ramiro, *Proceso ejecutivo vs. consorcio de copropietarios de hecho*, en J. A. 1993-II-271.

CURA GRASSI, Domingo, *Interdictos y acciones posesorias. Interdicto de obra nueva y las servidumbres*, en L. L. 1994-A-532.

CURA GRASSI, Domingo, *¿Tiempo compartido o sistema de propiedad por períodos determinables?*, en L. L. 1993-E-983.

D'ORS, Álvaro, *Derecho Privado Romano*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1968.

DABIN, Jean, *El derecho subjetivo*, trad. de J. Osset, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, Cap. II.

DASSEN, Julio y VERA VILLALOBOS, Enrique, *Manual de derechos reales*, Buenos Aires, 1962.

DE HOZ, Marcelo, *Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012.

— *Revalorización del estudio de títulos en el ejercicio de la función notarial*, en *Revista del Notariado*, N° 842, p. 485.

DE HOZ, Marcelo y MOREL DE MARTÍ, Josefina, *El derecho real de multipropiedad*, en L. L. 1992-A-795.

DE LORENZO, Miguel Federico, *El cuerpo humano que se vuelve cosa, cosas que se vuelven cuerpo humano*, en L. L. 2010-B-807.

DE LOS SANTOS, Mabel, *Conveniencia y necesidad de legislar sobre las tutelas de urgencia*, en J. A. 1999-IV-992.

DE LUCA, Javier, *Secuestro y entrega en causas penales*, en L. L. 1992-A-452.

DE MONTE, F., *Naturaleza de las obligaciones "propter rem" (el caso especial de las obligaciones tributarias y de las expensas comunes)*, en J. A. 2001-II-813.

DE REINA TARTIÈRE, Gabriel, *El rango de las hipotecas*, en L. L. 2003-D-1025, y en *Revista del Notariado*, N° 873, p. 81.

— *La hipoteca y el derecho real de superficie forestal*, en J. A. 2003-III-1186.

— *La inserción del derecho real de superficie en el ámbito forestal*, en E. D. 203-662.

— *La prenda de dinero como garantía autoliquidable por excelencia*, en J. A. 2004-IV-1366.

— *Las denominadas nuevas formas de dominio: revisión conceptual y perspectivas de futuro*, en E. D., Colección Académica, julio de 2004.

— *Negocios sobre el rango registral*, en *Revista Notarial*, 2004, N° 948, p. 501.

— *Sistema de derechos reales. Derechos reales de disfrute*, Buenos Aires, 2006.

DE ROSA, Carlos, *La llamada multipropiedad y su inserción en el ámbito de los derechos reales*, en L. L. 1987-D-1123.

DEMOGUE, René, *Notions fondamentales du Droit Privé*, Paris, 1911.

DI FILIPPO, Mabel, *El intercambio vacacional en el sistema de tiempo compartido*, en L. L. 1986-C-752.

— *Tiempo compartido. Algunas consideraciones acerca de su objeto*, en L. L. 1986-C-878.

— *Tiempo compartido. Derechos de propiedad involucrados*, en L. L. 1985-D-11248.

— *La personalidad jurídica del consorcio en el sistema de propiedad horizontal. Del axioma a la realidad. Replanteo de la cuestión*, en L. L. 1990-E-953.

DI LELLA, Pedro, *Bien de familia y quiebra*, en L. L. 2003-D-713.

DÍAZ, Guillermo, *La ley 17.801*, en MOLINARIO, Alberto (dir.), *Curso de Derecho Registral Inmobiliario*, Buenos Aires, 1971.

DÍAZ DE GUIJARRO, Enrique, *Aplicación exclusiva de las normas sobre edificación, siembra y plantación a las relaciones entre poseedor y titular del dominio*, en J. A. 74-242.

— *Los actos posesorios en la usucapión de sepulcros*, en J. A. 67-47, sec. doct.

DÍAZ REYNA, Emilio, *Derecho real de superficie forestal (comentario con motivo de un proyecto de ley)*, en L. L. 1993-B-913.

DÍAZ REYNA, José, *Las acciones reales. Posibilidad de una única acción real*, en *Revista Notarial*, N° 915, p. 302.

DÍAZ SOLIMINE, Omar, *Dominio de los automotores*, Astrea, Buenos Aires, 1994.

Diccionario de Sinónimos Castellanos, Sopena, Buenos Aires, 1980.

Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, Espasa-Calpe, Madrid, 1979.

DÍEZ, Lilia Noemí, *El catastro y su conexión con el Registro de la Propiedad Inmueble*, en *Revista del Notariado*, N° 865, p. 19.

DÍEZ, Manuel, *Derecho Administrativo*, t. IV.

DÍEZ-PICAZO, Luis, *Fundamentos del Derecho Civil patrimonial*, vol. II, N° 453.

DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil*, 6ª ed., vol. III, *Derecho de cosas y Derecho Inmobiliario Registral*, Tecnos, Madrid, 1997.

DIKENSTEIN DE KROCHIK, Susana y MARTÍNEZ SEGOVIA, Francisco, *Multipropiedad*, en *Gaceta del Notariado*, N° 103, mayo-agosto de 1987, p. 211.

DILLON, Gregorio, *Protección jurídica de la vivienda. La regularización del dominio de la ley 24.374*, Ediciones Jurídicas de Cuyo, Mendoza, 2006.

DO CAMPO, Adriana y FORTE, Roberto, *Derecho de retención y derecho a retener. Su análisis comparado en el contrato de depósito*, en L. L. 1981-C-1072.

DUGUIT, Léon, *Las transformaciones generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón*, trad. de Carlos G. Posada, Francisco Beltrán, Madrid.

EGEA, Federico, *Alcances del concepto de dominio originario de las provincias en el sistema federal argentino*, en L. L. 2009-A-1170.

FALBO, Miguel, *Calificación registral y recursos*, en *Revista del Notariado*, N° 776, p. 499.

FALCÓN, Enrique, *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1984, t. IV.

FARIÑA, Juan M., *Contratos comerciales modernos. Modalidades de contratación empresarial*, 2ª ed. act. y ampl., 1ª reimp., Astrea, Buenos Aires, 1999.

FAZIO DE BELLO, Marta, *Actos jurídicos y documentos inscribibles*, La Rocca, Buenos Aires, 1998, p. 142.

— *Comentario a la ley 24.374*, en J. A. 1995-III-850.

FAZIO DE BELLO, Marta y MARTÍNEZ, Nory, *Protección de la vivienda en el Proyecto de Código*, en L. L. 2013-A-658.

FAZIO DE BELLO, Marta y MOREDA, Graciela, *El llamado tiempo compartido y algunos aspectos de su problemática*, en J. A. 2001-11-905.

FENOCHIETTO, Carlos, *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales*, 2ª ed. act. y ampl., t. 2.

FERNÁNDEZ, Leonardo, *La causa fin en las garantías personales*, en L. L. 2009-F-369.

FERRARI CERETTI, Francisco, *Leyes de protección a la familia*, en *Revista Internacional del Notariado*, N° 35, 1957, p. 297.

FERRER, Francisco; CÓRDOBA, Marcos y NATALE, Roberto, *Observaciones al proyecto de Código Civil y Comercial en materia sucesoria*, en DFyP 2012 (octubre), p. 127.

DI FILIPPO, Mabel, *El intercambio vacacional en el sistema de tiempo compartido*, en L. L. 1986-C-752.

— *Tiempo compartido. Algunas consideraciones acerca de su objeto*, en L. L. 1986-C-878.

DI FILIPPO, Mabel, *Tiempo compartido. Derechos de propiedad involucrados*, en L. L. 1985-D-11.248.

FLAH, Lily y AGUILAR, Rosana, *Legitimación para el ejercicio de acciones en el régimen de propiedad horizontal*, en D. J. del 7-12-2011.

— *Los sepulcros y la eventualidad de su embargo*, en D. J. del 7-7-2010, p. 1822.

FLAH, Lily y SMAYEVSKY, Miriam, *Propiedad horizontal: problemas que se suscitan*, en L. L. 1991-A-1039.

FORNIELES, Salvador, *Hipoteca constituida por el condómino*, en J. A. 1945-III, sec. doct., p. 3.

FUNES, María Victoria, *Obligaciones en moneda extranjera en el nuevo Código*, en L. L. del 23-4-2015.

FUSTER, Gabriel, *¿Adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes?*, en L. L. Cuyo 2015 [noviembre], 1047.

GABÁS, Alberto A., *Adquisición del condominio por prescripción*, en L. L. 2014-B-609.

— *Derecho práctico de propiedad horizontal*, Hammurabi, Buenos Aires, 1992, t. II.

— *Juicios posesorios*, Hammurabi, Buenos Aires, 2001.

— *Manual teórico-práctico de propiedad horizontal*, Hammurabi, Buenos Aires, 1991.

— *Régimen jurídico de los barrios privados*, Hammurabi, Buenos Aires, 2008.

GAGLIARDO, Mariano, *Anticresis de acciones en el Proyecto de Reforma*, en L. L. 2013-B-1147.

GALLI, en SALVAT, *Tratado de Derecho Civil. Obligaciones*, t. I.

GARCÍA CONI, Raúl, *Fe pública y apariencia jurídica en sede registral*, en *Revista del Notariado*, N° 818.

— *Registración inmobiliaria argentina*, Buenos Aires, 1983.

GARCÍA, Goyena, *Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español*, Madrid, 1852, comentario al art. 449.

GARRIDO, Roque y ANDORNO, Luis, *Código Civil anotado*, Zavalla, Buenos Aires, 1972, Libro III.2.

GARRIGUES, Joaquín, *Negocios fiduciarios en Derecho Mercantil*, Madrid, 1976.

— *Temas de Derecho vivo*, Tecnos, Madrid, 1978.

GASTALDI, Dominio de automotores. Registración y reivindicación (¿conviene reformar el sistema de inscripción vigente?), en E. D. 116-477.

GATTI, Edmundo, *Teoría general de los derechos reales*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975.

GATTI, Edmundo y ALTERINI, Jorge, *El derecho real. Elementos para una teoría general*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975.

— *Ley de prehorizontalidad. Análisis crítico*, en L. L. 147-1111.

GELLI, María Angélica, *Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada*, 2ª ed. ampl. y act., La Ley, Buenos Aires, 2004.

GINOSSAR, citado por LAQUIS, Manuel, *Sobre una nueva clasificación de los derechos patrimoniales*, en *Revista Jurídica de Buenos Aires* 1966-II-239/252.

GIORGIANINI, Michele, *L'obbligazione*, Giuffrè, Milano, 1951.

GOLDENBERG, Alicia, *Derecho real de superficie: su aplicación a las actividades productivas en la República Argentina*, en L. L. 2003-D-1080.

— *Ejecución hipotecaria*, La Rocca, Buenos Aires, 1999.

GOLDENBERG, Alicia y HUMPHREYS, Ethel, *Régimen de la propiedad horizontal*, LexisNexis, Buenos Aires, 2004.

GÓMEZ LEO, Osvaldo, *La letra de cambio y el pagaré*, t. I.

GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, Jerónimo, *Estudios de Derecho Hipotecario y Derecho Civil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1948, t. I.

GRASSETTI, Cesare, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, en *Riv. Diritto Commerciale*, Parte 1ª, 1936, ps. 367 y 372/373.

GRIECO, María, *Obra que viola el reglamento de copropiedad. Alteración de fachada del edificio. Cerramiento de balcón*, en *Revista del Notariado*, Nº 875, ps. 133-136.

GUASTAVINO, Elías, *Actos fiduciarios*, en *Estudios de Derecho Civil en homenaje a Lafaille*, Nº 41, Buenos Aires, 1968.

— *Derecho de Familia Patrimonial*, Omeba, Buenos Aires, 1962.

— *Fideicomiso, leasing, letras hipotecarias y otros aspectos de la ley 24.441*, en L. L. 1995-B-1061.

— *Subrogación del bien de familia con oponibilidad retroactiva*, en J. A. 1997-III-84.

GUERRERO LECONTE, Víctor A., *Ejecución de letras hipotecarias*, en J. A. 1998-IV-632.

GURFINKEL DE WENDY, Lilian, *Derecho real que se constituye sobre cocheras y guardacoches*, en EDLA, Nº 28, 1983, ps. 8 y 9.

— *Derechos Reales*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. I; t. II.

— *Estado actual del debate acerca de la regulación del derecho real de superficie*, en J. A. 2001-I-981.

— *¿Se amplía la capacidad del consorcio de propietarios en el régimen de propiedad horizontal?*, en J. A. 2004-IV-845.

HAURIJOU, Maurice, *Principios de Derecho Público*, Comares, Granada, 2003.

HEDEMANN, Justus Wilhelm, *Tratado de Derecho Civil*, vol. II, *Derechos Reales*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955.

HERNÁNDEZ GIL, Francisco, *Introducción al Derecho Hipotecario*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963.

HIGHTON DE NOLASCO, Elena, *Derechos Reales*, Ariel, Buenos Aires, 1979-1981, t. 1.

— *Derechos Reales*, t. 1, *Posesión*; t. 4.

— *Hipoteca: la especialidad en cuanto al crédito*, Depalma, Buenos Aires, 2000.

— *Juicio hipotecario*, Hammurabi, Buenos Aires, 1995, t. 2.

— *Propiedad horizontal y prehorizontalidad*, Hammurabi, Buenos Aires, 2000.

HIGHTON DE NOLASCO, Elena; ÁLVAREZ JULIÁ, Luis y LAMBOIS, Susana, *La multipropiedad en el proyecto de unificación legislativa civil y comercial en las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil*, en L. L. 1988-A-739.

— *Nuevas formas de dominio*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1987.

HIGHTON DE NOLASCO, Elena; VILA, Ana María y VILA, Rosa, *¿Debe el representante legal del consorcio de propietarios informar sobre la existencia de juicios pendientes al transferirse una unidad?*, en *Revista del Notariado*, Nº 864, p. 43; L. L. 154-1019.

HIGHTON, Federico, *Cuestión de privilegios en el juicio ejecutivo con especial referencia al privilegio del Fisco*, en E. D. 114-962.

— *La empresa y sus vecinos. Los ruidos molestos*, en L. L. 1995-D-28/29.

HUMPHREYS, Ethel, *¿Debe admitirse una violación al reglamento de copropiedad frente al obrar malicioso de un copropietario?*, en J. A. 2003-I-754.

— *Las violaciones al reglamento de copropiedad y administración consentidas precariamente*, en L. L. 2004-A-34.

HUMPHREYS, Ethel y DESAGES, Marianela, *El Consorcio de Propietarios y el Consejo de Administración*, en L. L. 2008-E-141.

- HUMPHREYS, Ethel; RIGHINI, Marcelo y DESAGES, Marianela, *Las obligaciones de los ocupantes de unidades funcionales*, en L. L. 2005-D-205.
- IGLESIAS, Juan, *Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado*, Barcelona, 1965.
- IHERING, Rudolf von, *El fundamento de la protección posesoria*, trad. esp., Madrid, 1892.
- *El fundamento de la protección posesoria*, en *La posesión*, 2ª ed., trad. española de A. Posada, Madrid, 1926.
- *La dogmática jurídica*, Losada, Buenos Aires, 1946.
- ITURBIDE, Gabriela, *Los privilegios en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación*, en L. L. Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial 2014-181.
- ITURBIDE DE BRUSCO, Gabriela, *La ley 24.374 sobre regularización del dominio*, en L. L. 1995-A-1082.
- ITURRASPE, Juan, *¿Código Civil vs. Constitución Nacional?*, en L. L. del 30-12-2003.
- JORDANO FRAGA, F., *La constitución de la hipoteca inmobiliaria voluntaria*, Granada, 1999.
- JOSSERAND, Louis, *El espíritu de los derechos y su relatividad*, traducción al castellano de Elogio Sánchez Larios y José M. Cajica Jr., México, 1946.
- JUSTINIANO, *Institutas*, L. 2, t. 4.
- KANT, Immanuel, *Principios metafísicos del Derecho*, UNAM, México, 1968.
- KEMELMAJER DE CARLUCCI, Afda, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, Afda; KIPER, Claudio y TRIGO REPRESAS, Félix, *Código Civil comentado. Privilegios. Prescripción*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006.
- en ZANNONI, Eduardo (dir.) y KEMELMAJER DE CARLUCCI, Afda (coord.), *Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado*, Astrea, Buenos Aires, 2005, t. 10.
- *Primeras reflexiones en torno a los privilegios en el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial*, en L. L. 1988-C-797.
- *Protección jurídica de la vivienda familiar*, Hammurabi, Buenos Aires, 1995.
- KEMELMAJER DE CARLUCCI, Afda y PUERTA DE CHACÓN, Alicia, *Derecho real de superficie*, Astrea, Buenos Aires, 1989.
- KIPER, Claudio, *Acerca de la posibilidad de constituir derechos reales sobre espacios destinados a sepulturas en los cementerios privados*, en L. L. 1988-E-929.
- *Autonomía de la voluntad y discriminación*, en DFyP 2010-187.

- KIPER, Claudio (dir.), *Código Civil comentado. Derechos Reales*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. II.
- *Derechos de las minorías ante la discriminación*, Hammurabi, Buenos Aires, 1998.
- *El orden público y los derechos reales*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 2007-3, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 121 y ss.
- *El Proyecto de Código y el derecho real de usufructo*, en L. L. 2013-B-1101.
- *El usufructuario y el pago de las expensas comunes*, en Microjuris.com, del 7-9-2006, MJD2989.
- *Juicio de escrituración*, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, Cap. III.
- *La medianería urbana en el nuevo Código Civil y Comercial*, en Infojus: DACF140864, del 23-12-2014.
- *La prescripción adquisitiva de cosas muebles y el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial*, en L. L. 1988-C-868.
- *La prevención del daño y el proyectado Código Civil*, en RCyS 2012-VI.
- *¿Posesión de universalidades de hecho?*, en J. A. 2000-IV-940.
- *Régimen jurídico del dominio fiduciario*, La Ley, Buenos Aires, 1990.
- *Situación del locatario de inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal que asume la obligación de contribuir al pago de las expensas comunes*, en L. L. 1983-D-1067.
- KIPER, Claudio y CERVINO HENRY, Sofía, *El título putativo y el régimen jurídico de los automotores*, en J. A. 1988-IV-177.
- KIPER, Claudio y LISOPRAWISKI, Silvio, *El fideicomiso en el Proyecto de Código*, en L. L. 2012-E-812.
- *Fideicomiso en el Código Civil y Comercial de la Nación*, en L. L. Supl. Especial Nuevo Código Civil y Comercial, 2014 (noviembre), p. 125.
- *Registración del contrato de fideicomiso en el Código Civil y Comercial. Una novedad. Efectos*, en L. L. del 11-11-2014.
- KIPER, Claudio y LISOPRAWISKI, Silvio, MÁRQUEZ, José Fernando, *El fideicomiso en el Proyecto de Código*, en L. L. 2012-D-1325.
- KOZAK, Verónica, *Los derechos reales sobre inmuebles y la escrituración de cocheras*, en L. L. C. 2011-831.
- LACRUZ BERDEJO, José Luis, *Derechos Reales*, 3ª ed., Bosch, Barcelona, 1991, vol. I.
- *Elementos de Derecho Civil*, t. III, vol. 1.
- LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco, *Derecho Inmobiliario Registral*, Bosch, Barcelona, 1984.

LAFAILLE, Héctor, *Derecho Civil*, t. III, *Tratado de los Derechos Reales*, Compañía Argentina de Editores, Buenos Aires, 1943, vol. I; t. IV, vol. II.

— *Derechos Reales*, t. I, N° 230.

LAFAILLE, Héctor y ALTERINI, Jorge H., *Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales*, 2ª ed., La Ley-Ediar, Buenos Aires, 2010, t. II.

LAJE, Eduardo Jorge, *La personalidad del consorcio de propietarios creado por la ley 13.512*, en L. L. 99-430.

— *La prehorizontalidad y sus problemas*, en L. L. 143-908.

— *La propiedad horizontal en la legislación argentina*, Perrot, Buenos Aires, 1951.

— *Naturaleza jurídica de los sepulcros y sus problemas*, en L. L. 124-551.

— *Régimen de asambleas y de administración separadas en materia de propiedad horizontal*, en *Revista del Notariado*, N° 713, p. 1429.

LAMBOIS, Susana, *Cementerios privados*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 2002-2, *Propiedad horizontal*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.

LAQUIS, Manuel Antonio, *Derechos Reales*, Depalma, Buenos Aires, 1975; t. I.

— *Los servicios comunes y la obligación por las expensas de los propietarios locales*, en L. L. 1975-B-78/102.

— *Reflexiones críticas sobre la ley de prehorizontalidad*, en L. L. 149-982.

— *Sobre una sentencia renovadora de los fundamentos negativos de la personalidad jurídica del consorcio de propietarios*, en L. L. 1985-A-534.

LAQUIS, Manuel y SIPERMAN, Arnaldo, *La propiedad horizontal en el Derecho argentino*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966.

LAVALLE COBO, Jorge y FORNARI, María, en ZANNONI (dir.) y KEMELMAJER DE CARLUCCI (coord.), *Código Civil comentado, anotado y concordado*, Astrea, Buenos Aires, t. 11, comentario al art. 2924.

LEGÓN, Fernando, *Examen crítico-comparativo de las servidumbres en el Proyecto de Reformas*, Buenos Aires, 1939.

— *Letra de cambio y pagaré*.

— *Tratado de los Derechos Reales en el Código y en la reforma*, Abeledo, Buenos Aires, 1941, t. IV.

LEIVA FERNÁNDEZ, Luis, *Derecho de retención*, Astrea, Buenos Aires, 1991.

— *El derecho de retención en el Proyecto de Código. Avances y retrocesos*, en L. L. 2013-1272.

LEVITÁN, José, *Prescripción adquisitiva de dominio*, 3ª ed. act. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 1990.

LEWINTRE, Andrea y PROSPERI, Fernando, *Límites de la acción reivindicatoria y anulación de inscripciones registrales en materia de automotores*, en L. L. 1994-B-1064.

LINARES DE URRUTIGOTTY, Martha y PUJOL DE ZIZZIAS, Irene, *Barrios privados y otros conjuntos inmobiliarios en Mendoza. "¿Son útiles las soluciones de Buenos Aires en Mendoza?"*, en L. L. Gran Cuyo 2008-313.

— *Objeto del derecho real de superficie (con especial referencia al derecho de superficie proyectado y a la superficie forestal de la ley 25.509)*, en *Revista del Notariado*, N° 867, 2002, p. 4.

LISOPRAWSKI, Silvio, *La securitización. Necesidad de una legislación de fideicomiso financiero*, en L. L. 1994-B-1171.

LISOPRAWSKI, Silvio y KIPER, Claudio, *Fideicomiso. Dominio fiduciario. Securitización*, Depalma, Buenos Aires, 1995.

LLAMBÍAS, Jorge, *Tratado de Derecho Civil. Obligaciones*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1973, t. III.

— *Tratado de obligaciones*, t. II-A.

LLERENA, Baldomero, *Concordancias y comentarios del Código Civil argentino*, La Facultad, Buenos Aires, 1931, t. VII.

— *Concordancias y comentarios del Código Civil argentino*, 2ª ed., Jacobo Péuser, Buenos Aires, 1902, t. VIII.

LLORENS, *De nuevo: hipoteca de inmueble usufructuado (¡Un logro práctico!)*, en *Revista Notarial*, N° 928, 1997, ps. 695 y ss.

LLOVERAS, Néstor y COGHLAN, Antonio, *El artículo 1051 del Código Civil: fe pública registral o estudio de títulos*, en E. D. 103-997.

LOIZA, Fabián, en KIPER, Claudio (dir.), *Código Civil comentado*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.

— *Primeras reflexiones sobre la reciente Ley de Tiempo Compartido*, en *Microjuris*, del 9-4-2008, MJ-DOC-3409-AR, MJD3409.

LOIZA, Fabián y PICADO, Leandro, *Doctrina legal, en casos de edificación de mala fe en fundo ajeno*, en L. L. B. A. 2005-380, D. J. 2005-2-561.

LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, *Curso introductorio al Derecho Registral*, Zavallá, Buenos Aires, 1983.

— *Derechos Reales*, Zavallá, Buenos Aires, 1989, t. I.

LÓPEZ DEL CARRIL, Gonzalo, *Algunos aspectos actuales de la especialidad y accesoriedad hipotecaria*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 2010-1, *Hipoteca - I*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 53.

- LÓPEZ HERRERA, Edgardo, *Responsabilidad civil*, LexisNexis, Buenos Aires, 2005.
- LÓPEZ ZAMORA, Ximena y URTURI, Victoria, *Normas supletorias aplicables al derecho real de superficie forestal*, en J. A. 2003-III-1019.
- LORENZETTI, Ricardo, *Código Civil y Comercial comentado*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, t. I.
- *Tratado de los contratos*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, t. I; 2000, t. II.
- LOYARTE, *Fideicomiso testamentario: instrumento eficaz para la protección de los concebidos dentro o fuera del seno materno*, en J. A. 1999-III-1064.
- MACIAS CASTILLO, Agustín, *El daño causado por el ruido y otras inmisiones*, La Ley, Madrid, 2004.
- MALIZIA, Roberto, comentario a los arts. 2807 y ss., en *Código Civil comentado. Derechos Reales*, dir. por Claudio Kiper, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. II.
- MANRESA Y NAVARRO, José María; MIQUEL, Ignacio y REUS, José, *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y explicada*, Madrid, 1856, comentario de los arts. 691 y ss.
- MARIANI DE VIDAL, Marina, *Apuntes sobre privilegios*, en L. L. 137-932.
- *Automotores: la buena fe como requisito para la adquisición del dominio*, en L. L. 1991-B-1141.
- *Curso de Derechos Reales*, Zavalla, Buenos Aires, 1974, vol. I.
- *Curso de Derechos Reales*, Zavalla, Buenos Aires, 2000, t. 1; t. 2; t. 3.
- *Defensa de los servidores de la posesión*, en L. L. 137-615.
- *Derecho real de superficie forestal*, en L. L. 2002-F-1422.
- en BUERES, Alberto (dir.) y HIGHTON, Elena (coord.), *Código Civil y normas complementarias*, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 5.
- *Interdicto de adquirir*, Buenos Aires, 1971.
- *Islas. Reforma al artículo 2340, inciso 6º, Código Civil. Una oportunidad desperdiciada*, en E. D. 48-811.
- *La buena fe en la adquisición de automotores*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 2009-2, *Automotores - I*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 170/171.
- *Los derechos del consorcio de copropietarios, ¿sobre qué bienes pueden hacerse efectivos?*, en E. D. 45-865.
- *Los privilegios en el Proyecto de Código*, en L. L. 2012-D-1240.
- *Propiedad horizontal. Asambleas. Nulidad. Plazo para deducirla*, en L. L. 2014-B-485.

- MARIANI DE VIDAL, Marina, *Propiedad horizontal. Fondo de reserva y enajenación de la unidad*, en L. L. 2001-E-1137.
- *Régimen jurídico de las cosas muebles*, Zavalla, Buenos Aires, 1973.
- *Relaciones entre persona y cosa*, en J. A. Doctrina 1973-48 y ss.
- *Sobre los privilegios especiales en el Código Civil y Comercial*, en L. L. 2015-A-984.
- MARIANI DE VIDAL, Marina y ABELLA, Adriana, *Algunas reflexiones sobre las asambleas en la propiedad horizontal*, en J. A., *Estudios de Derechos Reales*, Número Especial, 2010-IV-9.
- *Clubes de campo y barrios cerrados*, Heliasta, Buenos Aires, 2009.
- *El tiempo compartido en el Proyecto de Código*, en L. L. 2013-C-679.
- *Las servidumbres en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación del año 2012. Aspectos salientes*, en J. A. 2012-IV.
- *Propiedad horizontal. El consorcio dueño de unidades funcionales*, en E. D. 208-1022.
- *Reglamentación del sistema turístico de tiempo compartido*, en L. L. 2014-D-870.
- *Reglamentación legal de los sistemas turísticos de tiempo compartido*, en L. L. 2014-D-870.
- *Temas de servidumbres*, en J. A., Número Especial, *Estudios de Derechos Reales*, 2008-IV-36.
- MARIANI DE VIDAL, Marina y KIPER, Claudio, *Promesa de hipoteca, naturaleza y efectos*, ponencia presentada ante las VI Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, Paraná, septiembre de 1986.
- MARIANI DE VIDAL, Marina; KIPER, Claudio y GOLDENBERG, Alicia, *Efectos de la adquisición del dominio por prescripción respecto de los derechos reales constituidos por el anterior propietario y por el usucapiente*, en L. L. 1987-C-942.
- *Registro, excepción, prescripción adquisitiva y juicio de usucapión*, en L. L. 1989-E-1084.
- MARIANI DE VIDAL, Marina y RUDA BART, Javier M., *Propiedad horizontal. Obras nuevas autorreglamentarias*, en L. L. 1994-C-1080.
- MARIENHOFF, Miguel S., *La reciente reforma del Código Civil en materia de aguas*, en J. A. 1970-255, *secc. doct.*
- *Régimen y legislación de las aguas públicas y privadas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1971.

- MARIENHOFF, Miguel S., *Tratado de Derecho Administrativo*, 2ª ed. act., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, t. V.
- *Tratado de Derecho Administrativo*, 4ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, t. IV; 2008, t. IV.
- *Tratado de dominio público*, Tea, Buenos Aires, 1960.
- MARIÑO GALASSO, Augusto, *La mal pretendida inscripción del boleto de compraventa, que continúa siendo un derecho personal*, en L. L., Supl. Esp. *Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos en particular* 2015 (abril), p. 36.
- MÁRQUEZ, José Fernando, *El fideicomiso en el Proyecto de Código*, en L. L. 2012-D-1325.
- MÁRQUEZ, José Fernando y CALDERÓN, Maximiliano, *Prescripción y caducidad en el Código Civil y Comercial*, en L. L. del 13-5-2015.
- MARTÍNEZ, F., *El privilegio general del gasto de justicia y del Fisco por impuestos*, en rev. *Impuestos*, t. XLII-a, 1984, p. 193.
- MARTÍNEZ, Nory Beatriz, *El Consejo de Administración en la propiedad horizontal. Alcances de sus facultades y funciones. Posibilidad de su delegación*, en L. L. 2007-C-73.
- MARTÍNEZ PAZ, Enrique, *Freitas: introducción a la consolidación de las leyes civiles del Brasil, en Freitas y su influencia sobre del Código Civil argentino*, Córdoba, 1927.
- MARTÍNEZ RUIZ, Roberto, *La reforma del Código Civil y la seguridad jurídica*, en *Revista del Notariado*, N° 702, ps. 1396/1397.
- MASNATTA, Héctor, *Interdicto de adquirir y acción "ex-empto" en la compraventa inmobiliaria*, en J. A. 1951-IV-3.
- MAVRICH, Ana Ingrid, *Servidumbres reales y aspectos urbanísticos de los complejos residenciales*, en L. L. Gran Cuyo 2014-1041.
- MAZBAUD, *Lecciones de Derecho Civil*, parte tercera, vol. 1.
- MERCADER, Miguel A., *Dificultades o imposibilidad de hecho para ejercer las acciones*, en *Examen y crítica de la reforma del Código Civil*, La Plata, 1971, t. II.
- MESQUIDA, Silvina y KOON, María Lucila, *La protección de la vivienda en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación*, en DFyP 2014 (noviembre), p. 61.
- MESSINEO, Francesco, *Manual de Derecho Civil y Comercial*, Ejea, Buenos Aires, 1971, t. III.
- *Titoli di credito*, Padova, 1933, t. II.

- MICHAS, H., *Le Droit réel considéré comme une obligation passivement universel*, Paris, 1900.
- MIRANDA, Marcelo, *El sistema Torrens y la transmisión y constitución de derechos reales inmobiliarios en Australia*, en *Revista Internacional del Notariado*, ONPI, 1982, N° 78, ps. 77/125.
- MOISSET DE ESPANÉS, Luis, *Camino de sirga*, en www.cca.unc.edu.ar.
- *Dominio de automotores y publicidad registral*, Buenos Aires, 1981.
- *El título de los automotores*, en J. A. 1990-III-860.
- *La buena fe y la propiedad de los automotores*, en obra colectiva, *La buena fe en el Derecho*, La Ley, Buenos Aires, 2004.
- *La oportunidad para hacer valer la prescripción y el derecho transitorio*, en J. A. 1975-29-463.
- *La oportunidad procesal para plantear la prescripción -Aclarando una opinión que se me atribuye-*, en J. A. 1979-IV-735.
- *Publicidad material y publicidad formal en el Registro de Automotores*, en *Revista del Notariado*, N° 821, p. 354.
- *Publicidad registral*, Advocatus, Córdoba, 1991.
- *Reflexiones sobre la oportunidad para hacer valer la prescripción*, en J. A. 1979-IV-764.
- MOISSET DE ESPANÉS, Luis y CIMA, Luis, *Los envases de gas licuado. ¿Cosa mueble o "mueble registrable"?*, en L. L. 2000-F-1242.
- MOLINA, Marcela, *El acceso y circulación restringida en las vías internas de los complejos residenciales privados: su regulación como derecho de uso especial del dominio público*, en L. L. Gran Cuyo 2014-1200.
- MOLINA QUIROGA, Eduardo, *Los cerramientos en balcones que afectan la seguridad y la estética del edificio sometido al régimen de propiedad horizontal*, en L. L. 1994-E-174.
- *Los nuevos derechos reales*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 2012-3, *Proyecto de Código Civil y Comercial - II*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.
- *Obras nuevas, innovaciones y abuso del derecho en la propiedad horizontal*, en L. L. 2000-B-336.
- *Pago de expensas y reparación de partes comunes*, en L. L. 2005-F-218.
- *Principales reformas en materia de derechos reales en el Código Civil y Comercial de la Nación*, L. L., Supl. Especial *Nuevo Código Civil y Comercial*, 2014 (noviembre), p. 165.

- MOLINA QUIROGA, Eduardo, *Propiedad horizontal y abuso del derecho*, en L. L. 2000-C-175.
- *Proyecto de Código Civil y Comercial – II*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.
- MOLINA QUIROGA, Eduardo y VIGGIOLA, Lidia, *Novedades en el régimen jurídico del automotor*, en L. L. del 4-8-2004.
- MOLINA SANDOVAL, Carlos, *Prenda de títulos valores*, en L. L. 2009-B-1208.
- *Publicación del listado de morosos y barrios cerrados*, en L. L. 2012-C-1375.
- MOLINARIO, Alberto, *De la pretendida e inexistente hipoteca abierta en el Derecho positivo argentino*, en J. A. 1972-1, sec. doct.
- *Derecho patrimonial y derecho real*, La Ley, Buenos Aires, 1965.
- *Inexistencia de la personalidad del consorcio creado por la ley nacional 13.512*, en E. D. 120-405.
- *Interpretación de la protección posesoria actual en función de la historia interna*, separata de *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata*, 1963, p. 45.
- *La locación del bien de familia e inconstitucionalidad del artículo 168 del decreto 2080/80*, en L. L. 1985-B-247.
- *Relaciones reales*, Buenos Aires, 1965.
- MOLITOR, J. P., *La possession, la reivindicacion, la publicienne et les servitudes en Droit Romain*, Paris, 1874.
- MORALES, P., *Los derechos humanos y la situación actual de los pueblos indígenas*, en L. L. Supl. Actualidad del 8-6-93.
- MOREIRA, Manuel Alberto Jesús, *La noción de territorio-hábitat y el requisito de buena fe*, en L. L. 2012-C-338.
- MOSSET ITURRASPE, Jorge, *Compraventa inmobiliaria*, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1991.
- *Responsabilidad por daños*, Ediar, Buenos Aires, 1973, t. II-B.
- MUSTO, Néstor Jorge, *Derechos Reales*, Astrea, Buenos Aires, 2000, ts. 1 y 2.
- NEPPI, Víctor, *El condominio frente a los acreedores hipotecarios*, en L. L. 43-473.
- NICOLAU, Noemí, *Los negocios de garantía*, Trabajos del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1998.

- NISSEN, Ricardo, *Prenda de documentos y facultades del banco frente al concurso preventivo de la deudora prendaria*, en L. L. 1995-C-201.
- O'FARRELL, Miguel, *La acción de reivindicación, ¿procede en los casos de piratería de marcas?*, en E. D. del 12-5-98.
- ORCHANSKY, Benito, *Las cosas muebles. Historia de su protección*, en L. L. 139-984.
- ORGAZ, Alfredo, *Legítima defensa*, en L. L. *Responsabilidad Civil. Doctrinas Esenciales*, t. II, p. 323.
- ORMAECHEA, Carolina, en KIPER, Claudio (dir.), *Código Civil. Derechos Reales*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, t. III, comentario al art. 8º de la ley 17.801.
- OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, 1995.
- PADILLA, Rodrigo, *El régimen de los privilegios en el Proyecto de Código unificado 2012. Antecedentes jurisprudenciales de Tucumán*, en L. L. NOA 2013-355.
- PALACIO, Lino E., *Derecho Procesal Civil*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, t. VII.
- *Manual de Derecho Procesal*, 2ª ed. act., Buenos Aires, 1968, t. I.
- PANERO [h], Federico Jorge, *Análisis de la ley nacional de catastro 26.209. Consecuencias en el tráfico jurídico, inmobiliario, notarial y judicial*, en L. L. Gran Cuyo 2007-139.
- PAPANO, Ricardo, *Acción reivindicatoria y propiedad intelectual*, Astrea, Buenos Aires.
- *Aportes para una eventual reforma del régimen legal de la propiedad horizontal*, en *Revista Derecho y Cultura*, N° 1, vol. 1, Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín.
- en KIPER, Claudio (dir.), *Código Civil comentado. Derechos Reales*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. II.
- *Innecesario recurso al abuso del derecho en un caso de propiedad horizontal*, en L. L. 1990-E-235.
- *La acción del consorcio por demolición de obra nueva*, en L. L. 1991-A-485.
- *La usucapión y el dominio público en un fallo de la Corte*, en L. L. 1990-B-439.
- *Obra nueva. Exigencias para su admisibilidad en la acción y el interdicto*, en L. L. 20-2-92.

- PAPAAÑO, Ricardo y FARINA, Miryam, *¿Un nuevo caso de dominio imperfecto?*, en L. L. 2006-F-1163.
- PAPAAÑO, Ricardo y KIPER, Claudio, *Algunas cuestiones que suscita la acción reivindicatoria en los supuestos de dominio revocable y fiduciario*, en L. L. 1985-B-794.
- PAPAAÑO, Ricardo; KIPER, Claudio; DILLON, Gregorio A. y ARBIT, Saúl, *Manifestaciones actuales relativas al derecho de dominio*, de las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1987.
- PAPAAÑO, Ricardo; KIPER, Claudio M.; DILLON, Gregorio A. y CAUSSE, Jorge R., *Derechos Reales*, 2ª ed., Astrea, Buenos Aires, t. 1; t. 2; t. 3.
- PELOSI, Carlos, *La función calificadora del registrador y el artículo 1277 del Código Civil*, en *Revista del Notariado*, N° 730, p. 1447.
- *Las formas extrínsecas. Concepto, doctrina extranjera y nacional*, en *Revista del Notariado*, N° 741, p. 799.
- PEPE, Marcelo, *Las expensas comunes en el Código Civil y Comercial*, en *Revista Código Civil y Comercial*, N° 1, julio de 2015, La Ley, Buenos Aires, p. 204.
- *Prenda sobre derechos*, en L. L. 2011-C-868.
- *Transferencia del usufructo*, en L. L. 2013-E-785.
- *Usufructo de fondo de comercio*, en L. L. 2007-C-1103.
- PETTIS, Christian, *El embargo y el derecho real de usufructo*, en MJD 3411, del 10-4-2008.
- PEYRANO, Jorge y EGUREN, María, *Medidas autosatisfactivas y la necesidad de su regulación legal*, en L. L. del 28-8-2006.
- PICADO, Leandro, en KIPER, Claudio (dir.), *Propiedad horizontal*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008.
- PICADO, Leandro y LOIZA, Fabián, *La prenda de créditos como garantía autoliquidable*, en J. A. 2008-IV-982.
- PICASSO, Sebastián, *La antijuridicidad en el Proyecto de Código*, en L. L. 2013-E-666.
- PIERRE, Juan, *Reflexiones sobre un supuesto abuso de derecho (propiedad horizontal)*, en L. L. 1981-D-1171.
- PINTO, Mauricio, *La certificación de factibilidad de uso y los derechos adquiridos frente a la modificación del ordenamiento ambiental del territorio*, en L. L. Gran Cuyo 2013-953.

- PIZARRO, Ramón y VALLESPINOS, Carlos, *Obligaciones*, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 1.
- PLANIOL, Marcel, *Traité élémentaire de Droit Civil*, 2ª ed., Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1904, t. I; 1926, t. II.
- PODETTI, José R. y GUERRERO LECONTE, Víctor A., *Tratado de las ejecuciones*, 3ª ed., Ediar, Buenos Aires, 1997.
- POTHIER, *Traité de la possession*, N° 102.
- POUYSSÉGUR, Martín, *El artículo 1051 del Código Civil*, en L. L. 152-890.
- PRÓSPERI, Fernando, *Régimen legal de automotores*, La Rocca, Buenos Aires, 1997.
- PRÓSPERI, Fernando y LEWINTRE, Andrea, *Construcciones ilícitas en la propiedad horizontal (criterios para decidir su demolición o mantenimiento)*, en L. L. 1994-A-101.
- PUERTA DE CHACÓN, Alicia, *Inmueble subastado. ¿Afectación real por deudas anteriores? Cristalización de una controversia*, en J. A. del 23-6-99.
- *Nueva versión del derecho real de superficie*, en J. A. 2001-II-836.
- PUJOL DE ZIZZIAS, Irene, *El tiempo compartido en el Código Civil y Comercial*, en KIPER, Claudio (dir.) y DAGUERRE, Luis (coord.), *Aplicación notarial del Código Civil y Comercial*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. III.
- *Un interesante caso de aluvión*, en L. L. Gran Cuyo 2008-862.
- PUJOL DE ZIZZIAS, Irene y GIL DE PAOLA, Jerónimo, *Cementerios privados en el Código Civil y Comercial*, en KIPER, Claudio (dir.) y DAGUERRE, Luis (coord.), *Aplicación notarial del Código Civil y Comercial*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. III.
- PUSTERLA, José y ANTONOWICZ, Martín, *El carácter local del Derecho Administrativo en los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema*, en L. L. Supl. Adm. 2010 (julio), p. 13; L. L. 2010-D-803.
- RACCIATTI, Hernán, *Destino de las unidades en propiedad horizontal*, en L. L. 1993-C-385.
- *Ejercicio de las acciones tendientes a obtener la supresión de obras nuevas efectuadas sobre bienes comunes en propiedad horizontal*, en J. A. 28-1975, p. 330.
- *El Consejo de Administración en propiedad horizontal*, en L. L. 1976-B-27.
- *Intereses por mora en el pago de expensas comunes*, en L. L. 1995-B-577.
- *La propiedad horizontal en el proyecto de unificación de códigos de la Cámara de Diputados*, en L. L. 1994-C-825.

- RACCIATTI, Hernán, *Obras nuevas y abuso del derecho en la propiedad horizontal*, en L. L. 1994-C-483.
- *Propiedad por pisos o por departamentos*, Depalma, Buenos Aires, 1973.
- REBÓN, Horacio, *Marcas, certificados y guías*, en L. L. 1984-C-873.
- RENARD, George, *La teoría de la institución*, Recueil Sirey, 1930.
- REPUN, Alicia, *El reglamento de copropiedad y administración. La defensa del consumidor*, en D. J. del 15-7-2009, p. 1909, y L. L. Online, AR/DOC/1854/2009.
- REZZÓNICO, Luis, *Estudio de los contratos*, Depalma, Buenos Aires, 1969, t. II.
- RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, *Tratado de Derecho Civil*, t. VI, *De los derechos reales*, La Ley, Buenos Aires, 1965.
- RIVAS, Adolfo, *Caducidad de la anotación de litis*, en L. L. 2010-F-44.
- RIVERA, Julio C., *Cesión de créditos en garantía*, en L. L. 1991-C-865.
- *Instituciones de Derecho Civil*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, t. II.
- *Letras hipotecarias*, en *Revista del Notariado*, Número extraordinario, 1995.
- *Los derechos incausados*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 16, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, ps. 47 y ss.
- RIVERA, Julio C.; GIATTI, Gustavo y ALONSO, Juan, *El objeto social y la constitución de hipoteca*, en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, N° 2010-2, *Hipoteca – II*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 77 y ss.
- ROCA SASTRE, Ramón, *Derecho Hipotecario*, Bosch, Barcelona, 1954, t. I.
- *La subrogación real*, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1949, N° 385.
- ROCA SASTRE, Ramón y ROCA SASTRE MUNCUNILL, Luis, *Derecho Hipotecario*, 7ª ed., Barcelona, 1979, t. III.
- RUFFINI, Francesco, *L'actio spoli*, 1889, Cap. IV, N° 3.
- RUGGIERO, R., *Instituciones de Derecho Civil*, trad. de la 4ª ed. italiana de R. Serrano Suñer y J. Santa Cruz Teijeiro, Madrid, 1929, t. I, vol. I.
- SACRISTÁN, Estela, *Dominio originario de los recursos naturales. La cuestión del dominio eminente*, en L. L. 2014-E.
- SAGARNA, Fernando, *Derecho de retención: concepto, caracteres y condiciones para su ejercicio*, en L. L. 1994-E-529.
- *La ley 24.374 de regularización dominiat: una fuente de litigios*, en L. L. 1996-D-975.
- *Los trasplantes de órganos en el Derecho*, Depalma, Buenos Aires, 1996.

- SALAS, Acdeel; TRIGO REPRESAS, Félix y LÓPEZ MESA, Marcelo, *Código Civil anotado*, Depalma, Buenos Aires, 1999.
- SALERNO, Marcelo Urbano, *El nuevo régimen catastral*, en D. J. 2007-I-819.
- SALIS, Lino, *El derecho de superficie*, Turín, 1958.
- SALVAT, Raymundo M., *Derechos Reales*, t. I; t. III.
- *Tratado de Derecho Civil argentino. Derechos Reales*, 5ª ed. act. por Argañarás, Tea, Buenos Aires, 1961, t. I; t. II; 1959, t. III.
- *Tratado de Derecho Civil argentino. Obligaciones en general*, actualizado por Galli, t. III, N° 2103 y 2104.
- SANZ FERNÁNDEZ, Ángel, *Instituciones de Derecho Hipotecario*, Reus, Madrid, 1947, t. I; 1953, t. II.
- SAUCEDO, Ricardo, en GURFINKEL DE WENDY, Lilian, *Derechos Reales*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. I; t. II.
- en RIVERA, Julio y MEDINA, Graciela (dirs.), *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. V.
- SAUX, Edgardo, *La acción de daño temido como mecanismo preventor del perjuicio todavía no causado*, en J. A. 1994-III-705.
- SAVATIER, René, *Cours de Droit Civil*, 2ª ed., Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1947, I.
- SAVIGNY, F. C., *Sistema del Derecho Romano actual*, Góngora, Madrid, 1878, t. I.
- *Traité de la possession en Droit Romain*, 7ª ed. act. por M. A. Fr. Rudorff, trad. del alemán al francés por H. Staldler, Bruxelles, 1866.
- SCILLAMÁ y D'AVANZO, citados ambos por GATTI, Edmundo, *Las dificultades posesorias y sus causas*, en *Revista del Notariado*, N° 751, p. 73.
- SCOTTI, Edgardo, *Derecho Registral Inmobiliario. Modalidades y efecto de las observaciones registrales*, Universidad, Buenos Aires, 1980.
- SCOTTI (h), E., *Régimen jurídico de los cementerios privados*, en L. L. del 22-12-86.
- SEGOVIA, Lisandro, *El Código Civil de la República Argentina con su explicación y crítica bajo la forma de notas*, Pablo Coni, Buenos Aires, 1881, t. II.

SERVENTE, Alberto, *La hipoteca revertida: Una oportunidad financiera para los propietarios de edad mayor: Una variante previsional basada en la vivienda propia*, en L. L. 1996-B-1267.

SILVESTRE, Norma y LUBINIÉCKI, Raquel, *Regulación legal del tiempo compartido. Aspectos salientes de la nueva ley 26.356*, en J. A. 2008-II-907.

SING, José, *Calificación registral*, en *Revista del Notariado*, N° 731, ps. 1905 y ss.

SLEMENSON, H., *Un nuevo derecho real: el derecho real de superficie forestal*, en L. L. del 18-9-2002.

SMAYEVSKY, Miriam y PENNA, Marcela, *Acerca de la interrupción en materia de usucapión*, en L. L. del 18-7-2008.

SOLIGO SCHULER, Nicolás, *Naturaleza jurídica del reglamento de copropiedad y administración*, en *Revista del Notariado*, N° 895, p. 75.

SPISSO, Rodolfo, *Régimen jurídico de los cementerios y de los sepulcros*, en L. L. 1983-C-924.

SPOTA, Alberto G., *El instrumento privado sin fecha cierta como prueba en materia de medianería*, en J. A. 1954-III-373.

— *La hipoteca que grava el derecho de condominio de un copropietario*, en L. L. 12-1167.

— *Prueba de la medianería y contribución al cerramiento forzoso*, en J. A. 1956-I-154.

— *Tratado de Derecho Civil*, t. I, *Parte General*, Depalma, Buenos Aires, vol. 3.8.

— *Tratado de medianería*, 2ª ed., Editorial Jurídica, Buenos Aires, 1938.

SZMUCH, Mario, *"Discursus" sobre el régimen de vivienda y la registración de su subrogación real en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Dinámica, interpretación amplia y propuestas para su implementación*, en *Revista del Notariado*, N° 917, febrero de 2015.

SZMUCH, Mario G. y GASTALDI, J. Mariano, *Una nueva herramienta para el crédito comercial entre empresas: la hipoteca global (Fijabilidad de la hipoteca e indiferenciabilidad del monto de responsabilidad hipotecaria)*, en KIPER, Claudio (dir.) y DAGUERRE, Luis O. (coord.), *Aplicación notarial del Código Civil y Comercial de la Nación*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. III.

TANZI, Silvia y FOSSACECA, Carlos, *Derecho de retención: ¿Cómo ha sido concebido en el Código Civil y Comercial de la Nación?*, en ADLA 2015-15-115.

— *Privilegios en el Código Civil y Comercial. Su comparación con el plexo falencial*, en L. L. 2015-C-839.

TARABORRELLI, José, *Tiempo compartido. Contrato del siglo XX*, en L. L. 1992-B-1203.

TOBÍAS, José, *Derecho de las personas*, La Ley, Buenos Aires, 2009, N° 68.

TRANCHINI, Marcela, *Consideraciones sobre los conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerios privados en el Proyecto de Código Civil y Comercial 2012. ¿Nuevos derechos reales para pocos?*, en J. A., Número especial, 2012-IV-78.

— *Nuevas formas de contratación. El tiempo compartido*, en *Revista Notarial*, N° 88, 1985, p. 672.

— *Sistemas turísticos de tiempo compartido. Ley 26.356*, en L. L. 2008-C-1171.

TRANCHINI DE DIMARCO, Marcela, *Tiempo compartido (consideraciones sobre el proyecto de ley sancionado por el Senado de la Nación)*, en L. L. 1996-C-1134.

TRIGO REPRESAS, Félix, *Ejercitación judicial del derecho de retención*, en L. L. 1990-E-195.

TUMMINELLO, José Pablo, *Hipoteca inversa o del mutuo hipotecario exigible post mortem*, en L. L. del 27-11-2014.

VALDECASAS, Guillermo, *La posesión*, Comares, Granada, 1987.

VALDÉS, Horacio y ORCHANSKY, Benito, *Lecciones de derechos reales*, Lerner, Córdoba, 1969, t. I.

VALENCIA RESTREPO, Hernán, *Derecho Privado Romano*, Temis, Bogotá, 1986.

VALIENTE NOAILLES (h), Luis M., *Acción de cada propietario en el régimen de propiedad horizontal por violaciones en partes comunes*, en L. L. 118-972.

— *Del derecho de cada propietario en la ley 13.512 a oponerse al uso no autorizado en partes comunes (un caso casi verídico)*, en L. L. 124-1241.

VÁZQUEZ, Alejandro, *Derecho de retención*, Depalma, Buenos Aires, 1962, N° 143-D.

- VÁZQUEZ, Gabriela, *El régimen de los Derechos Reales, el camino de sirga y las normas locales*, en D. J. del 26-5-2010, p. 1376.
- *Orden público y servidumbre de tránsito de constitución forzosa*, en D. J. del 8-2-2012.
- *Propiedad horizontal. Cerramientos de patios solares y abuso de derecho*, en D. J. 2007-2-747.
- VENTURA, Gabriel, *Análisis de la ley nacional de catastro 26.209*, publicación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
- *El artículo 2412 del Código Civil argentino. Vélez Sársfield, Bibiloni y el Proyecto de Código unificado 2012*, en L. L. C. 2014-1061.
- *La acción reivindicatoria del adquirente por usucapión antes de la sentencia que declara su dominio*, en *Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield*, t. III, Academia Nacional de Derecho de Córdoba, Córdoba, 2000.
- *Las defensas posesorias en el Código Civil y Comercial*, en L. L. del 16-10-2015.
- VIDELA ESCALADA, Federico, *Derecho Aeronáutico*, II.
- VIGGIOLA, Lidia y MOLINA QUIROGA, Eduardo, *Régimen jurídico del automotor*, La Ley, Buenos Aires, 2002.
- VILLANUSTRE, Cecilia, *División de hecho del consorcio de propiedad horizontal (enfoque legal. Consecuencias jurídicas y prácticas)*, en L. L. 1996-B-1119.
- *El crédito por expensas comunes frente al bien de familia*, en L. L. 1996-D-48.
- *La multipropiedad en las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil*, en L. L. 1988-B-898.
- *Letras y pagarés hipotecarios. Su tratamiento en la ley 24.441. Financiamiento de la vivienda y la construcción*, en L. L. 1996-B-961.
- *Obras nuevas realizadas por un copropietario*, en L. L. 1997-D-117.
- VILLARÓ, Felipe Pedro, *Elementos de Derecho Registral Inmobiliario*, Fundación Editora Notarial, La Plata, 1980.
- *Elementos de Derecho Registral Inmobiliario*, Scotti Editora, 2003.
- VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, *Derecho Administrativo*, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1952, t. IV.
- VIVANTE, César, *Corso di Diritto Commerciale*, t. III.
- WALSH, Juan Rodrigo, *El ordenamiento territorial como presupuesto mínimo de protección ambiental*, en L. L. 2005-D-1085.
- WILLIAMS, Jorge, *Títulos de crédito*, 2ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981.

- WINDSCHEID, Bernard, *Diritto delle pandette*, trad. italiana de Fadda y Bensa, Utet, Torino, 1930, t. I.
- en *Il diritto delle pandette*, vol. V.
- WOLFF, Martin, en ENNECCERUS, KIPP y WOLFF, *Tratado de Derecho Civil. Derecho de cosas*, trad. de Puig Brutau, Bosch, Barcelona, 1957, t. III.
- *Tratado de Derecho Civil. Posesión, derecho inmobiliario y propiedad*, 2ª ed., trad. y notas de Blas Peña y González Alguer, Bosch, Barcelona, 1994, t. III, vol. I.
- YGLESIAS, Arturo, *Derecho de las cosas*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1997, t. IV, vol. I.
- ZACCAGNINI, M. y PALATIELLO, A., *Enfiteusi superficiei oneri reali*, Jovene, Napoli, 1984.
- ZAGO, Jorge, *Normas que rigen la vida consorcial. Relación correcta entre el reglamento y la norma constitucional*, en J. A. 1996-II-603.
- ZANNONI, Eduardo, *Nulidad e ineficacia de los actos jurídicos*, Astrea, Buenos Aires, 1986.
- ZANNONI, Eduardo (dir.) y KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (coord.), *Código Civil comentado, anotado y concordado*, Astrea, Buenos Aires, t. 11.
- ZELAYA, Mario, *Algunas cuestiones de legitimación activa y pasiva en los reclamos por inmisiones inmateriales*, en RCyS 2011-X-67.
- en KIPER, Claudio (dir.), *Juicio de medianería*, Hammurabi, Buenos Aires, 2009.

MNR

ÍNDICE SUMARIO

CAPÍTULO I

TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS REALES

I. Metodología del Código	9
II. El derecho real es un derecho subjetivo	10
III. Los derechos reales en la clasificación de los derechos según la oponibilidad y el contenido	10
IV. Concepto del derecho real	11
a) Distintas doctrinas	11
a.1) Doctrina clásica	11
a.2) Doctrinas unitarias	12
a.3) Teoría de la institución	14
a.4) Teoría del sujeto pasivo determinado	14
a.5) Doctrina moderna	14
b) Definición legal	16
c) Persecución y preferencia	17
V. Objeto del derecho real	17
VI. Concepto de cosa	19
a) Energía	19
b) Cuerpo humano	20
c) Cadáver y partes del cuerpo humano	21
d) El embrión	22
e) Espacio aéreo	22
VII. Enumeración de los derechos reales	22
a) <i>Numerus clausus</i>	22
b) Diferencias entre creación legal y fuente legal	25

VIII. Convalidación	25
IX. Derechos reales no incluidos por el Código Civil y Comercial	26
a) Los censos y las rentas	26
b) Enfiteusis	27
c) Vinculaciones	27
d) Tanteo y retracto	27
X. Derechos reales legislados fuera del Código Civil y Comercial	27
XI. Diferencias entre los derechos reales y los derechos personales	28
a) Objeto	28
b) Sujetos	29
c) Orden público	29
d) Inmediatez	29
e) Carácter absoluto	29
f) Publicidad	30
g) Duración	30
h) <i>Ius persequendi</i>	30
i) <i>Ius preferendi</i>	30
j) Abandono	30
k) Pérdida de la cosa	31
l) Posesión	31
m) Prescripción	31
n) Causa	31
ñ) Carácter estático	32
o) Acciones	32
p) Juez competente	32
XII. Conexiones entre los derechos reales y los personales	32
XIII. Clasificación de los derechos reales	33
a) Derechos reales sobre cosa propia o cosa ajena	33
b) Derechos reales principales y accesorios	33
c) Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables.	34
d) Ejercicio por la posesión o por actos posesorios	34
XIV. Transmisibilidad	34

XV. Modos de adquisición de los derechos reales	35
XVI. Clasificación	36
a) Adquisición derivada por actos entre vivos. El título y el modo	37
a.1) Oponibilidad a terceros	39
a.2) Formas de concretar la publicidad	39
a.3) Inscripción y publicidad	40
a.4) Naturaleza de la inscripción registral	40
a.5) Los terceros frente a la registración	40
b) Adquisición por causa de muerte	42
c) Adquisición legal	42
d) Prescripción adquisitiva	42
e) Subasta judicial	43
XVII. Modos de extinción de los derechos reales	43
a) Destrucción	43
b) Abandono	43
c) Consolidación	44
d) Otros modos	44
XVIII. Concepto de carga real	44
XIX. Obligaciones reales	45

CAPÍTULO II

RELACIONES DE PODER

(primera parte)

I. Introducción. Relaciones de hecho entre la persona y la cosa	49
II. Posesión. Concepto	50
a) Distintas teorías	50
a.1) Teoría de Savigny	50
a.2) Teoría de Ihering	51
a.3) Teoría de Saleilles	54
a.4) Consideraciones sobre las teorías de Ihering y de Saleilles	54
b) La cuestión en el Código Civil y Comercial	55
c) Cuasiposesión. Su inexistencia	56

III. Cuestiones de prueba. Presunciones	57
a) Presunción de posesión	57
b) Presunción de fecha y extensión	58
c) Inmutabilidad de la causa. Intersión	59
c.1) Principio de inmutabilidad de la causa	59
c.2) Intersión de título	60
d) Presunción de legitimidad	61
d.1) Debe ser una relación actual	62
d.2) Posesión de cosas muebles	62
e) Presunción de continuidad	63
f) Presunción de adquirir a título oneroso	63
g) Presunción de posesión y duda sobre las fechas	63
IV. Naturaleza jurídica de la posesión	64
a) Teorías que la consideran un derecho	64
b) Teorías que la consideran un hecho	64
c) La cuestión en el Código	64
V. Importancia de la posesión	65
VI. Tenencia. Concepto	66
a) Clasificación de la tenencia	67
a.1) Tenencia absoluta	67
a.2) Tenencia relativa	67
b) Deber de nombrar al poseedor	68
c) Derecho a los gastos. Retención	68
VII. Relaciones derivadas de un vínculo de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad (servidores de la posesión)	68
VIII. Yuxtaposición local	69
IX. Objeto	70
X. Exclusividad de la posesión y de la tenencia	71
XI. Coposesión o cotenencia	72
XII. Clasificación de la posesión y de la tenencia	73
a) Legítima e ilegítima	73
b) Caso del poseedor de inmueble con boleto de compraventa	74
c) Relación de buena fe	74
d) Presunción de buena fe	75

e) Determinación de buena o mala fe	76
e.1) Momento en el que se califica a la relación de poder	76
e.2) Buena fe y demanda de reivindicación triunfante	76
e.3) Percepción de frutos	76
e.4) Caso del sucesor	77
e.4.1) Sucesión universal	77
e.4.2) Sucesión particular	77
e.5) Concurrencia	78
e.6) Personas jurídicas	78
f) Relación de mala fe	78
g) Presunción de mala fe	78
g.1) Cuando el título es de nulidad manifiesta	79
g.2) Cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlas	79
g.3) Cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue registrado por otra persona	79
h) Mala fe simple o viciosa	80
h.1) Muebles	81
h.2) Inmuebles	81
h.3) Relatividad de los vicios	82

CAPÍTULO III

RELACIONES DE PODER

(segunda parte)

I. Adquisición de las relaciones de poder	83
a) Capacidad	83
a.1) Edad	84
a.2) Habilidad mental	84
b) <i>Corpus</i>	84
II. Modos de adquisición	85
III. Desapoderamiento	85
IV. Tradición	86
a) Naturaleza jurídica	87

b) Importancia de la tradición	87
c) Forma de hacer la tradición	88
c.1) Actos materiales	88
c.2) Actos posesorios	88
c.3) Relación de poder vacua	89
c.4) La mera declaración	90
d) Otras formas de tradición	91
V. <i>Traditio brevi manu y constituto posesorio</i>	91
a) <i>Traditio brevi manu</i>	91
a.1) Tenedor que pasa a ser poseedor	92
a.2) Tenedor que poseyendo una cosa a nombre de una persona, pasa a poseerla a nombre de otra	92
b) <i>Constituto posesorio</i>	93
VI. Conservación de las relaciones de poder	93
a) Principio general	93
b) Presunción de continuidad	95
VII. Extinción de las relaciones de poder	95
a) Extinción de la cosa	96
b) Privación de la cosa	96
c) Imposibilidad física de ejercer la posesión o la tenencia	97
d) Conservación de cosas perdidas	97
e) Abandono	98
f) Otros modos	98
VIII. Efectos de las relaciones de poder	98
a) Derechos inherentes a la posesión y a la tenencia	98
a.1) Servidumbres reales	99
a.2) Límites al dominio	99
b) Deberes inherentes a la posesión	100
b.1) Obligación de restituir	100
b.2) Cargas reales que afectan a la cosa	101
b.3) Medidas judiciales impuestas a la cosa	101
b.4) Límites al dominio	101
c) Adquisición de frutos o productos según la buena o mala fe	101
c.1) Concepto de frutos y productos. Diferencia	101
c.2) Clasificación de los frutos	102

c.3) Momento en el que los frutos se entienden legalmente percibidos. Importancia	103
c.3.1) Frutos naturales e industriales	103
c.3.2) Frutos civiles	104
c.3.3) Frutos pendientes	104
c.4) Buena fe y percepción de frutos	104
c.4.1) Sucesión universal	104
c.4.2) Sucesión particular	105
c.5) Restitución y adquisición de frutos	105
c.6) Cesación de la buena fe	106
c.7) Productos	106
c.8) Tenedor	106
d) Responsabilidad por destrucción de la cosa según la buena o mala fe	107
d.1) Irresponsabilidad del poseedor de buena fe por la destrucción total o parcial de la cosa	107
d.2) Excepción a la regla de la irresponsabilidad	107
d.3) Responsabilidad del poseedor de mala fe	108
d.3.1) Mala fe simple	108
e) Transmisión de obligaciones al sucesor	108
e.1) Obligaciones reales	109
e.2) Responsabilidad del deudor	109
f) Indemnización y pago de mejoras	110
f.1) Mejoras. Concepto	110
f.2) Indemnización	111
g) Efectos propios de la posesión	111
g.1) Pago de impuestos y otros deberes	112
h) Efectos propios de la tenencia	112
h.1) Deber de conservar la cosa	113
h.2) Derecho a ser indemnizado por gastos y mejoras necesarias	113
h.3) Derecho de retención	113
h.4) Deber de nombrar al poseedor	114
h.5) Deber de restitución	114

CAPÍTULO IV RÉGIMEN DE LAS COSAS MUEBLES

I. El artículo 1895 del Código Civil y Comercial. Ámbito de aplicación	115
II. Naturaleza jurídica de la adquisición	117
III. Requisitos	118
a) Posesión	118
b) Buena fe	119
b.1) Buena fe y cosas muebles registrables	120
c) Título oneroso	120
d) Cosa mueble no hurtada ni perdida	121
IV. Excepciones	122
a) Dominio público	122
b) Accesorios de un inmueble reivindicado	122
c) Cosas muebles registrables	122
d) Cosas hurtadas, perdidas o abandonadas	123
e) Muebles del hogar conyugal o convivencial	123
f) Las universalidades	124
g) Títulos valores	124
V. Reivindicación de cosas hurtadas o perdidas	124
VI. Régimen de las cosas muebles registrables	124
a) Buques	124
b) Aeronaves	125
c) Automotores	125
c.1) Marco legal	125
c.2) Efecto constitutivo de la inscripción	126
c.3) Carácter abstracto	127
c.4) Adquisición del derecho real	127
c.5) Automotor hurtado o robado	129
d) Semovientes	130
e) Equinos de pura sangre de carrera	132
VII. Prescripción	132

CAPÍTULO V DOMINIO

I. Propiedad y dominio	133
II. Filosofía del Código	135
III. Concepto	136
IV. Caracteres	136
a) Absoluto	136
a.1) Facultades jurídicas	137
a.2) Facultades materiales	138
a.3) Abuso del derecho	139
a.4) Elasticidad del dominio	140
b) Exclusivo	140
b.1) Exclusividad en la adquisición del dominio	141
b.2) Facultad de exclusión	141
b.2.1) Facultad de excluir a terceros	142
b.2.2) Derecho del dueño para remover objetos colocados en su cosa	142
b.2.3) Cerramiento	143
c) Perpetuo	143
c.1) Abandono	144
c.2) Expropiación	144
d) Dominio perfecto	145
V. Extensión	145
a) Dominio de los accesorios	145
b) Extensión material del derecho de dominio inmobiliario	146
c) Construcciones, siembras o plantaciones	147
VI. Dominio del Estado	148
VII. Dominio internacional y eminente	149

CAPÍTULO VI MODOS DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO

I. Introducción	151
-----------------------	-----

II. Apropriación.....	151
a) Cosas sin dueño y abandonadas	152
b) Caza.....	153
b.1) Introducción	153
b.2) Persecución del animal herido	154
b.3) Lugares en los que se puede cazar	155
c) Pesca	155
d) Enjambres	156
e) Cosas no susceptibles de apropiación.....	156
III. Tesoros	158
a) Concepto de tesoro	158
b) Inmueble o mueble gravado	159
c) Concepto de descubridor.....	159
d) Personas que pueden buscar tesoros	160
e) Derechos del descubridor	160
e.1) Propiedad del tesoro	160
e.2) Situación de los cónyuges	161
e.3) Persona a la que se le encomienda buscar	161
f) Búsqueda por el propietario de un tesoro	162
IV. Régimen de cosas perdidas	163
a) Introducción	163
b) Concepto de cosa perdida	163
c) Deber de avisar y restituir	164
d) Falta de individualización del sujeto con derecho a la restitución	165
e) Transmisión de la cosa a un tercero de buena fe	165
f) Derecho a la recompensa y a los gastos	165
g) Dueño que no se presenta. Subasta	166
h) Adelanto de la subasta.....	167
V. Transformación de cosas muebles	167
a) Transformación y cosa no reversible	168
b) Caso en que es posible volver al estado anterior	169
VI. Adquisición de cosas muebles.....	170
a) Adquisición	170
b) Adquisición de cosas muebles.....	170

VII. Adquisición de cosas inmuebles	172
a) Aluvión	172
a.1) El aluvión debe ser natural.....	173
a.2) Aluvión por abandono	174
a.3) Aluvión formado a lo largo de varios inmuebles.....	175
a.4) Material comprendido en los límites del río	175
b) Avulsión	175
b.1) Concepto de avulsión.....	176
b.2) No hay derecho a indemnización.....	176
b.3) Situación del dueño del inmueble acrecido	177
b.4) Cosas no susceptibles de adherencia natural	178
c) Construcción, siembra y plantación	178
c.1) Construcción, siembra o plantación hecha por un tercero	179
c.2) Invasión de inmueble colindante	180
c.2.1) Construcción en terreno ajeno de buena fe.....	181
c.2.2) Construcción en terreno ajeno de mala fe.....	182

CAPÍTULO VII

LÍMITES AL DOMINIO

I. Concepto y caracteres.....	185
a) Fundamento.....	186
b) Los límites no son servidumbres	187
c) Daño no indemnizable	187
II. Límites en interés público.....	188
a) Reservados al Derecho Administrativo	189
b) Límites a la libre disposición jurídica. Cláusulas de inenajenabilidad.....	190
b.1) Actos a título oneroso.....	191
b.2) La denominada "inhibición voluntaria".....	192
b.3) Limitaciones a la libre disposición en los actos a título gratuito	192
b.4) Casos en los que se genere una comunidad	193
b.5) Sustitución fideicomisaria	193

b.6) Vivienda	193
b.7) Tierras rurales y extranjeros	194
c) <i>Numerus clausus</i>	194
d) Camino de sirga	194
d.1) Finalidad	195
d.2) Naturaleza jurídica	195
d.3) La restricción no es indemnizable	196
d.4) Legitimación	196
e) Restricciones del Código Aeronáutico	196
f) Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico	197
III. Límites por razones de vecindad	197
a) Inmisiones inmateriales	197
a.1) La normal tolerancia	199
a.2) Otras pautas que debe valorar el juez	199
a.3) Facultades del juez	201
a.4) La legitimación	202
a.4.1) La legitimación activa del poseedor y del tenedor	202
a.4.2) La legitimación pasiva	202
a.4.3) Prescripción	202
b) Obstáculo al curso de las aguas	203
c) Recibir aguas, arenas y piedras	204
d) Obras, trabajos e instalaciones	204
e) Luces y vistas	205
e.1) Vistas	205
e.2) Requisitos	206
e.3) Luces. Concepto	206
e.4) Ámbito de aplicación	207
e.5) Condiciones para abrir luces	207
e.6) Excepción	208
e.7) Privación de luces o vistas	208
f) Plantación de árboles y arbustos	208
f.1) Límites para la plantación de árboles, arbustos u otras plantas	208
f.2) Ramas y raíces	210

CAPÍTULO VIII

DOMINIO IMPERFECTO

I. Dominio imperfecto	211
a) Concepto	211
b) Caracteres del dominio que resultan afectados	212
c) Presunción de perfección	212
II. Dominio revocable	212
a) Concepto de dominio revocable	212
b) Diferencias con el dominio fiduciario	213
c) Sujetos	214
d) Duración máxima	214
e) Publicidad	215
f) Facultades	215
g) Efecto de la revocación	216
h) Readquisición del dominio perfecto	218
III. Dominio fiduciario	219
a) Concepto	219
b) Sujetos y objeto	220
b.1) Patrimonio separado	221
c) Modos de adquisición del dominio fiduciario	221
d) Duración	221
e) Facultades del dueño fiduciario	222
e.1) Régimen de los frutos	222
e.2) Actos de disposición	222
e.3) Acciones	223
e.4) Derecho a una retribución	224
e.5) Derecho a renunciar	224
e.6) Prohibición	224
f) Extinción del dominio fiduciario	224
g) Efectos de la resolución	225
h) Posibilidad de subrogación real	226
i) Fideicomiso testamentario	226

CAPÍTULO IX PROPIEDAD INDÍGENA

I. La Constitución Nacional	229
II. El Código Civil y Comercial	232
III. La cuestión de la tierra	233
IV. Es un derecho real	234
V. El objeto de este derecho real	234
VI. Modos de constitución	235
VII. Caracteres	236
VIII. Aprovechamiento de los recursos naturales. Consulta	237

CAPÍTULO X PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA

I. Introducción	239
II. Naturaleza jurídica	240
a) Situación del inmueble	240
b) Situación de los beneficiarios	240
c) Situación del propietario constituyente	240
III. El inmueble	241
IV. El constituyente	242
a) Propietario. Copropietarios	242
b) Capacidad	242
V. Beneficiarios	242
VI. Habitación efectiva	243
VII. Formas de constitución	243
a) Solicitada por el titular registral	244
b) Dispuesta por el juez	244
VIII. Caracteres de la afectación	245
IX. Efectos de la afectación	245
a) Inejecutabilidad	245
b) Excepciones	245

b.1) Obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que graven directamente el inmueble (inc. q)	246
b.2) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad con lo previsto en el artículo 250 (inc. b)	246
b.3) Obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda (inc. c)	246
b.4) Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida (inc. d)	247
c) Las situaciones de excepción no se extienden a otros acreedores	247
d) Frutos	247
e) Cosas muebles	247
f) Límites a la enajenabilidad	248
g) Actos de administración	248
X. Subrogación real	249
XI. Desafectación	250

CAPÍTULO XI CONDominio

A) CONDOMINIO SIN INDIVISIÓN FORZOSA

I. Antecedentes históricos	253
II. Concepto	254
a) Introducción	254
b) Definición. Caracteres	255
c) Constitución	256
c.1) Prolongación de la indivisión hereditaria	256
d) Comparación con otros estados comunitarios	257
e) Clasificación	257
III. Facultades de los condóminos	258
a) Sobre la parte indivisa	258
a.1) Poder de disposición sobre la parte indivisa	258

a.2) Derechos personales	259
a.3) Acreedores. Hipoteca	259
a.4) La renuncia	260
a.5) Acciones	260
b) Sobre toda la cosa	260
b.1) Actos de disposición	260
b.2) Uso y goce	261
b.3) Convenios de uso y goce	261
b.4) Uso y goce exclusivo y excluyente	262
b.5) Mejoras	262
IV. Obligaciones de los condóminos	263
a) Gastos	263
b) Deudas en beneficio de la comunidad	263
V. Administración	264
a) Imposibilidad de uso y goce en común	264
b) Asamblea	265
c) Frutos	265
VI. Conclusión del condominio	266
a) Modos generales	266
b) Partición	266
c) Formas de hacer la partición	267
c.1) Privada o judicial	267
c.2) En especie o por venta o licitación	268
c.3) Provisional o de uso	269
c.4) Partición parcial	270
d) Efectos de la partición	270
e) Adquisición por un condómino	271

B) CONDOMINIO CON INDIVISIÓN FORZOSA TEMPORARIA

I. Introducción	271
II. Convenio de suspensión de la partición	272
a) Concepto	272
b) Plazo	272
c) Partición anticipada	273
d) Publicidad	274

III. Partición nociva	274
a) Concepto	274
b) Plazo	275
c) Partición anticipada	275
d) Publicidad	276

C) CONDOMINIO CON INDIVISIÓN FORZOSA PERDURABLE

I. Condominio sobre accesorios indispensables	276
II. Condominio sobre muros, cercos y fosos	277
a) Distintas clases de muros	278
b) Derecho y obligación de encerramiento	279
c) Muro de cerramiento forzoso	281
d) Derecho del que construye el muro	281
e) Adquisición de la medianería	282
f) Cobro de la medianería	282
f.1) Hasta los tres metros de altura	282
f.2) Mayor valor por características edilicias	283
f.3) Adquisición y cobro de los muros de elevación y enterrado	284
f.4) Legitimación	285
f.5) Medida de la obligación	286
f.6) Época en la que se determina el valor de la medianería	287
f.7) Cesión del crédito	287
f.8) Obligación <i>propter rem</i>	287
f.9) Caso de la pared próxima	288
g) Prescripción	288
g.1) Prescripción liberatoria	288
g.2) Prescripción adquisitiva	289
h) Prueba. Presunciones	289
h.1) Presunciones de medianería y de privacidad	290
h.2) Deben ser dos edificios	290
h.3) Época de las presunciones	291
h.4) Prueba	291
i) Facultades de los condóminos	292
i.1) Facultades materiales. Regla general	292

i.2) Prolongación del muro	293
i.3) Restitución del muro al estado anterior	294
i.4) Reconstrucción	294
j) Gastos y mejoras	295
k) Abdicación de la medianería	296
k.1) Concepto	296
k.2) Alcance de la abdicación	296
k.3) Efecto de la abdicación	296
k.4) Forma del abandono	297
k.5) Condiciones del abandono	297
k.6) Readquisición de la medianería	297
l) Cerramiento forzoso rural	298
m) Condominio de árboles y arbustos	298

CAPÍTULO XII

PROPIEDAD HORIZONTAL

I. Antecedentes	301
II. Concepto	302
III. Constitución	304
a) Caso de la partición en especie del condominio	305
b) Constitución por el superficiario	306
IV. Objeto	307
a) Cosas y partes propias	307
a.1) Unidad funcional	307
a.1.1) Independencia funcional	308
a.1.2) Comunicación con la vía pública	308
a.2) Unidades complementarias	309
a.3) Cosas y partes propias	309
a.4) Cocheras	310
b) Partes comunes	311
b.1) Concepto	311
b.2) Clasificación de las cosas y partes comunes	312
b.3) Enumeración de las cosas y partes necesariamente comunes	312

b.4) ¹ Enumeración de las cosas y partes comunes no indispensables	313
b.5) ¿Conversión?	314
b.6) Uso exclusivo	315
b.7) Presunción de comunidad	316
c) Bienes del consorcio	316
V. Consorcio	316
a) Nombre y domicilio	317
b) Patrimonio	317
c) Capacidad	318
d) Capacidad para adquirir unidades	318
e) Concurso o quiebra	319
f) Extinción	319
g) Responsabilidad por las deudas del consorcio	319
h) Consorcio de hecho	320
VI. Facultades de los propietarios	320
a) Facultades jurídicas	320
b) Facultades materiales	321
b.1) Sobre la unidad funcional	321
b.2) Sobre cosas y partes comunes	322
c) Modificaciones en partes comunes	322
c.1) Principio	322
c.2) Mejoras u obras nuevas que requieren unanimidad	323
c.3) Acción judicial	324
c.3.1) Supuestos que autorizan el reclamo	325
c.3.2) Caducidad	326
c.3.3) Medida cautelar	326
c.3.4) Sentencia	327
c.4) Obras realizadas sin autorización	327
d) Reparaciones urgentes	328
e) Grave deterioro o destrucción del edificio	329
VII. Obligaciones	330
a) Conservar en buen estado la unidad	331
b) El fondo de reserva	331

VIII. Gastos	332
a) Concepto	332
b) Medida de la contribución	334
c) Defensas	335
c.1) No hay liberación del propietario por no uso, enajenación o abandono	335
c.2) Deudas devengadas antes de la adquisición.	336
c.3) Situación de los adquirentes.	337
c.4) Compensación	338
c.5) Prescripción	339
d) Obligados al pago de gastos	339
e) Procedimiento para perseguir su cobro.	340
f) Privilegio.	340
g) Intereses	340
IX. Prohibiciones	341
a) Respetar el destino	341
b) Moral y buenas costumbres	342
c) Tranquilidad	342
d) Tenencia de animales	342
e) Depositar cosas peligrosas o perjudiciales	343
X. Procedimiento para el cese de infracciones	343
a) Ámbito	343
b) Legitimación activa	344
c) Legitimación pasiva	345
d) Procedimiento	345
e) Prescripción liberatoria	346
XI. Reglamento	346
a) Concepto	346
b) Naturaleza	347
c) Contenido	347
d) Modificación del reglamento	349
e) Modificación judicial	350
f) Reglamento interno	351
XII. Asambleas	351
a) Concepto y facultades de la asamblea	351

a.1) Cuestiones atribuidas por la ley o el reglamento	353
a.2) Cuestiones que someta el administrador, el consejo, o por quien o quienes representan más del 5%	353
a.3) Designación y remoción del personal de consorcio.	353
b) Clases de asambleas	353
c) Legitimados para participar	354
d) Convocatoria	354
d.1) Concepto y forma	354
d.2) Orden del día	355
d.3) Autoconvocatoria	356
d.4) Decisiones tomadas sin reunión	356
e) Quórum y mayorías	357
f) Actas	358
g) Nulidad de la asamblea. Caducidad	359
h) Asamblea judicial	360
XIII. Consejo de propietarios	360
XIV. Administrador	362
a) Designación, remoción, duración	362
b) Derechos y obligaciones	363
c) Representación en juicio	365
d) Responsabilidad de los administradores	366
XV. Subconsorcios	367
XVI. Prehorizontalidad	368

CAPÍTULO XIII CONJUNTOS INMOBILIARIOS

I. Introducción	371
II. Concepto y caracteres	374
a) Concepto	374
a.1) Variantes	375
b) Caracteres	375
III. Marco legal. Derechos reales	376
a) Orden público	376

b) Situación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes	377
c) Normas administrativas	378
d) Localización y límites perimetrales	378
e) El uso de las calles públicas	379
f) Objeto del derecho real	379
IV. Cosas y partes necesariamente comunes	379
a) Servidumbres y otros derechos reales	380
b) Uso y goce de las cosas y partes comunes	381
c) Régimen de invitados	381
V. Cosas y partes privativas	382
VI. Facultades y obligaciones del propietario	383
a) Facultades	383
a.1) Transmisión del derecho	383
a.2) Cesión del uso y goce de la unidad	384
a.3) Otros derechos reales	385
b) Obligaciones	385
b.1) Gastos	386
c) Limitaciones y restricciones reglamentarias	387
d) Sanciones	387
VII. Protección al consumidor	388

CAPÍTULO XIV

TIEMPO COMPARTIDO

I. Situación anterior a la sanción de la ley 26.356	389
a) El régimen del Código Civil derogado	389
b) Denominación	390
c) La figura en el campo de los derechos personales	390
d) La figura en el campo de los derechos reales	391
II. La sanción de la ley 26.356	392
a) El decreto 760/2014	394
III. El Código Civil y Comercial	394
a) Concepto	395
b) Bienes que lo integran	397

c) Afectación	397
d) Legitimados para afectar	399
e) Los bienes	400
f) Inscripción de la afectación y sus efectos	400
f.1) Inscripción	401
f.2) Efectos	402
f.3) Períodos no enajenados	403
f.4) Registro de titulares	403
f.5) Oponibilidad de los derechos de los usuarios del tiempo compartido	403
g) Sujetos	403
h) Deberes del emprendedor	405
i) Deberes de los usuarios del tiempo compartido	406
j) El administrador	407
j.1) Designación	407
j.2) Deberes del administrador	408
k) Cobro ejecutivo	409
l) Extinción	410
m) Relación de consumo	410
n) Derecho real del adquirente de tiempo compartido	411
ñ) Situación de los derechos constituidos antes de la sanción del Código	413
o) Normas de policía	414

CAPÍTULO XV

CEMENTERIOS PRIVADOS

A) CEMENTERIOS PÚBLICOS

I. Introducción	415
II. Prescripción	417
III. Los sepulcros son inembargables	417
IV. Acción de partición	418
V. No hay inscripción registral	418

B) CEMENTERIOS PRIVADOS

I. Concepto	418
II. Naturaleza jurídica	420
III. Caracteres del derecho real de sepultura	420
a) ¿Derecho sobre cosa propia?	420
b) Otros caracteres	421
IV. Afectación	423
a) Legitimados	424
b) Forma	424
c) Oponibilidad de la afectación	424
d) Prohibición de cambiar el destino	424
V. Facultades del titular del derecho de sepultura	424
a) Facultades materiales	425
b) Facultades jurídicas	425
VI. Deberes del titular del derecho de sepultura	426
VII. Administración	427
VIII. Reglamento de administración y uso	428
IX. Registros de inhumaciones y sepulturas	429
X. Las parcelas son inembargables	430
XI. Relación de consumo	431
XII. Normas de policía mortuoria	431

CAPÍTULO XVI

EL DERECHO REAL DE SUPERFICIE

I. Antecedentes	433
II. Objetivos de la ley 25.509	434
III. El Código Civil y Comercial de la Nación	435
a) Introducción	435
b) Concepto. Naturaleza jurídica	435
c) Objeto	437
d) Caracteres	438
e) Legitimados	438

f) Duración	439
g) Dominio imperfecto del constituyente	439
IV. Modos de adquirir el derecho. Aspectos registrales	440
a) Contrato	440
b) Prescripción corta	442
c) Actos de última voluntad	443
d) Otros modos	443
V. Facultades materiales del superficiario sobre el inmueble ajeno. Uso y goce	443
VI. Facultades jurídicas del superficiario	444
a) Derechos de garantía	445
b) Derechos de disfrute	446
c) Propiedad horizontal	446
d) Efectos de los actos de disposición	447
e) Turbación por parte del propietario	449
f) Derechos personales	449
VII. Facultades del dueño del suelo	449
VIII. La hipoteca inscrita anterior al derecho de superficie	450
IX. Defensas	450
X. Obligaciones a cargo del superficiario. Pacto comisorio y cumplimiento de la condición resolutoria como causal de extinción	451
XI. Destrucción de la propiedad superficiaria	451
XII. Extinción del derecho real de superficie forestal	451
a) Renuncia expresa	452
b) Vencimiento del plazo contractual	452
c) Cumplimiento de una condición resolutoria	452
d) Consolidación	452
e) No uso	452
f) Desuso y abandono: ¿son causales de extinción autónomas?	453
g) Otras causas no mencionadas	453
XIII. Efectos de la extinción	454
a) En general	454
b) Indemnización	454

c) Derechos reales y personales constituidos	455
d) Obligaciones del superficiario	455
e) Consolidación	455
XIV. Normas aplicables al derecho de superficie y a la propiedad superficiaria	456

CAPÍTULO XVII

USUFRUCTO. USO. HABITACIÓN

A) USUFRUCTO

I. Derechos de disfrute sobre cosa ajena	457
II. Concepto de usufructo	458
a) Es un derecho real.	459
b) Sobre cosa ajena	459
c) Facultad de usar, gozar y disponer	459
d) No alterar la sustancia.	459
e) Es un derecho temporario	460
f) Divisible	460
III. Objeto	460
a) Cosa mueble o inmueble.	461
b) Derecho	461
c) Cosa fungible. Cuasiusufructo	462
d) Usufructo universal.	462
IV. Legitimados para constituir usufructo	463
V. Usufructo a favor de varias personas	463
a) Causufructo. Derecho de acrecer	463
b) Prohibición de usufructos sucesivos	464
VI. Modos de constitución	464
a) Usucapión	465
b) Prohibición de constitución judicial	465
VII. Presunción de onerosidad	465
VIII. Duración	466
IX. Modalidades	466

X. Derechos del usufructuario	467
a) Frutos. Productos. Acrecentamientos naturales	467
a.1) Frutos percibidos	467
a.2) Conjunto de animales	467
a.3) Productos	468
a.4) Acrecentamientos	468
a.5) Tesoros	468
b) Mejoras facultativas	468
c) Derechos reales y personales	469
c.1) Transmisión del usufructo	469
c.2) Constitución de otros derechos	470
d) Ejecución por acreedores	471
e) Prescripción adquisitiva en favor de un tercero	472
f) Acciones	472
g) Derecho de retención	472
h) Inventario y estado	473
XI. Obligaciones del usufructuario	474
a) No alterar la sustancia. Destino	474
b) Mejoras	475
c) Impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes	476
d) Comunicación al nudo propietario	476
e) Restitución	477
f) Inventario	477
g) Garantía	477
XII. Derechos del nudo propietario	478
a) Actos de disposición	478
b) Otros derechos	479
XIII. Deberes del nudo propietario	479
a) Entregar el objeto	479
b) Mejoras	480
c) Obligación de saneamiento	480
XIV. Extinción del usufructo	480
a) Modos generales de extinción	480

b) Medios especiales de extinción	481
b.1) Vencimiento del plazo. Cumplimiento de la condición	481
b.2) Muerte	482
b.3) Extinción de la persona jurídica	482
b.4) No uso	483
b.5) Uso abusivo. Alteración de la sustancia	483
b.6) Resolución de los derechos del constituyente	483
b.7) Resolución y revocación	483
b.8) Legado	484
c) Efectos de la extinción	484

B) USO

I. Concepto	484
II. Objeto	485
III. Régimen legal. Normas supletorias	485
IV. Facultades del usuario	486
a) Limitaciones al uso y goce	486
b) Limitaciones a la facultad de disponer	486
c) Derechos personales	487
V. Ejecución por acreedores	487

C) HABITACIÓN

I. Concepto	487
II. Caracteres	487
III. Régimen legal	488
IV. Objeto	488
V. Impuestos, contribuciones y reparaciones	489
VI. Derecho real de habitación del cónyuge o conviviente supérstite	489
a) Cónyuge supérstite	489
b) Requisitos	490
b.1) Inmueble de propiedad del causante	490
b.2) No tener atribución preferencial	490
b.3) Último hogar conyugal	490

c) Caracteres	490
c.1) Vitalicio y gratuito	490
c.2) Oponibilidad	490
d) Extinción	491
e) Situación del conviviente supérstite	491

CAPÍTULO XVIII

SERVIDUMBRE

I. Introducción	493
II. Concepto y caracteres	494
a) Derecho real	494
b) Duración	494
c) Se requieren dos inmuebles	494
d) Ubicación de los inmuebles	495
e) Otros caracteres	496
f) Contenido	496
g) Principio de la "atipicidad" de las servidumbres	497
h) Inseparabilidad. Inherencia de la servidumbre al fundo dominante y al fundo sirviente	498
i) Indivisibilidad	498
j) Servidumbre administrativa	499
III. Objeto	500
IV. Clasificación	500
a) Positiva y negativa	500
b) Real y personal	501
b.1) Servidumbre real	501
b.2) Servidumbre personal	501
b.3) Presunciones	502
b.4) Servidumbre personal a favor de varios titulares	502
c) Voluntaria o forzosa	503
c.1) Servidumbres forzosas	504
c.2) Servidumbre de tránsito	504
c.3) Servidumbre de acueducto	505
c.4) Servidumbre de recibir agua	506

d) Activa y pasiva	506
e) Continua y discontinua	506
f) Aparente y no aparente	507
g) Perpetua o temporaria	507
V. Legitimación	507
a) Legitimados para constituir una servidumbre	507
b) Modos de constitución	508
b.1) Prescripción	508
b.2) Testamento	509
c) Prohibición de servidumbre judicial	509
d) Presunción de onerosidad	509
VI. Modalidades	510
VII. Transmisibilidad	510
VIII. Derechos y obligaciones del titular dominante	510
a) Constitución de derechos personales	510
b) Extensión de la servidumbre	511
c) Ejercicio de la servidumbre	512
d) Mejoras necesarias	512
e) Trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbre	513
e.1) Obligación de no menoscabar la servidumbre	513
e.2) Sanción en caso de incumplimiento	514
f) Ejecución por acreedores	514
g) Comunicación al sirviente	514
IX. Derechos del titular sirviente	515
a) Disposición jurídica y material	515
b) Defensas que puede oponer el titular dominante	515
c) Suerte de los derechos reales constituidos	516
d) Alcances de la constitución y del ejercicio	516
d.1) El ejercicio de la servidumbre debe efectuarse del modo menos perjudicial para quien la debe soportar	516
d.2) Facultad del titular sirviente	517
X. Extinción	517
a) Medios generales	517
a.1) Renuncia o abandono	517

a.2) Destrucción de la cosa	518
a.3) Consolidación	518
b) Medios especiales de extinción	519
b.1) Extinción por falta de utilidad	519
b.2) Extinción por el no uso	519
b.3) Vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición	520
c) Efectos de la extinción	520

CAPÍTULO XIX

DERECHOS REALES DE GARANTÍA

(primera parte)

I. Introducción	521
a) Garantías	521
b) Finalidad de las garantías	522
c) Derechos reales de garantía	523
d) Derechos reales de garantía legislados fuera del Código Civil y Comercial	524
II. Convencionalidad	524
a) Diferencias entre causa fuente y convención	525
b) Derechos reales de garantía tácitos o legales	525
c) La hipoteca unilateral en la Ley de Obligaciones Negociables	526
d) No son susceptibles de prescripción adquisitiva	527
III. Accesoriedad	527
IV. Créditos garantizables	529
a) Crédito sujeto a condición suspensiva	529
b) Crédito sujeto a condición resolutoria	529
c) Plazo suspensivo	530
d) Plazo resolutorio	530
e) Crédito eventual	530
V. Especialidad	531
a) En cuanto al objeto	531

b) En cuanto al crédito	532
b.1) Tope máximo	533
b.2) Créditos indeterminados	534
b.3) Límite en el tiempo	536
b.4) Título ejecutivo	537
c) Cláusulas de ajuste	537
d) Contratos en moneda extranjera	538
e) Defectos en la especialidad	539
VI. Indivisibilidad	539
a) La indivisibilidad es un carácter natural	540
b) Consecuencias en cuanto al crédito	540
b.1) Lado activo	540
b.2) Lado pasivo	540
c) Consecuencias en cuanto al objeto	540
c.1) Lado activo	540
c.2) Lado pasivo	541
d) Excepciones a la indivisibilidad de la hipoteca	542
d.1) Acuerdo de partes	542
d.2) Decisión judicial	542
VII. Extensión en cuanto al objeto	543
a) Extensión de la garantía	543
a.1) Accesorios físicamente unidos	543
a.2) Mejoras sobrevinientes	544
a.3) Rentas debidas	544
a.4) Extinción de cargas	545
a.5) Frutos	545
b) Casos en los que no se extiende la garantía	545
b.1) Accesión moral	545
b.2) Bienes gravados con prenda o que pertenezcan a terceros	546
b.3) Minas o yacimientos	546
VIII. Extensión en cuanto al crédito	547
IX. Subrogación real	548
a) Seguro por siniestro	549

b) Seguro de vida	549
c) Expropiación	549
X. Facultades del constituyente	550
a) Actos que puede realizar	550
b) Límite	550
c) Caso del arrendamiento	551
d) Medidas en caso de alteración de la garantía	551
e) Inoponibilidad	552
f) Realización por un tercero	552
XI. Cláusula nula	553
XII. Responsabilidad del propietario no deudor	554
a) Diferencias entre constituyente no deudor y tercero adquirente	555
b) Cosa no registrable prendada	555
c) Ejecución contra el propietario no deudor	555
c.1) Previo reclamo al deudor	556
c.2) Defensas	556
c.3) Pago	557
c.4) Pedir que se cite a otros propietarios	557
c.5) Subrogación	558
c.6) Indemnización	558
c.7) Derecho al remanente	559
c.8) Prorratio de saldos en caso de haber otros acreedores	559
c.9) Requerir garantías	560
XIII. Rango de los derechos reales de garantía	560
XIV. Extinción. Subasta	561
a) Extinción de los derechos reales de garantía	561
b) Efectos de la subasta	562
XV. Cancelación	562
a) Cancelación voluntaria	563
b) Cancelación judicial	564
c) Cancelación automática	564

CAPÍTULO XX
DERECHOS REALES DE GARANTÍA
(segunda parte)

A) HIPOTECA

I. La hipoteca en el Derecho Romano	567
II. Concepto	568
a) Naturaleza jurídica de la hipoteca: Derecho real	569
b) Se constituye por contrato	569
III. Caracteres	569
IV. Legitimación	570
a) Dueño	570
b) Condominio	570
c) Propiedad horizontal	570
d) Conjuntos inmobiliarios	571
e) Superficie	571
f) Tiempo compartido y cementerios	571
g) Usufructuario	571
V. Hipoteca de parte indivisa	572
VI. Forma del contrato constitutivo	573
a) Promesa de hipoteca	573
b) Excepciones	573
c) Aceptación del acreedor	574
VII. Determinación del objeto	574
VIII. La denominada hipoteca revertida	575
IX. Duración de la inscripción	575
X. Extinción de la hipoteca	576
a) Por vía de consecuencia	576
b) Por vía principal	576
XI. Ejecución. Convenciones	577
XII. Letras hipotecarias	578

B) ANTICRESIS

I. Concepto. Definición legal	581
-------------------------------------	-----

a) Antecedentes históricos	581
b) Definición legal	581
c) Objeto	583
d) Posesión	584
II. Legitimación	584
III. Plazo máximo	584
IV. Derechos del acreedor	585
a) Uso y goce	585
b) Derecho a arrendar la cosa	585
c) Derecho a ejecutar	585
d) Privilegio	586
V. Deberes del acreedor	586
a) Conservar la cosa	586
b) No alterar el destino	587
c) Rendir cuentas al deudor	587
d) Responsabilidad	587
e) Pago de contribuciones y cargas	587
f) Restituir la cosa	588
VI. Gastos	588
a) Mejoras necesarias	588
b) Mejoras útiles	588
VII. Duración de la inscripción	589

CAPÍTULO XXI
DERECHOS REALES DE GARANTÍA
(tercera parte)

C) PRENDA

I. Disposiciones generales	591
a) Concepto	591
b) Legitimación	592
c) Objeto	592
c.1) Cosas muebles	592

c.2) Casos controvertidos	593
c.3) Créditos	593
d) Constitución. Requisitos	593
e) Contenido del contrato	594
f) Oponibilidad	594
g) Importancia de la posesión	594
g.1) Posesión de un tercero	595
g.2) Pérdida, sustracción o entrega de la cosa	595
g.3) Restitución voluntaria de la cosa	595
g.4) Interrupción de la prescripción	596
h) Prendas sucesivas	596
i) Rango de los acreedores	597
j) Derechos y deberes del acreedor	598
k) Extinción del derecho real de prenda	598
k.1) Por vía indirecta	598
k.2) Por vía directa	599
k.3) Efectos de la extinción	599
II. Prenda con registro	599
III. Prenda de cosas	601
a) Prenda de cosa ajena	601
b) Frutos. Prenda anticrética	602
c) Uso y abuso	602
d) Gastos	603
e) Venta del bien empeñado	604
e.1) Venta pedida por otro acreedor	604
e.2) Restitución de la cosa	604
f) Ejecución	605
f.1) Ejecución judicial	605
f.2) Venta de títulos	605
f.3) Otras opciones	606
f.4) Adjudicación al acreedor	606
f.5) Carácter optativo de las alternativas	607
f.6) Adquisición del acreedor	608
f.7) Rendición de cuentas	608
g) Documentos con derecho incorporado. Títulos valores	608

IV. Prenda de créditos	610
a) Créditos instrumentados	610
a.1) Concurso del deudor	611
a.2) Aplicación supletoria	611
b) Constitución	611
b.1) Notificación	612
b.2) Sujetos	612
b.3) Lugar de la notificación	612
c) Conservación y cobranza	612
c.1) Prestación dineraria	613
c.2) Prestación no dineraria	613
c.3) Opción o declaración de las partes	614
d) Participación en contrato con prestaciones recíprocas	614
e) Extinción de la prenda pero no del crédito	614

CAPÍTULO XXII

DEFENSAS DE LA POSESIÓN Y DE LA TENENCIA. ACCIONES POSESORIAS

I. La protección posesoria en general	617
a) Antecedentes históricos	618
b) Fundamentos	620
c) Concepto y finalidad	621
d) Concepto de turbación	621
d.1) "Actos materiales"	622
d.2) "Producidos o de inminente producción"	622
d.3) "Ejecutados con intención de tomar la posesión"	622
d.4) "Contra la voluntad del poseedor o tenedor"	623
d.5) "De los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor"	623
d.6) Total o parcial	624
e) Concepto de desapoderamiento	624
f) Variante. Realización de una obra	624
f.1) Obra nueva como despojo	625
f.2) Obra nueva como turbación	626

g) Acción de daños y perjuicios	626
h) Prescripción	626
i) Objeto	626
II. Defensas en el Derecho positivo	627
a) El Código Civil y Comercial	627
b) El Código Procesal	627
c) El Código Penal	627
III. Las vías legales para adquirir la posesión	628
a) El artículo 2239	628
a.1) Prohibición de la justicia por mano propia	628
a.2) Derecho a la posesión, derecho de poseer y derechos derivados de la posesión	628
a.3) El título válido	629
b) El interdicto de adquirir	630
IV. Naturaleza jurídica de las acciones posesorias	630
V. Defensa extrajudicial	631
a) Legitimación activa	631
b) Legitimación pasiva	631
c) Tipo de ataque	632
d) Casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde	632
e) No debe mediar intervalo de tiempo entre el ataque y la defensa	632
f) No se deben exceder los límites de la propia defensa	633
g) Inexistencia de responsabilidad	633
h) Incumplimiento de los requisitos	633
VI. Acción de despojo	633
a) Legitimación activa	634
a.1) Coposesión	635
a.1.1) Demanda contra un tercero	635
a.1.2) Demanda contra otro coposeedor	635
a.2) Tenedor	636
b) Legitimación pasiva	636
c) Sentencia	637
d) Interdicto de recobrar	638

VII. Acción posesoria de mantener	638
a) Legitimación activa	638
b) Legitimación pasiva	639
c) Requisitos	639
d) Sentencia	639
e) Prescripción	640
f) Interdicto de mantener	640
g) Interdicto de obra nueva	640
VIII. Procedimiento judicial	641
a) Trámite	641
b) Prueba	641
b.1) Caso de duda	642
c) Conversión	643
d) Efectos de la sentencia	643
IX. Daño temido	644

CAPÍTULO XXIII ACCIONES REALES

A) DISPOSICIONES GENERALES

I. Concepto	645
a) Método del Código	647
b) Imprescriptibilidad	647
II. Enumeración	648
a) Enumeradas en el capítulo dedicado a las acciones reales	648
b) ¿Otras acciones reales?	648
III. Finalidad de las acciones reales. Ámbito. Lesión que las habilita	648
a) Acción reivindicatoria	649
a.1) Ámbito	649
b) Acción negatoria. Concepto	650
b.1) Ámbito	650
b.2) Su ejercicio por el acreedor hipotecario	651

b.3) El <i>iura novit curia</i> y la acción negatoria	651
b.4) Derechos reales sobre cosas muebles	651
c) Acción confesoria. Ámbito	651
IV. Demanda y sentencia	652
V. Daño	652
VI. Legitimación activa	653
a) Titulares de derechos reales	653
b) Cesionario	654
c) Comprador al que no se le hizo la tradición	654
d) Reivindicación por quien adquirió el derecho real por usucapión	655
e) Acreedor hipotecario	655
f) Heredero	655
g) Legatario	655
h) Cotitulares. Cosa juzgada	656
h.1) Contra otro cotitular	656
h.2) Contra un tercero	656
h.3) Coacreedores hipotecarios	657
h.4) Cosa juzgada	657

B) ACCIÓN REIVINDICATORIA

I. Objeto	658
a) Cosas	658
b) Universalidades	658
b.1) Universalidad de derecho	658
b.2) Universalidad de hecho	659
c) Objetos no reivindicables	659
c.1) Objetos inmateriales	659
c.2) Cosas indeterminables o fungibles	660
c.3) Cosas futuras	660
c.4) Accesorios	660
c.5) Título valor	661
II. Legitimación pasiva	661
a) Poseedor	661
b) Tenedor	661

b.1) Tenedor que posee a nombre de un tercero	662
b.2) Tenedor que posee a nombre del reivindicante	662
b.3) Demandado que deja de poseer	663
c) Reivindicación de automotor hurtado o robado	663
III. Prueba en el juicio de reivindicación	664
IV. Prueba cuando se reivindican inmuebles	664
a) Ambos títulos emanan del mismo autor	665
b) Los títulos emanan de distintos autores	666
c) El demandado no presenta título	667
d) Importancia de la fecha del título	667
e) Usucapión	668
V. Prueba en la reivindicación de muebles registrables	669
a) Demandado de mala fe	669
b) Prueba	670
c) Autor común	670
d) Autores distintos	671
VI. Prueba en la reivindicación de muebles no registrables	671
a) Ámbito de aplicación	671
b) Antecesor común	672
c) Antecesores distintos	672
d) Otras pruebas	672
e) Acreedor frustrado	672
VII. Derecho a reembolso	673
a) Reivindicación de cosas no registrables robadas o perdidas y reembolso al demandado	673
b) Supuestos en los que procede el reembolso	674
c) Contenido del reembolso	674
d) Situación del que vende la cosa robada o perdida junto a otras semejantes	674
e) Sucesor de quien tiene derecho al reembolso	675
f) Cosas muebles registrables	675
VIII. Límites de la acción reivindicatoria respecto de cosas muebles no registrables	676
a) Reclamo del saldo insoluto	676

b) Exclusión de las cosas hurtadas, robadas o perdidas	677
c) Otros casos de reivindicación	677
d) Muebles de la vivienda familiar	677
e) Títulos valores	677
IX. Límites en materia de cosas registrables	678
a) El principio	678
b) Efectos respecto de terceros en cosas registrables	679
b.1) El tercero debe adquirir de quien está legitimado para transmitir de acuerdo a los asientos registrales.	679
b.2) El tercero debe desconocer la inexactitud del Registro	680
b.3) El tercero debe actuar con diligencia (estudio de títulos)	680
b.4) Cosas muebles registrables	682
c) Los actos <i>a non domino</i>	682
d) Reivindicación contra el adquirente en virtud del acto nulo	683
X. Medidas cautelares	684
a) Medidas preliminares	684
b) Medidas precautorias	684
XI. Sentencia	685

C) ACCIÓN NEGATORIA

I. Concepto	685
II. Legitimación pasiva	685
III. Objeto	686
IV. Prueba	686

D) ACCIÓN CONFESORIA

I. Concepto	687
II. Legitimación pasiva	687
III. Prueba	688

E) ACCIÓN DE DESLINDE

I. Concepto. Naturaleza jurídica	689
a) Incertidumbre sobre el límite	689

b) Presupuestos para el ejercicio de la acción de deslinde	690
c) Imprescriptibilidad	690
II. Legitimación activa y pasiva	690
a) Legitimación activa	690
b) Legitimación pasiva	691
c) La acción de deslinde contra el Estado. Distintos supuestos.	691
d) Deslinde contractual	691
III. Prueba y sentencia	691
a) La carga de la prueba	692
b) Deslinde judicial	692
c) Facultades del juez	692

F) RELACIONES ENTRE EL PETITORIO Y EL POSESORIO

I. Prohibición de acumular	693
II. Separación entre el posesorio y el petitorio. Independencia de las acciones	693
III. Prueba	693
IV. Suspensión de la acción real	694
V. Cumplimiento previo de condenas	694
VI. Acciones por un mismo hecho	695
a) Opción entre acciones posesorias y acciones reales	695
b) Opción por la acción posesoria	695
c) Opción por la acción petitoria	696
d) Inconstitucionalidad del artículo 623 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	696
VII. Acciones por distintos hechos	697
a) Situación del actor que optó por el petitorio.	697
b) Situación del demandado en el petitorio.	697
VIII. Turbaciones o desapoderamientos recíprocos	698
IX. Hechos posteriores	698

CAPÍTULO XXIV
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

I. Antecedentes históricos	699
II. Introducción	700
III. Concepto. Fundamentos	700
IV. Diferencia con la prescripción liberatoria	702
a) Distintas posturas	702
b) Metodología del Código Civil y Comercial	702
c) Balance	703
V. Modo originario	704
VI. Elementos	705
a) La posesión	705
a.1) El <i>animus</i> . Alcances	706
a.2) Posesión ostensible	706
a.3) Posesión continua	707
a.4) Posesión ininterrumpida	707
b) El tiempo	708
b.1) Plazos	708
b.2) Inicio del cómputo	708
b.3) Cómputo del tiempo	709
c) Unión de posesiones	709
c.1) Caso de sucesión universal	710
c.2) Sucesión particular. Unión de posesiones	710
c.3) Requisitos de la unión de posesiones	711
VII. Sujetos	711
a) ¿Quiénes pueden invocar la prescripción?	712
a.1) Las personas humanas	712
a.2) Las personas jurídicas	712
a.3) El Estado	712
a.4) La Iglesia	713
b) ¿Contra quiénes se puede prescribir?	713
b.1) Las personas humanas	713
b.2) Las personas jurídicas	714
b.3) El Estado	714
b.4) La Iglesia	714

VIII. Objeto	715
a) Partes comunes en propiedad horizontal	715
b) Partes de una cosa	716
c) El caso de las islas	716
IX. Renuncia	717
X. Suspensión	718
a) Concepto. Efectos	718
b) ¿Quiénes pueden invocar la suspensión?	719
c) Interpelación fehaciente	720
d) Mediación	720
e) Menores y demás incapaces	721
f) Matrimonio	722
g) Unión convivencial	723
h) Cosas comprendidas en una sucesión	723
i) Padres, tutores y curadores	723
j) Administradores	724
XI. Dispensa	724
XII. Interrupción	725
a) Interrupción por petición judicial contra el poseedor	726
a.1) Recaudos para la procedencia	726
a.2) Efectos	728
a.3) Supuestos en los que cesan los efectos de la interrupción	729
a.4) No es necesaria la notificación de la demanda interruptiva	730
a.5) Demanda presentada en las dos primeras horas del primer día hábil subsiguiente al vencimiento del término de prescripción	730
b) Interrupción por reconocimiento	730
c) Interrupción por solicitud de arbitraje	731
d) Alcance subjetivo	731
XIII. Prescripción breve	732
a) Justo título	732
b) Buena fe	734
c) Tiempo	734

d) Situación del sucesor singular del adquirente con justo título.....	735
e) Situación del subadquirente de cosa mueble con título gratuito.....	735
f) Formas de hacer valer la prescripción breve.....	736
g) Efectos de la sentencia.....	736
h) Derechos reales susceptibles de prescripción breve.....	736
XIV. Prescripción larga.....	737
a) Requisitos.....	737
b) Caso especial para cosas muebles registrables no inscriptas.....	738
c) Vías procesales para hacer valer la prescripción.....	739
c.1) Por vía de excepción.....	739
c.2) Oportunidad procesal para oponerla.....	740
c.3) Por vía de acción.....	741
c.4) Medida cautelar.....	741
d) Ley 14.159.....	742
d.1) Requisitos generales de la demanda.....	742
d.2) Prueba.....	743
e) Efectos de la sentencia.....	744
e.1) Efectos de la sentencia respecto de los derechos reales constituidos por el anterior propietario.....	745
e.2) Efectos respecto de los frutos.....	746
f) Efectos del fallo cuando la prescripción se hizo valer por vía de excepción.....	747
g) La prescripción y los derechos reales de disfrute.....	748
h) La prescripción como freno a la acción de reducción.....	749
XV. La ley de regularización del dominio.....	749
a) Objetivo de la ley.....	749
b) Beneficiarios.....	751
c) El procedimiento para acogerse a los beneficios de la ley 24.374.....	752
d) Efectos de la inscripción.....	753

PUBLICIDAD REGISTRAL INMOBILIARIA

I. Introducción.....	755
II. Distintos sistemas.....	756
a) De la transcripción.....	756
b) De los libros territoriales.....	756
c) Sistema Torrens.....	756
d) Sistema alemán.....	757
e) Sistema francés.....	757
f) España.....	758
g) Otras clasificaciones.....	758
III. Sistema actual.....	759
a) Registro de documentos.....	760
b) No convalidante.....	761
c) Otras características.....	761
d) El folio real.....	762
e) Inscripción facultativa.....	762
f) Formas de publicidad.....	762
IV. Principios registrales.....	763
a) Rogación.....	763
b) Principio de especialidad.....	764
b.1) Matriculación.....	765
b.2) Especialidad del objeto.....	765
b.3) Especialidad de los sujetos.....	766
b.4) Especialidad del título causal.....	766
c) Principio de legalidad.....	766
d) Principio de prioridad.....	767
e) Tracto sucesivo.....	768
e.1) Continuidad registral.....	769
e.2) Excepciones previstas para el principio de tracto sucesivo. Tracto abreviado.....	770
f) Principio de exactitud, legitimación y fe pública registral.....	772
f.1) Consecuencias.....	773

V. Documentos registrables	775
a) Títulos	775
b) Medidas cautelares	775
c) Leyes especiales	776
d) Requisitos que deben reunir los documentos	776
e) El caso del boleto de compraventa	777
VI. No convalidación	778
VII. Plazo general de presentación. Retroprioridad. Certificados	779
a) Plazo para inscribir una escritura pública	779
b) Retroprioridad	780
c) Escrituras simultáneas	782
d) ¿Puede cederse?	782
e) Afectación de la vivienda	783
VIII. Calificación registral	783
a) Límites de la función calificadora	784
b) Resultado de la calificación	785
c) Extensión y límites de la función calificadora	785
d) El asentimiento conyugal y la calificación registral	786
e) Estado civil del acreedor hipotecario	787
f) Resoluciones judiciales	788
g) Recursos registrales	788
IX. Inscripciones y anotaciones provisionales y preventivas	788
a) Inscripción o anotación provisional	788
b) Inscripciones y anotaciones preventivas	789
c) Diferencia entre inscripción provisional y condicionada	790
X. Anotación de las modalidades del negocio	791
XI. Prioridad. Pactos sobre rango	791
a) Forma de la asignación de la prioridad	792
b) El rango y la autonomía de la voluntad: pactos sobre rango	793
b.1) Permuta de rango	793
b.2) Posposición de rango	794
b.3) Reserva de rango	795
b.4) Rango compartido	795
b.5) La postergación	795
b.6) Forma	795

XII. Anotaciones personales	796
a) Secciones del Registro	797
b) Crítica a lo previsto en el inciso b, del artículo 30	797
c) Inhibición	797
d) Otras registraciones personales	798
e) Anotaciones personales con reflejo en el folio real	799
XIII. Rectificación de asientos	799
a) Rectificación de la inexactitud	799
b) Cuestión de la legitimación	801
XIV. Cancelación de las inscripciones	802
a) Necesidad de rogación y consentimiento. Cancelación implícita y expresa	802
b) Cancelación total y parcial	804
XV. Caducidad de las inscripciones	805
a) Caducidad de inscripciones y anotaciones	805
b) El caso de la anotación de litis	805
c) Caducidades especiales no incluidas en la enumeración	806
XVI. Catastro	807
a) Introducción	807
b) Policía inmobiliaria catastral	808
c) Concepto técnico legal de parcela	809
d) La certificación catastral	810

CAPÍTULO XXVI

PRIVILEGIOS

I. Antecedentes históricos	811
II. Concepto	812
III. Método del Código	812
IV. Fundamento	813
V. Naturaleza jurídica	813
VI. Clasificación	814
a) Generales y especiales	814
b) Asiento del privilegio	815

c) Cosas inembargables.....	815
d) Ámbito de aplicación del Código.....	815
VII. Caracteres.....	816
a) Origen legal.....	816
b) Accesorio.....	816
c) Excepcional.....	816
d) Indivisible.....	816
e) Renunciable.....	817
f) Objetividad.....	817
VIII. Extensión y cómputo.....	817
a) Extensión.....	817
b) Cómputo.....	818
IX. Subrogación real.....	818
X. Privilegios especiales.....	818
a) Enumeración.....	818
b) Extensión.....	819
XI. Extinción.....	819
a) Causas directas.....	819
b) Vía indirecta.....	820

CAPÍTULO XXVII DERECHO DE RETENCIÓN

I. Concepto.....	821
a) Fundamento.....	821
b) Diferencias con la suspensión de cumplimiento.....	822
c) Quiebra del acreedor de la restitución.....	822
II. Naturaleza jurídica.....	823
III. Caracteres.....	823
a) Accesorio.....	823
b) Facultativo.....	824
c) No subsidiario.....	824
d) Indivisible.....	824
e) Transmisible.....	824

f) Sustituible.....	824
g) Actúa principalmente como excepción.....	825
IV. Requisitos.....	825
a) Relación de poder con la cosa.....	825
b) Acreedor de una obligación cierta y exigible.....	825
c) Conexidad entre el crédito y la cosa.....	825
d) Modo de obtención de la cosa.....	826
V. Objeto.....	826
VI. Ejercicio.....	827
VII. Atribuciones del retenedor.....	827
a) Acciones.....	827
a.1) Acciones respecto del crédito.....	828
a.2) Acciones posesorias.....	828
b) Cobrar un canon.....	828
c) Percibir los frutos naturales.....	828
VIII. Obligaciones del retenedor.....	829
a) No usar la cosa.....	829
b) Conservar la cosa y efectuar las mejoras necesarias.....	829
c) Restituir la cosa.....	830
d) Rendir cuentas.....	830
IX. Efectos.....	830
a) Facultades del deudor.....	830
b) Facultades de otros acreedores.....	831
c) Interrupción de la prescripción.....	831
X. Extinción.....	831
a) Extinción del crédito garantizado.....	832
b) Pérdida total de la cosa retenida.....	832
c) Renuncia.....	832
d) Entrega o abandono voluntario de la cosa.....	832
e) Confusión de las calidades de retenedor y propietario de la cosa.....	832
f) Causas imputables al retenedor.....	833
g) Otras causas.....	833

BIBLIOGRAFÍA.....	835
-------------------	-----